

HERMES ZANETI JR.

**COMENTÁRIOS
AO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL** | **XIV**

ARTIGOS 824 AO 925

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS**

2019 - 09 - 17

Comentários ao CPC - v. XIV - Marinoni - Ed. 2018

DEDICATÓRIA

Dedicatória

Dedicado à Isabel Izilda Newton de Azevedo.

Agradecimentos a Fredie Didier Jr., Daniel Mitidiero, Carlos Frederico Bastos Pereira, Augusto Caballero Fleck, Gustavo Silva Alves, Gustavo Mattedi Reggianni e Graziela Argenta Zaneti, pelo auxílio e pelo diálogo franco.

© desta edição [2018]

2019 - 09 - 17

Comentários ao CPC - v. XIV - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE O AUTOR

Sobre o autor

Pós-doutor pela *Università degli Studi di Torino/IT* (UNITO). Doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutor em Teoria e Filosofia do Direito pela *Università degli Studi di Roma Tre/IT* (UNIROMA3). Professor adjunto da Faculdade de Direito – Graduação e Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado – da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Membro da Associação Internacional de Direito Processual (IAPL). Membro do Instituto Iberoamericano de Direito Processual (IIDP). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Promotor de Justiça no Estado do Espírito Santo (MPES).

© desta edição [2018]

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

Apresentação e premissa

LIVRO II - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

TÍTULO II - DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO IV - Da execução por quantia certa [Art. 824 a 909]

CAPÍTULO V - Da execução contra a Fazenda Pública [Art. 910]

CAPÍTULO VI - Da execução de alimentos [Art. 911 a 913]

TÍTULO III - DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO [Art. 914 a 920]

TÍTULO IV - DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO I - Da suspensão do processo de execução [Art. 921 a 923]

CAPÍTULO II - Da extinção do processo de execução [Art. 924 a 925]

Comentários ao CPC - v. XIV - Marinoni - Ed. 2018

1. APRESENTAÇÃO E PREMISSAS

1. Apresentação e premissas

1.1. Premissas deste volume: a) o processo de execução deve ser voltado para a tutela do crédito; b) não há direito fundamental de propriedade

Muito se discute sobre a natureza do processo de execução, sua finalidade e os critérios de justiça para este processo. Essas questões serão enfrentadas a partir de duas premissas que estabeleceremos nesta introdução: a) o processo de execução dever ser voltado para a tutela do crédito; b) não há direito fundamental *de* propriedade.

A execução por quantia certa deve ser voltada para a satisfação do crédito, para a tutela do crédito. Um processo de execução por quantia certa não é justo (*fair trail, giusto processo, procès équitable*), se não estiver voltado para a tutela do crédito. A atividade executiva no processo e o processo de execução somente atenderão ao processo justo se aderirem à premissa de estarem voltados para a tutela do crédito.¹

Este volume parte da premissa de que não há no ordenamento jurídico um direito fundamental *de* propriedade. O direito *de* propriedade é disponível e privado. O direito fundamental previsto no art. 5.º, *caput*, da CF/1988, consiste no direito de tornar-se proprietário, portanto, “direito fundamental à propriedade”. O direito *à* propriedade é indisponível e universal. A propriedade patrimonial é tradicionalmente disponível e particular, regida pelo direito privado, sua assimilação aos direitos fundamentais foi uma operação ideológica, como iremos demonstrar mais adiante (item 2.1, introdução).

Por outro lado, muito embora a relevante distinção apontada acima, há sim um *direito fundamental à tutela processual adequada, efetiva e tempestiva* (*Recht auf effektiven Rechtsschutz ; droit d'accès effectif à la justice ; diritto alla tutela giurisdizionale effettiva*).² Este direito fundamental no âmbito do processo de execução de pagar quantia serve à *tutela do crédito*.

Há, portanto, uma grande diferença entre: a) o direito fundamental à propriedade; b) o direito patrimonial *de* propriedade; e c) o direito fundamental à tutela processual do crédito.

Não sendo o direito *de* propriedade um direito fundamental, a proteção do devedor não se dá a qualquer custo, não decorre do direito *de* propriedade, mas sim de outros direitos fundamentais como a dignidade de pessoa humana e o processo justo.³ Parcela da doutrina sempre acreditou que o equilíbrio da execução dependesse do direito fundamental *de* propriedade do executado, mas, como veremos, este não é um direito fundamental. Há, isso sim, um direito *à* propriedade, um direito fundamental à tutela processual do crédito para o exequente, que tem direito à aquisição da propriedade mediante execução.

A distinção tem efeitos práticos e jurídicos muito relevantes. O direito de adquirir propriedade (direito *à* propriedade) é comum ao exequente e ao executado, por isso o exequente tem direito à execução efetiva para tutela do crédito como decorrência da amplitude constitucional do direito fundamental *à* propriedade.

1.2. Execução singular para a tutela do crédito, tríplice interesse (a. interesse do credor na satisfação do crédito; b. interesse do devedor na menor onerosidade possível; c. interesse

público no processo efetivo) e tríplice relação jurídica (a. exequente em relação aos órgãos de execução; b. órgãos de execução em relação ao executado; c. relação de direito material entre exequente e executado) em cooperação para com o processo

Este livro não trata das execuções universais e do problema do superendividamento nas sociedades de consumo. Temas para os quais existe regime jurídico específico. O foco da nossa abordagem dar-se-á, especialmente, quanto à execução singular para pagamento de quantia certa. Não iremos tratar da execução a título universal (falência, concordata e insolvência civil) e dos problemas referentes ao superendividamento, característico das sociedades de consumo por serem estes regimes jurídicos diferenciados em relação ao processo de execução. Embora haja um compartilhamento de institutos entre a execução universal e a execução singular, as razões da execução universal são distintas, seu foco pode variar quanto à mais intensa tutela do credor, do devedor ou quanto à manutenção de empregos e recuperação da empresa (tendência contemporânea no Brasil). Já as técnicas ligadas à tutela das situações de superendividamento no consumo visam à reabilitação do consumidor para a economia ativa e à tutela de seus direitos fundamentais em razão de sua hipossuficiência e vulnerabilidade.⁴ Por sua vez, o foco da execução para pagamento de quantia certa é outro, é a tutela do crédito; antagônico, portanto, aos objetivos mais amplos da execução a título universal.⁵

Assim, muito embora o processo de execução gire no eixo de três grandes interesses: a) interesse do credor; b) interesse do devedor; c) interesse do processo (consistente no interesse público do Estado na aplicação da norma de direito material e na efetividade do mecanismo posto à disposição da atividade executiva), é claro, para este texto, com as premissas estabelecidas, que a finalidade da atividade executiva, na execução singular, é a tutela do crédito. Isso significa que há uma predominância do interesse de tutela do crédito entre as normas do processo de execução, predominância que deve orientar o intérprete na compreensão e aplicação dos institutos e normas aplicáveis no processo de execução.

É preciso perceber que a relação executiva formada com a atividade processual executiva é uma relação complexa, um feixe de relações jurídicas, que exige o equilíbrio das atividades de todos os atores envolvidos e o respeito aos direitos fundamentais. Forma-se, em um esquema mínimo, uma relação triangular (*triangular relationship*): a) o exequente que requer aos órgãos de execução que atuem nos procedimentos executivos, os quais precisam adequar a sua atuação à demanda do exequente; b) os órgãos de execução em relação ao executado, que precisam tornar efetiva a execução com respeito às circunstâncias particulares do executado e aos direitos fundamentais que podem apresentar limites à execução; c) a relação de direito material entre o exequente e o executado, que pode significar um tratamento diferenciado na execução, como ocorre com os débitos de alimentos, bem como entendemos deva ocorrer em relação aos créditos suportados por tutelas coletivas ou tutelas ressarcitórias que tenham uma função deterrente de interesse público.⁶

No modelo cooperativo adotado pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 6º, CPC) esse feixe de relações deverá constituir uma comunidade de trabalho (*Arbeitsgemeinschaft*), capaz de adequadamente atualizar os interesses em jogo com a premissa de que o processo serve para a tutela das pessoas e dos direitos, adequada, efetiva e tempestiva, visando à composição e resolução efetiva do conflito.⁷ A cooperação de todos para com o processo é o mote que anima, inclusive, os trabalhos desenvolvidos para as normas modelo de processo civil para a Europa, projeto do ELI/UNIDROIT.⁸

1.3. Tutela do crédito adequada e efetiva: comportamento das partes, do juiz, complexidade do litígio e posta in gioco (origem do crédito)

Iremos traçar aqui uma analogia entre o direito fundamental à duração razoável do processo⁹ e o direito processual fundamental à tutela do crédito adequada, tempestiva e efetiva. Assim, o *comportamento das partes* (*the applicant's conduct*), a *atividade judicial* (*conduct of the competent authorities*), a *complexidade da causa* (*complexity of the cause*) e o *critério do bem jurídico tutelado ou da natureza do crédito* (*posta in gioco, what is at stake in the dispute*) deverão ser analisados

para se determinar ou não a adequação do procedimento executivo por penhora e expropriação, como procedimento típico e preferencial, para a execução da obrigação de pagar quantia.

Como o direito fundamental processual está ligado às máximas da adequação, da tempestividade e da efetividade (tutela dos direitos adequada, tempestiva e efetiva), a *natureza do crédito* (*posta in gioco*) poderá implicar uma diferenciação dos procedimentos executivos.

A obrigação de pagar quantia certa poderá ter um procedimento diferenciado em razão do direito material à base do título executivo. Isso vale para os títulos executivos judiciais e para os títulos executivos extrajudiciais, como se verá (arts. 139, IV, 771 e 513 do CPC/2015). Os direitos decorrentes de especial tutela de interesse público, como os direitos coletivos, os direitos do consumidor individual, os direitos de idosos etc., poderão influir no equilíbrio da execução. Não é a parte em si, grupo, consumidor ou idoso, que interfere, mas os próprios direitos materiais na base dos títulos executivos, que regem a relação material entre exequente e executado, que justificam o tratamento diferenciado e permitem, potencialmente, mais atividades atípicas na execução para pagamento de quantia certa.

Há também a possibilidade de convenções, acordos ou negócios processuais que interfiram no direito processual para a execução do crédito em respeito ao autorregramento da vontade no processo (art. 190 do CPC/2015), reconhecendo impenhorabilidades ou dispensando caução na execução provisória, por exemplo.

Também irá influir na flexibilização do procedimento o *comportamento das partes* (exequente e executado) e do juiz .

Muito embora a *complexidade do litígio* possa apresentar variações procedimentais em face dos embargos do executado no caso da execução de título extrajudicial, essa complexidade não ocorrerá – como regra geral – na fase de cumprimento de sentença em razão da diminuição do âmbito de cognição por força da existência da fase de conhecimento anterior, portanto, a complexidade do litígio pesa menos na equação que diz respeito à adequação do procedimento executivo ao direito à tutela tempestiva e efetiva. Há exceção à regra da baixa complexidade nas chamadas execuções negociadas para efetivação de políticas públicas, o que demonstra que na vida prática dos direitos poderão surgir questões de alta complexidade mesmo nos processos de execução.

Assim, como se viu, muito embora (e justamente porque se defende neste texto que o direito fundamental à propriedade difere do direito privado *de* propriedade) o processo de execução deverá ser pensado, estruturado e efetivado de maneira a garantir o direito à tutela do crédito adequada, tempestiva e efetiva.

Aplicam-se, ao processo de execução, as normas fundamentais do Código de Processo Civil previstas na Parte Geral do CPC e espalhadas ao longo de todo o diploma legal. O processo de execução deverá ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição (art. 1.º do CPC/2015).

Estas premissas afastam a concepção fraca da atividade executiva que estimula o comportamento irresponsável dos devedores ¹⁰ e a corrupção do sistema.

1.4. Estrutura e método

A estrutura destes comentários ao CPC divide-se nas seguintes partes. Na introdução fazemos um apanhado dos problemas históricos, teóricos e do direito comparado relativos à execução civil e à defesa do executado.

Após a parte introdutória histórica, teórica e de direito comparado aplicaremos, no desenvolvimento do trabalho, as premissas estabelecidas na parte introdutória, ao comentarmos individualmente cada artigo no que ele apresentar de desafios e a partir das tendências dogmáticas na doutrina brasileira, das orientações jurisprudenciais e dos precedentes dos tribunais superiores, tudo à luz da perspectiva sistemática, teórica e prática.

A atividade executiva é, de todas as atividades processuais, a mais ligada à vida dos direitos. Não há área em que a ligação entre o direito material e o direito processual ocorra de maneira mais direta e conectada.¹¹ Contudo, seu aspecto mundano torna-a externa ao processo, pois atinge diretamente o mundo da vida (*Lebenswelt; lifeworld*); não havendo como se pensar, portanto, em atividade executiva fora da sua dimensão prática e humana, sendo que as soluções propostas para os dilemas da prática executiva devem visar a garantia da maior efetividade desta atividade.

Os comentários distribuem-se ao longo de pouco mais de cem artigos (arts. 824 a 925). Cobrem o processo de execução extrajudicial do Livro II (Do Processo de Execução), dentro do Título II (Das Diversas Espécies de Execução), a partir do Capítulo IV (Da Execução por Quantia Certa), passando pelo Capítulo V (Da Execução contra a Fazenda Pública), pelo Capítulo VI (Da Execução de Alimentos), pelo Título III (Dos Embargos à Execução) e encerrando com o Título IV (Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução).

O processo de execução judicial dos títulos executivos extrajudiciais consistentes em obrigação de pagar quantia certa é tipificado mediante o procedimento da penhora, depósito e avaliação. Assim, organiza-se no CPC uma forma típica de execução para estes títulos, mediante uma Seção I (Das Disposições Gerais), Seção II (Da Citação do Devedor e do Arresto), Seção III (Da Penhora, do Depósito e da Avaliação).

A Seção III é a mais extensa, por se tratar do procedimento típico para a satisfação do crédito (tutela do crédito), objetivo principal do processo de execução, subdivide-se em Subseção I (Do objeto da penhora), Subseção II (Da documentação da penhora, de seu registro e do depósito), Subseção III (Do lugar de realização da penhora), Subseção IV (Das modificações da penhora), Subseção V (Da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira), Subseção VI (Da penhora de créditos), Subseção VII (Da penhora das quotas ou das ações de sociedades personificadas), Subseção VIII (Da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes), Subseção IX (Da penhora de percentual de faturamento de empresa), Subseção X (Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel), Subseção XI (Da avaliação).

A tipicidade do procedimento da penhora é uma herança germânica e traduz-se em garantia para o devedor em relação à expropriação de seus bens.¹² Assim, para cada obrigação típica (por exemplo, obrigação de pagar quantia certa, obrigação de dar dinheiro), uma espécie de procedimento executivo (por exemplo, a expropriação com as garantias do devedor através da penhora, do depósito e da avaliação).¹³ O tema será tratado com mais profundidade adiante, no item específico dedicado à atipicidade e adequação (art. 139, IV, do CPC), mas se percebe, claramente, uma mudança no Código processual de 2015 em relação ao Código processual de 1973, pois, para além deste modelo expropriatório típico, aquele irá prever, sob determinadas condições que ainda estão sendo construídas pela doutrina, a possibilidade de adequação através de procedimentos atípicos para a execução para pagamento de quantia certa (art. 139, IV, CPC/2015).

Prosseguindo no arco explicativo do procedimento típico de execução por quantia certa por expropriação, uma vez avaliado o bem, procede-se a expropriação e a consequente satisfação do crédito. A Seção IV (Da expropriação de bens) subdivide-se nas Subseções I (Da adjudicação) e II (Da alienação); segue-se a Seção V (Da satisfação do crédito), objetivo de todo o processo expropriatório.

As execuções especiais para pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública (regimes de pagamento por precatório e requisição de pequeno valor, RPV) e para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa referente a alimentos (pelo regime dos §§ 2.º a 7.º do art. 528, mediante determinação de pagamento sob pena de prisão civil; por desconto em folha, na forma do art. 912; ou, caso assim opte o credor, na forma dos arts. 824 e ss.) são reguladas após o procedimento típico da expropriação.

Na sequência serão tratados os embargos do executado, a suspensão e extinção do processo de execução.

A parte introdutória, que segue, visa a contextualizar os problemas da execução e permitir,

através de uma visão em *perspectiva comparada*, vertical (histórica) e horizontal (nos mais diversos ordenamentos jurídicos contemporâneos),¹⁴ a análise crítica da nossa dogmática jurídica e a superação de paradigmas antigos que não sejam capazes de propiciar a *tutela do crédito* mediante um *processo de execução focado na tutela dos direitos adequada, tempestiva e efetiva*.

2. Introdução e teoria de base

A estruturação destes *Comentários* passará pelo assentamento de alguns elementos teóricos de base que serão comuns a todo o trabalho posterior. Nos artigos específicos comentados mais adiante se fará remissão ao quanto fixado nesta parte, sempre que necessário. A leitura, portanto, deverá se articular entre a teoria de base tratada nesta introdução e os artigos do CPC analisados individualmente.

2.1. Direito à propriedade como direito fundamental: do direito de propriedade ao direito à propriedade (Luigi Ferrajoli)

Iremos tratar agora da distinção entre o direito privado de propriedade (alienar, fruir e dispor) e o direito fundamental à propriedade (direito de tornar-se proprietário).

A teoria de Luigi Ferrajoli sobre os direitos fundamentais, iniciada na década de 1960 (*Sulla possibilità di una teoria del diritto come scienza rigorosa*, 1963), consubstancia seu primeiro grande trabalho na década de 1970 (*Teoria assiomaticizzata del diritto. Parte generale*) com o seminal texto sobre a teoria axiomatizada do direito e consolida-se na obra máxima de sua produção em 2007 (*Principia Iuris. Teoria del Diritto e della Democrazia*). Este percurso teórico é também a evolução do pensamento do autor sobre a contraposição entre os direitos fundamentais e os direitos patrimoniais e a *progressiva aceitação por Ferrajoli do mercado como esfera autônoma de produção jurídica, porém regulada por direitos fundamentais como limites e vínculos*.

Ferrajoli distingue claramente o direito fundamental à propriedade e o direito privado de propriedade. O *leit motiv* da teoria de Ferrajoli é a equivocada assimilação entre os conceitos de liberdade e de propriedade. Como demonstrou a doutrina especializada, três foram os pontos enfrentados pelo autor ao longo de suas obras: a) o liberalismo burguês; b) a ideologia marxista; c) a ciência jurídica contemporânea.

Cada uma destas abordagens acaba por sobrepor e confundir as dimensões da liberdade e da propriedade.

O ponto de partida é a teoria contratualista defendida por John Locke (*Two treatises of government*) que justificou os direitos de liberdade com a afirmação de que, no mínimo, cada um é proprietário da própria pessoa. Essa afirmação transformou-se na justificação privada do direito de liberdade. “Patrão exclusivo do próprio corpo o indivíduo se torna patrão exclusivo das coisas criadas ou transformadas através da ação do próprio corpo. Incorporando uma parte de si nas coisas externas – na verdade incorporando-as o próprio trabalho – ele torna as coisas externas parte de si. Assim, o direito real de propriedade é deduzido imediatamente da natureza do homem: daquela natural propriedade das pessoas sobre si mesmas, consistente na imunidade da sujeição coacta ao arbítrio dos outros e na faculdade de agir segundo a própria vontade; consistente, isto é, na liberdade (...) representada como esfera do exercício da liberdade individual a propriedade – compreendida como domínio sobre as coisas – é desta forma consagrada ao papel de direito natural.”¹⁵

O passo seguinte será a equiparação do direito de propriedade à segurança, à resistência à opressão e à liberdade na *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen*, de 1789. O art. 2.º determinava que: “Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression”. Este direito de propriedade não poderia ser atacado, por ser “sacro e inviolável”, salvo em caso de necessidade pública legalmente constatada e sob a condição de uma justa e prévia indenização.

A queda do jusnaturalismo não abalou as convicções do binômio liberdade-propriedade: homem-livre, homem-autônomo, homem politicamente capaz, homem proprietário representam o ápice da burguesia e do seu triunfo social no século XIX, convertendo-se no elemento organizador do direito privado (autonomia da vontade e propriedade), tanto na Escola da Exegese, francesa, quanto na Escola Histórica ou Pandectística, alemã.

Como demonstra a doutrina, o sucesso desta fórmula revela-se na incapacidade de uma visão crítica marxista adequada aos direitos de propriedade e à liberdade individual. O marxismo simplesmente assemelha-os, criticando-os como direitos individuais. O marxismo, neste ponto, revela-se, na precisa crítica de Ferrajoli, acompanhada por Dario Ippolito, “culturalmente subalterno à ideologia burguesa”.¹⁶

Isso porque, ao contrário de criticar este vínculo entre os direitos de liberdade e de propriedade, colocando em discussão a relação orgânica criada a partir do discurso de John Locke, os marxistas irão qualificar estes direitos como direitos burgueses, deixando de lado o discurso dos direitos humanos, como se estes fossem exclusivo atributo do discurso capitalista. Para Ferrajoli, essa contraposição acaba por ser avalizada pela doutrina dos “direitos subjetivos”, que buscou justificar dogmaticamente os direitos de liberdade e de propriedade como direitos da mesma espécie.

Nas palavras do autor, muito embora o ideal fosse alterar os conceitos, extremando os direitos fundamentais dos direitos patrimoniais, os direitos subjetivos privados dos direitos fundamentais, a terminologia arraigada assim não nos aconselha. Devemos, porém, entender bem esta diferença, pois ela terá grande influência no tratamento da execução para pagamento de quantia. Faremos a seguir uma longa transcrição da doutrina,¹⁷ apenas justificada pela importância dos fundamentos deste debate.

“Na construção moderna da noção de ‘ *direito subjetivo* ’ são confluídas, sem jamais terem conseguido se amalgamar unitariamente, duas tradições culturais entre si profundamente diversas e heterogêneas: de um lado as doutrinas jusnaturalistas e contratualistas dos ‘direitos naturais’ dos séculos XVII e XVIII, que formarão a base do constitucionalismo moderno e da teoria do Estado Constitucional de Direito e dos direitos fundamentais; de outro lado, a velha tradição romanística-civilística do direito de propriedade e dos outros direitos patrimoniais, reelaborada pela ciência jurídica oitocentista, primeiro civilista e depois publicista. O encontro dessas duas tradições foi favorecido pelos significados expansivos e redundantes, até confundirem-se uma com a outra, associadas no léxico jurídico e filosófico, da “propriedade” com a “liberdade”. Isso aconteceu, nas origens do direito moderno, através de uma série de operações teórico-políticas – em parte, doutrinárias, em parte, institucionais – voltadas todas à supralégitimação política e moral da propriedade enquanto fundamento e corolário da liberdade.

A primeira operação remonta a John Locke, que identifica, repetidamente na vida, na saúde, na liberdade e na propriedade, os bens, igualmente tutelados pela “lei da natureza”, para os quais à conservação é finalizado o Estado. O primeiro movimento nesta direção é a identificação do primeiro e mais imediato objeto da propriedade com a própria pessoa: “mesmo que a terra e todas as criaturas sejam comuns a todos os homens”, escreve Locke, “cada um tem a propriedade da própria pessoa, para a qual tem direito ninguém mais que ele”. Nesse sentido, a propriedade, sendo referida à “própria pessoa”, é claramente um só com a liberdade e, ainda antes, com a identidade pessoal. A sua proclamação é de per se uma afirmação radical e revolucionária da liberdade, contrária à escravidão e a todas indevidas submissões do corpo, não diferente daquela que será exprimida por John Stuart Mill com a célebre frase “sobre si mesmo, sua mente e seu corpo, o indivíduo é soberano”. Mas essa surge aplicando à pessoa a linguagem patrimonial do proprietário. E vale por isso para fundar o segundo movimento de Locke, que é a derivação da propriedade de si mesmo como *imunitas* frente a lesões ou constrictões, assim da liberdade, enquanto *facultas agendi*, como da propriedade enquanto *potestas* sobre as coisas: se cada um é proprietário do próprio corpo, então é também proprietário das suas ações, isto é, do seu trabalho, e, portanto, dos frutos do seu trabalho. Nem se trata de bens distintos ou distinguíveis: “vida, liberdade, haveres”, conclui Locke, são “coisas que eu denomino, com termos gerais, propriedade”. É assim que a ideia da própria pessoa como “propriedade” vale para fundar a centralidade da

propriedade no liberalismo lockiano e a sua inteira doutrina da identidade, da liberdade e dos outros direitos naturais como outras tantas formas de propriedade.

A segunda operação foi a constitucionalização e, portanto, a positivação da propriedade, no sentido genérico referido acima, como direito natural. “O final de toda a associação política”, proclamou o art. 2 da Declaração Francesa de 1789, “é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade e a resistência à opressão”. E, treze anos antes, a Declaração dos Direitos da Virgínia, tinha afirmado, no seu art. 1: “Todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes, e tem alguns direitos inatos(...), isto é, o aproveitamento da vida, da liberdade, mediante a aquisição e a posse da propriedade, e a perseguir e obter felicidade e segurança”. A associação entre propriedade e liberdade recebe assim uma consagração constitucional, tanto mais potente enquanto os dois direitos venham juntos qualificados como “naturais” ou “inatos”, e estabelecidos nas próprias Declarações.

Enfim, se, na cultura anglo-saxã, propriedade e liberdade continuaram a ser concebidas como direitos pré-existentes ao artifício estatal e por este somente reconhecidas e tuteladas, na cultura alemã e italiana a aporia do seu estatuto natural e também constitucional vem resolvida com a afirmação do seu caráter inteiramente positivo. Mas o resultado não muda. Os direitos de liberdade, em particular, vêm caracterizados como “direitos públicos subjetivos”, “efeitos reflexos” do direito soberano do Estado e, ao mesmo tempo, subsumidos dentro da categoria geral dos “direitos subjetivos”, concebidos por sua vez por Savigny e por Windscheid, tanto quanto por Locke, como “domínio da vontade” ao mesmo tempo sobre a “própria pessoa” e sobre o “mundo externo” dos próprios bens, segundo o modelo privatístico e romanístico do direito de propriedade enquanto “ilimitado e exclusivo domínio de uma pessoa sobre uma coisa”.

Explica-se, assim, como a ideia lockiana da propriedade de si mesmo tenha sido assumida pelos atuais defensores da ausência de limites jurídicos à liberdade de mercado como “o axioma fundamental da teoria *libertária*”. E se explica, ao mesmo tempo, como no único, larguíssimo recipiente do direito subjetivo, seja esse produzido pelo poder negocial ou pelo poder legislativo, tenham sido agrupadas figuras estruturalmente opostas e referentes a tradições históricas diversas: dos direitos reais, primeiro entre todos o da propriedade, que são poderes exercidos por atos de disposição e por comportamentos de uso e direcionados em via exclusiva aos seus titulares, aos direitos de crédito, que são expectativas positivas que com os primeiros compartilham o caráter privado, exclusivo e disponível; para os direitos civis e políticos, que ao lado daqueles reais são situações ativas consistentes em poderes, mas diversamente desses são indisponíveis e reconhecidos universalmente a todos enquanto capazes de agir e/ou cidadãos, até todos os outros direitos fundamentais e universais, das liberdades fundamentais, que não são poderes não sendo exercitadas por atos jurídicos, aos direitos sociais, consistentes em expectativas positivas à prestações vitais.

Tal união de significados heterogêneos fez algumas vezes duvidar da consistência lógica e semântica do conceito e aconselharia, talvez, o seu abandono e a redefinição, com termos novos e distintos, das múltiplas e variadas figuras por esse desenhadas. Quanto menos, essa justificaria a adoção de duas palavras diversas para designar duas classes de direitos – os direitos fundamentais e os direitos patrimoniais. “(...) Mas isto não é possível sem contrapor-se a usos linguísticos fortemente consolidados não somente na linguagem jurídica, mas também na linguagem política e comum.” ¹⁸

A assimilação do direito de liberdade ao direito de propriedade é ideológica e, no processo de execução, resultou em uma distorção em benefício do devedor, segundo a qual, pela gravidade da invasão dos direitos de propriedade, apenas um procedimento complexo para a expropriação, com muitas garantias para o executado, poderia estar de acordo com o processo justo.

Devemos proceder a uma reclassificação dos direitos que permita efetuar a purificação deste desvio ideológico, dimensionando o direito de propriedade como um direito privado e o direito à propriedade como um direito fundamental.

Nesse sentido, Ferrajoli classifica os direitos de subjetivos em quatro tipos de direito, nos seguintes termos: *a) os direitos-poder*, que consistem em faculdades de atos preceptivos, e, portanto, em poderes potestativos: emblemático o *direito de propriedade*, que pode ser exercitado através de atos negociais de disposição e de escambo; *b) os direitos-faculdades*, que consistem em faculdades de meros comportamentos, tais como as clássicas liberdades fundamentais: de opinião, de palavra, de associação, de reunião, de circulação e similares; *c) os direitos-imunidades*, que consistem somente nas expectativas negativas de não violação, como os direitos à vida, à liberdade pessoal, à integridade física e, além desses, à paz, à defesa do meio ambiente e similares; *d) os direitos-pretensão*, que são expectativas de prestações positivas, como os direitos de crédito e os direitos sociais.¹⁹

O direito ao crédito e a tutela do crédito são típicos direitos-pretensão, exercidos mediante o processo de execução para pagamento de quantia em caso de inadimplemento. Na base deste direito está o direito de tornar-se proprietário, ou seja, o direito à propriedade.

A doutrina nacional de certa forma já vem a algum tempo arrefecendo a compreensão do direito de propriedade como um direito fundamental absoluto e aceitando a diferenciação tratada acima. A Constituição Brasileira garante o direito à propriedade, mas com condicionamentos (art. 5.º, *caput*, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito (...) à propriedade”).

Assim, “[a] propriedade compreende-se um direito fundamental enquanto atenda a função social que a reveste e legitima constitucionalmente. Isso é uma repersonalização do Direito, que importa deslocar o enfoque protetivo do campo jurídico da pertença para a pessoa, em seu sentido ontológico (...) A operação com o direito fundamental de propriedade fica ainda mais transparente quando se radiografam os elementos estruturais normativos que exprimem sua positividade imanente. A propriedade privada é composta do encontro de dois princípios especiais. O princípio da garantia da propriedade privada, como concreção do princípio geral da liberdade, e o princípio da função social da propriedade, que concretiza o princípio geral da igualdade”.²⁰

Assim, teremos: *a) o direito fundamental à propriedade; b) o direito patrimonial de propriedade; e, c) o direito fundamental à tutela processual da tutela do crédito.*

O direito fundamental à propriedade está ligado à justificação constitucional da proteção do credor no Brasil na execução para pagamento de quantia. A tutela do crédito visa à satisfação integral do credor com o menor prejuízo do devedor (art. 797 c/c art. 805, CPC). O direito à execução, portanto, deriva sua legitimidade diretamente da Constituição.²¹

O direito à propriedade não protege somente os bens ou interesses que tenham um valor pecuniário da expropriação ou de outras formas de esbulho ou perturbação pelo Estado, o direito à propriedade tem um sentido mais amplo e deve ser interpretado no sentido de se exigir do Estado que providencie nos meios efetivos para proteger o crédito.

Este também é o entendimento da doutrina sobre o art. 14 da Constituição da Alemanha: “[a]ll ‘substantive rights’ which have an economic value are protected by fundamental right to property guaranteed by art. 14 of the Federal Constitution (Grundgesetz, GG). Art. 14 GG protects the *right to property in a large sense*, including all claims against debtors based on substantive (private or public) law.”²²

Há aqui um direito à autonomia, por isso que, na teoria de Luigi Ferrajoli, os “pilares jurídicos do mercado, antes atacados como poderes intrinsecamente liberticidas, são agora valorizados como base do autogoverno”.²³

Nas palavras do próprio autor: “A autodeterminação em matéria econômica, e, em geral, o poder de agir com efeitos jurídicos sobre a esfera privada própria e alheia é uma dimensão essencial do autogoverno e, por isso, da democracia formal, não menor que a autodeterminação em matéria política, ou seja, na esfera pública. Poder tomar decisões juridicamente relevantes para a própria vida, da gestão quotidiana dos próprios interesses às escolhas decisivas para o

próprio futuro (...) equivale seguramente à forma mais elementar e espontânea de poder (...). Este tipo de poder e de produção autônoma das situações e das relações jurídicas, que identifiquei como o conjunto daqueles direitos-poderes fundamentais que são os direitos civis ou de autonomia privada, é evidentemente na base, em particular, do mercado, que é o sistema das relações nas quais se exprime a autodeterminação em matéria econômica através dos atos negociais de troca. Também o mercado é, portanto, uma dimensão da democracia formal, além do que o sistema, mais do que qualquer outro, idôneo para incentivar a produção de riqueza”.²⁴

Portanto, o direito fundamental à propriedade é um direito fundamental que tem dupla dimensão: protege aos credores e aos devedores, consistindo no direito de tornar-se proprietário. Por outro lado, o direito *de* propriedade não é direito fundamental, é um direito privado e disponível, ou seja, é o direito de dispor de seus bens contraindo obrigações voluntárias ou o dever de responder com seus bens perante à prática de atos ilícitos que gerem danos a terceiros, estando, conseqüentemente, ligado ao agir com efeitos jurídicos sobre a esfera privada própria e alheia, como dimensão essencial da autonomia privada, esta sim exercício de direito civil fundamental. O direito *de* propriedade não pode impedir, ao contrário, justifica que o executado responda à execução com todos os seus bens. Nesse sentido, o art. 789, “[o] devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (...)”.

2.2. Direito fundamental à tutela processual do crédito

Os ordenamentos jurídicos contemporâneos e a teoria do direito contemporânea reconhecem o direito processual como direito fundamental.²⁵ Há direito fundamental processual à execução.²⁶ Há, assim, um *direito fundamental à tutela processual adequada, efetiva e tempestiva* (*Recht auf effektiven Rechtsschutz* ; *droit d'accès effectif à la justice* ; *diritto alla tutela giurisdizionale effettiva*)²⁷ que no âmbito do processo de execução de pagar quantia serve à *tutela do crédito* . Portanto, um *direito fundamental à tutela processual do crédito* .

A Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos já reconheceram o direito à atividade de execução efetiva. O caso *Hornsby v. Grécia* , 1997, Corte Europeia de Direitos Humanos, estabeleceu que o direito de acesso à justiça (tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva) seria ilusório se o ordenamento jurídico interno de cada Estado-membro da UE permitisse que uma sentença judicial definitiva e obrigatória permanecesse inoperante em detrimento da parte executada, afirmando que o art. 6.1 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos determina o dever de proteção do crédito mediante a execução das decisões judiciais e para títulos executivos extrajudiciais (mesmo que não sejam executados judicialmente) e *exequatur* de decisões estrangeiras em matéria civil.²⁸

Não há processo justo (*fair trial* , juízo equitativo, *giusto processo*, *procès équitable*, *fairen Verfahren*) sem tutela do crédito mediante execução. A Corte Interamericana de Direitos Humanos assegurou níveis de tutela similares a partir do art. 8.º, cláusula geral de acesso à justiça e devido processo legal (processo justo), e do art. 25.2, c), direito a efetivar a decisão judicial após o recurso, previstos na Convenção Interamericana de Direitos Humanos.

Nos termos do caso *Mejía Idrovo v. Ecuador*, afirmou que: “A Corte concorda com a Corte Europeia de Direitos Humanos ao considerar que para lograr plenamente a efetividade de uma sentença a execução deve ser completa, perfeita, integral e sem demora. Desta forma, o princípio da tutela judicial efetiva requer que os procedimentos de execução sejam acessíveis para as partes, sem obstáculos ou demoras indevidas, afim de que alcancem seu objetivo de maneira rápida, simples e integral (...) O processo deve ter a materialização da proteção do direito reconhecido no pronunciamento judicial mediante a aplicação idônea de tal pronunciamento. Por tanto, a efetividade das sentenças depende de sua execução”.²⁹

Este direito fundamental decorre do direito fundamental à organização e ao procedimento, judicial e administrativo. A doutrina, com amplas referências às decisões do Tribunal Constitucional Alemão, afirma que: “Direitos a procedimentos judiciais e administrativos são direitos essenciais a uma ‘proteção jurídica efetiva’ (...) Direitos fundamentais são, em alguns aspectos decisivos, não procedimentais (...) Mesmo que a conformidade do resultado aos direitos

fundamentais não seja garantida pelo procedimento, há um aumento na *probabilidade* de um resultado nesse sentido. Por essa razão, procedimentos são necessários como meio de proteção dos direitos fundamentais. Mas é também claro que o mero aumento da probabilidade de um resultado conforme aos direitos fundamentais nunca poderá ser uma razão para se abrir mão de um controle judicial de compatibilidade material dos resultados com as normas de direitos fundamentais”.³⁰

A atividade executiva guarda uma conexão com os direitos fundamentais e com a Constituição. Faz parte da conexão entre Constituição e processo.

Há um duplo juízo de constitucionalidade, uma função de controle geral do procedimento de execução e de sua adequação à tutela dos direitos de crédito e dos direitos fundamentais do devedor ou de terceiros atingidos pela execução, como um todo, e uma função de controle em determinados procedimentos internos a atividade executiva e sua adequação ao modelo de execução e aos direitos fundamentais positivados em um determinado ordenamento.

Assim, “[t]he enforcement proceedings impose limitations to fundamental rights and could be questions if the limitations are according to the constitution and this control is centered on the proportionality. We could test the constitutionality of the entire enforcement proceeding in the framework of the rule of law, but also could be test each enforcement act. In order to answer the question about the conflict between the fundamental rights of creditor and debtor, the main problem is the limitation of the fundamental rights.”³¹

A história da atividade de execução é a história da tentativa de equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor, com o interesse público na manutenção do respeito à lei e à autonomia privada.

2.3. Histórico da execução³²

“O *nómos* é sobretudo o meio de limitar o poder da autoridade, porque a liberdade política consiste em não ter que obedecer senão à lei. Mas a lei é humana, é laica; já não tem nada de religioso, de divino.”³³

A história da execução é parte da história da evolução do direito. Princípios da execução, ideologias da execução e a arquitetura dos processos executivos descrevem em essência os movimentos pela efetivação da tutela dos direitos ao longo dos séculos. Não há técnica sem ideologia, direito é um fenômeno de poder e a finalidade dos ordenamentos constitucionais é justamente estabelecer limites (liberais) e vínculos (sociais) aos poderes selvagens do mercado e da política.³⁴ Os valores que orientam as diversas formas de execução (satisfação prática) dos direitos, ao longo dos tempos, são históricos. As opções humanas, mesmo que travestidas em justificativas religiosas, são o fruto artificial de decisões do juiz, da comunidade jurídica, do soberano ou de quem quer detenha o poder de editar as normas. Assim, são os homens, e não os deuses, os responsáveis pelo direito que possuem.

Nos contemporâneos Estados Democráticos Constitucionais, a Constituição representa um controle formal e substancial sobre os textos legais e sobre as decisões normativas dos poderes instituídos. A Constituição estabelece limites e vínculos através dos direitos fundamentais. Sem os limites e sem os vínculos decorrentes dos direitos fundamentais, o processo seria uma arma colocada, ora na mão do mercado, ora na mão do Estado (ou seja, dos interesses e poderes de ocasião), para atender a fins de interesse pessoal ou político.

A novidade do Estado Democrático Constitucional importa a ruptura com esta ordem de ideias e ideais. Soberana é a Constituição e soberanos são os direitos fundamentais em uma democracia de direitos contramajoritária. A defesa dos direitos fundamentais é o fim do Estado, e não apenas um instrumento para os interesses secundários da administração pública e do mercado.

Nesse contexto, pode-se dizer que há direito fundamental do credor na execução, assim como existem direitos fundamentais do réu. Cabe ao ordenamento jurídico disciplinar este equilíbrio,

sem que o núcleo essencial destes direitos seja afetado.

Adiante iremos progredir através de um breve aceno histórico pelos institutos que traduziram a tônica dos processos executivos desde o período romano, passando pelo direito comum, pelo racionalismo iluminista, pela emergência da questão social e pelos contemporâneos Estados Democráticos Constitucionais.

O problema da execução civil hoje pode ser dividido em duas ordens: a) meios de tutela, típicos e atípicos, capazes de propiciar a adequada e efetiva concretização da tutela do crédito; b) divisão de trabalho entre juiz, órgãos da administração pública e órgãos privados, mediante modelos de execução para pagamento de quantia.

2.3.1. Processo romano³⁵

O processo romano se dividiu em três fases, *legis actionis*, *per formulas* e *cognitio extraordinem*.

A execução romana e o direito processual romano caracterizaram-se pela inexistência da noção de direito subjetivo, pela natureza de direito privado da litigância,³⁶ pelas crescentes patrimonialização e obrigacionalização da execução e pela introdução progressiva de garantias para o devedor em compensação aos excessos iniciais e a absorção do direito pelo *Principis* (Imperador).

Em Roma não existia ainda uma separação clara entre normas de direito processual e de direito material. O processo não se distinguia do direito material.³⁷ Há aguda polêmica sobre o processo em dois estágios, *in iure* e *apud iudicem* consistir em uma voluntária submissão das partes para uma arbitragem sancionada pelo Estado.³⁸

2.3.1.1. Processo romano: *legis actionis*

O processo romano das *legis actionis* é o período da formação da cultura jurídica em Roma (período arcaico). A execução era fundamental para a manutenção da autoridade romana no direito privado, daí a sua gravidade.

São deste período as Leis das XII Tábuas e o seu livro III, 1-6, no qual era descrito o procedimento para execução das dívidas.³⁹

Este procedimento podia ser evitado, caso o devedor se entregasse à servidão por dívidas, de forma voluntária, para trabalhar como escravo até o pagamento integral dos valores devidos (*nexus*).⁴⁰ Também havia a figura do *vindex*, uma “figura anômala de intervenção processual” que permitia a atuação de um terceiro, geralmente membro da família ou amigo, em favor do devedor. “Esse personagem – parente ou amigo – opunha-se ao credor declarando (*vim dicere*) solenemente a violência da execução pessoal e a ilegitimidade ou injustiça da precedente sentença e afastava a mão do corpo do devedor (*qui manum depellit*), agindo, daí em diante, por si próprio (...) Com o passar do tempo, novas leis (em particular, a *lex Valia*) alargaram a possibilidade de recorrer-se à *manus iniectio*, mesmo sem a existência de um precedente processo, facultando ao próprio réu repelir a mão do autor e defender-se pessoalmente (*manus iniectio pura*), fator que restringiu consideravelmente a atuação do *vindex* (Gaio, I., 4.23-25). Essa evolução (...) decorre da *lex poetelia papiria* (326, a.C.) que, humanizando as relações creditícias, aboliu as medidas cruéis da execução pessoal”.⁴¹

No diálogo entre Favorino e Sexto Cecílio, conseguimos compreender melhor o que realmente estava em jogo com as severas leis de execução civil no período das XII Tábuas: a *boa-fé*. Ela era um instituto fundamental das virtudes romanas, no ambiente político e social, pelo qual o devedor em relação ao credor deveria se posicionar com boa-fé. Para os valores romanos, a virtude estava em honrar as suas dívidas e o rigor da execução visava deixar claro para o devedor este valor, ou seja, havia a necessidade de organizar o procedimento de execução de forma que os débitos fossem adimplidos espontaneamente.

Atentem para a diferença de épocas dentro da própria história de Roma, pois o diálogo entre Favorino e Sexto Cecílio ocorre alguns séculos após o fim das *legis actionis*.

Favorino, já em época imperial, indignava-se com a redação da lei das XII Tábuas: “E quanto às leis bárbaras que permitiam aos credores cortar e repartir entre si o corpo do devedor, que o juiz lhes adjudicava em comum, quero esquecê-las: me faz mal falar delas. Que barbárie! Que ultrajante inumanidade a de separar e repartir os membros de um devedor pobre, como se repartem hoje os bens!”⁴²

A resposta de Sexto Cecílio é carregada de historicidade. Sexto Cecílio, afirmando a natureza mutável de todas as leis humanas e defendendo a necessidade de que elas respondam aos anseios da sociedade, aos costumes dos tempos, à situação dos assuntos públicos, às conveniências do momento e ao estado da enfermidade (o problema social) que se deve curar, inicia a falar da razão por trás das leis antigas de Roma e explica:

“Resta agora esse despedaçamento do corpo humano que tanto te repugna e sobre a qual vou me opor. A prática constante de todas as virtudes foi o que fez passar tão rapidamente o povo romano da debilidade de sua origem ao esplendor de sua grandeza. A virtude que melhor praticou foi a boa-fé, sendo sagrada para ele nas relações privadas, o mesmo que nos assuntos públicos, chegando, para não violá-la, até entregar aos inimigos ilustres cônsules. Queria que ao cliente, cuja a fé se havia recebido, se lhe estimasse mais que aos parentes, e até se lhe defendesse contra estes. Não havia delito mais hediondo que o abandono do cliente. Nossos pais quiseram estabelecer essa boa-fé não somente em reciprocidade a deveres, mas, também, nas relações comerciais, e sobretudo no empréstimo, crendo que a indigência passageira, na qual todos podem se encontrar, restaria privada de socorros se o devedor podia, com pouco risco, burlar o credor. Confessada a dívida, ou provada em juízo, tinham-se trinta dias para buscar a quantidade e solvê-la. Os credores chamavam *justi* a esses dias, porque eram uma espécie de *justitium*, um chamamento à justiça, um interstício, durante o qual não podia reclamar-se legalmente nada. Transcorrido este prazo, se não se havia pagado, se citava o devedor perante o pretor, que o adjudicava ao credor reconhecido por sentença. Então se atava ao devedor com um nervo ou com correntes. Creio que este é o sentido da lei: ‘Confessada a dívida e pronunciada a sentença, ter-se-ão os trinta dias fixados pela lei. Depois haverá detenção: o devedor será levado à justiça. Ali, se não paga, e se ninguém o reclama, levasse ao credor; que lhe atará com um nervo ou com correntes, que pesem pelo menos quinze libras, ou mais pesadas, se quiser. Se o credor quiser que o devedor viva às suas [próprias] custas; se não vive às suas custas, o credor lhe dará uma libra de farinha por dia ou se quiser mais’. Também tinha o direito de ajustar; se não se fazia o acordo permanecia sessenta dias atado. Neste espaço de tempo ocorriam três dias de mercado, durante os quais, e em cada um deles, se levava ao *comitium* perante o pretor, que relembrava a quantia devida. No terceiro dia se lhe decapitava ou se lhe vendia, transportando-o para o outro lado do Tibre, como estrangeiro. Então, esta pena de morte, cujo objeto era colocar a boa-fé protegida de todos os ataques, se encontrava rodeada de tudo o que se podia para fazê-la formidável. Se se adjudicava ao devedor a muitos credores, a lei lhes permitia despedaçá-lo, se queriam reparti-lo entre si. Poderias crer que retrocedo ante aos termos da lei, e pelo mesmo os cito: ‘Depois de três dias de mercado, se lhe despedaçará, e se se corta demasiado ou muito pouco, não haverá fraude’. Existe algo mais bárbaro? Algo mais atroz? Não, sem dúvida; porém, não é evidente que não se tinha estabelecido um castigo tão tremendo senão para não se recorrer a ele? Diariamente vemos adjudicar e atar; Por quê? Porque os maus não temem as correntes. Não li nem ouvi dizer que nenhum homem fosse despedaçado na antiguidade; Por quê? Porque não se arrosta semelhante castigo. Suponhamos, oh! Favorino, que a famosa lei penal das Doze Tábuas, contra os falsos testemunhos, não estivesse abolida; que à testemunha falsa se lhe precipitasse desde a rocha Tarpeia; Haveria muitos testemunhos falsos? A severidade da lei é, muitas vezes, lição de conduta.”⁴³

O objetivo das rígidas leis de execução no período das XII Tábuas era claro: tornar a tutela do crédito efetiva, mesmo que a um custo desproporcionalmente elevado.

2.3.1.2. Processo romano: *per formulas*

A evolução do processo romano arcaico para o período *per formulas*, também chamado de

período clássico, trouxe já alguns sinais de humanização da execução. A doutrina esclarece que “[a]bandonadas as formalidades rigorosas das *legis actiones*, introduziu-se, em lugar da *manus iniectio*, a simples *actio iudicati* [nova ação]. O comparecimento das partes à presença do pretor tinha lugar como nas demais ações do processo formulário, e o autor lembrava a condenação proferida e afirmava não estar ainda pago. Também aqui as hipóteses eram duas: se o réu negava a obrigação, sustentando a nulidade da sentença ou a efetuação do pagamento ou opunha uma das outras exceções admissíveis a propósito, tornava-se necessária, como em qualquer outro caso, a *litis contestatio* e o *iudicium*, com a única advertência de que a *actio iudicati* está entre as que *infitiando crescunt in duplum* [autorizam a cobrança do dobro do valor da condenação]”.

A *actio iudicati* redundava em uma atividade prática, “o pretor proferia o decreto para execução [*addictio*] sobre a pessoa (*duci iubere*) ou sobre o patrimônio do devedor”.⁴⁴

Percebe-se claramente que no processo romano a necessidade de a cognição anteceder a atividade executiva era uma pedra fundamental de sua estrutura. Assim, o princípio de que se devem *conhecer das razões antes da execução* foi determinante para a construção do direito romano à execução em matéria patrimonial, para as execuções *in pecunia*. No período formulário ou clássico o credor deveria promover *nova ação* para cobrar a dívida decorrente da sentença condenatória não adimplida espontaneamente (*actio iudicati*). Após a sentença condenatória e decorrido o *tempus iudicati* (30 dias), no qual o vencido deveria espontaneamente pagar sua dívida, haveria um novo processo.

O novo processo se justificava como uma garantia. Isso ocorria justamente porque o devedor poderia ter pago a dívida espontaneamente durante o período de 30 dias (*tempus iudicati*). Mas não era esta a única razão para a *actio iudicati*, segundo a doutrina a *actio iudicati*, decorria da própria característica estrutural do processo romano, ia além de sua finalidade prática de permitir a defesa do executado e os atos executivos. Assim, “[o] efeito da sentença era, pois, unicamente o de fazer surgir uma nova obrigação, que não a precedente, porque provinha do julgado e não do vínculo originário. Eliminar-se-ão, portanto, muitas razões de defesa, serão inadmissíveis muitas exceções, sancionar-se-á pela *poena dupli* a *infitiatio* ilegítima, a obrigação originária, qualquer que seja o conteúdo ou a fonte, ver-se-á, por assim dizer, purificada e reduzida ao denominador comum da *obligatio iudicati* (...) simples relação obrigatória de direito privado (...) A nota saliente do processo romano clássico é o seu caráter privado; e tal caráter encontra expressão máxima na natureza contratual da *litiscontestatio* (...) A eficácia da sentença relaciona-se, por isso, à fórmula e deriva da voluntária submissão das partes ao pronunciamento do *iudex [x] privatus*. Essa é uma sentença arbitral alteada em seu grau de eficácia pelo *iussus iudicandi* do magistrado. O *addicere* e o *duci iuberi*, ou seja, os atos que autorizavam o credor a prececer à execução, inseriam-se no *imperium* do magistrado e não se podiam conter na sentença do juiz”.⁴⁵

A nova ação, denominada *actio iudicati*, não diferia substancialmente das demais ações do período formulário. As partes compareciam perante o pretor e o autor formulava sua pretensão de obter o pagamento diante do inadimplemento pelo devedor da obrigação constante da sentença condenatória. O autor requeria, a partir do inadimplemento, que a dívida fosse paga com a *entrega da pessoa do devedor* ou *seu patrimônio*.

Ocorrendo contestação pelo réu, surgiam a *litiscontestatio* e o *iudicium*. Caso aquela não fosse acolhida, haveria o pagamento em dobro da quantia originariamente devida pelo devedor.

Sucedida nova condenação e a ela nova *actio iudicati* para o caso de inadimplemento.

Como bem observado pela doutrina, não se pode imaginar que estas ações fossem sucessivas em rede interminável, pois, caberia ao pretor (magistrado), controlando as defesas temerárias e pela própria sanção de condenação em dobro, dissuadir os devedores recalcitrantes.⁴⁶

O pretor (magistrado) dispunha, portanto, de amplos poderes *in iure* para negar ouvidos à contestação feita evidentemente de má-fé e evitar que o réu protelasse indefinidamente a execução.

Há de se apontar que o processo romano previa a defesa que, com base em argumentos sólidos, poderia combater a procedência da execução. Exemplos de defesa admissíveis eram a nulidade da sentença condenatória e o pagamento da dívida após a condenação.

“O certo é, de qualquer modo, que ela só se tornava possível quando o condenado reconhecia procedente o pedido de execução do credor. Quer dizer que, mesmo depois de proferida a sentença condenatória, era dada ao devedor a oportunidade de impedir a execução quando pudesse lançar mão de bons argumentos para combater sua procedência, como seja, a nulidade da sentença condenatória, ou o pagamento da dívida depois de proferida a condenação. A execução nunca podia ser feita sem que constasse previamente a sua plena legitimidade.”⁴⁷

No período *per formulas*, marca-se claramente a precedência da cognição sobre os atos executivos na execução para pagamento de quantia certa. Aqui havia a necessidade de ajuizar nova ação, a *actio iudicati*, e distribuía-se a atividade entre o *praetor* (magistrado), fase *in iure*, e o *iudex* (árbitro privado), fase *apud iudicem*.

2.3.1.3. Processo romano: *cognitio extraordinem*

As garantias ao devedor foram mantidas no processo da *cognitio extraordinem*. A substituição do processo formulário foi gradual, como já havia ocorrido na passagem anterior do período *legis actionis*. A grande novidade é a concentração das fases *in iure* e *apud iudicem*, com a gradual “substituição integral [do] *ordo iudiciorum*”.⁴⁸ Há uma clara concentração no *principis* (Imperador), quer por desconfiança da magistratura, quer para enfraquecer o domínio das partes reforçando o caráter público da atividade jurisdicional e eliminado progressivamente o juiz privado (*iudex*).

Assim, “na Monarquia absoluta modifica-se totalmente o CARÁCTER do processo. O DOMÍNIO DAS PARTES sobre suas fases é limitado com o aumento do poder do Estado no sentido do DOMÍNIO JURISDICIONAL DO PROCESSO, a que as partes são submetidas. Por outro lado, a *desconfiança* do Imperador contra os juízes incapazes e pouco sérios, leva a que se limite com frequência a sua LIVRE APRECIACÃO, substituída por uma regulamentação legal rígida.”⁴⁹

A diferença principal do processo romano na fase do *cognitio extraordinem*, portanto, é que o processo se desenvolvia perante o magistrado, funcionário imperial, e este, depois de ouvidas as partes, autorizava ou negava a execução.

A religião também teve um importante papel nesta mudança de procedimento. Como afirma a doutrina: “[j]á na era cristã, o império romano chegou a organizar a Justiça de forma autônoma e totalmente pública. A esse período histórico deu-se o nome de *extraordinaria cognitio*, porque inicialmente o *praetor* passou a assumir, em determinadas causas, o seu conhecimento e julgamento, eliminando a figura arbitral do *iudex*. Essa abolição foi gradual, mas com o passar dos tempos generalizou-se. O *praetor* fundiu o *imperium* com o *iudicium* e se tornou um juiz completo, nos mesmos padrões que nos tempos atuais caracterizam o Poder Judiciário e os Juízes estatais”.⁵⁰

Assim, “a característica da nova época reside no fato de que o processo se tornou inteiramente estatal: o magistrado investido da jurisdição conduz o processo até o fim e profere, ele próprio, a sentença, ou delega o pronunciamento a um funcionário dependente dele (*iudex datus*)”.⁵¹

A concentração do direito no príncipe e no Estado, portanto, foi importante para a futura formação dos estados-nação. Os romanos haviam dado um passo determinante ao absorver todo o direito como fonte estatal e ao associar a atividade executiva com o Estado.

2.3.2. Processo dos povos germânicos: Alta Idade Média⁵²

Na Alta Idade Média, após a queda do Império Romano do Ocidente, os povos germânicos “bárbaros” invadiram a Europa Ocidental-românica.

No campo das execuções civis, a falta de cumprimento da obrigação era considerada no antigo

direito germânico como ofensa pessoal ao credor. O direito autorizava o próprio credor a reagir e a reparar o direito lesado pelo inadimplemento do devedor com o uso da força. Não havia qualquer recurso a um terceiro imparcial, à autoridade pública ou particular. Não havia espaço para a análise imparcial das afirmações do credor e as oposições do devedor.

Mesmo com o avanço da legislação, que passou a garantir o controle da atividade dos interessados e a *penhora*, que passou a ser necessariamente autorizada pelo juiz, a verificação era feita apenas quanto aos requisitos formais do pedido, e não quanto às provas dos fundamentos da defesa do devedor.

Somente se realizada *efetivamente* a penhora surgia para o devedor a possibilidade de impugnar, *a posteriori*, a legitimidade da execução e a possibilidade de impor multas pesadas ao credor que não fosse capaz de justificar os atos de execução praticados.

A doutrina aponta, ainda, *como tese deduzida logicamente*, que provavelmente já no período de Justiniano fosse permitido ao mesmo magistrado que conhecia da *actio iudicati* autorizar de imediato atos executivos, como característica dessa concentração dos poderes no magistrado estatal. Como afirma Liebman: “[d]e onde é lícito deduzir que, se por qualquer outra razão não se deva manter ainda aberto o contraditório (como no caso de rejeição das exceções opostas à *actio iudicati*), pode o juiz extrair, imediatamente, da renovada verificação do crédito a consequência lógica de emitir a ordem de execução (...) pela qual a *actio iudicati* se convertia em meio para requerer a execução da sentença, do que se queria efetivamente conseguir, mesmo que fosse ainda necessária a chamada do devedor a juízo, para poder, em sua presença, certificar-se que a obrigação não fora, até então, satisfeita”.⁵³

Enquanto no Império Romano do Oriente, sob as luzes de Justiniano, o direito e o processo seguiam em evolução à tradição romana ocidental, na primeira fase das chamadas invasões bárbaras, o direito na península já sofria severas modificações.

2.3.3. Direito intermédio: os povos germânicos na Itália (Alta Idade Média)

A queda do Império Romano do Ocidente resulta também no ingresso das fontes e costumes jurídicos dos povos invasores na península. O direito romano entra em choque com o direito dos povos germânicos em matéria de execução. É comum associar o modelo germânico a um modelo mais primitivo. Para a doutrina: “[o] direito dos povos que vieram a estabelecer-se na Itália com a queda do Império do Ocidente, constituía o fruto de uma civilização muito mais primitiva que a romana e dificilmente os poderes régios logravam restringir o uso antiquíssimo da vingança privada”.⁵⁴

Assim, “duas mentalidades profundamente diferentes entraram em choque: a romana, embebida de respeito pelo direito, que exigia, mesmo depois de proferida regularmente a sentença condenatória, que se desse entrada à execução por meio da *actio iudicati*, isto é, por meio de novo processo contraditório em que fosse possível apreciar se o direito do credor, já sancionado pela coisa julgada, assim subsistisse; e a germânica, rude e violenta, impaciente de qualquer demora, que permitia em primeiro lugar a realização de atos executivos e admitida só eventualmente e incidentemente o exame imparcial das razões dos contendores.”⁵⁵

Na Alta Idade Média, com o advento dos povos germânicos na Itália, não havia intervenção de um terceiro imparcial, as noções lentamente progrediram da vingança privada na pessoa do devedor para a composição pecuniária, era permitida a penhora privada para forçar ao devedor a composição, sob pena de perdimento dos bens e direitos; somente com o tempo surgiram limites à penhora que exigiram que esta fosse autorizada primeiramente pelo juiz. A doutrina faz um detalhamento da evolução deste período e suas diversas fases a partir da Lei Sálica (Francos-sálicos), do Édito de Teodorico (Ostrogodos) e do Édito de Rotari (Longobardos).⁵⁶

Em síntese: “[o]s preceitos dos Editos longobardos, interpretados à letra e em sua conexão lógica, demonstram que, no direito longobardo, analogamente (e talvez com maior precisão) a tudo o que se depara nos outros direitos populares germânicos, consumava-se a penhora sem

prévia verificação do crédito, mas em virtude da eficácia formal da afirmação do credor, ressalvada a possibilidade de instaurar-se, no curso da atividade executiva ou depois de concluída, um processo regular contraditório, para o exame das afirmações de ambas as partes”.⁵⁷

Mas, mesmo após o período carolíngio “[o]s documentos dos séculos IX e X demonstram como continuou a ter larga aplicação o uso da penhora por autoridade particular. E isso é confirmado pelos juristas no *Liber papiensis*, consideram a penhora longobarda com a tríplice advertência como direito praticamente em vigor. Numerosíssimos são, ademais, os contratos da época nos quais se encontra cláusula expressa que faculta ao credor exigir, em caso de inadimplência, a penhora, sem necessidade de se dirigir ao juiz”.⁵⁸ E ainda a afirmação de que, por princípio, “a execução não constitui estádio separado do processo, mas se articula imediatamente na sentença (...) as sentenças continham uma ordem particularmente precisa ao condenado, para acomodar-se ao teor da decisão, e que ao pronunciamento desta se seguira, independentemente de expresse requerimento do autor, subentendido, já, na demanda inicial, todo o esforço, por parte daquele que havia julgado, no sentido de se operar imediatamente, na própria audiência, a entrega (simbólica, se se tratasse de imóveis) da coisa disputada, ou o pagamento da multa e da dívida, ou, pelo menos, a formulação da promessa de adimplemento com a formalidade da *wadia* [espécie de garantia do direito longobardo, indicando também a tradição da coisa... não que] o juiz assistisse passivamente à espontânea execução desses atos; antes o vemos agir energicamente, com a ameaça de banimento, a fim de obter do condenado o adimplemento ou a promessa. Limitados os seus poderes pelo princípio de que não pode a sentença conduzir à execução forçada, o juiz procura por esse caminho atingir igualmente o resultado prático de efetiva obediência à sua decisão, e, isso, não a requerimento do interessado, mas no exercício de uma atividade naturalmente consequente à de julgar”.⁵⁹

Constata-se que não havia, portanto, precedência necessária da cognição à execução e que a atividade executiva não era necessariamente judiciária ou estatal, podendo ser privada, com controle posterior pela autoridade judiciária.

Essa fase foi seguida da redescoberta das fontes romanas cultas com a recepção do direito romano de Justiniano pela nascente universidade italiana. Iniciava-se a formação do direito culto, um direito comum a todos os povos (*ius commune*), no qual o *Corpus Iuris Civilis* representava a *ratio scripta* e os glosadores e pós-glosadores a autoridade da doutrina.

2.3.4. Processo comum: recepção do direito romano (Baixa Idade Média)

Após o período inicial da Idade Média, Alta Idade Média, em que se viveu a experiência dos direitos dos povos germânicos na península italiana, ocorreu na Europa o fenômeno da formação das universidades. Nesse período, a redescoberta do direito romano que havia sido compilado por Justiniano no Império Romano do Oriente resultou na construção de um saber jurídico culto, comum a todos os povos, o *ius commune*.

A doutrina, por estas razões, anota a ocorrência de um choque com a recepção do direito romano na Europa, a partir da formação das universidades e da redescoberta do direito imperial como direito culto, em contraposição com o direito germânico. Ocorrem influências recíprocas,⁶⁰ toda recepção é uma recepção criativa.⁶¹

A partir do século XI, as articuladas construções romanas, acrescidas com as notas e as realizações do direito romano do Império Oriental, condensadas no *Corpus Iuris Civilis* assumiram na Europa o papel de *ratio scripta* (razão escrita), iniciando-se o período dos glosadores e pós-glosadores, os estudos universitários e a formação do direito comum (*ius commune*).

No campo da execução civil, há claramente uma tentativa de síntese de virtudes, tomando de empréstimo as melhores soluções – em tese – de um e outro modelo.

Os juristas medievais construíram, a partir deste conflito de ideologias executivas, soluções de consenso adequadas para o seu tempo, a partir das exigências sociais, jurídicas e políticas implicadas.

Criou-se o instituto da *executio parata* (execução aparelhada), com elevada carga de praticidade, pois permitia a circulação de bens e serviços – produtos da crescente ascensão comercial das corporações de ofício, do comércio mercantil e da burguesia ascendente que resultava destas atividades. A *executio parata* (execução aparelhada) subsiste até hoje através dos títulos executivos. Antes de mais nada, os juristas medievais reafirmaram o “princípio da necessária precedência da cognição” (de origem romana), assim, “o credor devia sempre submeter suas pretensões à apreciação do juiz em processo contraditório para que fossem julgadas procedentes ou improcedentes: *primo intentanda est actio* (Glosa) ; *non est incoandum ab executione* (Bartolo). Proferida a condenação, torna-se possível a execução”.⁶²

Surge então um novo procedimento executivo, uma nova fase do processo de conhecimento, para reduzir a dilação e as formalidades da antiga *actio iudicati*, relegada a situações excepcionais de liquidação de condenação ilíquida, pedido de juros sucessivos à sentença etc., a então chamada “execução *per officium iudicis*”. Liebman explica que o “*officium iudicis* compreende todas as atividades que o juiz devia exercer naturalmente, em virtude de seu ofício”; demonstra que esta doutrina surge com Martino de Fano, se desenvolve posteriormente também ao processo de execução por força do costume germânico de não dissociação entre atividade de conhecimento e execução, e é posteriormente esclarecida por dois dos maiores juristas da idade média, Bartolo e Baldo, ao afirmar que: “*istud officium venit in consequentiam primae condemnationis* e que *ista executio est quaedam compulsio quae petitur quia in libello petitur reum condemnari et compelli* (...) na grande variedade, devia competir ao juiz que havia julgado promover a execução, e, se os bens, sobre os quais se tinha de agir, se achavam no território de outro juiz, era a este que se devia dirigir, não com a invocação de seu ofício, mas com a propositura da *actio iudicati*, a menos que não lhe transmitisse o encargo de executar o próprio juiz que julgara”.⁶³

Seguindo a tradição germânica de não dissociar a atividade de execução da atividade cognitiva, passou a doutrina a tratar da execução como simples prosseguimento e complemento do ato da prolação da sentença, como consequência da condenação, seu desdobramento natural (*istud officium venit in consequentiam condemnationis*, Bartolo). Em razão disso, a sentença condenatória adquire originalmente um valor que antes não possuía, um potencial novo, inovador, instrumentalizar o ato posterior de execução, no latim: *sententia habet paratam executionem*. A sentença passou a *aparelhar* a execução, sem necessidade de enfrentar um novo processo em contraditório, sem necessidade de nova ação, sem necessidade da *actio iudicati*.⁶⁴

Como a genialidade desta nova construção – consistente na passagem da cisão estanque entre cognição e execução, com a exigência de que a cognição sempre se antecede à execução, até que fosse possível o exercício dos atos executivos por força da confissão do devedor – era fecunda, ela permitia a utilização deste aparelhamento da execução para outras finalidades.

As classes ascendentes e as relações de comércio que ocorriam na Baixa Idade Média percebiam a necessidade de novas soluções, para dar maior agilidade aos intercâmbios mercantis e novas soluções foram pensadas. Ao permitir o aparelhamento da execução a doutrina identificou que as novidades não paravam por aí.

Perceba-se que, se a execução era *aparelhada* pela sentença, não era a prévia cognição e a prova produzida no processo judicial que autorizavam a execução, mas a própria sentença. O *ius executivum* atuava diretamente: “por essa via, pode-se atuar o *ius executivum* diretamente, sem verificação da subsistência do direito de crédito. E o que enunciam os doutores com a fórmula *sententia habet paratam executionem* (...) essa eficácia especial da sentença explica-se pela robustíssima prova que ela confere às afirmações de quem requer a execução. Mas já a doutrina do tempo sustenta vigorosamente que o conceito da prova não basta para atribuir à execução a justificação dogmática (...) A prova destina-se a convencer o juiz ou estabelece (no caso da prova legal) de que modo, de preferência a outra, deve ele julgar, ao passo que a *executio parata* exclui, em verdade, a exigência de um processo, para, em vez disso, abrir caminho livre ao ato executivo. Estamos, pois, fora do domínio da prova”.⁶⁵

A sentença não era a prova de que havia ocorrido uma atividade executiva, *era tão somente o título que autorizava a execução*. Dessa forma, para explicar a sua função dogmática, era

irrelevante a cognição anterior. Dissociava-se a cognição da execução.

A partir dessa dissociação, os fluxos comerciais e o papel dos cartorários no desenvolvimento do direito medieval fizeram que também outros documentos contendo a confissão da dívida pudessem ser equiparados à sentença para fins de aparelhar a execução – os *instrumenta guaranteegiata*.

“A conveniência de rápida realização de algumas categorias de créditos, estipulados com observância de formalidades especiais, fez com que a legislação estatutária das cidades em que o comércio florescente mal suportava as delongas do processo ordinário, reconhecesse a eficácia da execução aparelhada aos instrumentos de dívida lavrados perante o tabelião (*instrumenta guaranteegiata*).”⁶⁶

Surgiam, por necessidade prática e absorção dos conceitos decantados da experiência germânica, as execuções com base em títulos executivos extrajudiciais. Nascia a nova casta medieval dos notários, profissionais responsáveis pelos documentos que garantiam as atividades mercantis, os *instrumenta guaranteegiata*. A partir deles, os nascentes títulos de crédito e sua validação para o aparelhamento de execuções de títulos formados extrajudicialmente.⁶⁷

A praxe foi abonada originalmente pela equiparação da lavratura da escritura notarial como equivalente da confissão por parte do devedor, sendo que a sua declaração frente ao tabelião tinha o mesmo efeito daquela realizada em juízo. Aproveitou-se a máxima romana segundo a qual o confesso se equivalia ao condenado (*confessus in iure habetur pro condemnato*)⁶⁸ e o resultado a que se chegou foi que os efeitos executivos da sentença poderiam ser estendidos aos documentos preparados pelo tabelião.

Nesse sentido, afirmou a doutrina que: “[p]ara todos os efeitos, portanto, os créditos consagrados em tais instrumentos, chamados de garantia (*guarantigia*), autorizavam a agir por via executiva sem prévio processo, tal como se se consagrasse numa sentença de condenação definitiva. Por último, admitiram-se a desfrutar esse privilégio também as letras de câmbio”.⁶⁹

Os *instrumenta guaranteegiata* gozavam da mesma dignidade da execução aparelhada pela sentença. Havia, contudo, uma diferença substancial, na execução aparelhada pela sentença havia o selo da coisa julgada, que garantia a estabilidade da decisão, reduzindo-se as possíveis defesas do executado à arguição de nulidade da sentença ou a alegação de pagamento posterior à sentença (herança do processo romano). Na execução aparelhada pelo documento preparado pelo tabelião “permanecia íntegra a possibilidade de o executado defender-se por todos os meios”.⁷⁰

A partir desta diferença, ao longo da história processual, as execuções passaram a ser separadas por dois casos: a) caso se apresentem como *execução de sentença judicial* seguem como simples prosseguimento da ação (podendo ou não ser exigida nova ação, como ocorreu no Brasil de 1973 até as reformas processuais de 2006), com reduzidas possibilidade de defesa; b) caso se apresentem como *execução de títulos executivos formados extrajudicialmente*, como verdadeira *ação executiva*, terão prazos especiais para discussão das defesas do executado e maior amplitude e extensão de fundamentos. Muito embora não seja necessária, a execução *per officium iudicis* transformou-se na regra geral para as sentenças condenatórias.

Esta doutrina construiu e constituiu os ordenamentos jurídicos europeus, inclusive o de Portugal, influenciando fortemente o Brasil.

2.3.5. Direito reinol (ordenações do reino de Portugal)

O direito português foi o primeiro direito vigente no território brasileiro. É preciso compreender sua estrutura e influências para perceber como Portugal influenciou a legislação nacional posterior. Antes de mais nada, devemos nos recordar que Portugal consolidou-se como reino muito antes dos demais Estados europeus. Isso possibilitou, muito cedo, uma grande coesão linguística e a centralização do poder nas mãos do rei. A formação do direito tornou-se necessariamente estável para garantir essa estrutura, daí a exigência natural de controle dos

poderes menores pelo soberano. Assim, Portugal adiantou, em muito, o *centralismo jurídico natural* aos Estados absolutistas.⁷¹

No direito das Ordenações do Reino, a *actio iudicati* passou a ser residual. A regra geral era a execução *per officium iudicis* após a condenação, na qual o juiz continuava a atividade já iniciada. Por outro lado, os títulos extrajudiciais não eram equiparados aos títulos judiciais. Para a satisfação destes, as Ordenações determinavam um procedimento sumário especial prévio – a “assinção de dez dias”, seguido da execução *per officium iudicis* da regra geral. A ação executiva existia apenas para créditos extraordinários, que consistiam em títulos especiais autorizando a execução aparelhada.

A doutrina registra a passagem do direito comum às Ordenações. “A *actio iudicati* era considerada instituto excepcional, ao qual devia recorrer-se quando ‘se quer pedir coisa em que ainda não há condenação’. O caminho normal era pedir a execução *per officium iudicis*, observadas as formas estabelecidas nas Ord. Fil., liv. III, títs. 86 e ss. Quanto aos instrumentos, o direito português, ao invés de reconhecer-lhes execução aparelhada, admitiu que servissem de fundamento a uma ação sumária especial, chamada ‘assinção de dez dias’ (Ord., liv. III, títs. 25) e a sentença assim conseguida poderia ser depois executada pelas vias ordinárias. Só para alguns créditos privilegiados, (créditos do fisco, foros enfitêuticos etc.) subsistiu a ação executiva nos moldes indicados acima”.⁷²

O período de influência das Ordenações do Reino de Portugal no Brasil é muito amplo. Mesmo após a Proclamação da Independência, no período do Império (1822 a 1890) e com o advento da República (1890), as codificações brasileiras continuaram fortemente influenciadas pelo direito português anterior. O Regulamento 737, de 1850, que regulamentava o processo civil no âmbito comercial, depois estendido pelo Dec. 763, de 1890, também ao processo civil, previa as três espécies: a execução da sentença, a assinção de dez dias e a ação executiva.⁷³

Assim como na Europa havia sido abandonada a *actio iudicati*, o mesmo aconteceu no Brasil. Afirma a doutrina, ao comentar as Ordenações: “[o] mesmo se deu no Brasil. A *actio iudicati* é lembrada apenas como reminiscência histórica. O Regulamento 737, de 1850, prevê distintamente a execução da sentença, a assinção de dez dias e a ação executiva”.⁷⁴

Com a Proclamação da República, por força da Constituição de 1891, tivemos os diversos Códigos estaduais e somente após a nova Constituição, em 1934, o direito brasileiro unificaria seu direito processual em um único Código, eliminando-se a assinção de dez dias.

2.3.6. Direito brasileiro: 1939, 1973 (e reforma) e 2015

Iremos tratar agora da execução no direito brasileiro já sobre a influência direta da Europa. O direito brasileiro ainda irá demorar a construir um modelo executivo sólido. As regras de direito positivo revelaram-se complexas e a execução, cara, burocrática, ineficiente e demorada na maior parte da nossa experiência histórica. Há uma excessiva preocupação com a tutela do devedor e o caráter público do processo. A tutela do crédito não é o foco de convergência central no processo de execução para pagamento de quantia certa no direito brasileiro anterior à Constituição de 1988 e ao CPC/2015.

Poderíamos dizer do nosso ordenamento processual até as Reformas e o CPC/2015 o que já dissera a doutrina italiana do seu: a execução civil brasileira é/era o *pesadelo dos estudantes, um campo minado para os advogados e uma fonte constante de frustração para os juízes*.⁷⁵

2.3.6.1. 1939

O Código de Processo Civil de 1939 abandona a assinção de dez dias, mantendo unicamente a via ordinária, a execução de sentença como simples desdobramento da sentença condenatória (execução *per officium iudicis*),⁷⁶ e a via especial, a ação executiva para títulos executivos extrajudiciais. Não seguiu o direito brasileiro no particular a doutrina europeia da *execution parée*, consistente na equivalência da sentença e dos instrumentos públicos constitutivos de títulos

executivos extrajudiciais (as chamadas *lettres obligatoires*, instituídas primeiro pelo costume e depois albergadas pelas Ordenações do Rei. Conferir ainda, o *Code Louis XIV, Ordonnance Civil*, 1667; e o, Código de Napoleão, *Code de Procédure Civile*, 1806).⁷⁷

2.3.6.2. 1973

O Código de Processo Civil de 1973 nasceu como monumento técnico. Procurava descrever, em sua arquitetura de linhas claras, as distintas divisões entre os processos de conhecimento, cautelar e execução. Conhecer para declarar, acautelar para assegurar e executar para satisfazer, cada campo em um distinto livro do Código.

Assim estruturado, o Código pretendeu purificar as execuções das atividades de conhecimento, unificando a execução.

A execução não seria mais um simples desdobramento, como fase, da atividade de cognição, mas um processo em si, com estrutura própria e independente. Já não importava, para este fim, que fosse decorrente da existência de um título judicial ou de um título extrajudicial. Ambos os casos foram reunidos, unificando-se a execução. A diferença entre as execuções, portanto, era reduzida à matéria de defesa mediante a ação de embargos do executado, mais ampla no caso dos títulos extrajudiciais.

Isso foi devidamente anotado pela doutrina, ao atualizar a obra clássica de Liebman: “Com o Código de 1973, *as ações de natureza executiva foram unificadas*, desaparecendo a distinção registrada pela doutrina entre execução de sentença (ação executória), ação executiva propriamente dita (CPC/1939, arts. 882/1.030 e 298/301, respectivamente), e executivo fiscal (Dec.-lei 960, de 17.12.1938). Os títulos – *nulla executio sine titulo* (art. 583) – foram classificados em judiciais (art. 584) e extrajudiciais (art. 585), ambos com idêntica força executiva a propiciar a instauração do processo de execução com procedimento uniforme. O único ponto a distingui-los diz respeito à maior amplitude dos embargos do devedor quando se tratar de execução de título extrajudicial (art. 745 (...))”.⁷⁸

A verdade é que esta ordem de ideias fora já inspirada em Liebman e já estava traduzida nas transcrições literais que Alfredo Buzaid realizou de sua obra na exposição de motivos do CPC de 1973.⁷⁹ A construção era arquitetonicamente perfeita, porém acabava por tornar a atividade executiva mais cara, burocrática, lenta e inefetiva.

O CPC/1973 não resistiu às necessidades práticas da vida, o processo de execução não pôde, por ser o mais rente ao resultado prático do direito, permanecer distante das necessidades de efetividade e de concretização que dele se espera.

Em razão disso, o direito processual foi fortemente reformado.

Primeiro, quanto às tutelas de urgência, tutelas específicas e pelo resultado prático equivalente e pela tutela da evidência (Lei 8.952/1994 – tutela antecipada, tutela da evidência e tutela específica das obrigações de fazer, desfazer e não fazer; Lei 10.444/2002 – modelo integrado de tutela antecipada, fungibilidade das tutelas de urgência e tutelas específicas das obrigações de entrega de coisa), com especial destaque para os arts. 273, 461 e 461-A do CPC/1973 (reformado, em sua versão final, antes da integral revogação pelo CPC/2015), os quais já permitiam, no âmbito do processo de conhecimento, atividade satisfativa (processo sincrético), antes mesmo de obtenção do título, relativizando-se os brocardos *nulla executio sine titulo* e *nemo potest praecise cogi ad factum* e o *dogma de que o conhecimento deve preceder à execução*, ao mesmo tempo que relativizaram a tipicidade dos meios executivos, permitindo-se uma ampla gama de medidas sub-rogatórias e indutivas para as obrigações de fazer, desfazer, não fazer e entrega de coisa.

Depois, por força das reformas na própria estrutura do Código, tanto no processo de execução de título executivo judicial, que deixou de ser processo para se tornar, predominantemente, uma execução fase (Lei 11.232/2005 – alteração do conceito de sentença e cumprimento de sentença como execução fase do processo de conhecimento, especialmente os arts. 475-J e ss. que tratavam

do cumprimento das sentenças que reconhecem a obrigação de pagar quantia), quanto no processo de execução de títulos executivos extrajudiciais (Lei 11.382/2006 – alterações no processo de execução de títulos extrajudiciais), o antigo modelo arquitetônico deu espaço para uma estrutura totalmente nova, antecipando o CPC/2015.

2.3.6.3. 2015

O CPC/1973 não resistiu, foram tantas e tão frequentes as alterações que foi necessário pensar um Código de Processo inteiramente novo.

O antigo edifício contava com muitos remendos e sua lógica interna havia sido prejudicada, especialmente pela quebra das suas premissas metodológicas de *separação entre cognição e execução* e de *atividade de execução unificada*.

O CPC/2015 será analisado com mais detalhes mais adiante, ao falarmos do modelo de execução civil no Brasil. Por agora, contudo, basta afirmar que se consolidaram as alterações que haviam ocorrido com as leis reformadoras do CPC/1973 (Leis 11.232/2005 e 11.383/2006), sendo que parcela da atual doutrina processual civil, justamente por isso, afirma que não ocorreram alterações de relevo no CPC. Para esta doutrina, o CPC/2015 apenas teria reproduzido a imagem do CPC/1973 reformado, *sem alterar a ideologia das reformas*.⁸⁰

Há doutrina, contudo, que percebe, em maior ou menor extensão, uma revolução silenciosa no modelo da execução brasileira. Essa revolução é consistente na atipicidade dos meios executórios e na adequação dos meios à finalidade do processo: a tutela dos direitos adequada, efetiva e tempestiva. A atipicidade dos meios executivos está prevista como *dever-poder do juiz* no art. 139, IV, segundo o qual: *incumbe ao julgador “ determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária ”*.

Na doutrina:

“Ressalvada a execução contra a Fazenda Pública, a atividade executiva pode se valer de técnicas executivas atípicas para promoção da tutela dos direitos. No desenho original do Código Buzaid, tínhamos um sistema rígido de correlação entre tipos de obrigação e tipos executivos. As Reformas introduziram um sistema parcialmente maleável, permitindo emprego de técnicas atípicas para o cumprimento das situações substanciais consubstanciadas em um fazer, não fazer e no direito à coisa. Com exceção da execução contra a Fazenda Pública, o novo Código quebrou integralmente o sistema de tipicidade da técnica processual, permitindo emprego do meio executivo mais adequado para tutela do direito em toda e qualquer situação substancial (art. 139, IV, CPC). Trata-se de quebra que visa à promoção da tutela específica dos direitos, pugnada pela doutrina preocupada com a efetividade do processo. Com isso, o direito brasileiro afasta-se de um sistema de técnica executiva rígida e avizinha-se a um sistema de técnica executiva maleável, seguindo nesse particular a tendência que emerge do direito comparado. Todos os meios processuais têm de estar disponíveis para tutela dos direitos.”⁸¹

O modelo de uma execução típica para um tipo de obrigação, de corte germânico, vigente no ordenamento anterior com especial destaque para a tutela do crédito, vem assim substituído pelo modelo de adequação, do *common law* e pela generalização das *astreintes*, com a possibilidade de cominação de *astreintes* para compelir ao pagamento de quantia,⁸² no estilo francês.⁸³ O modelo da execução no Brasil torna-se assim um híbrido, voltado para a tutela adequada e para a efetividade da atividade executiva e, portanto, mais adequado à tutela dos direitos e ao Estado Democrático Constitucional.

2.4. Direito comparado atual: União Europeia, América Latina e Common Law

A execução é um dos campos mais nacionalistas e paroquianos do direito processual. No cenário do direito comparado, os estudos sobre execução são recentes e focados principalmente nas execuções de decisões judiciais, mas abrangentes também dos títulos extrajudiciais. Estudos

sistemáticos e tentativas de harmonização são recentes e isso pode ser explicado apenas por força, ao menos em parte, de uma prevalente “ *psicologia das profissões legais ligada ao processo de conhecimento* ” e que relega a execução a “ *um interesse privado das partes* ”.⁸⁴

Há, aqui, uma forte carga da perspectiva histórica e da noção medieval, do direito comum, de que a *iurisdictio in sola notione consistit* (jurisdição só em conhecimento consiste). Essa mitologia e essa ideologia deixou obliterado por anos o direito à técnica processual idônea à satisfação do direito material, em geral, e à tutela do crédito, no particular. Hoje, como faz a doutrina contemporânea em um mundo globalizado em que se deve pensar inclusive em execuções transfronteiriças (*cross-boarder enforcement*), há necessidade de uma inversão dessa lógica: *iurisdictio in sola executioni consistit* (a jurisdição só na execução consiste).⁸⁵ Em outras palavras, a jurisdição, compreendida aqui como atividade de satisfação do direito, não pode falhar no momento de garantir a própria efetividade do direito. Não se exige que o modelo de tutela seja somente judicial, poderá ser também administrativo ou privado, mas se exige que o procedimento voltado à tutela do direito seja efetivo. Em última instância, caberá ao Poder Judiciário controlar sua efetividade.

A regra anterior era não se preocupar com a atividade *prática* da execução – por ser ela uma atividade de menor importância. Essa situação começou a mudar por força da constatação da ineficiência de muitos sistemas europeus já no início do século XXI:⁸⁶ a) sistemática ineficiência para implementar decisões judiciais e a execução de títulos extrajudiciais; b) sistemática ineficiência para implementar decisões judiciais em tempo hábil, tornando-se uma questão fundamental após a Corte Europeia de Direitos Humanos condenar diversos países por violação ao art. 6.1 (processo justo, *giusto processo* , *fair trail* , *procès équitable*) da Convenção Europeia de Direitos Humanos (*Hornsby v. Greece* , 19 march 1997).⁸⁷

O direito fundamental à efetivação dos provimentos jurisdicionais e dos títulos executivos e decisões estrangeiras com *exequatur* (*cross-boarder enforcement*) foi então amplamente reconhecido. Os casos iniciais são da Grécia e da Itália, mas logo em seguida as novas democracias europeias, resultantes da dissolução da antiga União Soviética, começaram a ser condenadas na Corte Europeia de Direitos Humanos pelas mesmas razões, por falta de observância do processo justo na execução de decisões judiciais (*civil judgments*) e títulos extrajudiciais (*other enforceable documents*), aumentando as questões sobre os *standards* de proteção dos direitos humanos no processo judicial civil. Percebe-se que o problema tem, portanto, uma dimensão mundial, não limitada ao Brasil e à União Europeia, mas atingindo os países da América Latina e os Estados Unidos da América.

A abordagem que nos é permitida neste espaço serve apenas para indicar duas tendências de análise comparada.

A primeira diz respeito aos *modelos de execução* pensados em abstrato, a partir dos *meios executivos colocados à disposição* , subdivida em: a) modelo de *common law* : adequação dos meios executivos; b) modelo germânico: obrigações tipo e execuções tipo; c) modelo francês: generalização das *astreintes* , inclusive para a tutela de obrigações de pagar quantia.⁸⁸ O modelo brasileiro está claramente caminhando para um saudável hibridismo nesta matéria, abraçando as características do modelo de adequação norte-americano e de generalização das *astreintes* (art. 139, IV, CPC) ao lado da tradicional tipicidade da técnica da expropriação, *como regra geral* , para a execução de pagamento de quantia certa (arts. 824 e ss.).

A segunda diz respeito aos *modelos de administração da atividade executiva* , ou seja, quanto à autoridade competente para fazer valer os atos administrativos. Existem aqui três opções possíveis: a) modelos judiciais; b) modelos administrativos; c) modelo liberal ou misto de execução.

⁸⁹

Em uma breve sumarização, podemos dizer o seguinte:

a) o *modelo judicial* caracteriza-se por ter o juiz como sujeito principal (“Poder Judicial – Poder do Estado que organicamente titulariza a função executiva judicial”), seja ele um juiz especial de

execução ou o próprio juiz prolator da execução. Segundo a doutrina, “En este modelo se circunscribe España y los países de Centro y Sudamérica, y se basa en ciertos imperativos constitucionales, considerando a la ejecución como una continuación del proceso de conocimiento (es decir, función jurisdiccional excluyentemente judicial) en que nadie mejor que quien dictó la resolución puede hacerla cumplir. Si bien el centro es el juez, las actividades para la ejecución son, en los hechos, delegadas”.⁹⁰

Há, portanto, no modelo judicial, uma centralização da atividade no Poder Judiciário, mesmo que possam existir atividades delegadas aos oficiais de justiça e aos demais auxiliares do juízo. Este modelo é também quanto à administração da justiça executiva o modelo brasileiro. Pressupõe, como vimos, uma associação entre atos executivos e atos jurisdicionais, considerados como atos de soberania e percebidos a partir de uma visão de exclusividade da jurisdição nas mãos do Estado-juiz;⁹¹

b) o *modelo administrativo* de execução é aquele no qual uma agência ou órgão estatal tem a responsabilidade pela execução das sentenças e/ou títulos executivos extrajudiciais. Os agentes da execução são servidores públicos especializados na atividade de execução. Na Europa, este modelo é normalmente encontrado para cobrança de dívidas de natureza pública, como multas, ou decorrentes de funções estatais ou impostos. Este modelo também serve, por exceção, para cobrança de dívidas privadas, a exemplo da execução de sentenças ou títulos extrajudiciais por autoridades administrativas na Suíça, Suécia e Finlândia;

c) o *modelo liberal ou misto de agentes de execução privados e públicos*, com maior ou menor participação do Poder Judiciário como agente de controle. Neste modelo misto incluem-se atividades de agentes de execução privados ou públicos e do juiz, como órgão de garantias. O tema tem muitos desdobramentos, mas é bom ressaltar que o Conselho da Europa recomendou aos Estados-membros a adoção de agentes de execução administrativos e privados. Os agentes de execução estão sendo adotados no direito comparado em mais de um ordenamento jurídico. A Europa é precursora deste movimento pelos agentes de execução (*baillifs* ou *huissiers*).

Os agentes executivos são especializados em tornar efetivas as sentenças judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Geralmente são nomeados por órgãos administrativos ou pelo Poder Judiciário. Poderão ser funcionários públicos, servidores ou não do Poder Judiciário, profissionais liberais, a exemplo dos corretores de imóveis já reconhecidos no Brasil como auxiliares do juízo para o procedimento de alienação por iniciativa particular (art. 879 e ss.), mas todos devem ter por dever a preservação do devido processo legal e a justiça equitativa.

Nesta matéria, é importante perceber, como tendência geral, a adoção de modelos mistos, com agentes administrativos, agentes privados e atividade judicial, quando necessária, para assegurar a desburocratização, a agilidade e a redução do custo da execução para tutela do crédito (*debt collection* ou *money enforcement*).

2.4.1. Vantagens e desvantagens da distribuição de atividades executivas nos modelos comparados: judicial, administrativo e liberal ou misto

Vimos que os modelos comparados, segundo a tônica da atribuição da atividade executiva, podem ser divididos em: a) modelo judicial; b) modelo administrativo; c) modelo liberal ou misto. Uma tabela oferecida pela doutrina comparada ilustrará estes modelos em suas vantagens e desvantagens.⁹²

Antes de analisarmos as vantagens e desvantagens, é preciso realizar uma pequena explicação sobre o quadro a seguir. Como vimos no tópico anterior, a solução mista foi analisada em conjunto com a solução liberal, formando um único modelo, o c) *modelo liberal ou misto*. Neste modelo, como já analisado, as atividades executivas privadas serão combinadas com atividades executivas administrativas extrajudiciais. Tal modelo implica a desjudicialização da execução. Sua adoção pelo Brasil importaria uma mudança significativa em prol da economia processual, da redução de custos com a máquina pública, promovendo uma maior agilidade da execução. Ao mesmo tempo, um modelo deste tipo jamais se furtaria a um nível adequado de tutela jurisdiccional e estatal de

controle, pois a função do Poder Judiciário na execução seria residual e de garantias.

Por outro lado, *a) o modelo judicial exclusivo*, focado no *excesso de regulação* e na *centralidade do Poder Judiciário*, deve ser abandonado por qualquer ordenamento jurídico contemporâneo, por ser ineficiente, burocrático, caro e demorado. A jurisdição, e muito menos a atividade executiva, que nem jurisdicional precisa ser em essência, não é, ou não deve ser, uma atividade *exclusivamente* judicial.

Como afirmado na doutrina, partindo da experiência italiana que tanto influenciou o Brasil: o “*diabo está no detalhe*”. A obsessão por normas detalhadas por uma regulamentação pormenorizada para a execução civil é causa permanente de frustração para os agentes do sistema de justiça e os propósitos públicos deste sistema.

Nesse sentido, afirma a doutrina que: “(...) enforcement procedures in Italy are over-regulated, and that the abundance of minutely-detailed rules is not a key to fruitful results. An obsession for details often makes you lose sight of the overall issue, and the steps you take to achieve a certain outcome end up becoming more important than the outcome itself: this is what happens in Italy in the field of enforcement of judgments, and what makes the law on enforcement the nightmare of law students, a minefield for lawyers, and a source of endless frustration for judgments holders”.

93

A execução deve ser efetiva, o processo pensado para a sua efetividade. Não pode o procedimento previsto em lei ser um pesadelo para os estudantes, um campo minado para os advogados e uma fonte de frustração sem fim para os juízes. Queremos afirmar, assim, que problemas complexos como a inefetividade da execução precisam de soluções articuladas, partindo de premissas simples que as orientem e coordenem. Os passos para a obtenção do resultado não podem superar em importância o próprio resultado a ser obtido, o processo não é um fim em si mesmo.

Dessa maneira, a premissa da atividade de execução civil é que ela deve servir à tutela do direito, e, no caso da execução para pagamento de quantia certa por devedor solvente, à tutela do crédito e à satisfação do direito de crédito; ao mesmo tempo, deve permitir as garantias do executado e o interesse estatal na atividade mais eficiente e com o menor custo público.

Quanto às garantias do executado, vale dizer que estas não são o foco principal da atividade executiva, como se extrai da *prevalência do princípio de que a execução se faz no interesse do credor* (art. 797, CPC) sobre o *princípio da menor onerosidade possível* (art. 805, CPC). A *menor onerosidade possível* somente ocorre em relação aos meios executivos de igual efetividade, ou seja, um executado não pode obstar uma execução, afirmando um meio executivo menos efetivo sob o argumento de que este é um meio executivo menos oneroso para si. É bom lembrar ainda que a possibilidade de defesa não está ligada à satisfação do crédito, ou seja, a defesa do executado pode se dar por ação autônoma, mesmo após a satisfação do crédito (art. 903, § 4.º, CPC), e que, no caso de abuso de execução, esta poderá ensejar a responsabilização civil objetiva do exequente (art. 776, CPC). Estes princípios demonstram que já existe no Brasil um *direito fundamental a tutela processual do crédito* que precisa ser adequadamente disciplinado em seu procedimento, inclusive mediante a desjudicialização nos casos em que não for necessária a atividade judicial para controle de garantias.

Quanto ao interesse público na efetividade e baixo custo da execução, é necessário referir que a função do Estado não é assegurar a observância de suas próprias normas, mas sim a tutela dos direitos. O Estado é um ente artificial criado para fins não seus, seu objetivo não é tutelar na execução os próprios interesses, mas os interesses para os quais as normas de competência direcionam a sua atividade. Na atividade executiva, há possibilidade concreta de desjudicialização com redução de custos para o Poder Judiciário e aceleração de resultados para o exequente; medidas, portanto, *mistas* devem ser estimuladas para atingir este fim, resguardando o Poder Judiciário para as garantias constitucionais dos direitos fundamentais envolvidos.

Quais são as vantagens e desvantagens dos macromodelos, modelos tipo:

Vantagens		
Modelo Judicial	Modelo Administrativo	Modelo Liberal ou Misto
1. Qualidade do controle judicial; 2. Padrões de resposta equivalentes; 3. Nível de proteção do devedor mais elevado; 4. Vetor orgânico-institucional mais sólido; 5. Igualdade de acesso e outorga de serviços para o cidadão ao ser parte do serviço de justiça do Estado.	1. Rápido e expedito; 2. Flexível dentro da discricionariedade administrativa; 3. Mais econômico para o orçamento estatal (em comparação com o modelo judicial, em razão da maior preparação dos juízes, que pressupõe salários mais altos); 4. Custos e transparência do sistema previsíveis.	1. Rápido; 2. Eficiente; 3. Não tem custo para o orçamento estatal; 4. Soluções predominantemente <i>pré</i> ou <i>extrajudiciais</i>; 5. Qualidade profissional, maior discricionariedade e flexibilidade na sua atuação (poder discricionário maior e coerente com a melhor e maior formação dos profissionais); 6. Em modelos judiciais atenuados, em que existam já auxiliares privados, podem ser adequados ou reciclados às novas necessidades em razão da oportunidade, minimizando o custo na formação de novos profissionais; 7. Custos e transparência do sistema mais previsíveis para o usuário e suportados pelo usuário; 8. Alternativas e escassa complexidade do vetor financeiro-econômico e funcional; 9. Proximidade e contato direto com o usuário (relação profissional), com serviços customizados, de acordo com a necessidade do cliente.

Vistas as vantagens, devemos passar aos aspectos negativos. As desvantagens do modelo exclusivamente judicial são tantas que não nos permitem organizá-las em colunas. Assim, faremos a distribuição em linhas, sem prejuízo do conteúdo. O juiz deve exercer a função mais nobre de garantia dos direitos fundamentais, deixando para os órgãos administrativos e para os agentes privados a função de cobrança e execução dos créditos.

DESVANTAGENS
Modelo judicial (centralizado no juiz): 1. Caro; 2. Lento; 3. Rígido no desempenho do oficial de justiça, em razão de sua submissão ao juiz e menor formação profissional específica; 4. Excessivamente formalizado; 5. Atuação discricionária muito limitada. Não necessariamente cada ato ser submetido à prévia decisão e controle do juiz ou tribunal.

Nesse modelo, o início e o controle definitivo são determinados pelo juiz e o papel do facilitador ou mediador é muito reduzido e dependente deste poder central; 6. Custo e transparência do modelo menos previsível para o usuário (vetor econômico). Certa dificuldade funcional na eficiência da execução (vetor funcional); 7. O contato e a proximidade com as partes (o consumidor da justiça, *justiciable*) é através do juiz e com o auxílio de um profissional que assiste ou representa a parte, por escrito ou em audiências; 8. A carga de trabalho do juiz é sobrecarregada com a atividade executiva (processos de exceção). As consequências negativas manifestam-se na demora, ineficiência e ineficácia para decidir processos de conhecimento. Simultaneamente, o serviço da justiça executiva não tem os padrões de qualidade da justiça declaratória (justiça de conhecimento) e, portanto, incorrem em demora, carga de trabalho excessiva (processos pendentes dos quais não se têm registro de continuidade), falta de dedicação e recursos financeiros para uma adequada execução; 9. A etapa de execução normalmente é acadêmica e legislativamente de menor “relevância” e, portanto, o monitoramento de sua qualidade, frente à tutela de conhecimento, é menor. Há maior investimento acadêmico e legislativo na fase de conhecimento.

Modelo administrativo (centralizado na administração): 1. Falta de qualidade, em geral, não tem a mesma qualidade técnica de um juiz; 2. Intervenções externas; 3. Possibilidade de corrupção; 4. Possibilidade de burocratização; 5. O funcionário deve ser qualificado em sua formação e os custos normalmente são assumidos pelo Estado; 6. Dificuldade e limites no vetor econômico por utilizar o orçamento da administração pública.

Modelo liberal ou misto (articulado entre administração, agentes privados e atividade residual do Poder Judiciário): 1. Pode ser menos econômico para os consumidores do sistema (clientes que requerem seus serviços, necessidade de investimentos altos captar os clientes, especial ênfase em grandes negócios, bancos etc.); 2. Dificuldades de mudar e reformar, pois segue o padrão do mercado, necessitando normas claras de regulação externa; 3. Custos (para quem os assume) na formação de novos auxiliares com os padrões profissionais ou técnicos que se estabeleçam como exigência mínima; 4. Eventual intervenção na seleção de processos, gerando executividade seletiva; 5. Complexidade do vetor orgânico constitucional (reformas e desenho orgânico, fiscalização e responsabilidades, distribuição de tarefas de modo funcional); 6. Maior dificuldade na fiscalização. Custo na formação de organismos, tais como agências reguladoras e varas judiciais de garantia especializadas e medidas de urgência e salvaguarda na atividade executiva etc.

A tendência mundial, como se pode perceber, é a introdução de um modelo liberal de intervenção judicial moderada, no qual *oficiais de execução* ⁹⁴ organizados em instituições privadas, administrativas ou mistas dediquem-se à atividade executiva, com eventual controle judicial sobre excessos e medidas cautelares ou satisfativas constritivas de carácter extraordinário, que possam resultar em ofensas a direitos fundamentais dos executados.

O exemplo brasileiro da alienação por iniciativa particular ou por corretor credenciado representa um grande avanço ao constituir ferramentas de privatização de determinadas atividades executivas. Por outro lado, não só a privatização, mas também a utilização dos bancos de dados geridos pelos órgãos administrativos e privados, a exemplo da penhora online de dinheiro, veículos e imóveis, consistentes em atividades judiciais sem a necessidade de intervenção da máquina pública e oficiais de justiça, realizadas por simples meio eletrônico, *e-justice*, mostram-se de baixo custo e elevada efetividade. ⁹⁵

Nesse aspecto, o Brasil, apesar de ter um modelo excessivamente centralizado no juiz, avançou muito nos últimos anos. Seria necessário avançar mais exatamente no aspecto da descentralização, permitindo um maior número de atividades diretas por órgãos da administração pública (a exemplo da execução fiscal pela própria Fazenda Pública) e da iniciativa privada (a exemplo dos oficiais privados de execução organizados como agências de cobrança de dívidas, com poderes de penhora e expropriação).

Não podemos esquecer que tratamos neste trabalho da execução singular de devedor solvente; não tratamos aqui dos problemas relacionados ao concurso universal de credores, a execução coletiva por falência ou insolvência do devedor, pessoa jurídica ou pessoa natural, muito menos, de outro problema muito comum nas sociedades contemporâneas, o superendividamento. O superendividamento ainda aguarda uma regulação adequada no Brasil. Estes temas, portanto, têm outras premissas e outros valores em jogo, incidindo regimes jurídicos e direitos à tutela distintos,

que devem ser adequadamente protegidos pelo ordenamento jurídico (sua preocupação principal não é com a *tutela do crédito* defendida como premissa neste texto).

De qualquer sorte, parece-nos claro que a justaposição dos modelos liberais ou mistos com o modelo judicial evidencia uma proporção inversa quanto às vantagens e desvantagens, apontando para a necessidade de modelos mistos.

Modelos mistos, focados na tutela dos direitos e nas garantias da defesa, permitem, ao mesmo tempo, a aglutinação das atividades judiciais, administrativas e privadas de execução em torno do objetivo comum, com redução de custos para o Estado e maior efetividade para os consumidores da tutela executiva.

Nos modelos mistos, há uma franca residualidade do Poder Judiciário, acionado apenas para os casos de colisões dos direitos fundamentais e na ineficiência, desvio de finalidade ou eventual corrupção das atividades privadas e administrativas de execução.

2.5. Modelos de Estado e superação do paradigma legalista pelo Estado Democrático Constitucional

O paradigma legalista era ligado à tipicidade da execução; no paradigma do Estado Constitucional a atividade executiva decorre de um direito fundamental material – a tutela do crédito (direito à propriedade), e de um direito fundamental processual – a tutela processual do crédito (direito fundamental a organização e ao procedimento).

Marcelo Lima Guerra defendeu, originalmente no Brasil, o direito fundamental à tutela executiva, partindo da premissa de que um sistema jurisdicional deve reconhecer e ser capaz de “proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva”.⁹⁶ Em concreto, subdividiu este direito em três potencialidades: a) *melhor interpretação* : interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva para delas extrair a maior efetividade possível; b) *inconstitucionalidade da restrição indevida* : dever-poder do juiz deixar de aplicar norma material ou de procedimento que imponha restrição indevida a um meio executivo, sempre que esta restrição não se justificar à luz dos direitos fundamentais; c) *dever de efetividade do procedimento (adequação)* : o juiz tem o dever-poder de adotar os meios executivos que se revelem necessários à prestação integral da tutela executiva.⁹⁷

O direito fundamental à tutela executiva é um direito fundamental à organização e ao procedimento, portanto, deve ser compreendido como um direito fundamental à tutela processual do crédito. Partir desta premissa, como reconhece a doutrina, é fundamental para resolver uma série de problemas ao longo da atividade executiva desenvolvida pelo Poder Judiciário.⁹⁸

Para tanto, é preciso repensar o processo de execução e o estímulo ao cumprimento espontâneo das decisões judiciais a partir das premissas do novo modelo de Estado Democrático Constitucional fundado pela CF/1988. Este modelo caracteriza-se pela superação das fases liberais e sociais do Estado, propugnando uma democracia normativa calcada na metodologia deliberativo-procedimental, que representa a junção dos interesses do indivíduo e da comunidade em uma síntese dialética.⁹⁹

Trata-se de colocar a tônica no processo civil constitucional, uma proposta inovadora voltada para a nossa tradição constitucional republicana (Rui Barbosa, 1891) que identifica o Poder Judiciário como garantidor da harmonia e equilíbrio das relações entre os demais poderes e entre estes e suas funções determinadas para servir o cidadão (art. 1.º, CPC/2015). Garantidor, neste contemporâneo modelo de Estado, de uma *democracia de direitos* , tanto individuais quanto coletivos, ou seja, de uma *democracia que tem nos direitos fundamentais uma vacina contra as maiorias de ocasião, os poderes selvagens do mercado e da política* . Garantir direitos significa torná-los efetivos, já que revela-se caminho sem volta a ultrapassagem do modelo meramente enunciativo das declarações de direitos.¹⁰⁰

O Judiciário, na configuração republicana, substituiu o Poder Moderador. Responsabiliza-se

pelo *cheks and balances*, doutrina segundo a qual *poder freia poder*, sendo reservado aos juízes o papel de, com inércia, imparcialidade e independência, assegurar a supremacia da Constituição. Todo o desenvolvimento da ciência do Direito, neste último século, equilibra-se e sustenta-se nesta premissa, independentemente da conformação política ou jurídica adotada. Com isso, ressaltamos a natureza híbrida do nosso direito processual, misto de *common law* e *civil law*, na confluência da lógica da aplicação da lei (*code* ou *statute system*) e da realização dos direitos pelo Poder Judiciário (*judge made-law*), um modelo que claramente permite a integração entre o *Rule of Law* e o Estado de Direito. ¹⁰¹

Trata-se de evolução histórica, destacada no papel dos advogados públicos e privados na busca incessante da efetivação dos direitos de seus clientes, essencial para o desenvolvimento dos meios executivos, mesmo contrariando os termos expressos da lei. ¹⁰² Lembrem-se do exemplo notável de Rui Barbosa, o qual desenvolveu a doutrina brasileira do *habeas corpus civil* e a doutrina das ações possessórias de direitos pessoais, como técnicas para defesa de direitos, sem que houvesse expressa permissão legal. Mas não só, através da insistência e perspicácia dos advogados, antes mesmo das reformas processuais que reconheceram a antecipação de tutela em 1994, os tribunais já reconheciam as *cautelares satisfativas autônomas* ¹⁰³ como meio de efetivação do direito em casos de imperativa justiça, utilizando-se da técnica do poder geral de cautela. Lembrem-se, ainda, dos mandados de segurança para concessão de efeito suspensivo aos recursos, ou mesmo, dos efeitos suspensivos-ativos, que eram concedidos para decretar uma antecipação de tutela à míngua de norma autorizadora (naquela época as leis previam apenas o efeito suspensivo para a concessão de liminar, não seu reverso necessário, a concessão da liminar em sede recursal).

O poderoso laboratório destas evoluções foi a ação de mandado de segurança – ação de eficácia potenciada por sua matriz constitucional, única no mundo, impensável nos ordenamentos da Europa continental de onde extraímos nosso direito processual do Código Buzaid de 1973. Tudo isso deve-se, igualmente, ao papel corajoso de alguns juízes nacionais, que bem compreenderam a nossa índole constitucional, determinando soluções razoáveis para a ausência de meios legais de efetivação dos direitos, assumindo expressamente a máxima do *common law* que determina: onde existe um remédio judicial, ali também existe um direito (*ubi remedy, ibi ius* ou *remedy preceeds rights*).

Nada disso teria acontecido não tivesse a magistratura atendido aos reclamos dos advogados, pois, em matéria de execução, até muito pouco tempo, predominava a absoluta inércia do juízo (*ne procedat iudex ex officium* – o juiz não deve proceder de ofício ; *iudex secundum probata partium iudicare debet* – o juiz deve decidir de acordo com o que foi alegado e provado pelas partes). Certo é que o regime de responsabilização objetiva pelos danos causados pelo excesso na tutela executiva ou no cumprimento das decisões judiciais depende do requerimento da parte, o que aconselha fortemente a autocontenção judicial, evitando-se o arbítrio nesta área (o art. 776, assim prescreve: “[o] exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”). ¹⁰⁴

Portanto, como se pode perceber, a necessidade de criar procedimentos é natural à atividade de proteção judicial dos direitos, existindo antes mesmo do Estado Democrático Constitucional, mas reforçando-se enormemente neste modelo de Estado.

2.6. Era dos Códigos, Era das Constituições e (Re)codificação: dinamicidade do procedimento para atender à tutela dos direitos “sob medida” (made-to-measure)

A necessidade de criar procedimentos para fins de tutela dos direitos é uma decorrência da premissa de que o processo serve à tutela dos direitos, adequada, tempestiva e efetiva. Este é o mote do processo no Estado Democrático Constitucional. Pois bem, se isso já era possível, no Brasil, em tempos remotos, de franca prevalência do modelo positivista legalista, que aplicava o rigor formal da validade como requisito de legitimidade das normas jurídicas, ou seja, na chamada Era dos Códigos, muito mais poderá ser feito agora, em face da mudança de visão sobre a imperatividade e função do direito na chamada Era das Constituições, representada justamente pelos processos de (re)codificação mediante a introdução de princípios, cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, nos textos legais, enfim, pela introdução de normas abertas, flexíveis

que dialoguem com os microssistemas, procurando dar harmonia e plasticidade ao ordenamento para sua constante atualização e conformação à finalidade constitucional.

Para tanto, toda uma teoria constitucional renovada, teoria geral do direito da Constituição, não mais do direito civil, sobressai altaneira. Basta, para nossos propósitos preliminares, ressaltar as premissas do constitucionalismo de terceira geração, entre as quais destaca-se, além da expansão da jurisdição constitucional, a *teoria dos direitos fundamentais* como normas estruturantes do ordenamento jurídico e a *nova hermenêutica* que lhes deve ser afeta. Significa, também nesse prisma, reconhecer a *força normativa da Constituição* e o papel irradiador que ela desempenha para melhorar e adequar a tutela jurisdicional ao direito fundamental à organização e ao procedimento.

Mas não só. O próprio direito processual como direito fundamental sofre uma alteração significativa para atender de maneira dinâmica à tutela dos direitos como foco e finalidade do processo.

A recodificação do processo civil inclui a premissa de que o processo hoje deve deixar de ser pensado como *ready-to-wear* ou *one size fits all* para o *made-to-measure*, não somente na adaptação para as demandas individuais de grande complexidade, mas também para as demandas de massa – exigentes de soluções padronizadas, mas bem pensadas, no estilo *prêt-à-porter*, mas inspiradas nos ideais da *haute-couture*, como já ocorre nas grandes cadeias comerciais que se inspiram nas soluções de alta-costura para melhor atender ao cliente do dia a dia. Daí falar-se em *design* de litígios.

Na doutrina, justamente defendendo esta ordem de ideias, afirma Loïc Cadiet “[t]he system of justice must offer to each sort of case the type of procedure which is convenient to it, summary or not, rapid or not, and at the center even of the judiciary institution, it must be possible to pass easily from one procedure to another by means of ‘passageways’ which permit to reorient the procedure in the course of proceedings without having to redo all from the beginning, in function with the evolution of the case, which can simplify or in contrast, complicate. Diversity, flexibility and reactivity are a good response to the complexity of contemporary societies, which leads to letting go of the conception of *static* and *standard* process, relying on the rigid division of work between the judge and the parties determined by *law* to the benefit of a *dynamic* and *diversified* conception supposing to the contrary a permanent cooperation of the judge and parties susceptible to rely on the recourse to the *agreement* if needed, already evoked as a tool of management for procedure”.¹⁰⁵

Nesses termos, o sistema de justiça precisa oferecer, para cada tipo de caso que se apresenta perante o juiz, o processo que seja mais conveniente, isto é, adequado. Como afirma a doutrina, acima citada, esta adaptação poderá resultar em um processo sumário ou não, rápido ou não. No centro desta atividade de adequação, deve estar o Poder Judiciário, encontrando os caminhos para passar de uma técnica para a outra, *mesmo no curso do processo*. No nosso caso, o juiz poderá determinar a passagem de um meio executivo para o outro, reorientando o curso do procedimento, sem ter que realizar tudo desde o início novamente.

O CPC já indica neste sentido. Estas ideias são compatíveis com as normas fundamentais previstas no início do CPC/2015, mas também estão presentes no art. 327, § 2.º, CPC, ao determinar que ‘[q]uando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum’.

A própria evolução do caso pode influenciar na adequação, pois o caso pode se revelar simples ou complicado na medida que evolui. Por essas razões, a doutrina defende as ideias de diversidade, flexibilidade e reatividade como uma boa resposta para a complexidade de nossas sociedades contemporâneas. Devemos deixar de lado concepções estáticas ou *standards* processuais baseadas numa rígida divisão de trabalho entre o juiz e as partes, para focar em uma visão dinâmica, de permanente cooperação e boa-fé objetiva entre aqueles que participam dos

atos processuais.

Assim, os deveres-poderes do juiz (art. 139, IV, CPC) e o autorregramento da vontade (arts. 3.º e 190, CPC) podem auxiliar na conformação dos procedimentos executivos mais efetivos. Os negócios processuais, acordos sobre procedimento, e os poderes de gerência (*management power*) que o juiz exerce no processo para atingir a finalidade de tutela dos direitos necessitam ser compreendidos à luz do compromisso dinâmico com o resultado do processo justo, que no caso da atividade executiva de tutela do crédito é aquele que satisfaz ao exequente.

2.7. Inexistência de abstração e causalidade do título executivo: influência do direito material, primazia dos direitos-dever para fins de tutela adequada e função dinâmica do direito subjetivo

Como não poderia deixar de ser, também a função do direito material alterou-se profundamente. O papel dos direitos subjetivos neste contexto é renovado: do conceito clássico da pandectística alemã do séc. XIX, de cunho patrimonialista e individualista (o qual respeitava tão somente a dimensão liberal da democracia, conceito este que ensejou Clóvis Beviláqua a decretar o fim das ações coletivas no art. 76 do antigo Código Civil brasileiro de 1916, determinando que só poderia propor a ação quem tivesse interesse próprio ou de sua família) e que encetava um sistema de direitos subjetivos do indivíduo livre e senhor dos seus próprios interesses, calcado no Estado do *laisser-faire, laisser-passar* (deixar-fazer, deixar-passar – conforme a doutrina do livre-mercado e do Estado mínimo, não intervencionista); ¹⁰⁶ passamos para um conceito de direito subjetivo como *situação jurídica complexa* ou *permissão especial de aproveitamento*, no qual o direito não é exercido exclusivamente no interesse das partes contratantes e do seu titular; ao contrário, o direito é, muitas vezes, *funcionalizado* para efetivar os desideratos constitucionais de uma sociedade mais justa, livre e solidária, ultrapassando os interesses de seu titular e coarctando os comportamentos dos titulares às finalidades comunitárias.

Portanto, o direito subjetivo não é mais visto isoladamente, como pertencente ao domínio de seu titular, mas decorre de um complexo de situações jurídicas que envolvem os direitos e situações jurídicas de terceiros e, às vezes, condicionam o seu exercício em favor de pessoas determinadas ou do próprio interesse público primário.

A nova categoria de direitos que se alinha ao lado dos direitos subjetivos pretensão e dos direitos potestativos, é a dos *direitos deveres* (ou *deveres-poderes*, a exemplo do *poder familiar* ou do *poder exercido pela administração pública*). Nessa categoria, residem também as funcionalizações da propriedade, do contrato, das cidades, do meio ambiente e uma série de direitos fundamentais criados na Constituição de 1988, os quais, quase sempre, apresentam uma robusta dimensão coletiva.

Para atender a estas demandas, a tutela condenatória clássica (ressarcitória, reparatória ou sancionatória) vista em sua dimensão estática, pouco contribui.

Vale a pena reprimir, antes de avançarmos, os tipos ou espécies de tutela jurisdicional processual: tutela declaratória, tutela constitutiva, tutela condenatória, tutela executiva *lato sensu* e tutela mandamental. A doutrina cansa de repetir que destas, apenas as duas primeiras são autossuficientes, ou seja, bastantes em si. As demais, condenatória, executiva *lato sensu* e mandamental, exigem, demandam uma atividade externa no mundo concreto, em uma palavra: execução (atividade executiva). ¹⁰⁷

Para a finalidade de tutelar os direitos-deveres, a tutela condenatória em quantia certa é insuficiente. Por exemplo, ela revela, por exemplo, o último elo da conhecida preocupação dos ambientalistas: precaver, prevenir, reparar, traduzindo bem a noção de tutela específica das obrigações. A tutela condenatória que determina o pagamento de verba para o FDD (Fundo de Defesa dos Direitos Difusos) também não é adequada, se os mecanismos de execução são demorados e ineficientes. Ora, parte da ineficiência da tutela condenatória está ligada à ineficiência da execução para pagamento de quantia certa e da expropriação mediante penhora.

Esta herança do modelo executivo germânico, que prevê para cada espécie de obrigação uma espécie de execução (obrigação típica, execução típica), ou seja, para as obrigações de pagar quantia certa, a execução por expropriação, não atende adequadamente à tutela condenatória para pagamento de quantia certa que decorre de deveres, como é o caso do meio ambiente, pois é demorada, ineficiente e burocrática, enfraquecendo os elementos de prevenção geral e prevenção especial que estão na base desta tutela.

Não se pode tratar todos os direitos materiais como se fossem direitos de crédito decorrentes das relações comerciais privadas, abstraindo a sua causalidade. A complexidade e dinamicidade dos direitos subjetivos atuais, os direitos-dever e a tutela do interesse público nas obrigações de pagar quantia justificam um tratamento diferenciado a depender do tipo de direito material que está na base do título executivo. Condenações decorrentes de atos ilícitos coletivos, por exemplo, para reparação do meio ambiente, do consumidor e da improbidade administrativa merecem adaptação procedimental que torne mais efetiva sua tutela. ¹⁰⁸

2.8. *Nulla executio sine titulo e nemo potest praecise cogi ad factum*

“O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de *justificá-los*, mas o de *protegê-los*. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”. (Norberto Bobbio) ¹⁰⁹

O tema da execução cresceu em importância nos últimos anos. Ao lado da ampliação dos direitos fundamentais, exigiu-se sua efetivação. Não bastavam mais as cartas de direitos, meras declarações de intenções, era necessário alcançar a efetividade dos direitos através de sua concretização no mundo real.

Assim, a execução, antes preocupação quase isolada dos direitos patrimoniais, passou a ser agora um tema fundamental do processo. Efetivar não só o pagamento de quantia, mas também as obrigações/deveres de fazer e não-fazer, bem como, de entregar coisa, nos termos do nosso ordenamento constitucional, não exclusivamente patrimonialista, passou a ser uma exigência de direitos fundamentais.

As reformas da lei processual acentuaram a importância de efetivação das decisões judiciais, rompendo com antigos dogmas do processo civil cristalizados nos aforismos *nulla executio, sine titulo* (não existe execução, sem título executivo) e *nemo potest praecise cogi ad factum* (ninguém pode ser coagido a fazer algo que a lei não prescreve). ¹¹⁰

Pelo primeiro dogma, não haveria nenhum ato executório sem a formação de título executivo através de regular processo de conhecimento; pelo segundo, ninguém poderia ser compulsoriamente levado a fazer, deixar de fazer ou não-fazer algo, pois sua liberdade seria intangível, o comportamento seria apenas obrigado na forma da lei e na impossibilidade do cumprimento espontâneo seria convertível *in pecunia*. A intangibilidade era tão relevante para a doutrina francesa que ensejou a previsão no Code Civil de Napoleão de que “*[t]oute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur*” (art. 1.142, Código Civil Francês de 1804, “todas as obrigações de fazer ou de não fazer se resolvem em perdas e danos, no caso de inexecução pelo devedor”).

Ambos os princípios estão de acordo com ordenamentos processuais civis que atendam apenas a interesses patrimoniais, vinculados fortemente à noção de autonomia da vontade e de intangibilidade da vontade característica do Estado Liberal, do *paleojuspositivismo legalista* ou *normativismo legalista*, que tinha no procedimento ordinário do Livro I do CPC/1973, processo de conhecimento, seu corolário processual. Hoje esses aforismos não valem mais na sua essência original, as fases de conhecimento e execução não são mais estanques na estrutura do Código e admitir-se-ão medidas coercitivas inclusive para o pagamento de quantia, o procedimento ordinário do processo de conhecimento mudou radicalmente, constitucionalizou-se (art. 1.º, CPC/2015) para atender ao postulado da máxima coincidência: o processo deve dar a quem tem razão, tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito de receber. ¹¹¹

Essas noções valem não somente para as tutelas específicas, mas também para a tutela do

crédito. A associação entre o direito patrimonial e os direitos fundamentais foi uma manobra ideológica da doutrina e não deve se confundir o direito à propriedade com o direito *de* propriedade (cf. *supra*). O direito *de* propriedade é um direito patrimonial, privado e disponível; o direito à propriedade é um direito fundamental, universal e indisponível.

A clássica lição do Mercador de Veneza (William Shakespeare. *The Merchant of Venice*, escrito entre 1596 e 1598), quanto aos limites do título executivo, não corresponde mais às necessidades contemporâneas da execução civil.

Nesse sentido, quando Portia, travestida no juiz Balthasar, decide que Shylock tem direito a uma libra da carne de Antonio, conforme descrito no título executivo extrajudicial, na cártula, no título de crédito (*bond*), mas afirma que, se, ao retirar a carne, deixasse derramar uma gota de sangue ou retirasse mais que o devido, responderia com a própria vida, está, na verdade, enaltecendo a ideia de que apenas aquilo que é descrito no título poderia ser objeto de execução.

Hoje, contudo, cada vez mais se percebe que a necessidade de garantir a tutela do crédito pode permitir a “adaptação” da obrigação quando esta flexibilidade for necessária para a tutela do direito, preservada uma prevalência para a tutela específica das obrigações ou seu resultado prático equivalente (arts. 497, 499 e 536, CPC). A ideologia do contemporâneo Estado Democrático Constitucional é a efetividade da tutela das pessoas e dos direitos, mediante o processo justo.

Nesse sentido, importante registrar que este movimento vai no sentido oposto ao realizado antes e que também tinha conteúdo ideológico. A tradição romano-canônica de preservação dos direitos do devedor em detrimento da execução alcançou o CPC/1973 com uma série de efeitos: a) a *ordinarização* ou *obrigacionalização da tutela executiva*; b) a consequente conversão das “pretensões reais” e dos deveres em obrigações; c) a subsequente *patrimonialização e pessoalização* do direito real e dos deveres; d) resultando na *vis attractiva* da tutela condenatória, na qual, mesmo as pretensões reais, os deveres e as obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa deveriam permitir a conversão em dinheiro e, em razão disso, converter-se em obrigações de pagar quantia.¹¹²

Portanto, não é a opção do ordenamento jurídico atual a correlação tutela obrigacional *in pecunia* (obrigação de pagar) e execução para pagamento de quantia, seja na leitura constitucional dos direitos fundamentais que impõe a prevalência da tutela específica das obrigações e o direito fundamental à efetividade do processo de execução, seja no próprio CPC, desde suas modificações anteriores ao novo Código, ao identificar que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” (art. 499, CPC).

No atual CPC/2015, as atividades satisfativas não se restringem aos tradicionais direitos de crédito. Hoje, até mesmo a noção de tutela do crédito torna-se mais fluida e se pode imaginar até mesmo o contrário, ou seja, que, para satisfazer a obrigação de pagar quantia certa, seja possível, a requerimento do credor, a determinação judicial do pagamento, sob pena de *astreintes* (art. 139, IV, CPC) ou então substituir a obrigação de pagar quantia certa por uma obrigação de fazer ou entrega de coisa, inclusive por autocomposição (art. 515, § 2.º).

2.9. Enfraquecimento ou relativização do binômio cognição e execução: execução individual e execução coletiva; judicial e extrajudicial

Iremos tratar, a seguir, do *enfraquecimento ou relativização da distinção entre cognição e execução*, tema que caracteriza a execução moderna como superação das antigas doutrinas tecnicistas do processo tradicional.¹¹³ A mesma execução que serve para tratar dos direitos subjetivos individualmente considerados, serve para tratar dos direitos coletivos *lato sensu*, constituídos pelas três posições jurídicas subjetivas asseguradas pelo ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição Federal e a partir do Código de Defesa do Consumidor: direitos *difusos*, direitos *coletivos stricto sensu* e direito *individuais homogêneos* (art. 81, parágrafo único, incs. I, II e III do CDC).

As diferenças, em relação ao processo de execução, em cada uma das posições jurídicas subjetivas (seja nos direitos individuais, seja nos coletivos – *difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos*), advém do direito material que subjaz cada um dos direitos. Nos direitos coletivos em geral, há uma exigência maior de efetividade, pela presença de forte interesse público na tutela dos direitos coletivos, inclusive mediante a facilitação da execução pela adoção de técnicas atípicas. Ocorre, assim, a incidência do critério da *posta in gioco* (cf. infra) para fins de averiguar a duração razoável do processo e a admissibilidade de medidas atípicas mais adequadas a tutela dos direitos.

Por consequência da existência de diferenças entre o direito material presente nos diversos direitos envolvidos, um conceito amplo de execução processual coletiva deve ser formulado, de forma a abarcar todas as atividades necessárias à efetivação desses direitos novos: “a execução coletiva pode ser entendida como a realização material e fática, de forma voluntária ou forçada, de obrigações certas, líquidas e exigíveis, de fazer ou não fazer, de dar coisa certa ou incerta ou de dar quantia, contidas em determinado título executivo judicial ou extrajudicial que reconheça a existência de direitos ou interesses difusos, de direitos ou interesses coletivos em sentido estrito e de direitos ou interesses individuais homogêneos”.

Há doutrina que afirma a superioridade da tutela específica ou do resultado prático equivalente para a tutela dos direitos coletivos.¹¹⁴ Muito embora essa seja a regra geral, não se deve deixar de observar o papel relevante que, do ponto de vista econômico, em especial quanto à prevenção geral e a prevenção especial, desempenham as condenações em dinheiro e as sanções pecuniárias previstas em títulos executivos extrajudiciais. A tutela do crédito é fundamental para a efetivação dos direitos coletivos.

Não há diferença ontológica entre título executivo judicial e extrajudicial; a diferença entre a tutela executiva de direitos coletivos e a tutela coletiva de direitos individuais reside na necessidade de se equilibrarem as posições jurídicas de acordo com os interesses envolvidos. A regra da adequação permite que estes direitos sejam tutelados conforme as suas peculiaridades pela adaptação do procedimento, no caso concreto, com a universalização das técnicas adotadas para todos os casos idênticos futuros.

Igualmente, a antiga reserva da atividade de conhecimento e ao contraditório na atividade executiva deve ceder perante a constatação de que existe atividade de conhecimento conjuntamente da atividade executiva e vice-versa. Não há uma incompatibilidade, sendo totalmente relativizado este binômico atualmente.

A doutrina afirma que “[c]ognição e execução são atividades judiciais distintas, que se completam e se combinam de variadíssimas formas, com o fim de outorgar tutela jurisdicional (...) Embora o legislador possa optar pela divisão das atividades cognitivas e executivas em processos distintos, como já o fez no passado, trata-se de solução conotada por elevada dose de artificialismo, que o legislador vem abandonando gradativamente, tendo seu ponto culminante no CPC de 2015”.¹¹⁵

As atividades de cognição e execução estão ligadas pela finalidade do processo, a tutela dos direitos, adequada, tempestiva e efetiva.

2.10. O CPC/2015: Intercambialidade (arts. 513 e 771) e aplicabilidade da Parte Geral (aplicação supletiva, subsidiária e residual)

Muitos autores têm afirmado que o processo de execução não apresentou grandes inovações no CPC/2015. Vamos recuperar as noções básicas para analisar neste tópico a intercambialidade entre o cumprimento de sentença e o processo de execução. Iremos tratar ambos como atividade executiva, não importa se fase, módulo ou processo. Nos parece que a existência da forte inter-relação entre o cumprimento de sentença e o processo de execução no CPC vai além da mera formalidade, completando supletiva e subsidiariamente um ao outro e integrando ambos os meios de tutela adequada e efetiva dos direitos com a parte geral do CPC, em especial com as normas fundamentais e com o art. 139, IV (o qual prevê os deveres-poderes do juiz para efetivar o

cumprimento das decisões judiciais e garantir sua adequação ao direito material tutelado e ao comportamento das partes no processo). Além disso, a inter-relação entre as duas atividades executivas cria um modelo de execução no direito brasileiro que permite também a compreensão dos processos de execução especiais.

O cumprimento de sentença, Título II do Livro I, Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença, seguiu a linha das reformas do CPC/1973. Não há mais processo autônomo para a execução de título executivo judicial. Trata-se de execução fase. O recurso cabível das decisões durante a fase de execução, cumprimento, será o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC); o recurso cabível da sentença que conclui a fase será a apelação (art. 1.009 do CPC).

Não haverá nova citação e formação de processo autônomo para a execução dos títulos executivos judiciais, previstos no art. 515 do CPC. Trata-se de uma simplificação do modelo original de 1973, que homenageava mais a arquitetura à praticidade. As exceções estão previstas no art. 515, § 1.º. Haverá citação e processo autônomo, por uma exigência prática, nas hipóteses de sentença penal condenatória transitada em julgado, da sentença arbitral, da sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e na decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do *exequatur* à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça.

O processo autônomo do Livro II, Do Processo de Execução, foi desenhado para os títulos executivos extrajudiciais (art. 784 do CPC/2015). Tradicionalmente, a existência de um título executivo judicial era considerada a hipótese de escola (exemplo acadêmico por excelência) para negativa do interesse processual para o ajuizamento de uma ação de conhecimento. Assim, quem já possuísse um título não poderia querer obter, mediante o demorado processo de conhecimento, um novo documento que lhe assegurasse a mesma finalidade, ou seja, o acesso à via executiva. Há uma novidade polêmica no CPC/2015 quanto a este aspecto. O art. 785 do CPC/2015 prevê a possibilidade de o autor escolher entre o processo de conhecimento e o processo de execução, mesmo quando já possua um documento que, em tese, possa servir como título executivo extrajudicial, dando-lhe acesso direto à via executiva.

Nestes termos, o art. 785 estabelece que “[a] existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.

Essa possibilidade ilustra que há entre ambos os procedimentos uma intercambialidade radical totalmente nova.

Assim, devemos cotejar os arts. 513 e 771 do CPC para perceber que a remissão entre ambos já indica que, apesar da diferença entre o processo de execução e a execução fase (cumprimento), apesar da diferença quanto à matéria objeto da impugnação (direito material) ou embargos, caracterizada pela defesa do executado quer do título judicial, quer do título extrajudicial, não há uma distinção ontológica entre título executivo judicial e extrajudicial, mas uma diferença circunstancial. Prova disso é a combinação entre os dois artigos acima citados que possuem remissão recíproca. O juiz, quando for necessário adequar a tutela executiva típica para garantir a efetividade da execução, também poderá realizar essa atividade interpretativa corretiva, combinando meios executivos de procedimentos distintos.

Prevê o art. 513 que o “cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código”. O Livro II é o livro do processo de execução para os títulos executivos extrajudiciais.

O art. 771 estabelece que “[e]ste Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”, determinando no parágrafo único que “[a]plicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”, que trata justamente do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença.

Há, conforme se vê, uma *simbiose perfeita* entre ambas atividades executivas. Cada qual no seu âmbito e com as suas especificidades visando ao mesmo fim – a tutela dos direitos mediante execução forçada diante do inadimplemento do executado.

Na doutrina: “[r]esta clara, portanto, a simbiose entre os do[is] Livros da parte especial. E ela será muito importante porque, regra geral, o *cumprimento de sentença para pagamento de quantia sempre dependerá das regras expropriatórias descritas no Livro II da parte especial*, ao passo que, tratando-se de processo de execução de obrigações específicas, é fato inconteste que o Livro I da parte especial é mais bem aparelhado que o Livro II, que, por exemplo, nem sequer tem execução de obrigação de não fazer (o art. 822 trata do *desfazer*)”.¹¹⁶

E ainda, “[a]ssim, por exemplo, as normas fundamentais do processo civil (arts. 1.º a 12, CPC), as normas que regem o exercício da jurisdição (arts. 2.º e 16, CPC), da ação (arts. 17-20, 485, VI, CPC), a participação das partes, de terceiros e de seus procuradores (arts. 70-138, CPC), a competência jurisdicional (arts. 42-69, CPC), os poderes e deveres do juiz (arts. 139-148, CPC), a disciplina dos auxiliares da justiça (arts. 149-175, CPC), a prática dos atos processuais (arts. 188-283, CPC), a formação, a suspensão e a extinção do processo (arts. 312-317, CPC) e as técnicas processuais voltadas para a tutela dos direitos (arts. 536-538, CPC). A disciplina do processo de conhecimento aplica-se subsidiariamente à execução. A subsidiariedade indica que, existindo norma especial no Livro II, não se aplica a disposição geral do Livro I”.¹¹⁷

Os exemplos são marcantes da intercambialidade referida. Não se trata de mera subsidiariedade (complementação das normas existentes), mas de atuação supletiva (preenchendo inteiros espaços faltantes), sendo que o filtro da aplicação residual justificará a não aplicação dos institutos quando contrariarem a lógica e os princípios próprios de um ou outro procedimento.

A Parte Geral do CPC, contudo, não é *subsidiária* ao processo de execução e ao cumprimento de sentença. É da própria essência da Parte Geral ser aplicável a todo o processo. A finalidade da Parte Geral é garantir a unidade narrativa e interpretativa do direito processual. Por esta razão na Parte Geral estão encartadas as normas fundamentais. Muito embora o catálogo ali inserido seja meramente exemplificativo, não se pode negar sua finalidade orientadora de todo o processo, sejam o cumprimento de sentença e o processo de execução, sejam os procedimentos especiais não codificados. A Parte Geral ilumina, a partir de suas normas, interpretadas conforme a Constituição (art. 1.º, CPC), todo o direito processual brasileiro. A narrativa prevista na Parte Geral, em especial nas normas fundamentais, pode corroborar a afirmação de que o Código de Processo Civil atual é fruto da doutrina processual e somente pode ser interpretado à luz dos seus princípios formativos.¹¹⁸

Há, como já se apontou, um direito fundamental à execução, à efetividade do provimento judicial determinando que o executado cumpra com os deveres ou obrigações determinados em juízo, ou seja, um direito fundamental processual à tutela executiva. Este direito fundamental, derivado do direito fundamental à organização e ao procedimento, deve ser satisfeito mediante a combinação de todos os dispositivos do procedimento de execução em um modelo executivo adequado e efetivo para a satisfação do direito material.

2.11. O modelo brasileiro de execução/cumprimento das sentenças e títulos executivos extrajudiciais: sentenças que demandam execução e sua classificação

No Brasil, demandam atividade executiva ou de cumprimento as tutelas processuais mandamentais, executiva *lato sensu* e condenatória. As tutelas processuais declaratória e constitutiva, por terem natureza normativa, não exigem execução.¹¹⁹ Há, portanto, uma diferenciação clara entre as tutelas normativas ou autossuficientes, que se passam no campo do dever ser, e as tutelas fáticas, não autossuficientes ou dependentes de execução.¹²⁰

O modelo brasileiro de execução/cumprimento de sentenças pode ser apreendido da conjugação dos arts. 139, IV (atipicidade da execução), 297, parágrafo único (poder geral de “tutela provisória”, *rectius* : tutela antecipada¹²¹) e 513 c/c 771 (cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial) do Código de Processo Civil. Assim, atipicidade dos meios executivos, poder

geral de tutela provisória (*rectius* : antecipada, a exemplo das tutelas de urgência, cautelar ou satisfativa, e da tutela da evidência) e os meios típicos de execução das obrigações de fazer, desfazer, não fazer, entrega de coisa (dar coisa) e pagamento de quantia certa (dar dinheiro) se coordenam reciprocamente para formação de um modelo de execução voltado para a tutela do direito adequada, tempestiva e, acima de tudo, tratando-se de execução, efetiva.

A partir do CPC/2015, respeitada a tipicidade como regra,¹²² as medidas poderão ser intercambiadas entre si, desde que exista uma justificação adequada na decisão, nos termos do art. 489, § 1.º do CPC (cf. *infra*). Há correlação, igualmente, entre o cumprimento da decisão judicial e processo de execução para o título executivo extrajudicial (arts. 513 e 771), que são intercambiáveis.

O modelo brasileiro de execução em matéria cível evoluiu muito após o marco legislativo das reformas processuais ao CPC/1973 e, com o CPC/2015, deu um passo decisivo a favor da adequação e da efetividade do cumprimento da sentença e do processo de execução (art. 4.º, 139, IV, 513 e 771, CPC). Clarearam-se, em definitivo, algumas das angustiantes dúvidas que assolavam a doutrina sobre a possibilidade de execuções das tutelas mandamentais e executivas *lato sensu* e se instituiu a possibilidade de medidas atípicas para a garantia do cumprimento de ordem judicial, inclusive para pagamento de quantia (art. 139, IV, CPC). Na verdade, não se trata aqui de uma mera discussão terminológica, mas da preservação dos valores essenciais à adequada tutela jurisdicional, em especial à segurança jurídica e à efetividade.

Nesse sentido, substancialmente correta a tese de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira ao afirmar que *devemos abandonar os antigos debates sobre a ação de direito material e a ação de direito processual* , fixando o foco na *tutela jurisdicional* e, com isso, afastar também as tradicionais teorias da classificação da ação de direito material e das ações processuais, preferindo-se, por outro lado, *a concepção das formas de tutela jurisdicional* (declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva *lato sensu*) ao lado da tutela dos direitos (a exemplo da tutela inibitória e da remoção de ilícito, previstas no parágrafo único do art. 497, CPC).

Esta mudança tem efeitos concretos, não se trata de mera distinção acadêmica nem se reduz a uma celeuma desta ordem. Noutro giro, podemos demonstrar o suporte dogmático deste acerto no Código de Processo Civil. Como as tutelas antecipadas estão umbilicalmente ligadas às sentenças no atual modelo de execução, justamente no signo da eficiência, não faremos distinção entre sentença ou decisão antecipatória, tratando ambas como *decisões* , neste trabalho. As medidas atípicas previstas no art. 139, IV, CPC, e o poder geral de concessão de tutela provisória, art. 297, CPC, também irão incidir sobre o processo de execução de título extrajudicial.

Determinam as normas dos arts. 139, IV, 297, parágrafo único e 513 c/c 771 do CPC um modelo novo para as obrigações e deveres previstos no direito brasileiro. Note-se que os artigos combinados esclarecem que, como regra: *a*) as obrigações de fazer e não fazer serão executadas na forma dos arts. 497, 499, 500, 536 e 537 do CPC, tendo como correspondentes os arts. 814 a 823, CPC, na execução de título extrajudicial; *b*) as obrigações de entrega de coisa serão executadas na forma do art. 498 e 538, CPC, com disciplina da execução de título extrajudicial nos arts. 806 a 813, CPC; e, *c*) as obrigações de dar dinheiro, pagamento de quantia certa, serão executadas na forma dos arts. 523 a 527, CPC, que trouxeram para dentro do processo de conhecimento a fase executiva das ações condenatórias, como já ocorria no CPC/1973 reformado, sendo que para os títulos extrajudiciais serão utilizados os arts. 824 a 909, CPC, estes mesmos artigos definindo, de maneira comum a ambos os títulos, o procedimento de penhora e apropriação.

Perceba-se, a execução dos títulos executivos extrajudiciais, do CPC/2015, também se utiliza desses conceitos de obrigação típica e execução típica, já que o art. 513 c/c 771 prevê a *integração entre a execução de título judicial e a execução de título extrajudicial* . Além disso, é possível a cumulação de execuções pelo exequente, ainda que os títulos sejam diferentes, sempre que o executado for o mesmo e *competente o juízo e idêntico o procedimento* (art. 780 do CPC). Assim, inviável, como regra, a cumulação de execução para pagamento de quantia e execução para imposição ou determinação de obrigação de fazer.¹²³

Além disso, o sistema integrado da execução prevê a utilização de meios indutivos, coercitivos, mandamentais e sub-rogatórios (art. 139, IV do CPC), listados em rol não taxativo, que se depreende da expressão “*entre outras medidas*”, extraída como cláusula de abertura do art. 536, § 1.º, do CPC. Ao lado de *meios típicos* como as *astreintes*, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, e, se necessário, o uso da força policial (expressamente previstos), estão sendo aceitos pelos tribunais *medidas atípicas*, como o bloqueio de verbas orçamentárias (principalmente aquelas supérfluas, como as de publicidade e propaganda dos governos), intervenção para gestão das atividades, entre outras (decorrentes da prática judiciária e da criatividade dos requerentes).

Também é viável, e de todo aconselhável, o uso das medidas mais drásticas, como o reconhecimento da litigância de má-fé, o ajuizamento das competentes ações penais e de improbidade administrativa, quando a resistência ao comando judicial implicar infração mais grave. Aliás, o CPC/2015 expressamente consignou, neste sentido, que o “executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” (art. 536, § 3.º, CPC). Neste mesmo artigo, o CPC diferencia entre *deveres* e *obrigações* de fazer e não fazer, impondo, no que couber, o mesmo regime de cumprimento (art. 536, § 5.º). A distinção é relevante, pois deveres são de natureza pública e demandam adequação do procedimento para sua efetivação.

2.12. Tutela adequada e no money judgments

Persistimos, durante muitos anos, de 1916 até 1990, no erro de um sistema de ações, traduzido na dicção do art. 75 do CC/1916 que assim previa, “a todo o direito corresponde uma ação, que o assegura”. Hoje este sistema não existe mais. Vale, universalmente, a regra da tutela mais adequada, ou seja, para a efetiva proteção dos direitos são passíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar a sua adequada e efetiva tutela (art. 83 do CDC). Isso gerou a quebra do princípio da responsabilidade patrimonial, previsto no art. 789 do CPC, abrindo espaço para os *no money judgments*.¹²⁴ Ao mesmo tempo, os preceitos da tutela antecipatória rompem com o dogma da *nulla executio sine titulo* (art. 783 do CPC).¹²⁵ A possibilidade de várias espécies de demandas, a atipicidade da ação e a tônica na prevenção dos ilícitos é uma importante tendência da tutela dos direitos. Os meios executórios devem estar à disposição da efetividade destes fins. Os meios executórios devem permitir ainda a atipicidade, preenchidos determinados requisitos, da própria execução para pagamento de quantia.

2.13. No money judgments e execução para pagamento de quantia certa: conversão, astreintes e cumulação de obrigações em títulos executivos extrajudiciais. Exemplo dos termos de ajustamento de conduta (TACs)

A regra geral é a tutela específica ou o resultado prático equivalente para os julgamentos em que não há obrigação de pagar quantia certa (*no money judgments*). Os *no money judgments*, contudo, podem ser convertidos em obrigações de pagamento de quantia certa em duas situações: *a*) a requerimento do autor; ou *b*) quando não for possível o implemento da tutela específica e da tutela pelo resultado equivalente.

O CPC/2015 reafirma essa possibilidade, já existente no diploma anterior por força das Reformas. A conversão da obrigação específica em perdas e danos poderá ser por opção (nos direitos disponíveis) ou por força da impossibilidade da implementação da tutela específica ou do resultado prático equivalente (nos direitos indisponíveis e nas obrigações infungíveis). Assim, a “obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” (art. 499, CPC).

Convertida em perdas e danos, liquidado o valor devido a este título, proceder-se-á mediante execução para pagamento de quantia certa. A possibilidade de continuar no mesmo processo mostra o quanto é artificial a impossibilidade de combinação de procedimentos executivos distintos prevista no art. 780, CPC. Nos casos de conversão aqui tratados, no curso do procedimento, ocorre conversão de um procedimento de tutela específica em um procedimento de execução para o pagamento de quantia.

A problemática da combinação de procedimentos distintos também surge por força da condenação em *astreintes*, pois, serão objeto de execução para pagamento de quantia certa, as *astreintes* cominadas para o adimplemento da obrigação específica de fazer, não fazer e entrega de coisa, mesmo que ocorra a conversão. Como expressamente determina o CPC, a “indenização por perdas e danos dar-se-á *sem prejuízo* da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação” (art. 500, CPC).

A grande novidade é a possibilidade da cominação das *astreintes* para compelir ao cumprimento também das obrigações de pagar quantia certa (art. 139, IV, CPC).

O fato é que, em todas estas situações de conversão e *astreintes*, há execução para pagamento de quantia certa.

Os instrumentos à disposição do juiz e previstos na legislação devem ser capazes de garantir a efetiva tutela do crédito. O tipo de obrigação original implicará uma consideração de fundo sobre o direito material em jogo – critério da *posta in gioco*, permitindo a flexibilização dos procedimentos de execução para pagamento de quantia certa de forma a adequar a execução às necessidades de efetivação da tutela.

Há, portanto, uma especificidade importante quanto aos processos coletivos e à tutela dos direitos coletivos mediante os termos de ajustamento de conduta. Perceba-se que, nos termos de ajustamento de conduta (TACs) firmados pelos órgãos públicos colegitimados nas ações coletivas (Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, União, Estados, Municípios, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia e fundações), são títulos executivos extrajudiciais e podem prever obrigações de fazer, não fazer, pagar quantia e entrega de coisa. As obrigações estão todas presentes no mesmo título executivo extrajudicial e são, nestes casos, cumuladas, mas possuem naturezas diferentes e modos de execução diferenciados. Para executar situações como estas, obedecida a regra tradicional do art. 780 do CPC, exige-se o desmembramento com tantas cópias do título quantas forem as espécies de obrigações, uma vez que a cada tipo de obrigação corresponde uma execução típica.

Tal situação não faz mais sentido diante da complexidade dos direitos envolvidos e da flexibilização dos procedimentos executivos, devendo ser permitido ao juiz determinar a execução de procedimentos distintos nos mesmos autos, apartando as obrigações somente quando e nos casos em que isso se afigurar mais útil para a tutela do direito. O requisito formal não atende a esta finalidade e deve ser residual. Mesmo que se entenda pela sua manutenção, não poderá haver prejuízo da tutela do direito, advertindo o juiz qual o procedimento que segue e determinando qual obrigação deverá ser desmembrada para ensejar nova execução.

Esta plasticidade dos meios executivos já existe na tutela antecipada, que permite, ainda no processo de conhecimento, a cumulação de atividades executivas das mais diversas espécies, mas ainda não é permitida no processo executivo para os títulos extrajudiciais (art. 297, CPC), o que não faz sentido.

Nos termos de ajustamento de conduta, a norma prevê expressa exigência de que o descumprimento destes enseje cominações, geralmente, sanções pecuniárias (art. 5.º, § 6.º, LACP). Logo, estes títulos, muitas vezes envolvendo temas afetos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à tutela do consumidor e da concorrência etc., não podem perder sua “causalidade” (a natureza do bem jurídico, do direito material, envolvido) para os fins da execução civil. Os procedimentos executivos devem ser adequados à satisfação dos direitos, na maior parte das vezes, direitos fundamentais indisponíveis.

Portanto, quando o descumprimento reiterado de obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa em um termo de ajustamento de conduta gere a sua conversão em pecúnia não pode ter, no procedimento executivo, um modelo ineficaz de perpetuar a lesão, sob pena de tutelar de forma mais frágil direitos fundamentais mais relevantes previstos na Constituição.

O conteúdo de direito material que deu suporte à obrigação de pagar quantia é relevante para a

definição do procedimento de execução adequado. Assim, não deve haver um grau zero, uma “abstração excessiva”, uma “equiparação” pelo princípio da patrimonialidade na execução de todas as espécies de obrigações de pagar quantia certa com desconsideração do direito material que originou o título.¹²⁶ Estes títulos, no caso dos TACs, deverão ter um procedimento de execução adequado, logo plenamente aplicável o previsto no art. 139, IV, do CPC, para permitir ao julgador “*determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária*”.

2.14. Autocomposição na execução e cumprimento de sentença e execução do título decorrente da autocomposição

O tema da execução da autocomposição é relevante do ponto de vista global. Há um aumento generalizado de estímulos para a autocomposição nos litígios cíveis. O aumento das autocomposições (conciliações, mediações, negociações diretas entre outros métodos autocompositivos) permite dizer que, também nas execuções, será possível falar em uma nova fronteira para o aperfeiçoamento das técnicas de autocomposição. O CPC expressamente prevê a possibilidade de autocomposição na execução: “a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo” (art. 515, § 2.º, CPC) . *A regra se aplica igualmente ao cumprimento de sentença e ao processo de execução, por ser um desdobramento dos deveres-poderes do juiz (art. 139, V, CPC) e por força da intercambialidade (art. 513 c/c 771, CPC).*¹²⁷

Assim o título executivo deixa de ser um limite para a autocomposição, se é que algum dia foi, pois o exequente e o executado poderão conciliar sobre objeto diverso da execução, envolver sujeito estranho ao processo e mesmo assim haverá extinção da execução; ora, nada mais adequado, afinal, o processo serve a tutela dos direitos adequada, efetiva e tempestiva, e não a si próprio, a estabilidade objetiva e subjetiva da demanda não pode afetar a finalidade mais importante, que é a tutela adequada.

Evidentemente, caberá ao juiz controlar a validade da autocomposição e, nos casos que envolvam interesse público, como, por exemplo, a tutela dos direitos coletivos, se há tutela adequada do direito.

O aumento das conciliações leva também a outro problema. Muito embora a tendência seja a não execução dessas decisões, casos ocorreram em que as partes conciliadas, mediadas ou autocompostas precisaram recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer a autocomposição realizada.

Este problema, referente à necessidade de execuções efetivas para o caso de descumprimento da autocomposição, irá aumentar em muito na medida em que ocorre uma mudança na perspectiva dos meios de solução consensual, de meios residuais para meios mais adequados, no ordenamento jurídico brasileiro.

Esta mudança, que já se verificou na teoria e nos ordenamentos de outros países a mais tempo, trata da passagem de um inicial papel residual na doutrina e nos ordenamentos jurídicos da autocomposição e da arbitragem entendidos como *meios alternativos aos tradicionais meios judiciais* , para a adoção teórica e normativa da autocomposição e da arbitragem como *meios adequados em um modelo de justiça multiportas* , como forma de gerir melhor e de maneira mais efetiva as controvérsias, aumentando não somente a frequência das autocomposições e da arbitragem previstas em lei, como estimulando fortemente as partes a autocomposição.¹²⁸ No Brasil isto já está ocorrendo no âmbito normativo com as recentes mudanças legislativas (arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 165 a 175, 334, 515, § 2.º do CPC/2015; Lei da Mediação; Resoluções 118 do CNMP e 125 do CNJ etc.).

A execução do título executivo decorrente de autocomposição poderá ser por cumprimento de sentença, nos mesmos autos, como execução-fase, quando houver homologação judicial; ou por processo de execução, quando se tratar de autocomposição extrajudicial.

2.15. Negócios processuais na execução e cumprimento de sentença

Os negócios processuais ¹²⁹ podem ser celebrados extrajudicialmente ou judicialmente, pelas partes sozinhas ou com a participação do juiz, neste último caso o juiz já controlará, de imediato a validade do negócio.

Os negócios poderão versar sobre mudanças de procedimento, inclusive com a derrogação de normas processuais, estipulando mudanças do procedimento.

A disciplina dos negócios processuais tem seu núcleo nos arts. 190 ¹³⁰ e 200 ¹³¹, CPC/2015, que funcionam como cláusulas gerais dos negócios processuais atípicos.

Existem negócios processuais típicos *específicos* do cumprimento e da execução, por exemplo: o acordo de impenhorabilidade (arts. 833, I, CPC “ *[s]ão impenhoráveis(...) os bens (...) declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução*”, e 848, II, CPC); a escolha do administrador (art. 862, § 2.º, CPC, “ *[é] lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação*”); a escolha do leiloeiro (art. 880, § 4.º, CPC); a substituição consensual de bem penhorado (art. 847, § 4.º, CPC); o parcelamento do valor em execução (art. 916, CPC); a desistência da execução ou do ato executivo (art. 775, CPC); todos os contratos com garantia real (art. 835, § 3.º, “[*n*]a execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”). ¹³² A doutrina aponta pelo menos alguns exemplos de negócios processuais atípicos na atividade de execução: a execução negociada; o acordo de impenhorabilidade; acordo de substituição de bem penhorado; acordo para não promover execução provisória, acordo para dispensa de caução na execução provisória; e a execução negociada para a implementação de políticas públicas, que pode inclusive prever tutelas pecuniárias. ¹³³

Poderíamos, ainda, pensar em negócios processuais específicos para o processo de execução, por exemplo: prevendo procedimento atípico para a execução da obrigação de pagar quantia, resolvendo, de uma vez por todas, qualquer dúvida sobre a aplicabilidade do art. 139, IV, CPC, determinando desde logo que a execução seria promovida por medidas indutivas, sub-rogatórias ou mandamentais diversas do procedimento de penhora e expropriação; determinando a possibilidade do bloqueio de verbas ou bens; o pagamento de *astreintes*; a escolha consensual de gestor para efetuar o pagamento mediante a administração dos bens da empresa etc. Ainda, poderiam ser determinadas as contas-correntes e os limites sobre os quais deveria incidir a penhora on-line (art. 854, CPC).

2.16. Execução atípica: medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem de pagar quantia certa ou de outras ordens judiciais no curso do processo de execução

O art. 139, IV, CPC estabelece um novo modelo de execução civil no Brasil. ¹³⁴ Ao prever a atipicidade dos meios executivos ligada ao controle da adequada e efetiva tutela pelo juiz, o CPC migra de um modelo exclusivo de execução rígida, de obrigações-tipo e execuções-tipo (germânico), para um modelo combinado de execuções tipo flexíveis, tutela adequada (*common law*) e generalização das *astreintes* (francês). ¹³⁵

Nesse novo modelo, serão cabíveis medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das obrigações de pagar quantia, a tutela do crédito. Parafraseando o art. 297 do CPC, podemos dizer que: *o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela do crédito* (poder geral de tutela efetiva).

Há, contudo, uma ressalva: assim como para as tutelas provisórias para pagamento de quantia certa deve ser aplicado o regramento do cumprimento provisório de sentença (art. 297, parágrafo único c/c. 520 a 522, CPC), também para a tutela do crédito mediante processo de execução deverá ser aplicada a regra procedimental dos arts. 824 e ss., CPC, para o procedimento de penhora, avaliação e expropriação, como regra geral.

Contudo, quando a técnica processual da penhora e expropriação mostrar-se insuficiente ou deficitária, quer pelo comportamento das partes, quer pelo bem jurídico tutelado (*posta in gioco*), deverá o juiz determinar a sua adequação para garantia da efetividade, como desdobramento do direito fundamental à tutela do crédito (direito fundamental à organização e ao procedimento adequados e efetivos à tutela do crédito).

Como afirma a doutrina: “tem o órgão jurisdicional de aferir se a técnica processual destinada pelo legislador infraconstitucional para a tutela ressarcitória pecuniária é eficaz e apropriada. Em outras palavras, tem-se de verificar se a técnica expropriatória satisfaz as exigências mínimas, no que concerne à sua eficiência, para tutela da *res in iudicium deducta*. Se não satisfaz, então é porque a previsão legal é inadequada para a proteção daquele caso específico, e deve ser considerada. Isso porque uma regra só é aplicável se as suas condições de incidência são satisfeitas e se a sua aplicação não é excluída pela razão motivadora da regra. O raciocínio aí implicado denota a necessidade de examinar-se a razoabilidade da aplicação do binômio condenação-execução forçada, alcançando-se mão da razoabilidade na sua aceção de razoabilidade como equidade. Evidentemente, a motivação do art. 523, CPC, está em possibilitar a prestação de uma tutela adequada e efetiva às obrigações de pagar quantia. Se tal não se dá, por inadequação dessa técnica processual, a regra não pode ser aplicada. Uma vez demonstrada a não efetividade do procedimento do art. 523 e ss., CPC [na verdade, também o procedimento dos arts. 824 e ss. do CPC, até por serem intercambiantes], à espécie, o que indubitavelmente passa pela *explícita motivação dessa superação legal na decisão*, cumpre ao órgão jurisdicional examinar o emprego de ordem sob pena de multa coercitiva (ou outro meio de indução ou de sub-rogação) se oferece ou não aplicável ao caso concreto (art. 139, IV, CPC).” ¹³⁶

No entendimento aqui esposado, as normas da atipicidade aplicam-se também aos processos de execução de títulos executivos extrajudiciais. ¹³⁷

Algumas razões reforçam este entendimento: a) historicamente, não há diferença ontológica entre a atividade executiva, que se segue ao processo de conhecimento (*executio per officium iudicis*), e o processo de execução por título executivo extrajudicial. Como vimos no desenvolvimento histórico (cf. *supra*), desde o surgimento da *excecutione parata* e da subsequente equiparação dos títulos judiciais às confissões de dívida perante os notários e das letras de câmbio (*instrumenta guarentegiata* , *lettres obligatoires*) foi, justamente, a tentativa de equiparação entre a sentença e os títulos extrajudiciais (*execution parée*) que caracterizou a evolução da atividade executiva; ¹³⁸ b) o direito fundamental à execução e à tutela do crédito inclui a execução de títulos executivos extrajudiciais, ou seja, de outros documentos ou instrumentos reconhecidos como hábeis a ensejar a execução, nos termos reconhecidos pela Corte Europeia de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; ¹³⁹ c) o CPC estabelece uma intercambialidade entre o processo de execução e o processo de cumprimento de sentença (art. 513 c/c art. 771); d) a Parte Geral se aplica a todo o Código, tanto no que diz respeito às suas normas fundamentais, como no que diz respeito aos deveres-poderes do juiz. Logo, o art. 139, IV, CPC é aplicável a toda e qualquer atividade judicial prevista no CPC e também para além dele, nos termos do art. 15, CPC, de forma supletiva, subsidiária e residual, aos demais processos e procedimentos especiais fora do Código.

Há necessidade, contudo, de verificação da inadequação da execução por expropriação para que se possa prosseguir nos meios atípicos. Essa inadequação deve ser corretamente justificada na decisão do juiz, permitido o contraditório, mesmo que diferido. Isso ocorre porque a adequação exigida é consistente na demonstração da relação meio e fim. Nesse sentido, “(...) é, por exemplo, que a condenação, seguida de execução forçada, é o *meio* pelo qual se pode alcançar o *fim* tutela ressarcitória pecuniária. Ao fazer a ligação entre condenação, execução forçada e ressarcimento, o legislador infraconstitucional sopesou a adequação entre o meio e o fim, a necessidade do meio e a proporcionalidade em sentido estrito entre a realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais das partes.” ¹⁴⁰ Dessa maneira, a decisão de aplicar meios atípicos impõe ao juiz o ônus argumentativo de comprovar a inadequação dos meios típicos disponíveis no caso concreto.

A dificuldade doutrinária e dos tribunais consistirá em densificar estes critérios de forma racional em construções dogmáticas e precedentes sólidos que permitam a universalização das exceções atípicas, previstas no art. 139, IV, CPC, ao procedimento típico de penhora e expropriação previsto nos arts. 824 e ss., CPC. ¹⁴¹

Um dos critérios de análise da colisão de princípios na execução para afastar o meio típico é o da proporcionalidade, subdivido em três submáximas: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, podemos, mesmo que brevemente, fazer algumas indicações, acompanhando a doutrina, ao afirmar que, na decisão que aplica o meio atípico, o juiz deve: a) justificar o motivo do emprego do meio indutivo ou coercitivo é adequado ao fim, ou seja, porque leva à realização do fim (submáxima da adequação); b) justificar o motivo do meio ser necessário, identificando quais as razões pelas quais os meios típicos disponíveis não são efetivos, tornando-se imprescindível o uso de uma técnica diferenciada e atípica (submáxima da necessidade); c) justificar o motivo pelo qual não há eliminação das garantias fundamentais mínimas do executado (núcleo essencial), permitindo-se, do ponto de vista jurídico, uma restrição maior aos seus direitos de defesa (submáxima da proporcionalidade em sentido estrito). ¹⁴²

É bom frisar que a proporcionalidade é apenas uma das técnicas de justificação da decisão em colisões de direitos fundamentais. O afastamento da tipicidade pode ser justificado também à luz de outros critérios para controlar intersubjetivamente a decisão, como veremos no próximo tópico.

2.17. Execução e teoria da decisão judicial

O princípio da tipicidade e os meios executivos estão intimamente ligados no imaginário do processualista brasileiro, sul-americano e italiano, entre outros ordenamentos, muito por força de terem sido influenciados pelo modelo alemão de obrigações típicas e meios executivos típicos. ¹⁴³ Em razão disso, a doutrina corretamente afirma que “[d]urante muito tempo vingou a ideia de que o magistrado só poderia proceder à execução valendo-se de meios executivos tipicamente previstos na legislação. Essa era uma forma de controlar a sua atividade, evitando-se que agisse arbitrariamente e garantindo-se a liberdade ou a segurança psicológica do cidadão, ideias intimamente ligadas aos valores do chamado Estado Liberal”. ¹⁴⁴ Assim, “a lei, ao definir os limites da atuação executiva do juiz, seria uma garantia das partes no processo.” ¹⁴⁵

A partir das reformas processuais que conferiram meios atípicos para a tutela da execução específica das obrigações de fazer e não fazer, a doutrina passou a defender o “princípio da concentração dos poderes de execução do juiz”, assumindo que existe um “poder geral de efetivação”, e consequentemente um “princípio da adequação (adequabilidade) ao direito material subsistente ao título e a situação concreta em análise pelo juiz” que autoriza ao juiz os deveres-poderes necessários para efetivar a tutela dos direitos. Nesse sentido, o art. 461, § 5.º, do CPC/1973 (arts. 498 e 538, CPC/2015), inserido pela Lei 8.952/1994, consistiria em verdadeira “cláusula geral executiva”, abrindo a anterior tipicidade do modelo brasileiro para a atipicidade e adequação. ¹⁴⁶

A dificuldade permanecia em relação às obrigações de pagar quantia certa, obrigações de dar dinheiro. Aplicação da cláusula geral executiva e da atipicidade dos meios executivos ao procedimento executivo para pagamento de quantia certa já era defendido por Marcelo Lima Guerra: “(...) não há nenhuma razão para se dispensar um tratamento privilegiado aos credores de obrigações de fazer ou não fazer, em relação aos demais. Revela-se, assim, *anti-isonômico* que o credor de obrigações de fazer ou não fazer possa receber tutela executiva de modo mais eficaz, com utilização de meios executivos adequados à situação concreta e concebidos pelo juiz caso a caso. Impõe-se, portanto, também em face do *princípio constitucional da isonomia* (igualmente dotado de *status de direito fundamental*), a extensão dos poderes reconhecidos ao juiz no mencionado § 5.º do art. 461 do CPC/1973, *a toda e qualquer situação de tutela executiva, independentemente da natureza do crédito a ser satisfeito in executivis*”. ¹⁴⁷

A regra aberta da atipicidade prevista na atual legislação é muito mais ampla e atinge toda a atividade executiva. Por exemplo, o art. 139, IV, do CPC foi muito além do entendimento de

Marcelo Lima Guerra, pois permitiu as *astreintes* também para as obrigações de pagamento de quantia certa, e não só para que o devedor seja compelido a indicar os bens à penhora, como propunha o autor.

Na doutrina anterior, algumas vozes defendiam a possibilidade da atipicidade, desde que atrelada ao juízo de inconstitucionalidade da norma prevista como típica. Nesse sentido: “o órgão jurisdicional pode afastar a aplicação de uma regra processual que, no caso concreto, se revele inadequada à efetivação dos direitos fundamentais a um processo adequado, à dignidade da pessoa humana e à tutela executiva, em razão da sua inconstitucionalidade”.¹⁴⁸ A solução é razoável.

Uma das maneiras de se reconhecer a inconstitucionalidade da norma é através do teste de proporcionalidade. A proporcionalidade está presente no arco do raciocínio executivo em diversos aspectos. Sem dúvida, contudo, sua maior expressão se dá no equilíbrio entre o *princípio de que a execução se fará no interesse do exequente* (art. 797, CPC) e o *princípio da menor onerosidade possível* (art. 805, CPC).¹⁴⁹ A vedação da execução excessiva é reconhecida na maior parte dos ordenamentos jurídicos (§ 803, ZPO alemã; art. 592, Lei de Enjuiciamiento Civil espanhol), “consagrando-se a aplicação da proporcionalidade na execução”.¹⁵⁰

A vedação da execução excessiva não se confunde, contudo, com a execução que possa reduzir o devedor a indigência. Uma coisa é impor limites ao excesso da execução, permitindo o equilíbrio mediante a responsabilidade do exequente e o controle judicial; outra é reduzir a execução nos casos em que esta avance sobre o mínimo existencial do patrimônio do executado. Aqui o vetor não é o excesso na atividade executiva, não é o equilíbrio entre o devido e o satisfeito pela tutela judicial, mas a dignidade da pessoa humana. Apenas o núcleo essencial do direito fundamental à dignidade da pessoa humana autoriza a restrição aos direitos fundamentais à propriedade e à tutela processual do crédito mediante a atividade executiva.

Porém, para além da questão da inconstitucionalidade, que é a porta de entrada para a análise em concreto da possibilidade de afastar a norma típica e o procedimento típico, é necessário dissecar quais os elementos que permitem uma decisão adequadamente fundamentada na matéria. É o que iremos passar a analisar.

Em um primeiro momento, a doutrina tem se ocupado de exemplificar possíveis medidas a serem aplicadas com base no art. 139, IV, do CPC, tais como a proibição de pessoas jurídicas participarem de licitações, quando devedoras de obrigação pecuniária; a suspensão do direito de dirigir, quando a pessoa tiver sido condenada a pagar indenização por danos oriundos de acidente automobilístico; a vedação à contratação de novos empregados, quando a empresa for devedora de verbas salariais.¹⁵¹

Porém, tão ou mais importante que a criatividade na elaboração de novos meios aptos a dar efetividade à tutela processual do crédito é estabelecer critérios intersubjetivos que permitam controlar normativamente a aplicação de medidas executivas atípicas. É preciso superar a concepção formalista da interpretação que crê na fundamentação como uma garantia que, por si só, é suficiente para legitimar o exercício da atividade jurisdicional, independentemente do seu conteúdo.

Nesse ponto, a doutrina vem apostando em critérios genéricos e abstratos que nada dizem sobre os limites normativos desta atipicidade. Afirmam, em alguns casos, que “essa liberdade concedida ao juiz naturalmente aumenta sua responsabilidade, não sendo admissível que a utilize para contrariar a lei ou mesmo princípios gerais do Direito”,¹⁵² e, em outros casos, apenas levantam parâmetros sem aprofundar a dinâmica de sua aplicação no caso concreto, limitando-se a alegar que a aplicação de meios executivos atípicos encontra barreira na excepcionalidade da medida, proporcionalidade, fundamentação substancial e demais garantias constitucionais.¹⁵³

A proposta aqui é a de adequar à aplicação de medidas executivas atípicas uma teoria da decisão judicial, considerando que cabe aos juízes e tribunais o ônus argumentativo de demonstrar a respectiva adequação destas medidas, oportunidade em que deverão fazer juízos

concretos, explicitando as razões de decidir e as premissas da decisão, não só quanto ao seu desenvolvimento, mas também quanto à escolha das próprias premissas (art. 489, §§ 1.º e 2.º, CPC), com observância da estabilidade, coerência e integridade (art. 926, *caput*, CPC). Somente assim será possível garantir, através dos dispositivos do Código, o controle intersubjetivo interno e externo da decisão exarada.

De acordo com o CPC, o controle intersubjetivo da decisão judicial deve combinar: a) a observância do contraditório como direito de influência e dever de debates (art. 10 e 489, § 1.º, IV, CPC); b) justificação interna das razões de decidir (art. 489, § 1.º, CPC); c) a justificação externa, com o teste de estabilidade, coerência e integridade da decisão perante o ordenamento jurídico através da escolha das premissas e do controle do resultado (art. 926, *caput*, CPC). ¹⁵⁴

Iremos abordar cada um destes critérios e, de forma sucinta, analisar a sua aplicação especificamente em relação ao art. 139, IV, do CPC em um caso em que se pretenda a aceleração do pagamento de quantia certa decorrente do descumprimento de um termo de ajustamento de conduta ambiental.

Primeiro, a decisão judicial deverá ser controlada intersubjetivamente pelas partes envolvidas pelo a) *contraditório*, valor-fonte do processo civil brasileiro ¹⁵⁵ que, ao mesmo tempo, é composta de uma *garantia de influência* do exequente e do executado em relação ao julgamento sobre a adequação do meio executório atípico, e por um *dever de debates* entre juiz e as partes. ¹⁵⁶

No caso da multa ambiental decorrente de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, por exemplo, o juiz, ao despachar a citação do executado solvente para pagamento, irá adverti-lo que, se não for realizado o pagamento no prazo de três dias, poderá incidir *astreintes* por dia de atraso como forma de aceleração ao pagamento, independentemente de prosseguir o procedimento de penhora e expropriação.

Assim, o CPC é dotado de dispositivos que buscam constranger o diálogo entre o juiz e as partes (i) quando veda a prolação de decisões judiciais, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento que não contou com prévia manifestação das partes (art. 10, CPC); e (ii) quando não considera fundamentadas as decisões judiciais que deixam de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes capazes de infirmar a decisão (art. 489, § 1.º, IV, CPC).

Além disso, o controle intersubjetivo das premissas e do resultado da decisão judicial deve combinar a b) justificação interna (desenvolvimento interno da justificação em uma dada decisão) e c) a justificação externa (escolha das premissas fixadas na decisão e conferência do resultado). ¹⁵⁷

A b) *justificação interna* seria a possibilidade do controle lógico-formal do raciocínio judicial a partir do conteúdo do próprio ato decisório. Este modelo de controle não responde pela escolha das premissas da decisão. Esta escolha lhe é indiferente. A justificação interna exige apenas a verificação da lógica formal desenvolvida a partir das premissas estabelecidas no próprio ato decisório, ou seja, a passagem destas premissas, por inferência, por raciocínio dedutivo, à conclusão do silogismo. ¹⁵⁸

Assim, ao estabelecer, em um determinado processo, que o direito material é relevante para acelerar o procedimento, o julgador deve em seguida demonstrar como este procedimento será acelerado pela alteração do rito. Por exemplo, decorrendo o título de um dever de pagar quantia certa *resultante de multa ambiental prevista em termo de ajustamento de conduta*, o julgador poderá justificar a aplicação de *astreinte* para que o devedor solvente que não adimpliu a obrigação no prazo de três dias efetive-a. O julgador fixou a premissa de direito material (dever de pagar a multa ambiental) como relevante para a atipicidade e aplicou a *astreinte* como técnica de aceleração para o caso de não pagamento no prazo legal do art. 829, CPC.

O controle intersubjetivo da justificação interna tem por objetivo evitar que a decisão deixe de seguir uma fundamentação interna coerente/consistente com os resultados obtidos ao final. Daí a afirmação de que: “Internal justification deals with the validity of inferences from given premises to legal decision taken as their conclusion”. ¹⁵⁹ O objeto da justificação interna é a conferência da

validade das inferências a partir das premissas estabelecidas na própria decisão. Em outras palavras, fixada a premissa de que o título executivo extrajudicial fundado em direito ambiental em determinadas circunstâncias fáticas serve como premissa para acelerar o procedimento, a aceleração decorrente é coerente com a premissa nos casos em que se execute título dessa natureza e estejam presentes as mesmas circunstâncias.

Por fim, a c) *justificação externa* da decisão trata da fundamentação das premissas da decisão, sua base fática e jurídica, as quais dependem do controle da correta argumentação do juiz ou tribunal no momento da decisão. Refere-se ao ponto de vista substancial do direito em um determinado ordenamento, em um dado momento histórico e aos fatos considerados relevantes para o caso a ser decidido. O controle argumentativo da justificação externa é de ordem jurídica e de ordem fática. Verifica-se, não somente a validade das inferências (justificação interna, vista acima), mas a fundamentação das premissas e do próprio resultado obtido: “External justification of legal decision tests not only the validity of inference, but also the soundness of premisses”. ¹⁶⁰

O objeto da justificação externa é o controle da solidez, da correção das premissas fáticas e jurídicas escolhidas para a decisão ¹⁶¹ e do resultado que se obteve a partir da aplicação da justificação interna. Mesmo um resultado coerente/consistente internamente, poderá se verificar incorreto ao final, se não solucionar adequadamente o problema, por estar desconforme com a compreensão da unidade do ordenamento constitucional, portanto, por faltar no quesito da *soundness* (solidez ou integridade).

O controle intersubjetivo da escolha e solidez das premissas será objeto de um teste de resultado (*soundness*), constante da estabilidade, coerência e integridade da decisão judicial perante a ordem jurídica, previstos no art. 926, *caput* , do CPC/2015.

Retomando o exemplo do caso da execução da multa ambiental prevista no termo de ajustamento de conduta, a técnica proposta tem de ser legítima do ponto de vista da prevenção especial e geral (as *astreintes* devem se justificar diante da situação fática e jurídica como forma de aceleração da execução). Exemplificativamente, diante de uma situação em que várias empresas firmaram termos de ajustamento de condutas similares e que, economicamente, está se mostrando mais vantajoso, em determinado momento, ao grupo responder pela execução a cumprir o comportamento determinado no termo, o dever de pagar quantia, nesta situação, precisa ser reforçado com a execução acelerada (por exemplo, as *astreintes*), justificando-se a medida coercitiva.

Os deveres de contraditório e justificação interna e externa têm a função de promover a unidade do Direito, ao constranger o intérprete, vinculando-o, ao mesmo tempo, permitindo o controle intersubjetivo, ou seja, o controle pelas partes (endoprocessual – interno) e o controle pela sociedade (extraprocessual – externo).

Como se vê, estes postulados hermenêuticos e analíticos constituem critérios intersubjetivos necessários à “compreensão interna e abstrata do ordenamento jurídico”, ¹⁶² possibilitando aferir a responsabilidade da interpretação realizada pelos julgadores consoante a presença do contraditório efetivo, mesmo que diferido, a justificação interna e a justificação externa constante da decisão judicial. ¹⁶³

A aplicação da teoria da decisão de forma adequada evita que a atipicidade torne-se fonte de arbítrio e discricionariedade. Atinge um duplo objetivo: a) constrange a adotar as mesmas regras em casos similares ou análogos; e b) evita decisões não fundamentadas que não possam ser controladas intersubjetivamente.

As decisões singulares não fazem precedentes, mas a lógica da universalização também se aplica a elas. O mesmo juiz não pode decidir de forma diferente sobre a mesma matéria em situações similares ou análogas, sem justificação adequada. Nesse sentido, podemos dizer que as máximas da estabilidade, coerência e integridade também valem para o juiz singular.

2.18. Precedentes e execução

Uma das grandes novidades do CPC/2015 são os precedentes normativos formalmente vinculantes.¹⁶⁴ O núcleo do modelo de precedentes normativos formalmente vinculantes está nos arts. 927, 926 e 489, § 1.º, V e VI, CPC.

O Código estabelece um rol de decisões e formas de divulgação de decisões que serão considerados vinculantes, ao determinar que os juízes e tribunais observarão (art. 927 do CPC): a) as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado; b) enunciados de súmulas vinculantes; c) os julgamentos nos incidentes de assunção de competência e no julgamento de casos repetitivos (IRDR e recursos especial e extraordinário repetitivos); d) enunciados de súmulas dos Tribunais de Justiça estaduais, em matéria de direito local, do STJ, em matéria infraconstitucional, do STF, em matéria constitucional; e) as orientações do Plenário ou da Corte Especial dos tribunais a que estiverem vinculados.

Os precedentes, contudo, têm também um aspecto material. Eles dependem de uma análise de seu conteúdo, para se conformarem como precedentes. Somente será precedente a decisão que, estando presente no rol acima, possuir fundamentos determinantes que tenham sido aprovados pela maioria dos membros do órgão colegiado que estabeleceu o precedente.¹⁶⁵

Os fundamentos determinantes, *ratio decidendi* ou *holding* da decisão, são a junção dos fatos (circunstâncias fáticas) e do direito (solução jurídica).¹⁶⁶ A decisão do juiz atual somente será vinculada pelo precedente, e, portanto, fundamentada em um precedente-norma, se, ao comparar os fundamentos determinantes do caso precedente e o caso atual, demonstrar que aqueles se amoldam a este (art. 489, § 1.º, V, CPC).

Por esta razão, somente serão súmulas vinculantes ou súmulas ordinárias com efeito de divulgação de precedentes vinculantes, aqueles enunciados de súmulas que se referirem aos precedentes que lhes deram origem e as suas circunstâncias fáticas (art. 926, § 2.º, CPC). Os precedentes poderão ser ainda afastados por distinção¹⁶⁷ ou por superação¹⁶⁸ (art. 489, § 1.º, VI, CPC).

Bom, os precedentes podem tratar de direito material e processual. Os precedentes em direito processual poderão funcionar como normas vinculantes sobre o cumprimento de sentença e o processo de execução, como efetivamente ocorre em vários casos, conformando o modelo da atividade executiva juntamente com as normas-lei. O modelo da atividade executiva é formado, portanto, de normas-precedente e normas-lei. Assim, ao longo do trabalho, iremos analisar os precedentes do STF e do STJ em matéria de cumprimento de sentença e do processo de execução, denominando precedentes apenas aquelas decisões que, nosso entender, amoldem-se ao previsto acima, mesmo que proferidas antes da entrada em vigor do CPC/2015.

Por outro lado, ao longo do trabalho, quando as decisões dos tribunais não se encaixarem nas hipóteses de precedentes, como o entendimento dos tribunais superiores por seus órgãos fracionários, por exemplo, as turmas do STJ, falar-se-á em jurisprudência, que tem caráter de mera eficácia persuasiva.

A distinção no CPC é clara: precedentes são normativos, permitindo inclusive o julgamento liminar de improcedência (art. 332, CPC), a tutela da evidência (art. 311, CPC), o julgamento monocrático pelo relator (art. 932, IV e V, CPC) etc.; a jurisprudência é persuasiva, podendo ser aplicada segundo forneça ou não boas razões.¹⁶⁹

Alguns exemplos de precedentes que servem atualmente ao processo de execução são os enunciados das súmulas do STJ e do STF que não tenham sido especificamente contrastados pela nova lei.

Há, porém, alguns casos em que os precedentes anteriores devem ser abandonados em face da lei nova, utilizando-se a distinção (art. 489, § 1.º, VI, CPC); não devendo, portanto, ser aplicados pelo juiz. Isso ocorre porque o CPC, como lei nova, é fato novo. O fato novo, por não ter sido levado em consideração na decisão precedente, autoriza o seu afastamento por distinção. Assim, quando o legislador edita uma lei nova sobre a matéria que foi fixada por precedente, somente se

realizado o controle de constitucionalidade da nova norma, esta poderá ser afastada, incidindo a nova norma em lugar do precedente anterior. Este é o caso, por exemplo, do REsp 1.387.248/SC, que foi atingido pelo art. 910, § 3.º, ao prever que a Fazenda Pública, ao alegar o excesso de execução (*exceptio declinatoria quanti*), deve, desde logo, apresentar o valor correto.¹⁷⁰

Os embargos opostos à execução contra o franco entendimento de precedentes judiciais de notório conhecimento do embargante poderão ser sancionados como manifestamente protelatórios (art. 918, parágrafo único, CPC).

Isso é especialmente correto para os litigantes habituais que têm um dever acrescido pela experiência e o conhecimento empírico, em outros embargos opostos em situações idênticas, em que o precedente é aplicável. Assim, instituições financeiras, companhias de telefonia, Fazendas Públicas¹⁷¹ e outros litigantes habituais poderão ser sancionados pelo comportamento recalcitrante, ao impor embargos meramente protelatórios em face de matérias já assentadas em precedentes vinculantes.

2.19. Execução das decisões no processo coletivo em geral e a aplicação supletiva, subsidiária e residual do CPC ao microssistema

Infelizmente a tônica das *regras de processo coletivo* tem sido nas tutelas condenatórias, com especial destaque para o regramento da condenação genérica, liquidação e execução dos direitos individuais homogêneos. Para a doutrina dominante, “apesar de existir um tímido tratamento na lei pátria sobre a execução no plano dos direitos individuais homogêneos (arts. 95/100 do CDC), não há disciplina normativa própria e específica em relação aos direitos difusos e coletivos, salvo as disposições previstas nos arts. 13 e 15 da LACP.”¹⁷² Na verdade, temos um pouco mais: os arts. 14 e 16 da Lei da Ação Popular tratam, respectivamente, sobre a *tutela condenatória e sobre a obrigatoriedade de execução* pelo Ministério Público; o art. 13, da Lei da Ação Civil Pública, e o art. 18, da Lei de Improbidade Administrativa, entre outros, *determinam a destinação aos fundos específicos ou gerais dos valores obtidos nas execuções coletivas propriamente ditas* e o art. 100, parágrafo único do CDC, prevê na execução dos direitos individuais homogêneos a destinação da *fluid recovery* aos mesmos fundos de defesa dos direitos difusos.

Ao lado disso se constata que também os projetos de Código de Processos Coletivos não apresentaram uma disciplina adequada e exaustiva para a tutela dos direitos que depende de ato exterior, não normativo, para a efetivação do comando judicial. Esta constatação também serve para as reformas do Código de Processo Civil de 1973 (Leis 10.444/2002; 11.232/2005 e 11.382/2006), as quais em nenhum momento se preocuparam em atingir com mais rigor e atenção as necessidades do processo coletivo.¹⁷³

O Código de Processo Civil atual, contudo, muda totalmente esta relação: a aplicação do CPC/2015 ao processo coletivo será supletiva, subsidiária e residual. O CPC expressamente reconhece a existência do processo coletivo no dispositivo que trata dos poderes do juiz (art. 139, X, CPC) e nos dispositivos que tratam da suspensão dos processos e da aplicação da tese nos casos repetitivos aos processos individuais e coletivos. As normas fundamentais do CPC, portanto, se comunicam aos processos coletivos, inclusive a disciplina da execução atípica prevista no art. 139, IV, CPC, quando trata dos deveres-poderes do juiz.¹⁷⁴

Por outro lado, rara exceção deve ser feita para a disciplina do art. 84 do CDC, que por sua localização e sede é utilizável tanto para tutela individual quanto coletiva do consumidor, mas não somente deste, pois o microssistema dos processos coletivos é harmonizado e organizado pelos princípios do CDC. Muito embora não seja necessário, é bom recordar que a pretensão autoral com base no art. 84, CDC, permite ser aplicável na espécie todo o regramento do atual art. 497 do CPC (art. 461 do CPC/1973), originário do primeiro, e que significou um extremado avanço para os fins de tutela jurisdicional adequada dos deveres fundamentais previstos na Constituição.

A tutela específica das obrigações ou a tutela pelo seu equivalente é fortemente prevista no CPC. O Código realizou um acréscimo específico que atende à teoria da *tutela inibitória* e da *tutela de remoção do ilícito*, tutelas sem exigência de comprovação do dano, prova do dolo ou culpa, pois,

“para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo” (art. 497, parágrafo único, CPC). Isso não impede o que foi dito acima, mas, evidentemente, somente haverá *conversão* em perdas e danos se houver comprovação do *dano* (arts. 499 e 500, CPC).

Há que se ressaltar ainda no CPC/2015 uma clara divisão entre a sentença e a tutela provisória referente à tutela específica e ao resultado prático equivalente (arts. 497 a 500, CPC) e a sua fase de cumprimento ou satisfação (arts. 536 a 538, CPC). O CPC também unificou a defesa, permitindo a impugnação nos termos do art. 536, § 4.º, CPC c/c os arts. 525 e 538, CPC, para as obrigações de fazer, desfazer, não fazer e entrega de coisa.

Impõem-se agora ressaltar que as normas descritas acima, além de servirem como exemplos de disciplina das execuções na tutela coletiva, são “intercomunicantes”, atuando em uma espécie de diálogo de fontes de extraordinária utilidade, formam, centralizadas pela disciplina mais abrangente do CDC e da LACP (conjugação disposta expressamente nos arts. 21 da LACP e 90 do CDC), o chamado microssistema dos processos coletivos, reconhecido igualmente por precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se (...)”.¹⁷⁵

A aplicação do microssistema possibilita, por exemplo, para falar de processo de execução coletiva, a utilização da norma prevista no art. 14, § 3.º da LAP, ou seja, o *desconto em folha dos servidores públicos para ressarcir o erário*. Esta possibilidade já foi reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. É uma modalidade que muito bem se encaixa na abertura para a adequação prevista no art. 139, IV, CPC. Há para esta possibilidade agora um suporte que atinge a tutela do título judicial e extrajudicial. Se o termo de ajustamento de conduta (TAC) previu o ressarcimento ao erário, este poderá ser efetuado mediante desconto em folha, a requerimento do autor da execução; mais, aplicando-se a cláusula do art. 190 do CPC que permite os negócios processuais, poderá o termo de ajustamento de conduta prever expressamente que sendo descumprido haverá a possibilidade de desconto em folha no caso de execução judicial.¹⁷⁶

3. Conclusão: cinco mudanças essenciais na execução civil

A conclusão a que chegamos indica para um movimento de mudança da essência do modelo brasileiro de execução civil.

É correto dizer que esse movimento iniciou-se com as Reformas anteriores ao CPC/2015 por meio de várias leis que ruíram conceitos do *paradigma tradicional da tipicidade e da separação entre cognição e execução*, a exemplo das transformações ocorridas em relação aos brocardos *nulla executio sine titulo* e *nemo potest praecise cogi ad factum* (cf. introdução, 2.8).

Contudo, a organicidade do CPC/2015 derrocou, definitivamente, o modelo anterior e contribui para um *impulso transformacional* do modelo de tipicidade rígida previsto tradicionalmente para a atividade executiva no Brasil.

O novo modelo que se desenha no Código, interpretado à luz do vetor do direito fundamental à tutela satisfativa, é um modelo combinado de tipicidade flexível, adequação e generalização das *astreintes* (cf. introdução, 2.8 a 2.11). Esse modelo é o indicado pelas normas fundamentais que disciplinam o Código e o processo brasileiro em consonância com os direitos fundamentais e com a finalidade do processo: a tutela dos direitos justa, adequada, tempestiva e efetiva.

É justamente a efetividade o núcleo das preocupações com a atividade executiva. Como vimos, nas premissas a este trabalho, não há direito fundamental de propriedade que dê suporte a um processo de execução pensado para a tutela do devedor.

O processo de execução deve ser voltado para a tutela do crédito (cf. *supra*, premissas, 1.1).

O processo de execução (títulos executivos extrajudiciais) e a atividade executiva no processo (cumprimento de sentença, títulos executivos judiciais) buscam tutelar um tríptico interesse, com predominância do interesse do credor.

O regime jurídico da execução singular para pagamento de quantia certa procura tutelar, principalmente, o interesse do credor e, sendo possível, garantir a menor onerosidade possível ao executado, agilidade e economia no interesse público, considerando que há custos para o Poder Judiciário na atividade executiva (cf. *supra*, premissas, 1.2).

O direito à efetividade da tutela, por outro lado, é um comando constitucional que inclui a atividade satisfativa. Ele decorre do direito ao processo justo (art. 5.º, LIV, CF/1988), está previsto no art. 4.º, CPC, e é reconhecido no direito comparado como direito fundamental à tutela processual do crédito.

Nesse sentido, as normas fundamentais do Código orientam o processo de execução em sua interpretação e aplicação.

Forma-se, ademais, nesse modelo, um conjunto de normas de execução que combina as tutelas provisórias (art. 297, CPC, poder geral de tutela provisória, tutelas de urgência e da evidência), o cumprimento de sentença (art. 513, CPC, títulos executivos judiciais) e o processo de execução (art. 771, CPC, títulos executivos extrajudiciais) para a satisfação dos direitos.

Em consequência, as normas previstas para o cumprimento de sentença e para o processo de execução são intercambiáveis, ligadas entre si por dispositivos de coligamento e pela mesma finalidade: a tutela efetiva dos direitos (arts. 513 c/c 771, CPC). Há vinculação, igualmente, entre o procedimento comum e o processo de execução (art. 318, CPC), isso significa que o Código se articula *internamente* e *externamente* com outros microssistemas (por exemplo, com o microssistema do processo coletivo, cf. introdução, 2.19).

Essa articulação pode ser traduzida em uma dupla metáfora, o Código serve de estuário no qual desaguam vários afluentes e, ao mesmo tempo, retroalimenta esses afluentes como o tronco que carrega a seiva aos galhos de uma árvore. Estuário e arvore, o Código é, ele mesmo, plástico, moldável e flexível, para permitir sua adequação aos direitos materiais que tutela e também para a garantia de sua longevidade, sua atualização contínua na medida em que os próprios direitos evoluem no ordenamento jurídico. Nesse sentido, trata-se de um Código da “Era da (Re)Codificação”, um Código compromissado com a Constituição como fonte de validade formal e material de todas as normas do ordenamento jurídico (art. 1º, CPC, cf. introdução, 2.6).

Por essa razão, o Código não pode ser lido com os olhos apenas voltados para nossa experiência brasileira e passada, mas deve voltar os olhos para o futuro, por meio de um direito processual que sirva às finalidades constitucionais que o comandam. Conforme tratado neste volume, a tendência contemporânea na execução é a desformalização, desburocratização e desjudicialização, ¹⁷⁷ adotando-se um *modelo misto* em relação aos entes que participam da atividade executiva (juiz, Administração Pública e agentes privados) e um *modelo combinado* em relação aos meios executivos (tipicidade flexível, adequação e generalização das *astreintes*, cf. introdução, 2.4 e 2.4.1).

Por essas razões, ao contrário do que se colhe de grande parcela da doutrina, podemos, portanto, afirmar que a estrutura do processo de execução para pagamento de quantia certa já não corresponde ao modelo anterior.

Mudou a estrutura, por ter mudado a essência.

Assim, se as alterações textuais dos arts. 824 a 925 do CPC, que serão analisados a seguir, não são, à primeira vista, tão chamativas, por não trazerem novidades significativas, caso lidas isoladamente, a sua leitura, a partir das ideias trazidas nas premissas e na introdução a este volume, apresentam-se essencialmente transformadoras da atividade executiva.

Podemos, conseqüentemente, identificar cinco mudanças essenciais que fazem que tenhamos atualmente um novo processo de execução.

São elas as seguintes:

- a) atipicidade dos meios executivos (art. 139, IV, CPC, cf. Introdução, 2.16); ¹⁷⁸
- b) negócios processuais típicos e atípicos (art. 190, CPC, cf. Introdução, 2.15);
- c) incentivo à autocomposição a qualquer tempo durante a execução (arts. 139, V e 515, § 2.º, CPC, cf. Introdução, 2.14);
- d) precedentes normativos formalmente vinculantes que disciplinam o procedimento executivo (arts. 926, 927 e 489, § 1.º, V e VI, CPC, cf. Introdução, 2.18);
- f) justiça eletrônica com meios de *e-justice* para a atuação mais ágil, econômica e desburocratizada das atividades executivas (e.g., penhora *on-line*, arrestos e bloqueios *on-line*, buscas *on-line* etc.).

Os meios executivos já passaram por significativa transformação, portanto, não se podendo negar o conteúdo revolucionário dessas novidades que marcam a efetividade do novo processo de execução voltado ao direito fundamental à atividade satisfativa.

Poderíamos, contudo, almejar, ainda, e rogamos que isso ocorra em breve, uma transformação ainda maior, com a descentralização das atividades de execução na pessoa do juiz, admitindo um *modelo misto* de administração das execuções civis no qual haveria uma distribuição de tarefas mais racional entre os órgãos da Administração Pública, os agentes privados e o juiz, este último atuando apenas residualmente, como agente de garantias.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Há aqui uma clara analogia com a conhecida virada epistêmica proposta por Michele Taruffo em relação ao direito probatório: “(...) un proceso no es justo si no está estructuralmente orientado a la búsqueda y al descubrimiento de la verdad.” Michele Taruffo. *Leggendo Ferrajoli: considerazioni sulla giurisdizione. Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2008, p. 631-640; Idem. *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*. Roma/Bari: Laterza, 2009.

2

Na doutrina, com amplas referências às decisões do Tribunal Constitucional Alemão, conferir Robert Alexy, quando afirma que: “Direitos a procedimentos judiciais e administrativos são direitos essenciais a uma ‘proteção jurídica efetiva’ (...) Direitos fundamentais são, em alguns aspectos decisivos, não procedimentais”. Robert Alexy, *Teoria dos direitos fundamentais*. Trad. Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 488-489; Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero, *Direitos fundamentais processuais*. In: Ingo Wolfgang Sarlet; Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 736-803, esp. 749.

3

Este trabalho utiliza “processo justo” como equivalente ao “devido processo legal” (*due process of law*), temos, contudo, expressa preocupação com a inclusão da dimensão substancial ao processo justo. Luigi Paolo Comoglio. *Ética e técnica del “giusto processo”*. Torino: G. Giappichelli Editore, 2004, p. 47-51. Integra-se, portanto, ao termo “processo justo” a ideia reguladora da *justiça* , compreendida aqui como *pretensão de correção* , sem a qual se esvaziaria o seu potencial performativo. Na doutrina brasileira, defendem um aspecto menos substancial do processo justo Ingo Wolfgang Sarlet; Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 736-738; Humberto Ávila. “O que é ‘devido processo legal’?”. *Revista de Processo* , v. 163, set./2008. Há, não obstante, entre nossa compreensão do processo justo e a defendida pelos autores citados, uma convergência no resultado, pois também esses autores defendem que o processo justo inclui os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A dimensão substancial do processo justo refere justamente a esses princípios e a estas preocupações.

4

O superendividamento e a insolvência civil distinguem-se por alguns fatores indicados na doutrina, valendo ressaltar: a) no superendividamento, o que importa é que o consumidor, pessoa física, leigo e de boa-fé, não consegue pagar as suas dívidas de consumo sem o compromisso atual ou futuro pessoal e de sua estrutura familiar; b) na insolvência civil, as dívidas excedem a importância dos bens do devedor (art. 748, CPC/1973). Essa é uma das razões pelas quais há clara distinção entre os créditos em decorrência de sua origem. Os créditos de consumo devem ter uma disciplina adaptada às relações de consumo e às finalidades do direito consumerista. Uma das finalidades do direito do consumidor, nas sociedades contemporâneas, é a garantia de inclusão na sociedade e a educação para o consumo consciente, cf. GARCIA, Leonardo de Medeiros. *Consumo Sustentável. A Proteção do Meio Ambiente no Código de Defesa do Consumidor*. Salvador: Juspodivm, 2016. Como bem salientou a doutrina: consumo é igualdade, consumo é inclusão na sociedade, ou seja, “Consumo é igualdade, é ser cidadão-econômico ativo, é aproveitar as benesses do mercado liberal e globalizado. Consumo é inclusão na sociedade, nos desejos e benesses do mercado atual. Em outras palavras, consumo é para as pessoas físicas a realização plena de sua liberdade e dignidade, no que podemos chamar de verdadeira ‘cidadania econômico-social’”. Cláudia Lima Marques, cf. BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Disponível em: [portal.mj.gov.br/main.asp?Team={B5920EBA-9DBE-46E9-985E- 033900EB51EB}]. Acesso em: 16.02.2013 (Caderno de Investigações Científicas, vol. 1. Prevenção e Tratamento do Superendividamento/Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Professora Cláudia Lima Marques e juízas Clarissa Costa de Lima e Káren Bertoncello (elaboração). Brasília: SDE/DPDC, 2010). Ver ainda: Cláudia Lima Marques; Rosângela Lunardelli Cavallazzi (coord.). *Direitos do consumidor endividado : superendividamento e crédito* . São Paulo: Ed. RT, 2006. O art. 748, CPC/1973, continua vigente, pois, nos termos do art. 1.052, CPC/2015, a matéria aguarda regulamentação específica pelo legislador.

6

Os princípios gerais do processo, adaptados à execução, e os princípios especiais da atividade executiva são essenciais para compreender as diversas relações que se formam na distribuição de tarefas no processo executivo e no controle das atividades executivas. “The importance of the principles or general foundations in the Law of Enforcement, assumes a key role when they relate to the triangular relationship. (i) The creditor requests the enforcement organ to act in enforcement proceedings. Where there is still lack of compliance by the judgment debtor, the enforcement organism uses all suitable mechanisms and adequate proportionality to achieve the satisfaction of the creditor’s rights. (ii) The

relationship between the enforcement organism and the debtor or person against whom judgment has been executed cannot be explained only using the classic principles of the due and fair process of declaratory proceedings. It is the debtor who is going to be limited in his assets and personal sphere. (iii) The substantive and procedural relationship between the creditor and debtor (obligation) must also be remembered, given this relationship increase the legitimacy of aggression towards the personal or property sphere of the debtor”. Álvaro Pérez Ragone, General report, cit., p. 611.

7

Sobre o tema, cf. Hermes Zaneti Jr. *Cooperação e Processo*, no prelo. No Brasil, sobre o tema, cf. Daniel Mitidiero. *Colaboração no Processo Civil*. Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos . 3. ed. (2009) São Paulo: Ed. RT, 2015; Fredie Didier Jr. O princípio da cooperação: uma apresentação. *Revista de Processo* , n. 126, p. 75-79, 2005; Fredie Didier Jr. *Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português* . Coimbra: Coimbra Editora, 2010; Fredie Didier Jr. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. *Revista de Processo* , n. 198, 2011; Humberto Theodoro Jr. Juiz e partes dentro de um processo fundado no princípio da cooperação. *Revista Dialética de Direito Processual* , n. 102, 2011; Antonio do Passo Cabral. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. *Revista de Processo* , n. 126, p. 59-81, 2005; Antonio do Passo Cabral. *Nulidades no processo moderno* . Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 215 e ss.; Leonardo Carneiro da Cunha. *A atendibilidade dos fatos supervenientes no processo civil* . Coimbra: Almedina, 2012, p. 65 e ss.; Lorena Barreiros. *Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação processual* . Salvador: Juspodivm, 2013.

8

C.H. Van Rhee. Obligations of parties and their lawyers in civil litigation: the ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure. In: Jen Adolphsen et al. (org.). *Festschrift für Peter Gottwald zum 70. Geburtstag*. C.H. Beck, 2014, p. 669-679; C.H. Van Rhee. *Gerenciamento de Casos (Case Management) na Europa* : Uma Abordagem Moderna da Justiça Civil. Trad. e Rev. Daine Ornelas, Hermes Zaneti Jr. e Marco Antonio Rodrigues, no prelo; Alan Uzelac. Towards European Rules of Civil Procedure: Rethinking Procedural Obligations. *Hungarian Journal of Legal Studies* , 58, n. 1, p. 3-18, 2017.

9

Sobre o direito fundamental à duração razoável do processo, cf. Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero, *Direitos fundamentais processuais*, cit., esp. p. 797-801; José Rogério Cruz e Tucci, *Tempo e processo*, São Paulo: Ed. RT, 1997; Paulo Hoffman, *Razoável duração do processo*, São Paulo: Quartier Latin, 2006; Marco Felix Jobim, *Direito à duração razoável do processo: responsabilidade civil do estado em decorrência da intempestividade processual* , São Paulo: Conceito, 2011; Eugenio Dalmotto, *Diritto alla equa riparazione per l'eccessiva durata del processo*. In: Sergio Chiarloni (coord.), *Misure acceleratorie e riparatrici contro l'irragionevole durata dei processi*, Torino: Giappichelli, 2002, p. 136-144.

10

Não se pode falar da mesma irresponsabilidade em relação ao exequente, uma vez que, por lei, sua responsabilidade pelos prejuízos causados na execução excessiva é objetiva. Art. 776 do CPC: “O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”.

11

Jorge Carreras, *El embargo de bienes*, Barcelona: Bosch, 1957, p. 6, já igualmente citado por Álvaro Pérez Ragone, *General report*, cit., p. 605.

12

Originalmente privada, a penhora, progressivamente, será limitada pela legislação e controlada pelo juiz nos países que seguiram a tradição romano-germânica clássica, tornando-se a forma típica do procedimento para expropriação e satisfação do credor nas execuções para pagamento de quantia certa e símbolo da atividade do juiz na garantia dos direitos do executado. Nas palavras de Liebman: “A penhora de autoridade privada era o ato pelo qual se conseguia coercitivamente do devedor a composição; correspondia a costume originário dos povos germânicos e somente à custa de grandes esforços se foi progressivamente restringindo pelas leis do rei (...). Primeiro limite ao exercício incondicional da penhora privada opuseram-no várias leis que prescreveram a necessidade de prévia autorização do juiz (...)”. Enrico Tullio Liebman, *Embargos do executado. Oposições de mérito no processo de execução*. Trad. J. Guimarães Menegale, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1968, p. 28 e 29. Como veremos, há na modalidade de penhora e expropriação por órgão público uma distorção, por ser caro, demorado e ineficiente, este procedimento, como procedimento exclusivo, já não corresponde a maioria dos processos de execução para pagamento de quantia certa no direito comparado. No caso do direito brasileiro continua sendo o procedimento típico e preferencial, mas deve sofrer temperamentos em razão do comportamento processual das partes e do bem jurídico (*posta in gioco*) ligado ao título executivo.

13

Michele Taruffo, A atuação executiva dos direitos: perfis comparados. In: Michele Taruffo, *Processo Civil Comparado : Ensaio* . Trad. Daniel Mitidiero, São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 85/116, esp. p. 96 e ss.

14

Hein Kötz; Konrad Zweigert, *Introduzione al Diritto Comparato. I Principi Fondamentali*. Trad. Barbara Pozzo, Milano: Giuffrè, 1998. A revalorização dos estudos de processo comparado e as novas tendências podem ser aferidas em Rolf Stürner; Christoph Kern, Processo Civil Comparado – Tendências Recentes e Fundamentais, *Revista de Processo*, vol. 200, p. 203, out./2011, com amplas referências bibliográficas.

15

Dario Ippolito, Libertà e proprietà nella teoria dei diritti di Luigi Ferrajoli, *Ragion Pratica*, n. 44, p. 131, giugno 2015, p. 133.

16

Dario Ippolito, Libertà e proprietà, cit., p. 134.

17

Luigi Ferrajoli, *Principia Iuris. Teoria del diritto*, Roma/Bari: Laterza, 2007, p. 635-638. Para as principais fontes de Ferrajoli conferir: John Locke, *Two treatises of government* (1689), 5. ed., London: A. Bettesworth, MDCCXXVIII; Idem, *A letter concerning toleration* (1689), Huddersfield: J. Brook, 1796; J. Stuart Mill, *On Liberty*, 2. ed., London: John W. Parker and Son, MDCCCLIX; Paolo Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico. Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico*, Milano: Giuffrè, 1988; Idem, *Proprietà e contratto*. In: M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari: Laterza, 2004; Stephano Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna: Il Mulino, 1981; Idem, *Libertà e Diritti in Italia dall'Unità ai Giorni Nostri*, Roma: Donzelli, 1997. Destacamos especialmente a nota em que Ferrajoli indica o desmembramento entre o direito público e o direito privado na teoria do direito alemão: “De acordo com a sua concepção como ‘elementos orgânicos’ do Estado elaborada pela juspublicística alemã e ilustrada (...) estes ‘direitos públicos’ serão concebidos por Jellinek e depois por Santi Romano como efeitos de uma ‘auto-obrigação’ do Estado (G. Jellinek, *Sistema dei diritti pubblici soggettivi*, p. 159-163). Resulta-lhe um evidente despotenciamento dos direitos de liberdade, que paradoxalmente não atinge a propriedade, a qual permanece configurada, como observou Stefano Rodotà, como “poder absoluto” – o único limite ao “outro absoluto, o poder soberano” – de acordo com a velha máxima de Portalis “ao cidadão pertence a propriedade, ao soberano o império”, sobre a qual base “compreende-se o liame instituído entre exercício dos direitos políticos e posições proprietárias.” Enquanto os demais direitos subjetivos decorrem do poder estatal, *apenas* a propriedade seria a ele oponível, Luigi Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., nota 25, p. 714, as ricas notas de Ferrajoli merecem a leitura. Atualmente o Estado existe para fins não seus, ou seja, para a tutela dos direitos fundamentais.

18

Luigi Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., p. 635/638.

19

Idem, p. 639.

20

Ricardo Arone, *Direito à Propriedade*. In: J.J. Gomes Canotilho; Gilmar Ferreira Mendes; Ingo Wolfgang Sarlet; Lenio Streck, *Comentários à constituição do Brasil*, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 233-234. Mais adiante, afirma: “A norma é imanência; não é por si só, precisando ser no mundo para ser direito positivado”.

21

Princípios idênticos regem a execução espanhola, como regra geral nos art. 239 e 570 da LEC/2000, e se apresentam como norma geral dos ordenamentos constitucionais: “If an enforcement act limits a fundamental right could be tested its adequacy and rationality (proportionality) according first to the Law of Enforcement and in a second stage under constitutionality standards” cf. Álvaro Pérez Ragone, *General report*, cit., p. 611.

22

Gesetz zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland of 21 June 2002, Federal Gazette

(Bundesgesetzblatt, BGBl.), part I, p. 2010, *apud idem*, p. 609/610.

23

Dario Ippolito, *Libertà e proprietà*, cit., p. 155.

24

Luigi Ferrajoli. *Principia Iuris*, cit. , p. 229-230.

25

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. In: Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, *Do formalismo no processo civil* , 2. ed. rev. e acrescida de apêndice, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 260-274; Hermes Zaneti Jr., *A constitucionalização do processo*, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2014; Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Curso de Processo Civil. Teoria do Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2016, vol. 1.

26

C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.), *Enforcement and enforceability. Tradition and reform*, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010; Francisco Ramos Méndez (dir.), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal* , Barcelona: Atelier, 2014; Jesús González Pérez, *El derecho a la tutela jurisdiccional* , 3. ed., Madrid: Civitas, 2001, p. 337 e ss., quanto ao cumprimento das sentenças; Raúl Núñez Ojeda; Álvaro Pérez Ragone; Macarena Vargas Pavez, *Hacia una mejor ejecución civil. Rediseño orgánico procedimental para una justicia más eficiente, transparente, justa y accesible*, Santiago: Legal Publishing Chile/Thomson Reuters, 2013, que fala do direito a uma execução efetiva como direito processual fundamental (Idem, p. 6 e ss.). Na doutrina portuguesa, Miguel Teixeira de Sousa fala de efetividade do processo de execução, de processo equitativo e do *favor creditoris* como um dos elementos da reforma da execução civil, cf. Miguel Teixeira de Sousa, *A reforma da acção executiva*, Lisboa: Lex, 2004, p. 19 e 26, porém limita o princípio diante de alguns elementos do direito fundamental do executado, claramente apontando a existência de equilíbrio entre os direitos fundamentais do exequente e do executado. No direito brasileiro, Marcelo Lima Guerra, *Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil*, São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 99 e ss.

27

Robert Alexy, *Teoria dos direitos fundamentais* , cit., p. 488; Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero. *Direitos fundamentais processuais*, cit., p. 736-803, esp. 749.

28

Assim, *Hornsby v. Greece*, § 40; *Romanczyk v. France*, § 53 (2011); *Buj v. Croatia*, § 19 (2006); *Saccoccia v. Austria* (2007).

29

Cf. Álvaro Pérez Ragone, Derecho a la tutela ejecutiva del crédito: entre mitos, temores y realidad, *Cuadernos de extensión jurídica: Justicia civil: perspectivas para una reforma en la legislación chilena*, n. 23, p. 292. Cf., ainda, para a decisão o site da própria Corte Interamericana: [http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_228_esp.pdf]. Acesso em 01.07.2016.

30

Robert Alexy. *Teoria dos direitos fundamentais*, cit., p. 488-490.

31

Álvaro Pérez Ragone, *General report*, cit., p. 604.

32

Enrico Tullio Liebman. *Processo de execução*, São Paulo: Saraiva, 1968, p. 9-13; Idem, *Embargos do executado*, cit., n. 1 e ss.; José Alberto dos Reis, *Processo de execução*, vol. I, Coimbra, 1943; Giuseppe Chiovenda, Romanesimo e germanesimo nel processo civile, *Saggi di diritto processuale Civile (1900-1930)*, Roma: Il Foro Italiano, 1930.

33

John Gillissen, *Introdução histórica ao direito*, 2. ed. Trad. A. M. Espanha e L. M. Macaísta Malheiros, Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1995, p. 76.

34

Sobre os poderes selvagens o recente livro de Luigi Ferrajoli. *Poteri selvaggi : la crisi della democrazia italiana*, Roma/Bari: Laterza, 2011. Cf, ainda, sobre o surgimento e a evolução da lógica jurídica analítica na Itália o segundo ensaio de Luigi Ferrajoli. *La cultura jurídica nell'italia del novecento*, Roma/Bari: Laterza, 1999 (já traduzido para o português, cf. Luigi Ferrajoli. *A cultura jurídica e a filosofia jurídica analítica do século XX*. Trad. Alfredo Copetti Neto; Alexandre Salim; Hermes Zaneti Júnior, São Paulo: Saraiva, 2015).

35

Além dos trabalhos já citados sobre a história da execução, sobre processo romano consultar: Max Kaser, *Direito privado romano*. Trad. Sumel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999; John Gillissen, op. cit., p. 80-99; Luiz Carlos de Azevedo; José Rogério Cruz e Tucci, *Lições de história do processo civil romano*, São Paulo: Ed. RT, 1996. É importante destacar, ainda, a descoberta em 1981 de uma série de tábuas de bronze na Espanha, contendo os textos legais de um pequeno município existente no local. Estes textos, chamados *Lex Irnitana (91 AD)* descrevem com detalhes o processo civil seguido naquela localidade que nada mais era que um espelho do processo civil romano. A partir desta descoberta, Ernest Metzger passou a desenvolver uma série de estudos analisando as novas evidências sobre o direito processual romano. Ernest Metzger, *A new outline of the roman civil trial*, USA: Oxford, 1998; Ernest Metzger, *Litigation in roman law*, USA: Oxford University Press, 2005. Sobre o período de Justiniano, Ernest Metzger (ed). *A companion to justinian's institutites*, Bristol Classical Press,

2013. Para as fontes tradicionais do processo romano, com especial destaque para as Institutas de Gaio, descobertas no início do século, e os escritos de Cícero (106 – 43 BC, especialmente, *pro Caecina* e *pro Quinctio*), cf. Ernest Metzger, An outline or roman civil procedure. *Roman Legal Tradition*, n. 9, p. 1-30, 2013. O autor também ressalta o trabalho de Aulus Gellus, publicado em espanhol, cf. Aulo Gelio, *Noches aticas*. Trad. Francisco Navarro y Calvo. Buenos Aires: EJE, 1959.

36

“Ao gênio da coisa pública faltou ao Romano juntar a evolução democrática dos Gregos e a preservação da liberdade.” (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil* , atual. legislativa de Sergio Bermudes, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, vol. 1, p. XVII. Também Max Kaser, para quem “o direito e a jurisdição penal bem como toda a administração do Estado pareciam aos Romanos ser matérias públicas, influenciadas por forças políticas e, por isso, *não sujeitas a critérios exclusivamente jurídicos* ” (Max Kaser, op. cit., p. 35). Sobre a influência da filosofia e política grega no direito, consultar John Gillissen (*Introdução histórica ao direito*, op. cit., p. 73).

37

Ernest Metzger. Actions. In: E. Metzger (ed.), *A companion to justinian's institutes*, London/Ithaca: Cornell University Press, 1998, 208-228, esp. p. 208.

38

Ernest Metzger, *An outline or roman civil procedure*, p. 9, documenta a posição de Moriz Wlassak, seguida no Brasil por Humberto Theodoro Jr., *Processo de execução e cumprimento de sentença* , 24. ed., São Paulo: Leud, 2008, p. 34, de que se tratava de um processo privado (*ordo iudiciorum privatorum*) de feição arbitral, e Max Kaser, que ressaltava o caráter público da atividade desde a fase das *legis actiones* , em especial por se tratar de um poder decorrente do rei. Atualmente, conforme salienta Metzger, as recentes descobertas da *lex Irnitana* revelam um procedimento extremamente consensual, inclusive diante de partes hostis (Idem, ibidem).

39

“Nas leis das doze tábuas se elaborou com extrema severidade um conjunto de normas referentes aos devedores. A elas se dedicou a tábua III. Ao devedor, uma vez que havia reconhecido sua dívida perante o tribunal, se lhe concediam 30 dias de tempo para recolher o dinheiro necessário para a extinção da dívida. Vencido este termo, o credor “lançava mão” [*manus iniectio*] no devedor e o levava para a execução da sentença. Se o devedor não estava em condições de cumprir a decisão do juiz e ninguém oferecia garantia por ele, o credor tinha a faculdade de levá-lo para sua casa e colocá-lo a ferros, de colocá-lo em um cepo (...) Durante o tempo em que o devedor permanecia prisioneiro, se podia se alimentava por sua própria conta; em caso contrário, o credor estava obrigado a subministrar-lhe não menos que uma libra de grão por dia. O devedor permanecia nessa situação por 60 dias. Durante o período era levado três vezes, nos dias de mercado (*nundinales*), à praça pública perante o pretor, e ali se apregoava a soma que devia. Se ninguém se responsabilizava por ele, depois do terceiro ‘nundinal’ o devedor podia ser morto ou vendido como escravo para além do Tibre [para um estrangeiro], quer dizer, fora dos limites da cidade. No caso em que os credores fossem mais de um, a lei admitia uma medida completamente bárbara: no terceiro ‘nundinal’, o devedor será cortado em pedaços. Se os pedaços resultam maiores ou menores não

importará” (Tábua III, art. 6.º)”. Aureo Yépez Castillo, *Roma*, Caracas: UCAB, 1995, p. 79. O autor deixa claro que este artigo, pelos registros históricos que se tem, não chegou a ser aplicado, porém, fica registrada a gravidade com que a questão patrimonial era tutelada em Roma e o *terror dissuasório* que se pretendia com as medidas legais, no mesmo sentido: Azevedo; Cruz e Tucci, *Lições de história do processo civil romano*, cit., p. 61.

40

Max Kaser, op. cit., p. 438.

41

Azevedo; Cruz e Tucci. *Lições de história do processo civil romano*, cit., p. 60/61. Conforme anota a doutrina a mudança não foi imediata, sobreviveu, de forma atenuada, a execução pessoal em Roma após a *Lex poetelia papiria*, cf. Ignacio M. Poveda Velasco, *A execução do devedor no direito intermédio. Beneficium Competentiae*, São Paulo: Livraria Paulista, 2002, p. 13; Idem. *A execução do devedor no direito romano*, São Paulo: Livraria Paulista, 2002.

42

Aulo Gelio, *Noches aticas*. Trad. Francisco Navarro y Calvo. Buenos Aires: EJE, 1959, p. 226.

43

Aulo Gelio, op. cit., p. 229/232.

44

Enrico Tullio Liebman, *Embargos do executado*, cit., p. 5.

45

Idem, p. 9-12.

46

Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução*, cit., p. 9; Idem, *Embargos do executado*, cit., p. 7.

47

Idem, *Processo de execução*, cit., p. 9.

49

Max Kaser, op. cit., p. 468-469.

Humberto Theodoro Jr., *Processo de execução e cumprimento de sentença*, 24. ed., São Paulo: Leud, 2008, p. 34.

Liebman, *Embargos do executado*, cit., p. 18, 26. Observação conclusiva de Liebman, apesar de reconhecer a constância da *actio iudicati* e a sua progressiva transformação e publicização no período imperial, é de que no “mundo romano não existe título executório (...) pois não era de se conceber que, a um juiz privado, correspondesse poder de exercer o que é essencial a esse conceito, a saber, a aplicação da sanção, que transfere o efeito constitutivo – processual da sentença para fora e para além das relações de direito material (...)”.

Para uma exposição ampla sobre o direito medieval, Alta Idade Média (p. 37 e ss., as origens, sécs. V a XI) e Baixa Idade Média (p. 345 e ss., o sistema do direito comum, sécs. XII a XV), cf. Francesco Calasso, *Medio evo del diritto. I° Le fonti*, Milano: Giuffrè, 1954. As fontes que mais influenciaram os povos da Península Ibérica foram as do direito visigótico, vigente neste período intermédio através do *Codex Theodosianus* (438 d.C.), do Breviário de Alarico (*Lex Romana Visigotorum*, 506 d.C.) e na sua fusão posterior que veio a ser conhecida como *Liber iudicorum*, *Forum iudicum*, *Fuoro juzgo* ou simplesmente Código Visigótico (654 d.C.), Ignacio M. Poveda Velasco. *A execução do devedor no direito intermédio*, cit., p. 15-16. A pesquisa se conclui afirmando que o *beneficium competentiae* (*condemnatio in id quod debitor facere potest*, do direito romano) compreendido como limite a condenação que reduzisse o devedor a indigência somente aparece no direito português a partir da recepção do *Corpus Iuris Civilis*, primeiro pela adoção em Portugal das Siete Partidas, depois pela adoção direta da *deductio ne egeat* (impenhorabilidade de roupas, utensílios de trabalho etc.) do próprio direito justineaneu pelas Ordenações Afonsinas (Tít. 121, Livro III), idem, p. 94-95.

Liebman, *Embargos do executado*, cit., p. 24.

Idem, p. 27.

Liebman, *Processo de execução*, cit., p. 10.

Idem, *Embargos do executado*, cit., p. 26 e ss.

Idem, p. 37.

58

Idem, p. 40.

59

Idem, p. 42.

60

Veja-se, para uma síntese, Giuseppe Chiovenda, Romanesimo e germanesimo nel processo civile [Universidade de Parma, 05 de dezembro de 1901]. In: Giuseppe Chiovenda, *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma: Il Foro Italiano, 1930. vol. 1. p. 181-224; Giuseppe Chiovenda, Roman and german elements in continental civil procedure. Trad. Robert W. Millar. In: Arthur Engelmann, *History of Continental Civil Procedure*, Boston: Little Brown and Company, 1927, p. 875 e ss.

61

A recepção dá-se como uma recepção (re)criativa, para além do processo ativo e criador de fora (direito externo). Segue-se um processo recriador, e não meramente passivo nos próprios ordenamentos internos. “Prima facie podríamos decir que ‘recepción’, desde una perspectiva puramente lingüística, significa que un primer proceso productivo ‘activo’ y creador que surge desde fuera le sigue igualmente otro proceso ‘pasivo’ y siempre recreador (...). Lo que a veces parece una mera recepción pasiva se convierte, al contemplarlo de forma más precisa en el transcurso del tiempo, en un fenómeno creativo que es justamente lo que debe ser.” (Peter Häberle, Elementos teóricos de un modelo general de recepción jurídica. In: Antonio-Henrique Perez Luño (coord.), *Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio*, Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 156).

62

Liebman, *Processo de execução*, cit., p. 11.

63

Liebman, *Embargos do executado*, cit., p. 56. A *actio* servia para os casos em que não se havia transferido a atividade executiva por delegação e para os casos em que a sentença era ilíquida (Baldo), pois servia como meio de “encaminhar o processo de liquidação” (Idem, p. 57).

64

Idem, p. 58.

65

Idem, p. 59.

66

Idem, p. 60.

67

Tullio Ascarelli, *Lezioni di Diritto Commerciale*, Milano: Giuffrè, 1955.

68

Liebman, *Embargos do executado*, cit., p. 60.

69

Idem, ibidem.

70

Idem, *Processo de execução*, cit., p. 12.

71

Consoante clássico da nossa literatura: “Define-se, a partir da corte [séculos XII e XIII], a distinção entre *dominare*, reservado à nobreza territorial, e o *regnare*, exclusivo do príncipe, embrião da futura doutrina da soberania, cujo proprietário será o rei (...). São as vésperas – vésperas de alguns séculos – do absolutismo.” (Raimundo Faoro, *Os donos do poder*: a formação do patronato político brasileiro, 3. ed. rev., Porto Alegre: Globo, 2001, p. 29).

72

Liebman, *Processo de execução*, cit., p. 12.

74

Liebman, *Processo de execução*, cit., p. 14.

75

Elisabetta Silvestri, The devil is in the details: remarks on italian enforcement procedures. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.), *Enforcement and enforceability*, cit., p. 207.

76

A reminiscência dos institutos de direito comum no CPC de 1939 foi bem apontada por Enrico Tullio Liebman. Istituti del diritto comune nel processo civile brasiliano. In: Enrico Tullio Liebman. *Problemi del Processo Civile*. Napoli: Morano, 1962, p. 490-516.

Liebman, *Processo de execução*, cit., p. 14, n. 10. Para a importância do processo francês na evolução da execução civil cf. Liebman, *Embargos do executado*, cit., p. 72 e ss. Especial atenção a função dos *Sergents du Roy* ou *Huissiers* para garantir a efetividade da execução independentemente da participação do juiz, idem, p. 76. Naquele modelo, somente mediante impugnação ou recurso o juiz tomaria conhecimento da oposição do devedor.

Joaquim Munhoz Mello. *Notas*. In: Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução*, cit., p. 14.

Alfredo Buzaid, Exposição de motivos, *Código de Processo Civil. Histórico da lei, vol. I. t. I*, Brasília: Senado Federal. Secretaria de Edições Técnicas, 1974, p. 23.

Por todos, com claras e concisas razões, entende a doutrina que: “Para este *Manual*, cabe destacar que *absolutamente nada das conquistas efetuadas pela doutrina do direito processual civil desde 1994 no que tange a este tema foi modificado pelo CPC de 2015 (...)*. Trata-se, tão somente, de uma constatação: *a de que durante todo o processo legislativo não prevaleceu nenhuma ideologia ou entendimento diverso (...)* parece ainda ser bastante para concretizar o ‘modelo constitucional do direito processual civil’, em seus três pontos nodais (...) ‘princípios-síntese’: acesso à justiça, devido processo constitucional e efetividade do direito material pelo processo (...) O mérito do CPC de 2015 no particular foi tratar da matéria de forma mais coesa, muito mais clara e bem dividida que o CPC de 1973 (...) Outro mérito (...) foi o de distinguir o *conteúdo* das sentenças que ensejam o cumprimento dos atos relativos a este cumprimento, isto é, de sua *eficácia*. Sim, porque, nada impede, muito pelo contrário, este comportamento seria o ideal, que o réu cumpra voluntariamente o que lhe foi determinado pelo magistrado, tornando *desnecessária* a etapa de cumprimento de sentença” Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de Direito Processual Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 422. Para o autor, o conteúdo das sentenças das modalidades obrigacionais de fazer, não fazer e entrega de coisa ficou corretamente alocado na parte relativa as sentenças, arts. 497 a 500, sendo a produção concreta dos efeitos daquelas decisões, segundo o autor, sua *eficácia* disciplinada na parte referente ao cumprimento das sentenças, arts. 536 e 538 (Idem, p. 396-397). Vale ainda indicar que Cássio Scarpinella Bueno afirma a existência dos deveres-poderes de condução do processo de execução pelo juiz (arts. 772 e 773), mencionando a “atipicidade dos meios executivos (art. 139, IV): ‘dever-poder geral de *efetivação*’, contudo parece limitar sua extensão ao quanto previsto nos próprios arts. 772 e 773: (i) ordenar o comparecimento das partes; (ii) advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável (Idem, respectivamente p. 591 e 526). Não dá, portanto, pelo menos em princípio, a amplitude que propomos neste trabalho ao dispositivo do art. 139, IV.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil*

82

“É possível a utilização de multa coercitiva para a obtenção de tutela ressarcitória – em geral, para toda e qualquer espécie de tutela do direito que exija pagamento de quantia para satisfação do demandante (art. 139, IV, CPC). As particularidades do caso concreto podem determinar solução desta ordem”, Idem, p. 528.

83

Cf. Michele Taruffo. A atuação executiva: perfis comparados, cit., p. 85-117, no qual Taruffo distingue entre três modelos: a) os sistemas de *common law* , voltados para a adequabilidade da execução; b) o modelo germânico, de tipos de obrigações e tipos de execução; c) o modelo francês, com a generalização das *astreintes* .

84

C.H. Van Rhee; A. Uzelac Enforcement and enforceability, cit., p. XXV/XXXII, esp. p. XXV.

85

Evidentemente que este é um exagero da doutrina para apontar a passagem de um processo pensado para as garantias da certeza, para um processo pensado para a efetividade da tutela. Não há uma predominância, mas uma concorrência dos valores: *iurisdictio in non sola notione consistit* (a jurisdição não consiste somente no conhecimento). Cf. Francisco Ramos Méndez (dir.), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Barcelona: Atelier, 2014.

86

A doutrina frisa, ainda, que a União Europeia começou a prestar mais atenção ao debate acadêmico em torno da tentativa de harmonização da legislação processual nesta matéria, muito por força do trabalho de Marcel Storme e da Storme Commission para a aproximação do processo civil na Europa. Cf. Marcel Storme, Marcel (ed.), *Rapprochement du droit judiciaire de l'Union européenne/Approximation of Judiciary Law in the European Union*. Antwerp/Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1994. A União Europeia do ponto de vista regulatório introduziu a *Order for Payment Procedure* (Regulation (EC) 1896/2006 criando a European Order for Payment Procedure, *Official Journal* 2006, L 399/1) e a *European Enforcement Order* (Regulation (EC) 805/2004 criando a European Enforcement Order for Uncontested Claims, *Official Journal* 2004, L 300/6). Não obstante os progressos regulatórios e apesar de algumas opiniões otimistas na doutrina (Xandra Kramer, Enhancing enforcing in the european union. The european order for payment procedure and its implementation in the member states, particularly in Germany, the Netherlands, and England. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and enforceability* , cit., p. 17), existem muitas críticas aos mecanismos existentes na União Europeia. Cf. Mirjan Freudenthal, Attitudes of European Union Members States towards Harmonisation of Civil Procedure. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform* , cit., p. 3 e ss; Nina Bettetto, Implementation of European Civil Procedural Regulations in the Case Law of Slovenian Courts. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*, cit., p. 103 e ss.

C.H. Van Rhee; A. Uzelac *Enforcement and Enforceability. An Introduction*. cit., p. XXV/XXXII, esp. p. XXV.

Michele Taruffo. A atuação executiva dos direitos: perfis comparados. In: Michele Taruffo. *Processo Civil Comparado*, cit., p. 85-116.

Burkhard Hess, Different enforcement structures. C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and enforceability*, cit., p. 41/63; Álvaro Perez Ragone, El modelo orgánico de la ejecución civil desjudicializada desde el punto de vista del Derecho Comparado. Mitos y realidades de la desjudicialización, *Revista de Direito de la Pontificia Universidade Católica de Valparaíso*. n. XXXVIII, p. 394-395.

Álvaro Perez Ragone, cit., p. 394/395. Também na Itália, que muito influenciou os países da península ibérica e da América Latina, o modelo é centralizado no juiz, cf. Elisabetta Silvestri. The devil is in the details: remarks on italian enforcement procedures. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*, cit.

A centralidade do Judiciário para a efetividade da tutela dos direitos começou a ser questionada na doutrina e resultou em muitas das alterações do CPC/2015, como as tutelas autocompositivas (arts. 3.º, 165 a 175, 334 e 515, § 2.º, por exemplo), o reconhecimento da arbitragem como atividade jurisdicional não estatal (art. 337, § 6.º) e uma maior abertura para a jurisdição internacional e a cooperação jurídica entre os Estados (arts. 21 e ss.). Essa característica também está ligada à noção de soberania estatal, de jurisdição como atributo de soberania e ao dogma da *jurisdictio in sola notione consistit*. Zaneti Jr., Hermes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o protocolo do Mercosul para cooperação jurisdicional em medidas cautelares: perfil de um processo transnacional para a efetividade. In: Daniel Francisco Mitidiero; Hermes Zaneti Jr., *Introdução ao estudo do processo civil*: primeiras linhas de um paradigma emergente, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004, p. 231-272.

Raúl Núñez Ojeda; Alvaro Pèrez Ragone; Macarena Vargas Pavez, op. cit., p. 183/185.

Silvestri, Elisabetta. The Devil is in The Details: Remarks on Italian Enforcement Procedures. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010, p. 207. O modelo italiano de execução é subdividido conforme o tipo de obrigação e o tipo de execução em: a) expropriação para o pagamento de quantia certa (*expropriazione* e *pignoramento*), com diversos procedimentos a depender do título judicial ou extrajudicial; b) execução em forma específica (*esecuzione in forma specifica*), cf. Besso, Chiara. *Il Processo Civile. Nozione Generale*. 2. ed.

Torino: Giappichelli , 2015, sendo regulado nos arts. 2910 e ss. do CC e no Título III do CPC italianos. A descrição da doutrina é muito clara e muito similar ao que temos no ordenamento brasileiro atual. Comentando o CPC italiano afirma Elisabetta Silvestri: “A whole book of the code (the third book) deals with enforcement of judgments and other judicial orders. That amounts to no fewer than 150 articles of the code, to which one must add several statutes governing the so-called special enforcement procedures, such as the ones belonging to the state or public bodies, the attachment of ships or aircraft, and the like: from this list you can already understand that enforcement procedures are real legal maze, in which even a skilled lawyer can easily get lost”, SILVESTRI, Elisabetta. *The Devil is in The Details: Remarks on Italian Enforcement Procedures* , p. 207. Por força do excesso de procedimentalismo a autora afirma que o processo de execução italiano é longo e incômodo, altamente custoso, e que os muitos detalhes levam à ineficiência e à falha, o que na efetivação do direito que se espera dos processos executivos equivale a denegação de justiça.

95

A tendência mundial é a introdução de um modelo liberal de intervenção judicial moderada, no qual oficiais de execução organizados em instituições privadas ou mistas dediquem-se à atividade executiva com eventual controle judicial sobre excessos e medidas cautelares constritivas de caráter extraordinário. C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and enforceability. Tradition and reform* , cit.

96

Marcelo Lima Guerra, *Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil*, São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 102-103.

97

Idem, p. 103-104; Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira, *Curso de Direito Processual Civil. Execução*, vol. 5, 6. ed., Salvador: Juspodivm, 2014, p. 46.

98

“Partir da premissa de que existe um *direito fundamental à tutela executiva* é indispensável para a solução de diversos problemas oriundos do procedimento executivo, principalmente aqueles relacionados à aplicação das regras de proteção do executado, como as hipóteses de impenhorabilidade” (Idem, p. 46).

99

“Conforme Hegel (v. *hegelianismo*), a natureza verdadeira e única da razão e do ser que são identificados um ao outro e se definem segundo o processo racional que procede pela união incessante de contrários — *tese* e *antítese* — numa categoria superior, a *síntese* .” Dicionário Aurélio Eletrônico. Sobre o novo modelo de Estado, cf. o cap. 3 de Hermes Zaneti Jr., *A constitucionalização do processo*, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2014.

100

Por todos, Norberto Bobbio, *A Era dos Direitos* . Trad. Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro: Campus,

101

Luigi Ferrajoli. *A democracia através dos direitos. O constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político*. Trad. Alexander Araujo de Souza; Alexandre Salim; Alfredo Copetti Neto; André Karam Trindade; Hermes Zaneti Júnior; Leonardo Menin, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 35, 188.

102

Com destaque para o Ministério Público brasileiro que nas ações coletivas exerce o relevante papel de *advogado do povo*, em verdadeira função promocional dos direitos coletivos *lato sensu*.

103

Perceba-se que não eram verdadeiras cautelares, como cansou de afirmar a boa doutrina, por estar presente o requisito da satisfação do direito pleiteado. Tratava-se, em verdade, de tutelas preventivas autônomas ou de meras antecipações de efeitos da tutela principal, requeridas como cautelar.

104

O processo de execução admite a impugnação por meio de exceção de pré-executividade (cf. Danilo Knijnik, *A exceção de pré-executividade*, Rio de Janeiro: Forense, 2000) nos termos previstos no art. 803, elencando as hipóteses de nulidade da execução, pelo qual não haverá necessidade de oposição de embargos do executado.

105

Loïc Cadiet, Introduction to french civil justice system and civil procedural law, *Ritsumeikan Law Review*, n. 28, 2011, p. 331-393.

106

Luís Augusto Fischer, *Dicionário de palavras e expressões estrangeiras*, Porto Alegre: LPM, 2004, p. 185.

107

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Curso de Direito Processual*, vol. I, p. 703.

108

O problema da generalização da abstração dos títulos executivos de pagar quantia certa é central na teoria da execução. A doutrina, justamente preocupada em diluir a autonomia entre cognição e execução, afirma que “(...) a fundamentação teórica para a autonomia executória das cambiais acabou justificando, de outra perspectiva, a autonomia da ação de execução de sentença condenatória (...) A necessidade de outorgar aos títulos negociais uma ação de execução, sem prévio processo de cognição, exerceu papel decisivo para

a autonomia da ação de execução (...) A influência do racionalismo foi talvez mais decisiva para este resultado (...) A influência das filosofias racionalistas dos séculos XVII e XVIII sobre o direito, e especialmente sobre o processo civil, além do que ficou dito antes (...) foi mais notável ainda por haver determinado duas consequências decisivas e inteiramente dominantes na ciência moderna: (a) o confinamento dos juristas no ‘mundo jurídico’, um mundo conceitual puro, criado pelos próprios juristas, que os eliminou do mundo social, fazendo com que o direito se distanciasse, cada vez mais, da cambiante realidade histórica que lhe cabia regular; (b) a separação entre moral e direito, determinada pela filosofia kantiana, assegurou e fortaleceu a alienação dos juristas, com relação aos problemas sociais e políticos de seu tempo, e contribuiu para mantê-los na servil condição de executores da lei do Estado”. Ovídio Baptista da Silva, *Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica*, p. 152 e 154-155. Analisando o problema sob o prisma das defesas oponíveis e da necessidade de instrumentalizar o título com informações que dele não constam originariamente para fins de execução, defende a doutrina que “[e]ssas características dos títulos de crédito exerceram influência, primeiro, na concepção dos títulos executivos extrajudiciais e, depois, de todos os títulos executivos, em face do tratamento unificado que lhes foi conferido. De fato, o título executivo em geral passou a ser visto como autônomo em face da relação jurídica de direito material nele espelhada, o que representa equívoco manifesto”. Heitor Sica, *Cognição e execução no sistema de tutela jurisdicional civil brasileiro*, p. 218-219 (Tese de Livre Docência). Para o livro, cf. SICA, Heitor Vitor Mendonça. *Cognição do Juiz na Execução Civil*. São Paulo: RT, 2017.

109

Norberto Bobbio, op. cit., p. 24.

110

Luiz Guilherme Marinoni esclarece que *este princípio está ligado à universalização da tutela condenatória* e aponta o seu desenvolvimento a partir da doutrina italiana (Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória: Tutela individual e coletiva*, São Paulo: Ed. RT, 1992, p. 283-312). Consultar na doutrina italiana, especialmente, Sergio Chiarloni, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano: Giuffrè, 1980 (com edição em espanhol, Sergio Chiarloni, *Medidas coercitivas y tutela de los derechos*. Trad. Lima: Palestra, 2005); Salvatore Mazzamuto, *L'attuazione degli obblighi di fare*, Napoli: Jovene, 1978, entre outros. Para consulta do latim, Gilberto Caldas. *O latim no direito*, 2. ed., São Paulo: Brasiliense, 1985.

111

No texto de Chiovenda, “ *il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi há um diritto tutto quello e proprio quello ch’egli há diritto di conseguire .*” Giuseppe Chiovenda. *Dell’azione nascente dal contratto preliminare*. In: Giuseppe Chiovenda. *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, Milano: Giuffrè, 1993, vol. 1, p. 110.

112

O processo histórico pelo qual a *obligatio* romana absorveu os interditos e a *vindicatio*, assumindo o domínio absoluto dos direitos, pretensões e ações no direito moderno pode ser consultado em Ovídio A. Baptista da Silva, op. cit. A doutrina, por outro lado, descreve bem a pretensão obrigacional: “Em uma relação obrigacional, tem-se os seguintes elementos: crédito (credor), débito (devedor), vínculo que os une (a relação), o objeto (mediato – o bem devido) e o objeto imediato (a prestação a ser realizada). Uma vez

descumprida a obrigação, o credor pode então ‘exigir’ o seu cumprimento. Não cumprida essa exigência, certamente diante dessa crise jurídica só há um caminho para o credor: buscar a tutela jurisdicional”, Marcelo Abelha. *Manual da execução civil*, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 35.

113

“Existe hoje, no sistema processual brasileiro, uma relativização da separação processual das atividades de cognição e execução. Essa dicotomia, outrora fundamental na operação do sistema processual, mostra-se enfraquecida pelos novos problemas colocados ao direito e pelas novas estratégias adotadas pelo legislador nacional para a modernização do processo”. Carlos Alberto Salles. *Execução judicial em matéria ambiental*, São Paulo: Ed. RT, 1998, p. 236-237.

114

Nesse sentido, insta observar ainda: “as prestações específicas, especialmente as preventivas, ou as ressarcitórias na forma específica, são fundamentais para a tutela adequada e efetiva dos direitos massificados. Considerando a indisponibilidade que se encontra presente nos direitos massificados, especialmente os difusos, a conversão de obrigações específicas em genéricas somente é adequada, no plano da tutela coletiva, quando se tornar impossível a realização da tutela na sua forma específica”. Gregório Assagra de Almeida, Execução coletiva em relação aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos: algumas considerações reflexivas. Mirna Ciani e Rita Quartieri (coord.), *Temas atuais de execução civil*: estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 316. No mesmo sentido, reforçando o papel da tutela executiva indireta, com meios de coerção, cf. Elton Venturi. *Execução da tutela coletiva*, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 160.

115

Heitor Sica, op. cit., p. 331; SICA, Heitor Vitor Mendonça. *Cognição do Juiz na Execução Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2017.

116

Marcelo Abelha, op. cit., p. 70.

117

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 736. Nesse sentido, STJ, 4.^a Turma, REsp 39.296/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 11.06.1996, DJ 12.08.1996, p. 27.487.

118

Para a evolução do direito processual civil francês e a compreensão do *Code du Procédure Civile* de 1975, que também possui uma parte geral, tendo inspirado a solução brasileira, cf. Loïc Cadiet, op. cit., p. 331-393, que afirma: “[i]t is not excessive to say that the new Code of Civil Procedure is a doctrinal code. The overall idea of civil litigation is shown directly in the core of the twenty-four Articles of the Code. These Articles constitute the first Chapter, on Guiding Procedural Principles” (p. 345). E mais, é preciso se dar

conta da historicidade destes princípios de direito processual (Robert Wyness Millar, *The formative principles*, cit., p. 3-81 (Continental Legal History Series, vol. VII); Robert Wyness Millar, *Los principios formativos del procedimiento civil*. Trad. Catalina Grossmann. Prólogo de Eduardo J. Couture. Buenos Aires: Ediar, 1945) e da característica de servirem tanto ao processo inquisitivo (*inquisitorial*), quanto ao processo dispositivo (*adversarial*). No Estado Democrático Constitucional, há necessidade de dosagem e equilíbrio entre ambas as tendências, em uma composição e em coordenação. No mesmo sentido deve ser interpretado o *Code* francês, pois a doutrina salienta que: “[t]he Code is essentially a work in composition, neither adversarial nor inquisitorial; these qualifications do not suit what civil litigation fundamentally is. It is a work in composition, because it must conciliate the liberal principles of French tradition which make parties the owners of the lawsuit, and the affirmation of the powers of the judge, who must – as a procedural mandate – realize his mission to achieve the fairest solution to the dispute, which is in the general interest. Justice is a public service and impartiality is not passivity. In fact, it is justified to say that Articles 1 to 13 of the new Code define a genuine principle of co-operation between the judge and the parties in the elaboration of the judgment. This is, of course, the aim of civil procedure. This doctrine is not the fruit of a spontaneous generation, issued to satisfy some academic satisfaction. As we see, the Guiding Procedural Principles, and the conception of civil litigation that they convey, have a long history” (Loïc Cadiet, op. cit., p. 349).

119

Isso não impede que, nas ações preponderantemente declaratórias ou constitutivas, haja outras eficácias sentençiais, outras tutelas processuais sejam concedidas e, conforme o caso, dependam de atividade executiva. Isso explica por que cabe o pedido de tutelas antecipatórias em ações declaratórias ou constitutivas, pois o que se antecipa não é a eficácia normativa, mas as eficácias condenatória, executiva *lato sensu* e mandamental – estas que se dão no mundo dos fatos. Estas, nestes casos, decorrem ou são conectadas às eficácias declaratória ou constitutiva, que, possuindo caráter normativo, não exigem desdobramento no mundo dos fatos para a sua efetividade. A sentença que constitui a propriedade por usucapião e a sentença que determina a interdição reconhecendo a incapacidade são constitutivas e não dependem da averbação nos registros cartorários para fazerem efeito, mas a ordem para a averbação é mandamental e desdobra-se em ação no mundo dos fatos.

120

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 665. A mesma doutrina indica que esta noção já era defendida no direito italiano por Crisanto Mandrioli, *L'azione esecutiva*, p. 310 (“Nelle sentenze di mero accertamento e nelle sentenze costitutive la tutela giurisdizionale si esaurisce fruttuosamente, mentre nella sentenza di condanna si esaurisce soltanto una fase di quella tutela”) e Cristina Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria*, Padova: Cedam, 1987, p. 231 e ss.

121

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 306; Daniel Mitidiero Francisco. *Antecipação da tutela*, cit.

122

Nesses termos, o enunciado n. 12 do FPPC: “A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1.º, I e II”.

123

Esta ainda é a doutrina dominante, contudo, cabe uma observação, que poderá ensejar teses a serem desenvolvidas posteriormente. Ao reconhecermos a atipicidade da execução em razão da necessidade de adequação e efetividade (art. 4.º c/c art.139, IV), podemos imaginar a modificação do procedimento executivo para atender a estes princípios. Portanto, não seria irrazoável entender que, em determinadas situações, o exequente poderia, *justificadamente*, utilizar um mesmo procedimento atípico para atender as obrigações de natureza diversa, mesmo que os procedimentos típicos fossem diversos, em homenagem a adequação e à efetividade. Por exemplo, para satisfazer duas obrigações constantes de um título executivo extrajudicial, uma de fazer e a outra de pagar quantia, poderia propor – caso presentes os requisitos – uma execução cumulando ambas as obrigações e solicitando a determinação de *astreintes* para compelir ao adimplemento de ambas.

124

Nesse sentido, Araken de Assis, *Manual da execução*, São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 101. No Brasil, o artigo que inaugura esta tendência é justamente o seminal art. 84, § 5.º, do CDC.

125

Em sentido contrário, com argumentos razoáveis, mas descolados do problema, cf. Idem, p. 99-100.

126

Na doutrina, expressamente afirmando a responsabilidade patrimonial como exclusiva: “A atividade executiva é essencialmente patrimonial. Significa isto dizer que os atos executivos incidem sobre bens do executado, e não sobre seu corpo (com a única exceção da prisão civil do devedor de alimentos, constitucionalmente autorizada). Impende, então, compreender qual a parcela do patrimônio do executado que pode ser alcançada pela execução”. Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 337. A regra é tão forte que o art. 797, CPC, “à guisa de indicar a finalidade de toda e qualquer execução, independentemente de sua modalidade obrigacional, acaba indicando a finalidade da execução por quantia certa”. Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de Direito Processual Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 550.

127

Para um panorama geral sobre o tema da justiça multiportas e da autocomposição cf. ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier (coord.). *Justiça Multiportas*. Mediação, Conciliação, Arbitragem e outros meios adequados de solução de conflitos. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018.

128

Na doutrina comparada, observando a emergência do problema, C.H. Van Rhee; A. Uzelac, *Enforcement and Enforceability. An Introduction*, p. XXVI; Rob Jagtenberg; Annie Roo. *Enforcing Mediated Settlements in Europe*. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.), *Enforcement and enforceability. Tradition and reform*, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010, p. 271-290. Como registra a doutrina: “While in the early days of Council of Europe recommendations on various forms of mediation the principal issue was to cater for the needs of the users (by fostering mediation as an informal, friendly method of dispute resolution supplementing formal courts procedures), the *current trends*, expressed clearly in the EU Mediation Directive [Directive 2008/52/EC on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters, *Official Journal* 2008, L 136/3], see mediation primarily as a means to reduce the excessive workload of courts. Such a change of perspective (from bottom-up to top-down) leads to a strong urge for finality and enforceability of settlements” (C.H. Van Rhee; A. Uzelac, p. XXVI). A homologação da autocomposição extrajudicial também serve como instrumento para dar mais efetividade ao seu conteúdo, em caso de inadimplemento espontâneo (Idem, ibidem), contudo a homologação pode representar um problema para o próprio Poder Judiciário, visto que, na perspectiva atual de abordagem, a autocomposição também é uma forma de reduzir a sobrecarga da justiça estatal. Nesse caso, uma alternativa possível seria que a homologação ocorresse por um notário ou outro agente público (Rob Jagtenberg; Annie Roo. *Enforcing Mediated Settlements in Europe*, p. 287). No Brasil, muito embora não possam homologar a autocomposição, de forma a que essa se estabilize como título judicial, o CPC prevê que o instrumento de transação (autocomposição) referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores (daqueles que realizarem a autocomposição) ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal será considerado título executivo extrajudicial, possuindo força executiva (art. 784, IV, CPC).

129

A terminologia doutrina oscila entre negócios, acordos ou convenções. Optaremos por negócios processuais, por agora. Cf. Fredie Didier Jr., *Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 376; Antônio do Passo Cabral, *Convenções Processuais*, Salvador: Juspodivm, 2016; Fredie Didier Jr.; Pedro Henrique Pedrosa Nogueira; Antonio do Passo Cabral, *Negócios Processuais*, 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2016 (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, vol. 1); Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, *Negócios Jurídicos Processuais*, Salvador: Juspodivm, 2016.

130

Nos termos do CPC: Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único: De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

131

Assim redigido: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

A outros negócios processuais típicos que podem ser cabíveis na execução, muito embora não visem primacialmente a atividade executiva. A doutrina considera negócios típicos: a eleição negocial do foro (art. 63, CPC); o negócio tácito decorrente da tramitação da causa em juízo relativamente incompetente (art. 65, CPC); o calendário processual (art. 191, §§ 1.º e 2.º, CPC); a renúncia ao prazo (art. 225, CPC), o acordo para suspensão do processo (art. 313, II, CPC); o saneamento compartilhado (art. 357, § 3.º, CPC); o adiamento consensual da audiência (art. 362, I, CPC); a convenção sobre o ônus da prova (art. 373, §§ 3.º e 4.º, CPC), a escolha consensual do perito (art. 471, CPC); a escolha do arbitramento como técnica de liquidação (art. 509, I, CPC); a desistência do recurso (art. 999, CPC), entre outros. Fredie Didier Jr., *Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 377.

“Um bom exemplo de negócio processual atípico celebrado pelas partes e pelo juiz é a execução negociada de sentença que determina a implantação de política pública”. Idem, p. 381 e 383. Sobre execução negociada, cf. Eduardo José da Fonseca Costa, A “execução negociada” de políticas públicas em juízo, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, n. 212, 2012; Fredie Didier Jr.; Hermes Zaneti Jr., *Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 448/449.

O tema não é pacífico na doutrina, mas existem muitas vozes favoráveis e já começam a surgir entendimentos jurisprudenciais neste sentido. Cf. Eduardo Talamini; Marcos Youji Minani (coord.). *Medidas Executivas Atípicas*. Salvador: Juspodivm, 2018 (Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Coordenador geral: Fredie Didier Jr.), com amplas referências e posicionamentos favoráveis e contrários. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria, admitindo a retenção da carteira nacional de habilitação (CNH) e, eventualmente, a retenção de passaporte, desde que adequadamente fundamentada a medida, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o STJ entendeu que essa razoabilidade em relação ao passaporte não havia sido demonstrada, mas que a retenção da carteira de habilitação não ofendia o direito de ir e vir do paciente. Nos termos do voto do Min. Relator, em relação ao passaporte, afirmou: “A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência”. Cf. RHC 97.876/SP, STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Michele Taruffo. A atuação executiva dos direitos, cit., p. 85-116.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 529 (g.n.).

O Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, reforçando esta conclusão, afirmou no enunciado n. 12, por votação unânime, que: “A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em

qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1.º, I e II”. As mesmas ideias foram seguidas pelo enunciado n. 48 da Enfam, ao afirmar que: “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”.

138

Para a *execution parée* não é tão importante a existência de um novo processo, quanto é o reconhecimento das mesmas garantias processuais à tutela do crédito. Não era correto o entendimento de Alfredo Buzaid de que seria mais certa a nova citação do devedor e formação de novo processo (Alfredo Buzaid, Exposição de motivos. In: *Código de Processo Civil. Histórico da Lei*, vol. I. t. I, Brasília: Senado Federal. Secretaria de Edições Técnicas, 1974, p. 23). Aparelhar a execução e considerar ambas atividades executivas (execução de título judicial e extrajudicial) equiparadas não exige que o processo de execução seja autônomo.

139

Conferir as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos: *Hornsby v. Greece*, § 40; *Romanczyk v. France*, § 53 (2011); *Buj v. Croatia*, § 19 (2006); *Saccoccia v. Austria* (2007). Para a Corte Interamericana: *Mejía v. Ecuador*.

140

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 529.

141

Sobre a teoria dos precedentes e a sua aplicação também ao direito processual cf. Hermes Zaneti Jr., Hermes, *O valor vinculante dos precedentes*, 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2016, com amplas referências bibliográficas.

142

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 529.

143

Michele Taruffo, A atuação executiva dos direitos, cit., p. 96 e ss.

144

Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira. *Curso de*

Direito Processual Civil , cit., p. 46. No mesmo sentido, servindo de base para a construção doutrinária, cf. Luiz Guilherme Marinoni. *Técnica processual e tutela dos direitos*, cit., p. 43. É de se registrar as referências das quais parte Luiz Guilherme Marinoni para demonstrar que foi a *doutrina italiana* que associou a *condenação aos meios executivos tipificados em lei* (como já vimos, partindo das premissas da doutrina alemã); a mesma doutrina elegeu o *elogio da forma* como a garantia de liberdade e segurança psicológica do devedor, sendo nestes termos a mesma doutrina e ideologia que foi transposta para o direito brasileiro, cf. Crisanto Mandrioli. *L'azione esecutiva* , cit.; Idem, L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, *Rivista di Diritto Processuale* , 1975 , p. 23; Vittorio Denti, Il processo di cognizione nella storia delle riforme, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile* , 1993, p. 808; Giuseppe Chiovenda, Le forme nella difesa giudiziale del diritto [1901]. In: Giuseppe Chiovenda, *Saggi di Diritto Processuale Civile* , vol. I, Giuffrè: Milano, 1993, p. 353 e ss.

145

Luiz Guilherme Marinoni. Controle do Poder Executivo do Juiz. *Execução Civil: Estudos em Homenagem ao Professor Paulo Furtado* . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 225.

146

Idem, p. 231; Fredie Didier Jr.; Hermes Zaneti Jr., *Curso de Direito Processual Civil* , cit., p. 48.

147

Marcelo Lima Guerra, op. cit., p. 152.

148

Fredie Didier Jr.; Hermes Zaneti Jr., *Curso de Direito Processual Civil* , cit., p. 49.

149

Sobre o princípio da menor onerosidade possível a doutrina afirma: “(...) a opção pelo meio menos gravoso pressupõe que os diversos meios considerados sejam igualmente eficazes” Barbosa Moreira, José Carlos. *Tendências na Execução de Sentença e Ordens Judiciais*, p. 221. No mesmo sentido Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado* , cit.; Fredie Didier Jr.; Hermes Zaneti Jr., *Curso de Direito Processual Civil* , cit., p. 54.

150

Fredie Didier Jr.; Hermes Zaneti Jr., *Curso de Direito Processual Civil* , cit., p. 57.

151

Daniel Amorim Assumpção Neves, *Manual de direito processual civil*, 8. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 986-987; Alexandre Freitas Câmara, Novo CPC ampliou sobremaneira os poderes do juiz, *Consultor Jurídico*. Disponível em: [www.conjur.com.br/2016-jun-23/alexandre-freitas-camara-cpc-ampliou-poderes-juiz#sdfootnote2sym]. Acesso em: 08.08.2016; Fernando Gajardoni, A revolução silenciosa da execução por

quantia, *Jota*. Disponível em: [http://jota.uol.com.br/a-revolucao-silenciosa-da-execucao-por-quantia]. Acesso em: 08.08.2016.

152

Daniel Amorim Assumpção Neves. *Manual de direito processual civil*, op. cit., p. 987.

153

Estes critérios, por sua vez, são citados por Fernando Gajardoni, A revolução silenciosa da execução por quantia, op. cit.

154

Previsto para os tribunais, mas neste caso válido também para o juiz.

155

Hermes Zaneti Jr., *A constitucionalização do processo: o modelo constitucional da justiça brasileira e as relações entre processo e Constituição*, cit., p. 179-184.

156

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, O juiz e o princípio do contraditório, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, ano 18, n. 71, p. 31-38, jul./set. 1993; Idem, A garantia do contraditório, *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*, vol. 15, p. 7-20, 1998; Antonio do Passo Cabral, Il principio del contraddittorio come diritto d'influenza e dovere di dibattito, *Rivista di Diritto Processuale*, anno 60, n. 2, p. 449-463, apr./giu. 2005; Dierle José Coelho Nunes, O princípio do contraditório: uma garantia de influência e de não surpresa In: Fredie Didier Jr.; Eduardo Ferreira Jordão (org.). *Teoria do processo. Panorama doutrinário mundial*, Salvador: JusPodivm, 2008, p. 151-174; Daniel Mitidiero. *Colaboração no processo civil. Pressupostos sociais, lógicos e éticos*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011; Fredie Didier Jr., *Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil português*, Coimbra: Coimbra Editora, 2010.

157

A distinção lógico-argumentativa entre justificação interna e externa foi originalmente desenvolvida por Józef Wroblewski, Legal decision and its justification, *Logique et Analyse*, n. 53-54, p. 409-419, 1971. Posteriormente, foi acatada às teorias da argumentação contemporâneas, cf. Robert Alexy, *Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica*. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 219-278; Michele Taruffo. *A motivação da sentença civil*. Trad. Daniel Mitidiero, Rafael Abreu e Vitor de Paula Ramos, São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 234-247; Riccardo Guastini, *Interpretare ed argumentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 354-356; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007. No Brasil, cf. Hermes Zaneti Jr., *O valor vinculante dos precedentes*, p. 134-140; além de Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, cit., p. 84-90.

158

“Os problemas ligados à justificação interna têm sido amplamente discutidos sob o nome ‘silogismo jurídico’”. (Robert Alexy, *Teoria da argumentação jurídica*, cit., p. 219).

159

Jérzy Wroblewski, op. cit., p. 412.

160

Idem, ibidem.

161

Robert Alexy, *Teoria da argumentação jurídica*, cit., p. 228.

162

Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, cit., p. 165.

163

Nesse sentido, The decision in question is internally justified if the inferences are valid and the soundness of the premisses is not tested. [...] External justification of legal decision tests not only the validity of inferences, but also the soundness of premisses”, cf. Jérzy Wroblewski, op. cit., p. 412.

164

Sobre a teoria dos precedentes e a sua aplicação também ao direito processual cf. Hermes Zaneti Jr., *O Valor Vinculante dos Precedentes*, cit., com amplas referências bibliográficas.

165

IV FPPC-BH Enunciado n. 319 – (art. 927). Os fundamentos não adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão julgador não possuem efeito de precedente vinculante. (Grupo: Precedentes). O voto vencido não se confunde com o *obiter dictum*. No CPC/2015 o voto vencido integra o acórdão para todos os fins, inclusive para fins de pré-questionamento (art. 941, § 3.º). Teoria dos fundamentos não ratificados ou não aprovados pelo órgão colegiado, os quais, não sendo determinantes para a conclusão final por terem adoção parcial, não expressam o entendimento da corte, não tendo força vinculante. Sobre o problema da colegialidade, ver Luiz Guilherme Marinoni, *Julgamento nas Cortes Supremas*, cit.

166

Sobre a *ratio decidendi*, na doutrina do *Common Law*, ver Eugene Wambough, *The Study of Cases*, 2. ed., Boston: Little Brown and Company, 1894, p. 17; Arthur L. Goodhart, Determining the ratio decidendi of a case, cit., p. 161/183, Dec/1930; Rupert Cross; J. W Harris, *Precedent in english law*, New York: Oxford

University Press, 1991, p. 77; Maccormick, *Rethoric and the Rule of Law, A theory of legal reasoning*, New York: Oxford University Press, 2005, p. 209; Neil Duxbury, *The nature and authority of precedent*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 77.

167

Sobre o problema principal da identificação das similaridades entre as categorias de fatos que podem ser albergadas sobre um mesmo precedente, conferir, na doutrina do Common Law, Frederick Schauer, *Thinking like a lawyer. A new introduction to legal reasoning*, Cambridge: Harvard University Press, 2009, § 3.4. Para Schauer, muito embora as categorias sejam desenhadas como relevantes a partir do direito, existe uma grande influência das categorias reais (do mundo) nesta definição, esta influência será maior ou menor dependendo da matéria e da existência de uma base legal para a identificação da categoria que não decorra do precedente. No *civil law* geralmente estamos acostumados a identificação das categorias relevantes a partir do direito legislado: “Assim, incumbe ao julgador do caso-atual demonstrar ‘(...) fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor solução jurídica diversa”. A questão é de fundamental importância, por exemplo, no julgamento dos casos repetitivos, nos quais o CPC determina a verificação pelo tribunal de todos os argumentos favoráveis e contrários à tese jurídica discutida (art. 984, § 2.º, e art. 1.038, § 3.º). (Hermes Zaneti Jr., *O valor vinculante dos precedentes*, cit., p. 355).

168

“Such a doctrine should be overruled if, but only if, the advantages of making the legal socially congruent and systemically consistent outweigh the costs of not serving the values that underlie doctrinal stability and stare decisis”. Cf. Melvin Aron Eisenberg, *The nature of the common law*, Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 122; na doutrina brasileira, Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, cit., p. 251-260; Ravi Peixoto, *Superação do precedente e segurança jurídica*, Salvador: Juspodivm, 2015. Vale ressaltar que apenas os tribunais que formaram o precedente é que poderão proceder à sua revisão, sob pena de ruína do modelo de precedentes e o efeito vinculante que essencialmente lhe subjaz: “Os precedentes não são imutáveis, podem, portanto, ser modificados, alterados, superados pelo tribunal que os estabeleceu ou por tribunal superior (art. 489, § 1.º, VI; art. 927, §§ 2.º e 4.º). O tribunal ou juiz que não possui hierarquia para superar o precedente deverá aplicá-lo com a ressalva de seu entendimento pessoal, possibilitando a parte que recorra da decisão (v.g., art. 941, § 3.º)”. (Hermes Zaneti Jr., *O valor vinculante dos precedentes*, cit., p. 355). Além do *overruling*, a doutrina distingue também o *overriding* (superação parcial do precedente) e o *reversal* (reforma do precedente), cf. Fredie Didier Jr.; Paula Sarno Braga; Rafael Oliveira, *Curso de direito processual civil*, cit., p. 494-508; Celso de Albuquerque Silva, *Do efeito vinculante : sua legitimação e aplicação*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 297; Marcelo Alves Dias de Souza, *Do precedente judicial à súmula vinculante*, Curitiba: Juruá, 2007, p. 153.

169

Hermes Zaneti Jr., *Precedentes normativos formalmente vinculantes*, cit.; Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr.; Lucas Buril de Macêdo, *Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes*, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2015, p. 407-425.

170

Leonardo Carneiro da Cunha, Comentários ao art. 910. In: Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1174.

171

Conferir a Portaria n. 502/2015 da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional que dispõe sobre atuação contenciosa judicial e administrativa dos Procuradores da Fazenda Nacional, ficando dispensada a defesa da Fazenda Pública quando a tese for contrária aos precedentes normativos formalmente vinculantes do CPC/2015.

172

Gregório Assagra de Almeida, *Execução coletiva em relação aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos*: algumas considerações reflexivas, p. 289.

173

Consoante Gregorio Assagra de Almeida bem delineou. Idem, p. 289.

174

Sobre a execução no processo coletivo e a aplicação do CPC ao processo coletivo como um todo cf. Fredie Didier Jr.; Hermes Zaneti Jr., *Curso de Direito Processual Civil*, cit.

175

STJ-REsp 510.150/MA, 1.^a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 17.02.2004, *DJU*, 29.03.2004, p. 173.

176

Sobre os negócios processuais, acordos processuais ou convenções processuais cf. Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, Salvador: Juspodivm, 2015; Nogueira, Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, *Negócios jurídicos processuais*, Salvador: Juspodivm, 2016; Fredie Didier Jr.; Antonio do Passo Cabral; Pedro Henrique Pedrosa Nogueira (coord.), *Negócios Processuais*, Salvador: Juspodivm, 2016 (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, vol. 1).

177

Essa proposta já iniciara com o Projeto Florença, visando ao deslocamento da visão do processo centrado nos atores processuais para os consumidores da justiça. Cf. Mauro Cappelletti; Bryant Garth. *Acesso à Justiça*. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988; Mauro Cappelletti. *Acesso à Justiça: Conclusão de um Projeto Internacional de Investigação Jurídico-Sociológica*. In: Idem, *Processo, Ideologias e Sociedade*, vol. II. Trad. Hermes Zaneti Jr., Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2010.

178

Cf., ampla seleção de textos, favoráveis e contrários, limitando ou ampliando a tipicidade flexível

decorrente deste dispositivo legal, a coletânea Eduardo Talamini; Marcos Youji Minani. *Medidas Executivas Atípicas*. Salvador: Juspodivm, 2018.

5

Execução singular para pagamento de quantia não se confunde com os processos de insolvência ou falência (execuções universais para satisfação de todos os credores com relação a um mesmo devedor). Muito embora exista certa interconexão, há, nos processos para execução universal, uma diferença significativa no que diz com a concorrência de créditos e com o trabalho para estabelecer preferências entre créditos de origem distinta, bem como com a equiparação entre credores da mesma espécie. Há ainda outra distinção significativa em razão da necessidade de se preocupar com a dicotomia de interesses entre a proteção do devedor ou de seus credores e a preservação dos empregos. Álvaro Pérez Ragone. *General report. The conflicts between the fundamental rights of the creditor and the debtor*. International Association of Procedural Law – IAPL – Seoul Conference, 2014, *passim*.

48

Idem, *Embargos do executado*, cit., p. 18.

73

É de se observar que a codificação processual teve uma nova cisão, a Constituição de 1891 autorizou os códigos processuais estaduais. Além dos códigos estaduais há de se referir a Consolidação de José Higino Duarte Pereira, que regulou a matéria processual na Justiça Federal. Sobre o tema e seus desdobramentos, conferir o estudo de Rodrigo Mazzei, Código de Processo Civil do Espírito Santo: breve notícia histórica, *Código de Processo Civil do Espírito Santo. Texto Legal e Breve Notícia Histórica*, Vila Velha: Eppur Si Muove, 2014, p. 7-18.

94

Estes oficiais de execução são adotados em muitos países europeus. Na França os *Huissiers de Justice*, uma das instituições mais ativas e respeitadas na Europa, têm o monopólio da execução e seus honorários são pagos pelo devedor de acordo com uma tabela de tarifas previamente estabelecida. Raúl Núñez Ojeda; Alvaro Pérez Ragone; Macarena Vargas Pavez, op. cit., p. 183-185. Conferir, sobre os *Huissiers* e sobre os *Bailiffs*, M. Chardon, How to Implement Common Standards of Enforcement Law? In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*, cit., p. 113/124; Idem, Training Judicial Officers in France. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*, cit., p. 155/160; C.H. Van Rhee. The History of the ‘Huissier de Justice’ in the Low Countries. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and enforceability. Tradition and Reform*, cit., p. 161-178; A.W. Jongbloed, The dutch court bailiffs act eight years after its Introduction. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and enforceability. Tradition and reform*, cit., p. 179-206; Burkhard Hess, Different enforcement structures. In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and enforceability. Tradition and reform*, cit., p. 41/63. É de se falar também do modelo dos países em transição, na passagem dos ordenamentos socialistas para o modelo capitalista de mercado, cf. Alan Uzelac, *Privatization of enforcement services. A step forward for countries in transition?* In: C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.). *Enforcement and enforceability. Tradition and reform*, cit.

Capítulo IV. Da Execução por Quantia Certa

¹

*Seção I - Disposições gerais*²

Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais.

1. Execução por quantia certa. A tutela pecuniária (tutela do crédito) é o objetivo e a finalidade da execução por quantia certa. Na introdução deste trabalho estabelecemos as duas premissas que o orientam: a) não há direito fundamental *de* propriedade para ser tutelado em relação ao executado; e b) a atividade executiva deve ser voltada à tutela do crédito, e, portanto, para a tutela do crédito deve ser pensado todo o processo de execução (cf. *supra*, premissas, 1.1).

Assim, para que a execução seja eficiente, ela deve ser voltada para a tutela pecuniária (tutela do crédito), para a sua adequação ao direito material que lhe dá suporte, para a efetivação das medidas externalizadoras da atividade executiva e para a sua duração razoável. Não pode ser a atividade executiva pensada para outra finalidade; não é objetivo da atividade executiva atender a outros fins. A sua razão de existir é garantir a tutela pecuniária adequada, efetiva e tempestiva.

O direito de crédito documentado no título executivo é o direito a satisfazer. O título é o suporte da obrigação de pagar quantia certa.

A técnica processual adequada para a tutela do crédito no ordenamento jurídico brasileiro é a técnica processual expropriatória.³ Geralmente, e na maior parte dos casos, esta será a técnica adotada. Como vimos na introdução (cf. *supra*, introdução, 2.14 a 2.17), contudo, esta técnica pode admitir exceções especialmente: a) em razão da previsão da atipicidade dos meios executivos (adequação da tutela executiva, art. 139, IV, CPC); b) em razão do incentivo aos meios autocompositivos (art. 3.º, §§ 2.º e 3.º, CPC); e c) em razão do autorregramento da vontade no processo (negócios processuais prévios ao processo e incidentais ao processo de execução, art. 190, CPC).

O procedimento típico previsto neste Capítulo vale para a obrigação pecuniária prevista em título executivo judicial ou título executivo extrajudicial (arts. 824-909 c/c arts. 513 e 771, CPC). Ele é a regra. Esta regra decorre da nossa tradição jurídica e da relação histórica entre obrigações e meios executivos, já debatida na parte introdutória (cf. introdução, 2.4). A regra é tão forte que o art. 797, CPC, ao tratar da finalidade de toda e qualquer execução, acaba por se referir apenas às execuções por quantia certa, mediante expropriação e penhora.⁴

A obrigação pecuniária é a obrigação de pagar quantia líquida e certa, obrigação de dar dinheiro, tendo como forma típica de execução a penhora e a expropriação, razão pela qual serão sempre consideradas uma exceção à tipicidade todas as medidas diversas das previstas no procedimento que se inicia com o art. 824.

A exceção mais conhecida no sistema é a prevista no procedimento de execução de alimentos, que permite a prisão por descumprimento da obrigação alimentar como meio coercitivo.

“Relativamente ao descumprimento de uma obrigação de pagar quantia líquida e certa, a plena satisfação do direito depende, necessariamente, da realização de execução forçada. Via de regra, ninguém será detido por dívida inadimplida – exceto nos casos de descumprimento de obrigação alimentar (CPC, art. 733, § 1.º; NCPC, art. 528, § 3.º) –; a execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor a fim de satisfazer o crédito exequendo (CPC, arts. 646 e 475-I; NCPC, arts. 824 e 513).”⁵

Contudo, como bem acentuado na doutrina, existem casos em que a finalidade da execução por quantia certa não é a expropriação. “Execução por quantia é para a expropriação? O art. 646 do CPC/1973 determina que: “Art. 646. A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor (art. 591).” O NCPC (Lei 13.105/2015) previu no art. 824 que: “Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais.” Com a nova redação, o legislador corrigiu a asserção do dispositivo legal, simplesmente porque nem toda execução por quantia pretende a expropriação de bens do executado, embora esta seja a regra especial. Na execução contra a Fazenda Pública, em razão do regime de precatórios, não há expropriação de bens da Fazenda Pública.”⁶

Há no art. 824, desta forma, duas leituras possíveis: a) tipicidade dos meios expropriatórios, com residualidade das execuções especiais expressamente determinada por lei, não se admitindo exceções; b) prevalência da tipicidade, como regra geral, porém com reconhecimento da possibilidade de atipicidade dos meios executivos, mesmo para as execuções de pagar quantia certa, desde que adequadamente justificada.

Na primeira, as execuções especiais serão as típicas execuções que admitem meios diversos da penhora e expropriação. A exemplo da execução de alimentos e da execução em face da Fazenda Pública, que se dá pelo regime da RPV (requisição de pequeno valor) ou dos precatórios, vedada a expropriação de bens da Fazenda Pública.

Em ambos os casos, há justificativa jurídica que dá suporte a opção legislativa. O legislador estabeleceu procedimentos diversos da expropriação em *razão das pessoas* envolvidas, como é o caso da Fazenda Pública, para a qual a execução dar-se-á pelo regime dos precatórios ou pela requisição de pequeno valor (RPV); ou, em *razão dos direitos* (direito material e bens jurídicos tutelados), como é o caso do direito à vida, tutelado na obrigação de prestar alimentos.

Poderíamos nos perguntar, também, se em outras obrigações pecuniárias que deem suporte a direitos fundamentais, como a tutela da probidade administrativa, do consumidor e do meio ambiente, por exemplo, não seria cabível a alteração da técnica expropriatória para melhor satisfazer estes direitos fundamentais? Como vimos na introdução (cf. *supra*, premissas, 1.3, introdução, 2.4), o modelo da atividade executiva brasileira começou a migrar do modelo rígido de execuções típicas para um modelo combinado, de execuções típicas flexíveis, de adequação (*common law*) e de generalização de *astreintes* (direito francês).⁷

Os tribunais têm assegurado que a finalidade da execução é satisfazer o credor, valorizando o *princípio* de que *a execução se faz no interesse do credor* (art. 797). Contudo, por força da tradição jurídica de *civil law*, fortemente influenciada pelo direito germânico, a tutela das obrigações típicas e as decorrentes formas típicas de execução, têm predominado um espírito de tutela do executado, de maneira que, para cada obrigação, teríamos apenas uma forma de execução, sendo que para a obrigação pecuniária restaria apenas a execução por expropriação. Isso gera uma supervalorização do art. 805, que prevê o princípio da menor onerosidade possível.

O STJ já se manifestou, contudo, pelo afastamento desta lógica em abstrato ao afirmar: “O STJ já afirmou que o princípio da menor onerosidade para o devedor não prepondera, em abstrato, sobre o da efetividade da tutela executiva. (...) É clássica a regra hermenêutica segundo a qual onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir.” (REsp 1287915/BA, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.09.2012, DJe 11.09.2012).

Como vimos, o CPC permite outras medidas atípicas para o pagamento de quantia certa,

voltando-se para a finalidade da tutela, consistente no adimplemento da obrigação pecuniária, nos termos do art. 139, IV. Assim, incumbe ao juiz no curso do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, *inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária*”.

Muito embora a expropriação, mediante o prévio procedimento da penhora, continue sendo a forma típica de execução e a regra geral, poderá ser permitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem ao princípio de que *a execução se faz para a tutela pecuniária (tutela do crédito) e no interesse do credor*, a utilização de meios atípicos, quando os requisitos para tanto estejam preenchidos (relevância do bem jurídico tutelado, por exemplo) ou quando houver recalcitrância do devedor em adimplir a obrigação (comportamento das partes). Isso poderá ocorrer tanto para substituir o procedimento para expropriação por outro mais adequado, quanto para determinar medidas de reforço e aceleração do próprio procedimento de expropriação.

Art. 825. A expropriação consiste em:

I – adjudicação;

II – alienação;

III – apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.

1. Expropriação. A expropriação é uma técnica processual – técnica típica da obrigação de dar quantia certa que predomina como forma de satisfação do crédito consubstanciado em título executivo condenatório. Na verdade, a técnica expropriatória divide-se em um conjunto de técnicas, com o objetivo comum de retirar, por sub-rogação, do patrimônio do executado os valores que sirvam para a satisfação do exequente.⁸

A expropriação consiste na a) adjudicação (arts. 825, I, 876 e 877, CPC); b) na alienação por iniciativa particular ou em leilão público (arts. 825, II, e 879 e ss., CPC); ou c) na apropriação de frutos e rendimentos (art. 825, III e 866-869, CPC).

2. Preferência. Os meios expropriatórios observam uma ordem de preferência, marcada pelo legislador de forma topológica na ordem dos incisos do art. 825. Há clara preferência da adjudicação à alienação e destas à apropriação de frutos e rendimentos. Isso ocorre por razões que atendem ao triplice interesse que governa a atividade executiva: a) o interesse do exequente; b) o interesse do executado; e c) o interesse público (cf. *supra*, premissas, 1.2). Tanto é assim que a adjudicação, do ponto de vista do exequente, é a satisfação direta; do ponto de vista do executado, é a garantia do preço de avaliação e, do ponto de vista do interesse público, é a expropriação (ou outro meio de satisfação do exequente) mais eficiente e econômica, exigindo menor esforço dos órgãos de execução. Mais, no caso da apropriação de frutos e rendimentos, a sua colocação em último lugar decorre, em muitos casos, da necessidade de preservar a *função social da empresa*, como veremos mais adiante. Essa característica resulta em uma clara residualidade desta opção em relação às demais (arts. 861 a 869).⁹

A tutela executiva, desta maneira, torna-se mais “eficiente e fidedigna, compondo um processo de execução mais justo (art. 5.º, LIV, CF).”¹⁰ Ademais, dentre as formas de alienação deverá ser preferida a alienação por iniciativa particular, por ser menos onerosa e mais efetiva que a alienação por leilão público (art. 880, CPC), obtendo-se maior economia processual.

3. Adjudicação. A adjudicação é técnica processual executiva típica voltada à satisfação do crédito em execução por quantia certa, ao lado da alienação por iniciativa particular e da alienação por leilão público. Hoje, porém, além da finalidade de excutir o bem, transferindo o patrimônio para o exequente (art. 904, II, CPC), a adjudicação ampliou sua função, incluindo-se a função de alienação do bem por adjudicação (art. 904, I, CPC), isso porque o terceiro poderá exercer direito de preferência adjudicando o bem (art. 876, §§ 5.º e 7.º).

Há, portanto, uma *dúplice* finalidade na adjudicação: a) forma de pagamento ao credor-exequente (art. 876, *caput* c/c, art. 904, II CPC); b) forma de aquisição de propriedade por terceiro (art. 876, §§5.º e 7.º c/c art. 904, I, CPC).

Na doutrina: “(...) a adjudicação *pode* ser *também* forma de pagamento ao credor-exequente (art. 904, II, CPC), caso ele seja o adjudicatário (art. 876, *caput*, CPC): a obrigação executada é satisfeita com a transferência da coisa adjudicada ao patrimônio do exequente, no limite do valor da respectiva avaliação. Quando a transferência é feita a terceiro não exequente (art. 876, §§ 5.º e 7.º, CPC), a adjudicação serve ao exercício de um direito de preferência que a lei lhe outorga; nesse caso, a satisfação da obrigação ocorrerá com a entrega do dinheiro pago pelo terceiro ao exequente (art. 904, I, CPC). Há, aqui, uma alienação judicial sem hasta pública [leilão público], em que se garante um direito de preferência a certos sujeitos. A adjudicação pode ser tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. Bem penhorado que possa ser alienado pode ser adjudicado (...)”.¹¹

Assim, no *caput*, através de um procedimento expropriatório, bem(ns) móvel(is) ou imóvel(is) de propriedade do executado são transferidos ao patrimônio do exequente. Não há que se confundir a *adjudicação*, transferência do bem para o patrimônio do exequente com: a) a *execução de entrega de coisa ou ação de imissão de posse*, pois enquanto nestas o bem em si é que se revela objeto da execução, na adjudicação é o crédito;¹² (b) a *ação em pagamento*, pois enquanto esta é um instituto de direito material (art. 356 a 359, CC) que necessita de consentimento para que o bem seja transferido, na adjudicação o bem penhorado é transferido coativamente.¹³

4. Alienação. A alienação dá-se por duas medidas executivas: a) a alienação por iniciativa particular (art. 879, I, CPC); ou b) leilão judicial eletrônico ou presencial (art. 879, II, CPC). *O CPC não fala mais em hasta pública, divisão antiga que resultava em leilão ou praça.*

A alienação por iniciativa particular é prevista no art. 880, CPC. A alienação na forma direta é uma novidade legislativa introduzida com as reformas da execução civil ainda no período anterior à vigência do CPC/2015. Trata-se de solução muito mais eficaz, barata, de simples execução e que desonera o serviço público de justiça de tarefas necessárias à expropriação. Atende assim aos interesses de todos envolvidos na atividade executiva, pois, ao mesmo tempo que acelera o procedimento e reduz os custos, permite na maior parte das vezes obter um valor mais elevado do que a alienação por leilão público.

O leilão público será preferencialmente eletrônico, o que também traduz um sinal dos tempos, em benfazeja mudança em prol da aceleração dos procedimentos executivos e redução dos seus custos de realização, além de maior transparência e acesso. Trata-se de um mecanismo de *e-justice*, que produz uma série de vantagens para as partes e para o juízo, em especial pela agilidade, ausência de custos com o espaço físico e servidores e pela transparência que pode ser obtida através desses mecanismos. Conferir, sobre o tema, os comentários ao art. 882, § 1.º e a Res. CNJ 236/2016, a qual regulamenta os leilões eletrônicos em todos os tribunais do país e reconhece como objetivos dos leilões eletrônicos a participação dos licitantes, a redução de custos e a agilização dos processos de execução, garantindo mais eficiência operacional ao sistema de Justiça e promovendo mais responsabilidade social (segue, assim, os objetivos estratégicos do Poder Judiciário, Resolução CNJ 198/2014).

5. Fim do usufruto judicial: simples apropriação de frutos e rendimentos. O CPC abandonou a *vetera* noção de usufruto judicial, substituindo-a por afirmação simples do direito à *apropriação de frutos e rendimentos* (art. 825, III, CPC), com nomeação de administrador-depositário, que será investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades (art. 868, CPC). O administrador-depositário receberá as quantias e entregará ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida (art. 869, § 5.º), que dará quitação ao executado (art. 869, § 6.º, CPC). Como bem marcou a doutrina, a previsão de que a expropriação se dá com a *apropriação de frutos e rendimentos* consiste em apuro técnico em relação à equivocada nomenclatura anteriormente utilizada pelo art. 647, IV, do CPC/1973.¹⁴

Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

1. Remição da execução. Remir a execução significa resgatar a dívida, solver a obrigação antes da adjudicação ou alienação tornar-se definitiva (art. 903, CPC). Esta atividade pode ocorrer antes da adjudicação ou alienação, a qualquer tempo, como diz o CPC, pela própria natureza jurídica da atividade adjudicatória ou alienatória que *transforma* juridicamente o título de propriedade em relação ao bem. Após a *transformação do título de propriedade* não há mais que se falar de remição.

Remir significa *pagar* (art. 304, CC/2002, assim determina: “[q]ualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste”) ou consignar (art. 334, CC/2002, “[c]onsidera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”).

Há uma importante questão de linguagem aqui. *Remir* é pagar a dívida, resgatar, pagando, a dívida de alguém. Daí o instituto da *remição*. *Remitir*, que gera *remissão*, é o perdão. Ambos institutos não se confundem. Uma coisa é pagar, outra, bem diferente, é perdoar a dívida de alguém.

O CPC é claro em determinar que, na fase executiva, o pagamento ou consignação deverá ocorrer integralmente, incluídas as despesas processuais executivas (juros, custas e honorários advocatícios) e a dívida exequenda, devidamente atualizada.

Ao mesmo tempo, não se considera necessário e é desinteressante para fins de remição o depósito de qualquer quantia alheia ao pedido executivo (STJ, 1ª Turma, REsp 61.240/SP, rel. Min. Garcia Vieira, j. 26.04.1995, DJ 29.05.1995, p. 15.486).

Com a remição, a execução deverá ser extinta e considera-se satisfeita a tutela pecuniária da obrigação (“art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita”, CPC).

2. Remição da Execução Fiscal. O instituto da remição tem guarida também na legislação sobre a execução fiscal (arts. 15, I, 19, II, Lei 6.830, de 1980). Quando requerido pelo executado, sendo deferido pela Fazenda Pública, poderá ocorrer parcelamento dos valores envolvidos na execução em até 60 (sessenta) vezes (art. 10, Lei 10.522, de 2002; STJ, 1ª Turma, REsp 643.234/SC, rel. Min. José Delgado, j. 28.09.2004, DJ 08.11.2004, p. 187).¹⁵ Trata-se de evidente política de recuperação de créditos pela Fazenda Pública, presente não só no direito brasileiro, mas também no direito comparado.

Vale frisar que existem diversas formas de incentivo ao cumprimento das obrigações de pagar quantia certa. Portanto, essa alternativa de incentivar a remição da dívida fiscal poderia ser transportada para as dívidas em geral. Afinal, a finalidade da execução é a tutela pecuniária. O atingimento da finalidade é mais relevante do que o procedimento pelo qual a mesma será atingida. No Código, o art. 916 irá permitir uma espécie de remição denominada pela doutrina de moratória, com escopos muito similares (cf. *infra*).

A remição da execução fiscal, contudo, mesmo que permita o parcelamento, depende de a Fazenda Pública manifestar-se positivamente, sendo que a manifestação positiva quanto à remição parcelada deverá se dar antes da adjudicação ou alienação (REsp 643.234/SC, rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 28.09.2004, DJ 08.11.2004, p. 187).

3. Legitimidade. A remição é incentivada pelo legislador. Assim, não só o executado, mas qualquer terceiro, interessado (art. 304, *caput*, CC/2002) ou não, desde que este último o faça em nome e à conta do devedor/executado (art. 304, parágrafo único, CC/2002), poderá remir a execução antes de adjudicados ou alienados os bens penhorados.

O STJ tem ampla jurisprudência sobre o incentivo à remição e à possibilidade de remição por terceiros.

Assim, por exemplo, a sociedade cooperativa poderá remir a dívida de seu cooperado: “É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 591, CPC) (...) *Dada a restrição de ingresso do credor como sócio e em respeito à afecção societatis, deve-se facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC), remir o bem (art. 685-A, § 2.º, CPC) ou concedê-la e aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas (art. 685-A, § 4.º, CPC), a tanto por tanto, assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota*” (REsp 1278715/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2013, DJe 18.06.2013).

O cônjuge, ascendente ou descendente, também poderão remir a execução: “A melhor orientação é a que *admite poderem cônjuges, descendentes ou ascendentes de sócio de pessoa jurídica remir bens prazeiros*, consoante diretriz inserta no art. 620 do CPC. *A norma contida nesse dispositivo zela pela menor onerosidade ao devedor no desenvolvimento do processo de execução*” (REsp 565.414/SP, rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 25.10.2005, DJ 14.11.2005, p. 245).

O incentivo não constituirá, contudo, um direito a participar do procedimento, não havendo necessidade de intimação dos legitimados a remir a dívida. Cabe aos legitimados manifestar interesse e comparecerem ao processo espontaneamente. Nesse sentido: “*O art. 651 do CPC indica as pessoas que podem remir a arrematação, mas não determina sejam elas intimadas.*” (REsp 965.741/SP, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 17.04.2008, DJe 06.05.2008).

É bom atentar para algumas particularidades do instituto, por estar entre o direito material e o processual.

Antes de mais nada, deve-se perceber que a disciplina do Código Civil deixa claro que a remição por terceiro, não interessado, não gera sub-rogação, sendo, ainda, condicionado o direito ao reembolso ao prazo de vencimento da dívida, quando a mesma for paga antes do vencimento.

Por outro lado, nos casos em que o pagamento for efetuado por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, ficará este desobrigado a reembolsar os valores pagos se tinha meios de ilidir a execução (art. 306, CC).

4. Termo Final: adjudicação ou alienação – ato jurídico perfeito. São dois os requisitos para ser considerada remida a execução: *a) pagar ou consignar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios (art. 826); b) realizar o pagamento ou a consignação do montante devido, antes que a arrematação possa ser considerada perfeita, acabada e irretratável, isto é, em momento anterior à assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro (art. 903, CPC).* Reforçamos aqui o quanto fora afirmado antes, trata-se de defesa dos direitos do adjudicante e do adquirente na alienação em face da mudança jurídica ocorrida na propriedade do bem, protegendo-se aqui os atos jurídicos perfeitos (art. 5.º, XXXVI, CF).

Já se manifestou o STJ: “*Alegam ser impossível o devedor remir a execução, após a assinatura do auto de arrematação pelo juiz. (...) Consoante os arts. 651 e 694 do CPC, o executado tem direito de remir a Execução, devendo, contudo, obedecer aos seguintes requisitos: a) pagar ou consignar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios (art. 651); b) realizar o pagamento ou a consignação do montante devido, antes que a arrematação possa ser considerada perfeita, acabada e irretratável, isto é, em momento anterior à assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro (art. 694).* 6. In casu, alegou-se oportunamente o não cabimento da remição, sob o argumento de que “o auto de arrematação já havia sido assinado pelo Juiz, situação descrita na decisão agravada e facilmente verificável na cópia de fl. 206” (fl. 366). Esse elemento fático de natureza temporal, fundamental para o deslinde da controvérsia, haja vista o que preceitua o art. 694 do CPC, não consta no acórdão recorrido. 7. Diante da alegação de que a cópia de fl. 206 dá conta de que o auto de arrematação já havia sido

assinado pelo magistrado, era dever do Tribunal *a quo* apreciar a matéria de forma exauriente, cotejando os fatos à luz do art. 694 do CPC. 8. A 2ª Turma do STJ já afirmou ser impossível investigar, em Recurso Especial, os elementos fáticos que circundam a remição, sob pena de afrontar a Súmula 7/STJ (REsp 565.414/SP, rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 14.11.2005). 9. Clara está a afronta ao art. 535, II, do CPC, pois o acórdão recorrido é silente sobre questões fundamentais para o deslinde da controvérsia (...) Recurso Especial de Adriano Marcel Zimmermann e Gilson Treis provido para anular o acórdão recorrido. Recurso Especial interposto por Juriti Alimentos Ltda. prejudicado.” (REsp 1268097/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.10.2012, DJe 08.03.2013)

Conforme a doutrina, “[a] adjudicação e as alienações consideram-se perfeitas nos termos dos arts. 877, § 1.º, 880, § 2.º, e 903, *caput*, CPC. O direito à remição da execução está limitado à perfectibilização da adjudicação ou da alienação (STJ, 1ª Turma, REsp 643.234/SC, rel. Min. José Delgado, j. 28.09.2004, DJ 08.11.2004, p. 187). Já se decidiu, contudo, que o adjudicante, o adquirente ou o arrematante não pode ser prejudicado “pela omissão do serventuário em colher a firma do juiz” no respectivo auto ou termo (STJ, 3ª Turma, REsp 944.451/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 06.12.2007, DJ 18.12.2007, p. 276)”.¹⁶

Há ainda uma consideração necessária quanto às execuções fiscais. Enquanto não aceito o parcelamento pela Fazenda Pública, a remição parcelada na execução fiscal não terá efeitos. Portanto, não se interrompe o procedimento, permitindo-se a adjudicação e a alienação, mesmo quando requerida a remição. A remição somente terá ocorrido, quando aceita pela Fazenda Pública. Somente a manifestação positiva da Fazenda Pública gera os efeitos da remição.

Nesse sentido: “(...) O Tribunal *a quo* deu provimento ao agravo e julgou prejudicado o regimental, entendendo *aceitável a remição da execução com amparo na Lei 10.637/2002, que possibilita o parcelamento em até 60 meses, acaso defira-o a Fazenda*. Inconformada, esta movimentou recurso especial alicerçada na alínea *a* do permissivo constitucional, apontando violação do art. 651 do CPC, *sustentando que a remição da execução contemplada nesse dispositivo legal não permite que seja efetuada de modo parcelado, mas somente através do pagamento instantâneo e integral do crédito exequendo e demais consectários legais. Contra-razões defendendo que a Lei 10.637/2002 prevê o parcelamento de débitos em até 60 vezes, cujo deferimento constitui atribuição exclusiva da autoridade fazendária*. 2. O teor do art. 651 do CPC é claro ao limitar o direito de remição da execução à arrematação do bem constrito, a qual se torna definitiva e irretratável nos moldes previstos no art. 694 do mesmo diploma processual, por ocasião da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou pelo leiloeiro, e não pela expedição da carta de arrematação. 3. Deve ser prestigiada a solução que o tribunal *a quo* talhou à controvérsia, pois, com vistas nos arts. 651 do CPC e 10 da Lei 10.522/2002, deixou claro que *só se considerará remida a execução após a manifestação positiva da Fazenda Nacional sobre o pedido de parcelamento*” (REsp 643.234/SC, rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 28.09.2004, DJ 08.11.2004, p. 187).

5. Desconstituição da adjudicação ou alienação. Há a possibilidade de serem desconstituídas a adjudicação e a alienação, nestes casos, por força do retorno ao *status quo ante*, ocorrerá a abertura de novo prazo para remir a execução, limitado, por força da lei (art. 903, CPC), à nova adjudicação ou alienação.

6. Regimes de remição. A doutrina individualizou quatro regimes jurídicos para a remição da execução:¹⁷ a) o *regime geral* (art. 826, CPC); b) a regra do pagamento em três dias que reduz em 50% os honorários na execução de título extrajudicial (art. 827, § 1.º, CPC); c) a regra do pagamento em 15 dias que afasta o pagamento da multa de 10% e os honorários no cumprimento da sentença (art. 523, § 1.º, CPC);¹⁸ d) a regra do pagamento parcelado da dívida em até sete vezes, condicionada ao reconhecimento da dívida, a não oposição dos embargos e a sua consequente preclusão, segundo a qual é preciso que “o executado reconheça o crédito do exequente e deposite 30% do valor da execução (crédito + honorários + custas), podendo requerer pagar o restante em até seis parcelas iguais, acrescidas de juros de 1% ao mês e correção monetária”.¹⁹ Perceba-se que estes regimes de remição tratam do mesmo problema, com matizes distintas. Nada impede que

ocorra a remição convencional (art. 3.º c/c art. 139, V, CPC) ou o estabelecimento de regime convencional de remição para o caso de inadimplemento mediante negócio processual prévio (art. 190, CPC).

7. Limites Temporais da Remição. Ainda quanto ao tema da remição, vale destacar que esta pode ser feita a qualquer tempo, até mesmo depois de realizada a penhora, nesse sentido destaca a doutrina: “E essa remição da execução pode o executado efetivá-la a qualquer tempo, antes ou depois da penhora, atendido o limite do art. 651, e o fato da regra estar posta na subseção pertinente às disposições gerais, relativas à execução por quantia certa, já diz muito bem de sua generalidade, sem qualquer vinculação com o fato de ter havido ou não efetiva constrição em bens do executado ou de alguém responsável patrimonialmente”.²⁰

Caso a remição seja realizada após o prazo previsto de 3 (três) dias da citação, art. 829 c/c art. 827, § 1.º, CPC, não será aplicada a redução de 50% no valor dos honorários advocatícios.

8. Preferência na remição. Em caso de existirem diversos pretendentes à remição do bem, deverá preferir o pretendente que oferecer o maior preço. Esta regra tem, contudo, uma exceção, quando o pretendente for o próprio executado – a sua preferência é máxima, podendo remir com o valor da avaliação. Apesar de o art. 1.482 do CC/2002, ter sido revogado pelo art. 1.072, II, do CPC/2015, a inteligência do art. 826 do CPC/2015 indica neste sentido.

9. Recorribilidade do provimento judicial que julga o pedido de remição. No CPC/1973, art. 790 falava em sentença, sendo que, por esta razão, a doutrina previa o recurso de apelação para a decisão que julgava a remição. Na doutrina, Nelson Nery Jr. e Barbosa Moreira entendiam, já à época, ser esta decisão uma decisão interlocutória, portanto, agravável.²¹ O CPC/2015 disciplinou que todas as decisões interlocutórias, no curso da execução, serão recorríveis por agravo (art. 1.015, parágrafo único). Logo, o recurso cabível, da decisão que julga o pedido de remição, será o agravo de instrumento.

*Seção II - Da citação do devedor e do arresto*²²

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

1. Citação do executado e arresto e avaliação: A Seção II tem claramente o objetivo de oferecer sanções premiais ao executado que se antecipe efetuando o pagamento. O executado será citado para pagar no prazo de três dias. Caso não efetue o pagamento, serão arrestados os bens necessários para assegurar a tutela pecuniária. Há possibilidade de arresto antecipado (pré-penhora) nas hipóteses de tutela de urgência e nas hipóteses em que o executado não for encontrado.

As sanções premiais²³ e incentivos econômicos estão presentes em toda a Seção II. Por exemplo, o CPC estabelece com clareza que os honorários de advogado serão fixados em 10% do valor da execução, o que por si só permite ao devedor que evite a execução desnecessária, adimplindo a obrigação, se não quiser ser onerado com os acrescidos 10% de honorários de advogado.

O CPC faz mais, prevê a redução dos honorários arbitrados em 50% nos casos em que o executado pague a dívida no prazo de três dias, claramente uma sanção premial decorrente do comportamento não litigioso, mesmo após o inadimplemento.

Deixa claro, ainda, que, caso o executado oponha embargos e reste vencido, os honorários de advogado serão elevados para 20%, desestimulando a defesa frívola.

Prevê, no mesmo sentido, outros instrumentos de estímulo, como o arresto, como forma de incentivo ao pagamento (art. 830), inclusive o cautelar e o arresto on-line, e ao comparecimento do executado para a indicação dos bens à penhora. Além do arresto, prevê a averbação da execução, nos termos do art. 828. A averbação pode se revelar em potente instrumento para a tutela do crédito. Segundo o art. 828, poderá ser procedida a averbação da execução, mediante prova por certidão de que a mesma foi admitida pelo juiz. A averbação dar-se-á no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. O cumprimento da sentença previu o protesto do título executivo judicial como forma de estimular o devedor ao adimplemento (arts. 517 e 528, § 1.º, CPC). A mesma técnica também pode ser utilizada em relação aos títulos extrajudiciais (art. 782, §§ 2.º a 5.º, CPC).²⁴

Toda a Seção II, portanto, está voltada para estimular o adimplemento, a efetividade da tutela pecuniária, mesmo que após o ajuizamento da execução, e fornecer elementos de constrição para além da penhora, que permitam a sua efetividade, como o arresto, o protesto e a averbação da execução.

2. Honorários de Advogado. A norma processual determina a fixação pelo juiz de honorários de 10%. Recebida a inicial, o juiz fixará os honorários (art. 827). Mesmo que não ocorra pedido da parte autora, o arbitramento decorre do simples ajuizamento da execução, devendo o juiz agir de ofício. Note-se claramente que os honorários de advogado exercem um importante papel dissuasório do inadimplemento da obrigação.

3. Redução da verba honorária: pagamento integral. Após o ajuizamento da execução, o pagamento integral que permite a redução da verba honorária (art. 827, § 1.º) será aquele que compreende o crédito objeto da execução devidamente atualizado, acrescido dos juros, quando forem devidos, das despesas processuais (custas processuais e honorários advocatícios). Somente com todos estes elementos presentes no pagamento, ocorrendo o mesmo em três dias contados da citação, com a integralidade do depósito, será possível a redução do valor da verba honorária.

Como bem afirmou a doutrina: “[t]rata-se de evidente sanção premiativa”.²⁵

Importante frisar que tal prêmio não decorre do parcelamento da dívida, mas apenas do pagamento integral, daí que não se aplica o art. 827, § 1.º aos casos do art. 916 do CPC (“art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”).

Nesse sentido: “[a] solicitação de parcelamento do valor em execução (art. 916, CPC) não atrai a incidência do art. 827, § 1.º, CPC. O pagamento tem de ser integral.”²⁶

A jurisprudência do STJ já havia compreendido a finalidade da cominação de pronto dos honorários: “O art. 652-A do CPC prescreve que o juiz deve fixar, de plano, os honorários a serem pagos pela parte executada. Com a finalidade de estimular o devedor a efetuar logo o pagamento, conferindo assim maior efetividade ao processo de Execução, seu parágrafo único determina que a verba seja reduzida pela metade, caso o adimplemento ocorra no prazo de três dias.” (REsp 1297844/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2.ª Turma, j. 06.03.2012, DJe 12.04.2012).

4. Não aplicação ao cumprimento de sentença condenatória. Há neste dispositivo uma distinção com o procedimento do cumprimento de sentença. Como se percebe da leitura do art. 523, § 1.º, CPC, o juiz, naquele caso somente, fixará os honorários de advogado, quando não atendida a exortação ao pagamento, por força do prosseguimento do processo. Frise-se que o impacto sobre a dívida reconhecida em juízo será ainda maior, pois além dos honorários incidirá a multa de 10% decorrente do não pagamento, somando-se ao total reconhecido no título executivo judicial o valor de 20% (“art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em

liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, *o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito*, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1.º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”). “Não há, por isso, espaço para a redução dos honorários”,²⁷ no arbitramento de honorários no processo judicial.

Portanto, no caso do art. 827, até porque não houve arbitramento de honorários anteriores, por se tratar de processo que se inaugura com a petição de execução do título extrajudicial, o tratamento diferenciado implica, desde logo, arbitramento dos honorários face ao princípio da causalidade.

5. Multa cominatória: art. 139, IV. O art. 139, IV, além de prever formas atípicas de execução, pode ser utilizado para *reforçar* as medidas típicas. Serve tanto para alterar o procedimento, como para auxiliar a torná-lo efetivo. Dessa forma, parece correta a afirmação da doutrina de que o juiz poderá determinar, inclusive para o agente público responsável que se apresente, sem razão, recalcitrante, multa cominatória para que efetue o pagamento, quando se tratar de título executivo extrajudicial. Lembre-se, contudo, das técnicas de justificação adequada amplamente descritas na introdução (cf. *supra*, 2.14 e 2.15) e da necessidade de demonstrar a partir dos fatos a justificativa externa para a excepcionalidade da medida atípica.

Assim: “Ressalte-se, ainda, que em face do regime de precatório e o de requisição de pequenos valores em face da Administração Pública direta, é pacífico que tais multas não podem ser impostas às pessoas jurídicas de direito público interno e às autarquias e fundações públicas. Nada impede, todavia, que o juiz imponha a multa em desfavor do agente público responsável pelo cumprimento do precatório ou da requisição de pequeno valor. Já em relação ao crédito certificado em título extrajudicial, o legislador processual não impôs qualquer limitação à incidência da multa (art. 827). Logo, em tese, o juiz, com fundamento no inc. IV do art. 139 do CPC/2015, pode mandar citar o executado para pagar a quantia certificada no título extrajudicial sob pena de incidência de multa cominatória.”²⁸

6. Inscrição no cadastro de inadimplentes. O executado poderá ser inscrito no cadastro de inadimplentes. Conforme preceitua o art. 782, § 3.º, depois de ter sido citado e decorrer o prazo de três dias para o pagamento, *a requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes*. A necessidade de observar o prazo para pagamento decorre do fato de ser providência integrada ao disposto no art. 517, CPC (prevê a possibilidade de protesto da decisão judicial transitada em julgado depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523, CPC, o qual trata justamente da fase de cumprimento da sentença condenatória de pagar quantia certa).

Nesse sentido: “(...) é de se dizer que *a previsão da inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes* além de estar inserida em local inapropriado, deveria estar em sintonia com a previsão do protesto da decisão judicial com força executiva transitada em julgado (art. 517 do CPC/2015), pois se em relação aos títulos judiciais o protesto (e em decorrência dele a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes) só acontece após expirado o prazo do art. 523 do CPC/2015 sem o adimplemento do executado, então, pensamos, *a possibilidade de inscrever o devedor em cadastro de inadimplentes deveria também só ser possível após decorrido o prazo fixado pelo juiz para o adimplemento da obrigação contida no título extrajudicial* (art. 827, § 1.º, do CPC/2015).”²⁹ Além da inscrição no cadastro de inadimplentes, também será viável o protesto do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 782, § 2.º, CPC c/c o art. 517, CPC (intercambialidade da execução). Este protesto não se confunde com o de natureza cautelar, que possui outros requisitos (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*, art. 301, CPC).

7. Aplicação ao cumprimento de sentença e em execuções fundadas em título extrajudicial de obrigação de não fazer, fazer e entregar coisa. Importantíssimo salientar que a previsão do art. 827, § 2.º, CPC aplica-se também na fase de cumprimento de sentença (arts. 513 e ss. do CPC), sendo, nesse sentido: “Aplica-se a regra decorrente do art. 827, § 2.º, ao cumprimento de sentença” (450 FPPC).

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1º No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

§ 5º O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2º indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.

1. Averbação. A averbação prevista neste artigo tem por principal objetivo garantir a execução contra a dilapidação do patrimônio pelo executado e impedir a fraude à execução (art. 792, II). Além deste objetivo, dá-se também uma finalidade pública, ao comunicar aos terceiros adquirentes do bem e àqueles que porventura pretendam entreter obrigações comerciais com o executado da pendência de execução civil em relação a ele. A averbação, por fim, tem uma finalidade proativa de estimular o executado a negociar o débito e a efetivar o pagamento da quantia para o fim de levantar o quanto averbado, de forma a sanear, aos olhos do público, a existência de obrigações não honradas. Nesse sentido, colabora como estímulo para a solução conciliativa (art. 515, § 2.º, CPC, cf. *supra*, introdução, 2.17).

Averbar-se-á a existência da execução mediante a comprovação pela certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes e do valor da causa, junto aos registros públicos de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Averba-se a propositura da ação já admitida pela autoridade judiciária. A função principal continua sendo a caracterização da alienação ou oneração de bens posteriores à averbação como fraude à execução (art. 792, CPC). A Resolução CNJ 236/2016 que prevê o leilão eletrônico também disciplina que o CNJ celebrará convênios com entidades públicas e privadas, a fim de viabilizar a efetivação da penhora de dinheiro e as averbações de penhoras incidentes sobre bens imóveis e móveis por meio eletrônico. Estes convênios também poderão prever a averbação por meio eletrônico (art. 828) e o acesso às informações cadastradas (art. 772, III, CPC). Alguns destes convênios estão sendo amplamente utilizados, como o Renajud, o Bacenjud e o Infojud.

Como a averbação antecede a citação do executado, em regra, a doutrina afirma que a “finalidade evidente do art. 828, CPC, é antecipar o marco a partir do qual se pode considerar em fraude à execução alienações ou onerações realizadas pelo demandado, fazendo-o coincidir com a data da averbação no registro competente da admissão do processamento da ação”.³⁰ Há, na verdade, como dissemos acima, uma tríplice finalidade: a) tornar inequívoca ineficácia da alienação ou oneração posterior em face da fraude à execução (art. 792, § 1.º, CPC);³¹ b) comunicar aos terceiros a existência da pendência de execução; c) estimular o executado a sanar a obrigação para levantar a averbação realizada.

2. Faculdade do demandante ou ônus? Pode ocorrer dúvida se a averbação e o requerimento de certidão são faculdades ou ônus para o exequente. O ônus é configurado como um imperativo do próprio interesse, ao não exercê-lo há prejuízo. A faculdade, por outro lado, poderá ser exercida ou não, sendo que o não exercício não gera uma sanção. A averbação do registro é uma faculdade, e não um ônus, pois não há sanção pelo não requerimento da certidão e pela não

averbação da mesma. A ausência de averbação elimina a presunção de fraude à execução (art. 828, § 4.º). Quando não há averbação, para que seja configurada fraude à execução, exige-se a citação do executado (art. 792, CPC).

Assim, precedente do STJ: “[a] averbação no registro competente da propositura de ação ou de requerimento de cumprimento de sentença condenatória constitui faculdade do demandante. Obviamente, é possível a caracterização de fraude à execução sem que tenha o demandante averbado a propositura da demanda em qualquer registro de bens (STJ, 4.ª Turma, Ag 956.278/DF, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 27.11.2007, DJ 05.12.2007). É claro que aí é imprescindível a citação do executado para configuração de fraude à execução (art. 792, CPC).”³²

3. Amplitude da averbação: sentença condenatória, arresto ou indisponibilidade cautelar anterior à execução. A doutrina defende, com razão, a possibilidade de averbação também do título judicial, pois o núcleo do direito à averbação dá-se na garantia da atividade de execução frutífera. Defende ainda a averbação cautelar da própria petição inicial do processo de conhecimento, quando a concessão da tutela do direito possa levar o demandado ao estado de insolvência. Para tanto, vale-se do poder cautelar do juiz, uma vez que deve persistir o direito à tutela adequada, efetiva e tempestiva e, ocorrendo os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, estará presente a possibilidade de averbação antecipada (arts. 297 e 301, CPC).

Na doutrina afirma-se que, “O objetivo do art. 828, CPC, é manter atrelado à tutela jurisdicional o patrimônio do demandado, de modo que seja possível alcançá-lo para eventual atuação da tutela jurisdicional em favor do demandante (arts. 790 e 792, II, CPC) (...) certo é que também é possível a averbação de requerimento de cumprimento de sentença condenatória (art. 523, CPC) (...) a compreensão da ação como direito fundamental à efetiva tutela do direito impõe que a possibilidade de averbação da petição inicial no registro competente se estenda para toda e qualquer demanda capaz de reduzir o demandado ao estado de insolvência. A razão é simples: não há possibilidade de execução frutífera sem que se mantenha íntegro o patrimônio do executado, atrelando-o à finalidade expropriatória.”³³

Assim, ao permitir a averbação, em razão de indisponibilidade ou arresto cautelar o art. 828, *in fine*, “autoriza a interpretação proposta, na medida em que possibilita a averbação à vista da propositura de arresto ou indisponibilidade, que, como é sabido, pode ocorrer a partir da caracterização da verossimilhança do direito alegado e da urgência em prover, não estando atrelados, portanto, à possibilidade de imediata execução. O arresto e a indisponibilidade estão vinculados à futura e eventual execução”.³⁴

4. Conteúdo da certidão e órgão competente para certificar. A certidão deve ser requerida no cartório que tramita a causa, perante o juízo em que proposta a atividade executiva, seja através da ação executiva de título extrajudicial, do cumprimento de sentença sujeita à execução ou, mesmo, da ação condenatória ao pagamento de quantia certa. A certidão exige a confirmação da admissão do processamento da execução, da fase de cumprimento ou da ação condenatória. Não pode o cartório deixar de fornecer a certidão. O direito à certidão é direito subjetivo da parte. O cartório, contudo, exigirá o pagamento dos emolumentos, incluído o eventual cancelamento.³⁵ Deverão constar da certidão a identificação das partes, a natureza do feito e o valor da causa.³⁶

5. Dever de comunicação. O demandante tem o dever de comunicar ao juízo a averbação realizada. A comunicação tem dupla finalidade: a) possibilitar o controle a respeito da averbação (art. 828, § 1.º, CPC); b) permitir a responsabilização do exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar em dez dias as averbações após a penhora dos bens suficientes para garantir a execução (art. 828, § 5.º, CPC).

A averbação visa ao princípio da concentração (*fólio real*), patente no direito registral.³⁷ Logo sua comunicação ao juízo também obedece a este princípio. Eventuais danos ou prejuízos causados pela ausência de comunicação em juízo deverão ser considerados nos termos do art. 828, § 5.º, CPC. O prazo de dez dias não deve ser considerado um prazo próprio ou preclusivo, justamente por ser interesse público o registro em cartório da existência da demanda, especialmente a executiva. Exatamente por esta razão, o cartório não poderá negar o registro.³⁸

6. Cancelamento. A finalidade principal da averbação é a preservação do patrimônio do demandado para imediata ou futura execução. Assim, formalizada a penhora, mas também o arresto, sobre bens suficientes para “cobrir a expressão pecuniária do direito do demandante”, deve o exequente providenciar no cancelamento das averbações que ultrapassem o necessário para a satisfação da obrigação de pagar quantia, em sua integralidade, incluídos as custas, honorários, no prazo de dez dias.

Cabe ao juiz, pelo dever-poder de garantir a gestão adequada do processo, controlar esta atividade e, não tendo sido demonstrado nos autos o cancelamento das averbações sobressalentes, deverá, de ofício ou a requerimento, determinar esse cancelamento.

É bom reafirmar que há necessidade de comprovação de prejuízo para a responsabilização, pois a “simples averbação em registros de bens superiores àqueles necessários à satisfação do demandante, sem abuso do direito, não configura hipótese passível de responsabilização na forma do art. 828, § 5.º, CPC”. Contudo, o comportamento da parte no sentido de não cooperar com o juízo, quando sabe que deve proceder ao cancelamento, poderá ser sancionado (art. 6.º, CPC).³⁹

7. Aplicação de sanção para a averbação manifestamente indevida ou seu não cancelamento. O art. 828, § 5.º, prevê sanção específica pela má-fé da parte na averbação indevida ou no seu não cancelamento. A sanção não decorre da mera averbação, mas da averbação indevida ou do não cancelamento doloso. A existência de demanda condenatória ou de execução é suficiente para legitimar a averbação, salvo se a demanda for manifestamente temerária, caso em que poderá ocorrer a responsabilização. A responsabilidade será averiguada em autos apartados, em incidente.

Não há necessidade da propositura de demanda autônoma e, portanto, não há interesse processual para o executado em promover ação fora do processo no qual fora requerida a certidão para averbação (art. 485, VI, CPC). A doutrina fala aqui na aplicação do art. 81, § 3.º, CPC, o qual determina que deverá ser “fixada a responsabilização desde logo pelo juiz em quantia entre um e dez por cento do valor da causa ou dimensionada em liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum.”⁴⁰

8. Tutelas provisórias de urgência e a natureza da averbação. O legislador utilizou o termo *tutela provisória* para definir as *tutelas de urgência* (arts. 300 a 310, tutelas cautelar e antecipada, incidentais e antecedentes) e a *tutela da evidência* (art. 311).

Conforme a doutrina, não se pode mais falar em medidas cautelares, mas em tutelas de urgência como gênero, pois “[a] última novidade refere-se ao fato de o legislador ter trocado a expressão “medidas cautelares” por “medidas (...) urgência”, afinal a urgência passou a ser o gênero do qual a cautelar e a satisfativa são espécies. Outrossim, transferiu o conteúdo do art. 615-A do CPC/1973 para o art. 828 do CPC/2015 (destinado corretamente ao processo de execução por quantia contra devedor solvente), fixando a regra de que incumbe ao exequente proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros.”⁴¹

Há, contudo, que se diferenciar entre as finalidades acauteladora da averbação e a finalidade executiva. Para a doutrina, a finalidade acauteladora não se confunde com a finalidade executiva. O art. 828 possui nítida finalidade acauteladora. Nesses termos, “[h]á atos praticados na execução, porém, que, embora possam ter uma finalidade acauteladora, não se caracterizam no rol dos atos executivos. O principal exemplo é o ato previsto no art. 828 do CPC (...). Nessa ordem de ideias, a suspensão dos atos executivos ensejada pelo deferimento do pedido de parcelamento não impede a expedição de certidão atestando que a execução foi deferida e a solicitação, pelo exequente, da averbação prevista no art. 828 do CPC”.⁴² Suspende-se os atos executivos, não os acautelatórios, quando suspensa a execução.

Estamos de acordo com a conclusão, não há que se abrir mão da finalidade acauteladora da averbação durante o período de parcelamento do crédito. A averbação não é suspensa junto com o procedimento executivo, ela continua hígida ao seu propósito de assegurar que, caso não seja

totalmente adimplida a dívida parcelada, possa ser procedida a execução.

9. Inaplicabilidade a fatos pretéritos. O STJ entendeu que não é possível aceitar a aplicabilidade da fraude à execução a fatos pretéritos, para que seja possível falar-se em fraude à execução é necessário que a averbação já tenha ocorrido ou que exista a prova da má-fé do adquirente. Assim, “[o] reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ). Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da má-fé do adquirente, evidenciada com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto (...) *Inaplicabilidade do art. 615-A do CPC a fatos pretéritos.*” (AgRg no REsp 1365627/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 05.05.2015, *DJe* 12.05.2015).

Em *precedente* firmado pela Corte Especial a questão ficou ainda mais clara: “Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3.º do art. 615-A do CPC (...) O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (...) A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. (...) Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4.º, do CPC. (...) Conforme previsto no § 3.º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.” (REsp 956.943/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014, *DJe* 01.12.2014).

Averbar é faculdade do exequente; a vantagem é que gera presunção absoluta de conhecimento pelo terceiro: “Havendo prévio registro, o credor tem o benefício da presunção absoluta de conhecimento pelo terceiro adquirente da pendência do processo (CPC, arts. 615-A e 659). De outro lado, não havendo esse registro prévio, sobre o credor-exequente recai o ônus de demonstrar que o adquirente tinha conhecimento da pendência do processo. Deve, nesse caso, ser resguardada a boa-fé do terceiro” (REsp 437.184/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.09.2012, *DJe* 23.04.2013).

O CPC/2015 também afirmou a ineficácia dessa alienação após a averbação (art. 792, II, § 1.º, CPC). A ausência da averbação atrai o ônus probatório da má-fé do terceiro adquirente para o exequente.

10. Desnecessidade de decisão judicial para obtenção da certidão. *A obtenção da certidão prevista no art. 844 independe de decisão judicial* (130 FPPC). Assim, basta o requerimento em cartório e o pagamento das custas da certidão.

11. Aplicação ao cumprimento de sentença. *As averbações previstas nos arts. 799, IX, e 828 são aplicáveis ao cumprimento de sentença* (529 FPPC). A aplicação decorre da intercambialidade entre o cumprimento de sentença e o processo de execução (arts. 513 e 771, CPC, cf. *supra*, introdução, 2.10).

12. Desnecessidade da certidão do art. 828 para obtenção/averbação de certidão de propositura da execução. *A certidão a que se refere o art. 828 não impede a obtenção e a averbação de certidão da propositura da execução* (art. 799, 539, FPPC). O direito de requerer certidão é assegurado para os fins legais, desde que pagos os emolumentos devidos ou obtida isenção.

13. Identidade e continuidade registral. Na doutrina, indicam-se alguns cuidados que o registrador deve tomar para efetuar a averbação: a) compatibilidade entre o titular do direito real e o executado que consta da certidão; b) existência de prenotação de futuros registros que mereçam atenção específica do registrador por ocasião da averbação; c) cotitularidade do direito real na matrícula por pessoa que não consta da certidão judicial como executada. Cada hipótese deverá gerar procedimentos e consequências distintas, em homenagem aos princípios da identidade (perfeita identificação entre a pessoa titular do direito real e a pessoa cuja a situação

processual justifica o exercício da averbação, art. 799, IX, CPC) e da continuidade registral (eficácia futura da averbação para os fins que a justificam, inclusive para a configuração da fraude à execução, art. 828, § 5.º e 792, II, CPC).

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

1. Citação. A citação abre ao executado três possibilidades: a) pagar; b) embargar; c) requerer o parcelamento da dívida. O prazo para pagar é de três dias da citação. Não se aplica aqui a regra da juntada do mandado de citação, prevista no art. 231, II, CPC.⁴³

Assim, pode o executado efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), com o pagamento integral do principal, honorários de advogado e das custas, haverá a redução à metade da verba honorária, a título de sanção premial (art. 827, § 1.º, CPC). Pode, ainda, embargar a execução independentemente de penhora, depósito ou caução, opondo-se à execução (art. 914, CPC). Há, por fim, a possibilidade de o executado requerer o parcelamento do valor em execução (art. 916, CPC, “[n]o prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”). Neste último caso não poderá opor embargos.

A citação do executado é para efetuar o pagamento da dívida no prazo de três dias (art. 829, CPC). Assim, não paga a dívida no prazo de três dias da citação (e não da sua juntada aos autos), com a juntada aos autos do mandado de citação, ou dos outros instrumentos citatórios, começa a fluir o prazo de 15 (dias) para embargos à execução (art. 915, CPC) ou para requerer o parcelamento (art. 916, CPC).

2. Indicação dos bens pelo exequente e dever de cooperação do executado. A regra é que o exequente deverá indicar os bens à penhora, sendo que não cabe ao executado essa prerrogativa.

Assim, “[p]ode o exequente indicar na petição inicial à penhora bens do executado (art. 829, § 2.º, CPC). Pode inclusive requerer liminarmente a colaboração do órgão jurisdicional a fim de identificar bens do executado que servem à penhora [o que poderá ser efetivado através dos recursos do Bacenju, Renajud e Infojud]. Tendo o juiz o dever de auxílio para com os litigantes, próprio do processo civil pautado pela colaboração (art. 5.º, LV, CF [art. 6.º, CPC]), e tendo o exequente direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5.º, XXXV, CF), tem a parte direito de requerer penhora on-line (arts. 835, I, e 854, CPC) e requerer a expedição de ofícios a entes e/ou serviços cadastrais (por exemplo, registros imobiliários, Detran etc.) a fim de individualizar bens do executado que sirvam à finalidade executiva. Negando-se o órgão jurisdicional a colaborar, estará a frustrar o acesso à ordem jurídica justa.”⁴⁴

Uma vez tenha sido realizada a penhora ou tenha obtido informações sobre a indicação efetuada pelo exequente poderá o executado indicar outros bens, desde que demonstre que há proporcionalidade na nova indicação entre a tutela de seu interesse, com a menor onerosidade possível (art. 805), e a tutela do interesse do exequente, na garantia de que a nova penhora irá mostrar-se igualmente eficaz (art. 797, CPC).

A legislação processual abre a possibilidade de o executado ser obrigado a indicar bens à penhora por determinação judicial.

“O executado, em sendo o caso, tem o dever de indicar bens à penhora (arts. 772, III e 774, V, CPC). Obviamente, tem o dever de indicar bens à penhora atendendo à ordem preferencial (art. 851, CPC). Significa isso que o executado tem o dever de considerar em primeiro lugar a existência de ‘dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira’ (art. 835, I, CPC) para indicação à penhora. Não há racionalidade em estabelecer ordem para a penhora e concluir que o executado pode indicar qualquer bem. Se o executado, dispondo de outros bens, indica bens à penhora desobedecendo à ordem preferencial, tem o juiz o dever de sancioná-lo na forma dos arts. 80, IV, e 81; bem como dos arts. 774, IV, e parágrafo único, CPC, por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça. O juiz pode determinar que o executado indique bens à penhora sob pena de multa coercitiva (art. 537, CPC), a fim de constrangê-lo ao cumprimento (art. 139, IV, CPC), porque o art. 772, III, CPC, impõe dever geral, oponível ao executado e a qualquer terceiro.”⁴⁵

A possibilidade de aplicação de multa coercitiva para a indicação dos bens à penhora é uma demonstração de que, além de serem cabíveis também nos processos de execução as medidas atípicas, elas podem servir para reforçar o procedimento típico, e não somente para substituí-lo. A finalidade do art. 139, IV, é garantir o cumprimento das ordens do juiz que visem à tutela dos direitos adequada, efetiva e tempestiva. Nesse sentido, ver as notas introdutórias a este texto.

O dever de indicar os bens à penhora pelo executado, ademais, trata-se de verdadeiro dever de cooperação (art. 6.º, CPC). O executado deve cooperar objetivamente para com o resultado prático da atividade executiva. Recusando-se a indicar os bens, incide na tipologia dos atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC, “[c]onsidera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que (...) intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exhibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”) e será, conseqüentemente, sancionado em multa não superior a 20% do valor atualizado do débito, exigível nos próprios autos do processo, em favor do exequente e sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e material (art. 774, parágrafo único, CPC). Sendo norma sancionatória, a comprovação de sua incidência não permite alternativa ao juiz em deixar de aplicá-la, sendo dever-poder.

3. Decisão que determina a citação. Será agravável por instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), como todas as decisões interlocutórias no processo de execução, pois gera gravame ao executado, uma vez que o seu patrimônio passa a ser suscetível à constrição pela penhora e à expropriação (STJ, 1ª Turma, REsp 212.018/RJ, rel. Min. Garcia Vieira, j. 17.08.1999, DJ 27.09.1999, p. 57).

4. Litisconsórcio passivo e citação. O STJ tem entendimento no sentido que “havendo litisconsórcio facultativo, desnecessária a citação de todos os devedores para que se inicie o prazo previsto no art. 652, do CPC, sendo perfeitamente válida a penhora realizada em bem de apenas um dos devedores, que responderá somente pela sua cota-parte” (STJ, 1ª Turma, REsp 182.234/SP, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 12.03.2002, DJ 29.04.2002, p. 164).

Havendo pluralidade no polo passivo, o prazo para pagamento e o prazo para embargos do executado serão independentes para cada um dos executados, fluindo conjuntamente (arts. 829, *caput*, e 915, CPC). A única exceção será para os cônjuges (art. 915, § 1.º, CPC), neste caso o prazo começará a fluir da juntada do último comprovante de citação.

5. Penhora e avaliação. O juiz expedirá o mandado de citação determinando desde logo, ao receber a petição inicial executiva, a penhora e avaliação de bens. Serão duas vias – uma para a citação do executado, que será a que importará para fins de comprovação da citação com a juntada aos autos fluindo os prazos a partir daí nos termos dos arts. 829, *caput*, e 915, CPC; a segunda serve ao oficial de justiça, independentemente de novo despacho, para proceder à penhora e à avaliação de bens e valores do executado (arts. 154, V, e 829, § 1.º, CPC), uma vez verificado o não pagamento da dívida.

6. Direito de indicação de bens pelo executado. Ciente da indicação feita pelo exequente ou da penhora realizada pelo oficial de justiça, o executado pode indicar outros bens em seu lugar,

desde que demonstre que essa constrição será menos onerosa para ele e igualmente eficiente para a execução (art. 829, § 2.º). Isso pode ocorrer como modificação à penhora já realizada (art. 847, CPC) ou, desde logo, antes de realizada qualquer penhora (art. 829, § 2.º, CPC), bastando que o juiz tenha ciência dos bens cuja penhora pretende o exequente, para que possa contrastar essa indicação com aquela feita pelo executado. Note-se que não é necessária a prévia ciência ao executado da indicação de bens feita pelo exequente. Do contrário, ter-se-ia burocratização exagerada da execução, em detrimento da duração razoável do processo (art. 4.º, CPC). Porém, caso o executado por alguma razão tenha ciência da indicação feita pelo exequente, ou após a realização da penhora sobre estes bens, pode ele solicitar a modificação da penhora, nas condições do art. 829, § 2.º, CPC.

7. Realização superveniente da penhora e impugnação por simples petição. A penhora pode não ocorrer em um primeiro momento. O problema surge por não ser mais necessária a penhora para a oposição de embargos (art. 914, CPC). A impugnação da penhora incorreta ou avaliação errônea pode se dar por embargos, nos termos do que prevê o art. 917, II, CPC, “[n]os embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) II – penhora incorreta ou avaliação errônea”. Isso pode gerar um problema por já terem sido opostos os embargos, e o prazo ter se expirado ou consumido antes de realizada a constrição. É bom ter presente, portanto, que há o direito de impugnação por *simples petição* a contar da ciência do ato impugnado, previsto no art. 917, § 1.º, CPC, “[a] incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”.

8. Incidente de desconconsideração da pessoa jurídica. O CPC regulou o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. O Código permite alcançar os bens do sócio por dívida da sociedade (desconconsideração da pessoa jurídica), e, também, a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconconsideração inversa da pessoa jurídica). Há previsão de incidente específico nos arts. 133 a 137, CPC, uma novidade da codificação.

No incidente poder-se-á produzir prova das alegações, a respeito da ocorrência dos pressupostos que a autorizam no plano do direito material (conforme o caso, arts. 50, CC/2002 ou 28, CDC, teoria da maior proteção ou subjetiva, e 28, CDC, § 5.º, teoria da menor proteção ou objetiva) a desconconsideração da personalidade jurídica.

Aqui é preciso frisar que há polêmica sobre a aplicação do incidente na Justiça do Trabalho e nos direitos do consumidor e meio ambiente.

Nesses casos, como se trata da teoria da menor proteção da pessoa jurídica, ou teoria objetiva (art. 28, § 5.º, “[t]ambém poderá ser desconconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”), os requisitos cingem-se a dificuldade de satisfazer as obrigações de pagar quantia certa pelo devedor e a existência do débito, não se exigindo prova do abuso da personalidade jurídica, configurado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, característicos da teoria da maior proteção ou subjetiva (art. 50, CC/2002 e art. 28, CDC, *caput*).

Para a desconconsideração pela teoria da maior proteção, não há dúvida de que é preciso que tenha havido debate processual específico a respeito da possibilidade de desconconsideração da pessoa jurídica. Nestes casos, a “[d]ecisão judicial que desconsidere personalidade jurídica sem oitiva da parte interessada é nula por afronta ao direito ao processo justo (art. 5.º, LIV, CF).”⁴⁶

Com a entrada em vigor do CPC ainda não se pacificou o entendimento em relação à teoria da menor proteção da pessoa jurídica ou da desconconsideração objetiva.

O certo é que o Código, no processo de execução, ao afirmar que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, salvo nos casos expressos por lei, justamente visando a manutenção de sua integridade, prevê, no art. 795, § 4.º, que: “[p]ara a desconconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens

quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

1. Pré-penhora. O dispositivo trata da pré-penhora, consistente no arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução no caso de o oficial de justiça não encontrar o executado em seu domicílio. Há também a possibilidade da pré-penhora on-line, arresto on-line, quando o exequente requerer inaudita altera parte na forma do art. 854, §§ 1.º a 5.º, CPC.

O artigo elenca dois pressupostos: a) não ser encontrado o executado; e, b) a identificação de bens penhoráveis.⁴⁷ Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial o art. 830, CPC, “não se aplica faltando qualquer um de seus dois pressupostos (STJ, 3ª Turma, Ag 438.015/DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. 27.05.2003, DJ 10.06.2003)”.⁴⁸

2. Arresto cautelar. Será possível na presença dos requisitos da tutela de urgência cautelar. Há pelo menos uma decisão favorável ao caráter cautelar do arresto on-line mesmo de forma antecipada: “Admite-se a medida cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC.” (REsp 1407723/RS, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 21.11.2013, DJe 29.11.2013).

Atualmente o arresto não é mais previsto como procedimento cautelar nominado e autônomo, uma vez que no CPC não há procedimentos cautelares nominados ou mesmo um livro para o processo cautelar. O arresto é mencionado entre as medidas ou tutelas cautelares no art. 301, segundo o qual, “[a] tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito”.

Afirmando o cabimento do arresto on-line: “O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on-line, como também o arresto on-line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o ‘arresto prévio’ (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos corresponsáveis (rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.12.2010)”. (REsp 1240270/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011).

3. Citação. Com a realização da pré-penhora, é necessário citar o executado. O oficial procurará o executado por mais duas vezes, em dias distintos, para citá-lo e cientificá-lo. Não o encontrando, cabe ao oficial certificar e buscar efetuar a citação do executado por outro meio, e, havendo suspeita de ocultação, proceder à citação com hora certa, em consonância com a Súmula 196 do STJ (“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”) que já dispunha de maneira similar quanto a essa possibilidade.

Não sendo o caso de ocultação ou frustrada a citação por hora certa, deverá proceder na citação por edital. “Não havendo essa suspeita, deve o exequente requerer a citação por edital.” Neste caso, é obrigatório o requerimento, sob pena de extinção da execução e desfazimento da penhora: “A ausência de requerimento do exequente para citação do executado por edital importa desfazimento da pré-penhora e extinção da execução”.⁴⁹

A doutrina aponta que a escolha do legislador decorreu da construção jurisprudencial anterior ao CPC. Nesses termos, afirma que seguindo “a orientação firmada no âmbito do STJ de que ‘é possível a citação por hora certa em processo de execução’ (AgRg no REsp 1.131.711/SP, 4ª Turma, j. 05.06.2014, rel. Min. Marco Buzzi, *DJe* 12.06.2014), o art. 830, § 2.º, NCPC (Lei 13.105/2015) tratou de admitir de forma expressa a citação por hora certa, sendo a editalícia admitida apenas quando infrutífera aquela outra. ‘Art. 830. (...) § 2.º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.’”⁵⁰

4. Conversão automática. Findo o prazo da citação por edital (arts. 231, IV, e 257, III, CPC), converte-se a pré-penhora automaticamente em penhora. Isso ocorre caso o executado não tenha efetuado o pagamento, quer por não ter comparecido, quer por comparecendo não ter pago no prazo de 3 (três) dias (art. 829, CPC). A conversão é automática. Logo “A conversão independe de requerimento da parte ou de qualquer manifestação do juiz nesse sentido (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 238.097/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2001, *DJ* 18.02.2002, p. 410)”.⁵¹

No arresto on-line (bloqueio anterior à penhora on-line com indisponibilidade dos valores depositados em conta), o prazo de defesa será de cinco dias após a intimação e, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz determinar a instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, § 5.º).

A doutrina entende que, somente quando não encontrado o executado, caberá o arresto executivo sobre dinheiro (indisponibilidade ou bloqueio – arresto *on-line*): “Já em relação ao *arresto executivo sobre dinheiro* (CPC/1973, art. 653 c/c art. 654; NCPC/2015, art. 830), o mesmo somente deve ser concedido quando, apesar de procurado, o devedor não é encontrado, e o oficial de justiça depara-se com a existência de dinheiro em nome do devedor. Isso ocorre porque o arresto executivo tem por fito evitar que a frustração da citação impeça o desenvolvimento regular da execução.”⁵²

5. Desnecessidade de intimação da conversão da pré-penhora em penhora por não ser mais necessária a penhora para o oferecimento de embargos. As mudanças no procedimento acarretaram que não é mais necessária a intimação do executado da conversão da pré-penhora em penhora. Isso ocorre porque, para a oposição dos embargos, não é mais necessária a penhora, o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos embargos flui da *citação* para os embargos, nos termos do art. 915, CPC.

Sob a égide do CPC anterior, à jurisprudência exigia – antes das reformas de 2005 – a intimação da conversão, porque da penhora fluía o prazo para o executado propor embargos do executado (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 238.097/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2001, *DJ* 18.02.2002, p. 410).

Naquela época, a oposição de embargos dependia da segurança do juízo. A penhora era o pressuposto para propositura de embargos do executado. Atualmente, o prazo para os embargos do executado flui: a) da juntada do mandado de citação do executado aos autos (art. 915, CPC); b) da data em que finda a dilação assinada pelo juiz na citação por edital (art. 231, IV, CPC). De qualquer sorte, o prazo se dá independentemente de penhora (art. 914, CPC, “[o] executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”). Logo, não é mais necessária “a intimação do executado da conversão da pré-penhora em penhora”.⁵³

Subseção I Do objeto da penhora⁵⁴

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

1. Aspectos introdutórios. O dispositivo em questão inaugura a Seção III que trata da penhora, do depósito e da avaliação. Em relação ao CPC/1973, não traz muitas novidades, apenas alterações redacionais que não influenciaram o conteúdo material da prescrição prevista no artigo. As novidades ocorrem principalmente se compararmos os dispositivos aqui presentes com a grande gama de novidades do CPC que são aplicáveis à penhora: a) a atipicidade como forma de aceleração dos procedimentos e flexibilização dos procedimentos executivos (art. 139, IV, CPC); b) os negócios processuais (art. 190, CPC); b) a conciliação a qualquer tempo (art. 515, § 2.º, CPC); c) os precedentes judiciais com força normativa (arts. 926, 927 e 489, § 1.º, V e VI, CPC); d) os meios executivos eletrônicos, *e-justice* (cf. introdução, 2.14 a 2.18 e 3). Também é ideal analisarmos nosso modelo de execução a partir das potenciais mudanças futuras, já em curso nos modelos de direito comparado (cf. introdução, 2.4).

2. Conceito e objetivo da penhora. Vale destacar que, por meio da *responsabilidade patrimonial* o devedor ou o responsável responde à dívida com todo seu patrimônio, ou seja, todos os seus bens estarão sujeitos à atividade executiva satisfativa (art. 789, CPC).

Nesse sentido, conceitua-se a penhora como um ato executivo instrumental que identifica no patrimônio do devedor ou responsável quais bens estarão sujeitos à expropriação, ou seja, dentre a universalidade dos bens do devedor ou responsável apontam-se quais bens servirão ao ato final da expropriação, sendo exatamente este seu objetivo principal.⁵⁵

3. Objeto da penhora. A partir do conceito e do objetivo, torna-se fácil identificar qual o objeto da penhora, serão exatamente todos os bens passíveis de valoração econômica para satisfação do valor exequendo, que como se observa da redação do artigo será composto também de eventuais juros, das custas processuais e dos honorários advocatícios, salvo os impenhoráveis (cf., na sequência, os comentários aos arts. 832 e 833, CPC).

Vale destacar ainda que, qualquer despesa que o exequente venha a possuir no decorrer da execução poderá ser incorporada a esse montante principal, como, por exemplo, já decidiu o STJ (REsp 300.044/SP) em relação às despesas com a inscrição da penhora.

Assim, a princípio não se pode negar ou descartar a possibilidade de que a penhora alcance um valor maior do que o montante inicial principal (valor da dívida atualizada, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios).⁵⁶

Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.

1. Bens Impenhoráveis e Inalienáveis. Nesse ponto, o CPC reproduziu literalmente a regra prevista no art. 648 do CPC/1973, dessa forma, prescreve que não podem ser objetos da execução, inclusive da penhora, aqueles bens considerados em lei, impenhoráveis ou inalienáveis. Essa é uma das restrições legais a que faz menção o art. 789 do CPC.

Vale destacar, ainda, que essa natureza impenhorável ou inalienável atribuída aos bens decorrerá na maior parte das vezes do texto legal, mas existe a possibilidade, muito embora com forte carga argumentativa e decisão amparada em fundamentação adequada, de que o juiz venha a determinar que bem não previsto na listagem legal é impenhorável ou inalienável.

Consideram-se como bens impenhoráveis exatamente aqueles que não são suscetíveis de penhora. O art. 833 do CPC traz um rol de bens que possuem esta característica. O rol, entretanto, não é taxativo, ou seja, existem e poderão existir outras hipóteses de impenhorabilidade previstas em legislação extravagante, como, por exemplo, os imóveis de uso residencial e os bens de família

voluntários e involuntários (Lei 8.009/1990 e arts. 1.711 e 1712 do CC/2002). Também poderá ser estabelecida a impenhorabilidade por negócio processual, mediante o pacto de impenhorabilidade (art. 190, cf. introdução, 2.17, Enunciado FPPC n. 19).

Por outro lado, os bens inalienáveis conceituam-se como aqueles que o proprietário não pode dispor de forma alguma, logo, percebe-se que a inalienabilidade abrange também a impenhorabilidade, podendo-se afirmar que todo o bem considerado inalienável também será impenhorável, art. 1.911 do CC/2002, já que, uma vez que o bem não poderá ser expropriado, não faz sentido nenhum possibilitar-se a penhora.⁵⁷

2. Disponibilidade. Existe ainda discussão quanto à possibilidade de o próprio executado indicar bens considerados como impenhoráveis. Nesse sentido, com ressalva aos bens de família e aos inalienáveis (STJ, 4.^a t., AgRg nos EDcl no REsp 787.707/RS, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 14.11.2006, DJ 04.12.2006), o STJ já entendeu ser possível essa atitude por parte do próprio executado, dispondo ele mesmo da impenhorabilidade de determinados bens (STJ, 3.^a t., REsp 351.932/SP, rel. Min. Castro Filho, j. 14.10.2003, DJ 09.12.2003). Como veremos a seguir (art. 833, 1), este raciocínio está de acordo com a compreensão das impenhorabilidades a partir da teoria dos direitos fundamentais e do direito fundamental à liberdade de contratar (autonomia da vontade e *pacta sunt servanda*). Se vale para o próprio executado, em momento anterior à execução, evidentemente valerá para cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade estabelecidas por terceiros nos casos de transferência do bem para o executado.

Art. 833. São impenhoráveis:

I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III – os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI – o seguro de vida;

VII – os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

XI – os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII – os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de

incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do *caput* não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do *caput* os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

1. O espectro constitucional de limitação à penhora. A impenhorabilidade é atualmente ligada aos direitos fundamentais.

Sua matriz constitucional não é o direito à propriedade, mas outros direitos fundamentais como o direito à dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, CF/1988) e, além deste, o autorregramento da vontade (direito fundamental civil, *introdução*, 2.1.), a função social da empresa (como desdobramento dos interesses públicos e dos direitos individuais e coletivos dos empregados considerados também como direitos fundamentais sociais), entre outros.

O executado tem seus bens e patrimônio protegidos, na medida em que a legislação estabelece limites à execução para preservação de direitos fundamentais.

O ato lícito de disposição dos bens (e, também, o ato ilícito) resulta na responsabilização do devedor e dá ensejo à tutela do crédito. Estes atos estão no âmbito das responsabilidades civis (autonomia da vontade e responsabilidade civil)⁵⁸ e os bens e o patrimônio do executado respondem pela dívida em dinheiro por força do *princípio da patrimonialidade* (art. 789, CPC).⁵⁹ Trata-se de noção básica, o executado responde pela execução com *todos os seus bens presentes e futuros*.⁶⁰

Assim, para enfrentar o problema, iremos definir três critérios:

a) a *impenhorabilidade* será *absoluta* ou *relativa*, essa poderá ocorrer quanto aos sujeitos (impenhorabilidade absoluta subjetiva) e quanto às espécies de obrigações a que se pode opor a impenhorabilidade (impenhorabilidade objetiva), se para todos sujeitos e objetos (impenhorabilidade absoluta)⁶¹ ou para apenas alguns sujeitos e objetos (impenhorabilidade relativa)⁶²,⁶³

b) impenhorabilidade parcial, quando a própria lei estabelece o limite acima do qual é permitida a penhora (ex., art. 833, § 3.º, naquilo que os vencimentos ou salários etc. superarem o valor de 50 salários mínimos);

c) a *impenhorabilidade* será *indisponível* ou *disponível*, conforme seja possível, por ato voluntário do próprio executado, dispor ou não da impenhorabilidade.⁶⁴ Havendo disponibilidade, haverá preclusão na ausência de alegação oportuna da impenhorabilidade como consequência do não exercício desse direito no primeiro momento em que se afigura possível nos autos.⁶⁵ Isso é assim porque, querendo o executado, poderá solver a dívida alienando o bem impenhorável e se pode alienar o bem também pode admitir a sua penhora e expropriação.

O tema, contudo, não é pacífico. Há dissidência na doutrina quanto à manutenção das categorias de impenhorabilidade. A comparação entre os artigos 833, CPC/2015, e 649, CPC/1973, pareceria indicar que a espécie de impenhorabilidade absoluta teria deixado de existir.

Neste caminho, há quem defenda na doutrina que não faz mais sentido a distinção entre as

espécies de impenhorabilidades absoluta e relativa. “Já no sistema do CPC/2015, não se fala mais, em seu art. 833, em bens ‘absolutamente impenhoráveis’, não havendo razão, portanto, para a classificação das impenhorabilidades em absolutas e relativas. Aliás, considerando o fato de que a aplicação, ou não, de uma hipótese de impenhorabilidade deve considerar, sempre, os valores conflitantes no caso concreto, convém, mesmo, abolir a ideia de que haveria impenhorabilidades absolutas”.⁶⁶

Nos parece que a conclusão vai além do momento atual da nossa tradição jurídica e cria excessivo relativismo. A impenhorabilidade continua a existir em suas modalidades absoluta e relativa, sendo possível, assim como o é na teoria dos direitos fundamentais, a seguir analisada, reduzi-la às hipóteses legais e ao núcleo do direito fundamental tutelado.

Um exemplo de proteção absoluta é o caso do seguro de vida. A previsão típica do seguro de vida protege o prêmio pago para a garantia do seguro (salvo se rescindido o contrato pelo próprio contratante) e o *direito expectativo* ao valor segurado que tem o beneficiário em caso de morte do segurado. Essa impenhorabilidade é absoluta. Contudo, não atinge o valor recebido caso ocorra o sinistro, pois então o valor passa a integrar o patrimônio do beneficiário. A impenhorabilidade absoluta diz respeito ao valor já integralizado no prêmio e ao *direito expectativo*. O direito fundamental protegido aqui é a ideia de ato jurídico perfeito e autonomia da vontade ligada à decisão anterior do contratante em empenhar determinado prêmio para garantia do beneficiário em caso de sua morte (cf., abaixo, item 9).

É importante perceber que as impenhorabilidades estão assentadas em direitos fundamentais, assim como suas restrições e exceções. A teoria dos direitos fundamentais permite-nos visualizar, ademais, que há interesse público na impenhorabilidade – o que não quer dizer que as normas que tratam da impenhorabilidade sejam de ordem pública, de caráter indisponível, inderrogável e inalterável por si mesmas.⁶⁷

A teoria dos direitos fundamentais deve ser compreendida como um modelo combinado de normas. As normas de direitos fundamentais podem ser compreendidas como normas-regras, normas-princípios e normas-procedimentos.

“O que até agora descrevemos, no nível da regra e dos princípios, não proporciona um quadro completo do sistema jurídico. Nem os princípios, nem as regras, regulam por si mesmos sua aplicação. Eles representam somente a face passiva do sistema jurídico. Se se quer obter um modelo completo, temos que agregar à face passiva uma ativa, referente ao procedimento de aplicação das regras e princípios. Portanto, os níveis das regras e princípios têm que ser completados com um terceiro nível. Em um sistema orientado pelo conceito da razão prática, este terceiro nível pode ser somente o de um procedimento que assegure a racionalidade. Desta maneira, surge um modelo de sistema jurídico de três níveis que pode ser chamado ‘modelo regras/princípios/procedimentos’”.⁶⁸

O Código de Processo Civil, no art. 833, indica um rol típico de impenhorabilidades com hipóteses absolutas, relativas e parciais, no formato de regras, que funcionam como razões determinativas para as impenhorabilidades ali descritas.⁶⁹ Contudo, como as normas sobre impenhorabilidade são normas fundamentais, as normas sobre impenhorabilidade podem se apresentar como normas de cada uma das espécies normativas (regras, princípios e procedimentos).

Não existem direitos fundamentais absolutos no sentido de que, em face de outros direitos fundamentais, deve ser efetuado o seu sopesamento, mediante ponderação (arts. 8.º e 489, § 2.º, CPC). Os direitos fundamentais, embora indisponíveis e universais, admitem restrições, em face de outros direitos fundamentais, além de admitirem a disponibilidade⁷⁰ e a renúncia⁷¹ por ato voluntário praticado pelo titular do próprio direito. Em ambas as situações há sempre o limite do núcleo essencial.

Assim, restrições de direitos fundamentais têm como limite a impossibilidade de eliminação de seu núcleo essencial e somente se justificam as restrições se fundamentadas em outros direitos

fundamentais.⁷²

O raciocínio não é diferente com a impenhorabilidade, pois devem ser admitidas restrições das restrições. A impenhorabilidade é uma restrição explícita ao direito fundamental à *tutela do crédito* e ao *direito fundamental ao processo para a tutela do crédito* (cf. premissas, 1.1). A impenhorabilidade somente pode se fundamentar, portanto, como uma restrição de direitos fundamentais que é, quando justamente fundada em direitos fundamentais do executado ou de terceiros que entrem em relação com o executado ou seu patrimônio. Dito isso, é bom perceber que os bens do executado e seu patrimônio não estão, de regra, protegidos por direitos fundamentais. Os bens do executado e seu patrimônio são, de regra, direitos disponíveis, por natureza, de caráter privado – direitos de propriedade dos quais o executado pode usar, fruir e dispor. Portanto, eles são um desdobramento da autonomia da vontade que é um dos princípios formais das democracias constitucionais.⁷³

A distinção é importante porque na comparação das posições jurídicas na execução o credor/exequente, *prima facie*, possui dois direitos fundamentais: um de origem material e outro de origem processual. Por um lado, na esfera material, o direito à propriedade, percebido na perspectiva ampla, inclui o *direito do credor à tutela do crédito*, não se confundindo com o direito de propriedade (privado e disponível, cf. *supra*, introdução, 2.1). Por outro, na esfera processual, o *direito fundamental à tutela processual do crédito* implica organização e procedimentos necessários à sua efetivação. Portanto, restrições aos direitos fundamentais do exequente exigem uma justificativa adequada de direitos fundamentais, sob pena de frustrar as posições jusfundamentais das quais o próprio credor é titular.

A partir deste quadro de direitos fundamentais, é possível construir algumas propostas para o tema da impenhorabilidade. A doutrina divide entre impenhorabilidade indisponível (art. 833, I, CPC) e impenhorabilidade disponível (arts. 833, II a XII).⁷⁴ A impenhorabilidade indisponível decorre da inalienabilidade (indisponibilidade) dos bens, não incidindo sobre ela a preclusão. A impenhorabilidade, nestes casos, pode ser alegada a qualquer tempo. A impenhorabilidade disponível, por sua vez, é afastável por atitude voluntária da parte a quem a impenhorabilidade beneficia (o executado, de regra), sendo que a sua não alegação gera a preclusão (relevância da omissão como ato de vontade).

Assim, no mesmo sentido, “[a] impenhorabilidade de certos bens é uma restrição ao direito fundamental à tutela executiva. É técnica processual que limita a atividade executiva e que se justifica como meio de proteção de alguns bens jurídicos relevantes, como a dignidade do executado, o direito ao patrimônio mínimo e a função social da empresa”.⁷⁵

Em razão disso, ao analisarmos as diversas hipóteses de impenhorabilidade que são previstas no art. 833, CPC, devemos ter presente que as restrições aos direitos fundamentais precisam se amparar em uma correta justificação de direitos fundamentais.

Mesmo novas hipóteses de impenhorabilidade não previstas poderão, por consequência, surgir, desde que corretamente amparadas na justificação de direitos fundamentais que as justificará como restrição.⁷⁶

Por outro lado, será possível, mediante o ônus argumentativo adequado, demonstrar a existência de *restrições às restrições*, afastando a impenhorabilidade em benefício da tutela do crédito.

A fundamentação, nesses casos, deverá seguir os parâmetros previstos no art. 489, §§ 1.º e 2.º do CPC e os deveres de estabilidade, coerência e integridade que determina o art. 926, CPC, com vistas à universalização e a formação de precedentes normativos formalmente vinculantes (cf. introdução, 2.15).

É bom, portanto, ter presente que a tipicidade é a regra da impenhorabilidade, assim como a tipicidade é a regra da execução para pagamento de quantia certa. Afastar a aplicação de uma regra exige ônus argumentativo adequado, pois há presunção *prima facie* de constitucionalidade e

incidência. Regras são razões determinativas. O princípio democrático (ter passado por processo legislativo regular) atribui à regra um caráter *prima facie* de que estas devem ser aplicadas quando incidem, independentemente de outras razões que poderiam ser aplicadas ao caso. Para afastar essa presunção, é necessário demonstrar a existência de outras regras aplicáveis ou a inconstitucionalidade da regra.⁷⁷

A regra da impenhorabilidade precisa ser adequada à distinção entre texto e norma e à possibilidade de extrair normas implícitas por fundamentação adequada a partir de direitos fundamentais.

Nos casos concretos, precisará ocorrer uma análise da constitucionalidade da restrição e das restrições à restrição. A regra legal da impenhorabilidade é em princípio típica, mas admite ampliações e restrições por força da existência de direitos fundamentais implícitos e posições jurídicas fundamentais não previstas nas hipóteses casuísticas na regra declinada. A doutrina denominou este processo de *duplo juízo de proporcionalidade*, no primeiro juízo *a)* a norma que estabelece a impenhorabilidade é constitucional em abstrato; no segundo, *b)* a norma que estabelece a impenhorabilidade poderá ser desaplicada em controle de constitucionalidade difuso em razão das peculiaridades do caso concreto, afastando-se as impenhorabilidades disponíveis já existentes ou criando-se novos casos de impenhorabilidade como exceção positiva à tipicidade.

Na primeira hipótese, o exemplo mais citado na doutrina, consistente no caso do executado que ostenta riqueza sem patrimônio penhorável, vivendo em condições luxuosas em “mansão nababesca” de alto valor imobiliário, serve de parâmetro para o afastamento da regra da impenhorabilidade e a consequente permissão da penhorabilidade do imóvel, desde que reservado valor ou parcela do bem para a garantia da dignidade do devedor. Garantida a dignidade da pessoa humana, salvo a inalienabilidade do imóvel, não há razão para deixar de temperar as regras de impenhorabilidade com o direito à tutela do crédito.

Na segunda hipótese, a impenhorabilidade poderá ser afastada no caso concreto, como já ocorreu na jurisprudência da Corte Constitucional italiana. A Corte decidiu que uma “cadeira de rodas” em uso pelo executado não poderia ser penhorada, portanto, reconheceu a impenhorabilidade de bem não expresso na relação de bens impenhoráveis. Há outros exemplos na doutrina que defende a impenhorabilidade implícita: *a)* o cão-guia do cego; *b)* a aliança de compromisso na união estável etc.⁷⁸

A regra da impenhorabilidade dos bens prevista nos incs. do art. 833 do CPC toma como parâmetro principal dois princípios previstos na Constituição Federal de 1988: *a)* a *função social da propriedade* (art. 5.º, XXIII, da CF/1988); e, *b)* a *dignidade da pessoa humana* (art. 1.º, III, da CF/1988).⁷⁹

Trata-se de um desdobramento da experiência romana, lusitana e brasileira do *beneficium competentiae*, pelo qual vedava-se a execução infamante que viesse reduzir o devedor à indigência.⁸⁰

Afirma-se isso, pois, ao analisar o rol dos bens impenhoráveis previsto no artigo em comento, pretendeu o legislador garantir um mínimo existencial de bens ao executado, que garantam sua subsistência e também a de seus dependentes; além de conservar-se, em algumas situações, a função social que vem sendo desempenhada pelo bem ou pelos recursos com destinação considerada social, como ocorre no caso do inc. IX deste regramento (os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social).

Por outro lado, os casos de impenhorabilidade não devem ser absolutos ou muito amplos. Também devemos relembrar que, do ponto de vista do credor, a execução sempre resulta da tutela do crédito como direito fundamental à propriedade (direito de tornar-se proprietário) e à tutela processual do crédito (processo justo, *fair trail*, *procès équitable*, *processo giusto*) e poderá resultar da necessidade de efetivação de direitos fundamentais ainda mais urgentes e essenciais, como acontece no caso de execução para pagamento de prestação alimentícia,⁸¹ a qual tem por

fundamento o direito fundamental à vida.

2. Possibilidade de preclusão. Atualmente, o STJ possui precedente afirmando que cabe ao interessado arguir no primeiro momento que se manifestar nos autos sobre a impenhorabilidade de determinado bem, sob pena de preclusão (EAREsp 223.196/RS, Corte Especial, rel. Min. Eliana Calmon, rel. p. ac. Min. Nancy Andrighi, j. 20.11.2013, *DJe* 18.02.2014), porém, tal regra não se aplicaria aos imóveis residenciais, considerados como bem de família (Lei 8.009/1990 e arts. 1.711 e 1.712 do CC/2002).⁸²

Com a devida vênia, entende-se aqui que tal precedente merece sofrer exceções e não parece ser uma interpretação constitucionalmente mais adequada para todos os casos, isso porque, como prevê o art. 1.º do CPC, todo o processo será ordenado conforme a Constituição e já reconhecemos como premissa deste trabalho o *favor creditoris*.

Logo, tendo em vista os princípios constitucionais citados acima – dignidade da pessoa humana e função social da propriedade – deveria se permitir ao executado a possibilidade de alegar a impenhorabilidade do bem nomeado à penhora na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos em relação aos bens impenhoráveis, não importa se a impenhorabilidade seja absoluta ou relativa, uma vez que, para fins de preclusão, o que importa é se o bem é ou não disponível. Sendo disponível o bem haverá preclusão. Portanto, a questão se resolve na dimensão da indisponibilidade ou disponibilidade, sendo indisponível o bem não há preclusão, como é o caso dos bens inalienáveis.

Assim, mesmo na hipótese do bem de família, como se trata de bem alienável – de regra – não se pode opor a impenhorabilidade se o executado deixou de sobre ela se manifestar em tempo oportuno.

A única exceção cabível nesses casos seria a adequada justificação da razão pela qual o executado deixou de fazê-lo, apontando algum vício que permita a reabertura do prazo para a manifestação, afastando a preclusão.

Na doutrina há quem aborde o problema a partir da questão da dicotomia entre impenhorabilidade absoluta e impenhorabilidade relativa. Parcela da doutrina entende que a impenhorabilidade absoluta poderia ser alegada sempre até a transformação do bem e que também a impenhorabilidade relativa poderia ser alegada ao menos até sua adjudicação ou alienação judicial,⁸³ outros, acompanhando o entendimento do STJ irão afirmar que haverá preclusão, nos termos da regra geral, se o executado deixar de se manifestar na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos após a penhora.

Assim, “[p]enhora sobre bem impenhorável *disponível*. Intimado a defender-se, o executado não a questiona, deixando de exercer o seu direito de não ter aquele bem penhorado. Há, no caso, preclusão, pois a invalidade do ato deve ser requerida no primeiro momento em que couber à parte falar nos autos [art. 278]”.⁸⁴

Entendemos em conformidade com a segunda corrente, se o executado pode dispor dos bens convencionalmente a não alegação da impenhorabilidade constitui em concordância com a penhora. No caso concreto, contudo, embora disponível o bem para a penhora, se ao longo da causa ficar constatado possa a expropriação gerar a ofensa ao núcleo essencial dos direitos fundamentais do executado, poderão ser criadas exceções a partir da teoria das restrições aos direitos fundamentais, conforme vimos no item anterior, permitindo-se a superação da eventual preclusão.

3. Supressão da expressão “absolutamente”. Ocorreu alteração significativa no texto do CPC/2015. Em relação ao art. 649 do CPC/1973, o CPC/2015 suprimiu da redação acertadamente a expressão “absolutamente” do *caput* do art. 833.

Conforme analisado nos itens anteriores os bens serão absoluta ou relativamente impenhoráveis conforme a impenhorabilidade possa ser alegada para todos ou em apenas

algumas situações jurídicas e em relação a algumas pessoas. Há também a impenhorabilidade parcial, quando é possível a penhora dos valores que estiverem acima de um determinado teto. A outra distinção relevante é entre a impenhorabilidade de bens indisponíveis e a impenhorabilidade de bens disponíveis. As três categorias se sobrepunham na terminologia do CPC anterior, “impenhorabilidade absoluta”, como ainda se sobrepõem na doutrina, causando grande confusão.

A compreensão que devemos ter é que não há no ordenamento jurídico pátrio a noção de direito fundamental absoluto (art. 60, § 4.º, IV, CF/1988). As posições jurídicas são dinâmicas e dependentes da maneira em que são exercidas (cf., *supra*, introdução, 5.7), conforme o art. 187 do CC também comete ato ilícito quem no exercício de um direito excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Dessa forma, “não se pode considerar lícito o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, premissa que se aplica também no âmbito da impenhorabilidade (art. 1.º, III, da CF/1988)”.⁸⁵

A impenhorabilidade não será, por consequência, sempre absoluta. Teremos assim três categorias: a) impenhorabilidade absoluta ou relativa; b) impenhorabilidade parcial; c) impenhorabilidade sobre bens disponíveis ou indisponíveis.

4. Bens Inalienáveis e os bens não sujeitos à execução. O inc. I prescreve como impenhoráveis os bens inalienáveis e os não sujeitos à execução. Como se afirmou anteriormente, os bens inalienáveis são aqueles que o proprietário não pode dispor, assim, como, não existe também a possibilidade de que sofram qualquer ato expropriatório, logo, não podem também ser nomeados à penhora, sendo, portanto, impenhoráveis. Outrossim, ainda existe a possibilidade de que um bem venha a se tornar não sujeito à execução por declaração feita por ato *inter vivos* (um contrato de doação com uma cláusula de inalienabilidade) ou ainda *mortis causa*, no caso de declaração contida em testamento.

Quanto ao bem de família (*rectius*: bem imóvel residencial), exemplo de bem imóvel impenhorável (art. 1.º da Lei 8.009/1990), já decidiu o STJ que: “É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação ante o que dispõe o art. 3.º, VII da Lei 8.009/1990” (STJ, REsp Repetitivo 1.363.368/MS, 2ª Seção, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 12.11.2014, *DJe* 21.11.2014), assim como, “a penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família” (STJ, REsp 1.114.767/RS, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.2009). A distinção marcada na doutrina entre o bem de família (arts.1.711 a 1.722, CC/2002) e o imóvel residencial de que trata a Lei n. 8.009/1990 é relevante por demonstrar a diferença de regime jurídico. O STJ, atento a esta distinção, editou o enunciado de Súmula 364, que determina que “[o] conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. Por outro lado, “[a] vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora” (Súmula 449 STJ).

Existem, ainda, alguns entendimentos sumulados que constituem, a partir de seus precedentes (art. 926, § 2.º c/c art. 927, cf. introdução, 2.18), precedentes-norma. “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família” (Súmula 486 STJ); “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação” (Súmula 549 STJ). Há também um precedente em recurso especial repetitivo (art. 927, III, CPC): “é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3.º, VII, da Lei 8.009/1990” (REsp repetitivo 1.363.368/MS).

O STF, em repercussão geral, estabeleceu no “Tema 295 – Penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação” a seguinte Tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3.º, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6.º da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. (RE 612.360/RG, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em

13.08.2010, LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300). Há, contudo, entendimento do STF, mais recente, que, analisando a questão do fiador, decidiu que o bem de família do fiador não pode ser objeto da penhora quando se tratar de locação de imóvel comercial (RE 605.709, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 12.06.2018).

5. Bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas. São considerados como impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, excepcionam-se os bens de alto valor, os quais poderão ser penhorados. Pretendeu-se garantir aqui que bens tidos como artigos de luxo, aqueles que ultrapassam os parâmetros médios de necessidade comum dos indivíduos possam e devam ser nomeados à penhora. Não existe justificativa para o executado manter um alto padrão de vida, com sofisticação e suntuosidade, em detrimento e prejuízo de seus credores. Assim, por exemplo, caso o executado possua em sua residência, por exemplo, cinzeiros de cristal ou obras de arte, estas poderão ser objeto de penhora.

6. Vestuário e Pertences de uso pessoal (inc. III). Assim como fez no inc. II, o legislador ampliou a impenhorabilidade também ao vestuário e aos pertences de uso pessoal do executado, com ressalva daqueles considerados como bens de alto valor. Vestidos de grife e garrafas de vinho de uma adega, se possuírem alto valor, poderão ser penhorados.

7. Remunerações e outras fontes de renda do executado. Nesse inciso consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ou seja, qualquer fonte de renda que tenha natureza alimentar.

Entretanto, em que pese à regra prevista no dispositivo, existem duas exceções, que funcionam como restrições à restrição da penhorabilidade: *a)* execuções de alimentos, não importa a origem (legítimos ou indenizatórios); *b)* rendimentos superiores a cinquenta salários mínimos (art. 833, § 2.º).

Assim, nas execuções para pagamento de prestação alimentícia os rendimentos do executado não ficam imunes à penhora, podendo ser objeto de expropriação, por previsão expressa.

Quanto a esta exceção, é bom ressaltar a restrição da restrição, pois releva-se o fato de que mesmo a penhora podendo incidir sobre as remunerações do executado, nos casos de execução para prestação alimentícia de alimentos vencidos, devem ser resguardados 50% de seus ganhos líquidos, conforme prevê o art. 529, § 3.º do CPC, também com o intuito de salvaguardar um valor mínimo para subsistência do executado (arts. 513 c/c 771). Há entendimento de que tal limitação deve ser aplicada apenas aos casos de execução alimentar, pois *a limitação de que trata o § 3.º do art. 529 não se aplica à execução de dívida não alimentar* (587 FPPC). Nos parece irrazoável tal conclusão, afinal, se a execução alimentar é a que permite a maior amplitude de meios executivos não se poderá limitar essa em detrimento de outras.

Além disso, também foi abarcada nessas situações a possibilidade de serem objeto de penhora, as remunerações previstas no inc. IV, especialmente, no caso de execução de honorários advocatícios. No mesmo sentido já vinha sendo reconhecido pelo STJ (STJ, AgRg no REsp 1.297.419/SP; STJ, AgRg no REsp 1.397.119/MS). Tal fato se dá exatamente, pela natureza alimentar dos honorários, que já reconhecida pelo STF (RE 470.407/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2006) e agora foi confirmada no CPC, em seu art. 85, § 14.º.

A outra restrição à restrição que foi inserida pelo legislador no CPC está prevista no art. 833, § 2.º, determinando que as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais poderão ser objeto de penhora. Tal alteração mostra-se acertada, pois, o executado não pode se escusar de suas obrigações patrimoniais quando recebe tão vultosa quantia, que excede em muito um valor razoável para satisfazer as necessidades médias de um lar brasileiro.

Existem, ainda, duas outras possibilidades de penhora sobre rendas e vencimentos. Estas possibilidades atípicas poderão ensejar a penhora mesmo quando as rendas e vencimentos forem inferiores a 50 salários mínimos. A primeira é a *penhora consensualmente autorizada por negócio jurídico processual atípico* (art. 190 c/c art. 200, cf. *supra*, introdução, 2.17). A segunda é a *penhora das rendas e vencimentos decorrente da cláusula de atipicidade dos meios executivos* prevista no art. 139, IV (dever-poder do juiz, cf. *supra*, introdução, 2.14 e 2.15). Neste último caso deverá estar presente a justificação adequada capaz de afastar a presunção de adequação do procedimento típico. Como dissemos na parte introdutória deste volume, os critérios da complexidade do litígio, do comportamento das partes, da postura do órgão judicial e da relação jurídica de direito material subjacente ao título executivo poderão ensejar a quebra da tipicidade do procedimento executivo para pagamento de quantia desde que demonstrada: a) a adequação meio fim; b) respeitada a necessidade da medida; e c) a proporcionalidade em sentido estrito. Além disso, deve ser permitido o contraditório efetivo e a decisão deverá ser adequadamente justificada (arts. 10 e 489, § 1.º, CPC).

8. Bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Acertadamente o legislador atribuiu a impenhorabilidade aos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens necessários ou úteis ao labor que desempenha o executado, isso porque, garante-se aqui a continuidade do trabalho e a dignidade da pessoa humana do executado. O trabalho inclusive é forma de permitir ao executado que venha a saldar o débito com o exequente. Nesse sentido, basta que o bem seja necessário ou útil para que seja aplicada a impenhorabilidade, por exemplo, já se decidiu pela impenhorabilidade dos micro-ônibus de uma empresa de transportes (STJ, 2ª Turma, REsp 667.866/RS, rel. Min. Franciulli Netto, j. 21.06.2005, DJ 05.09.2005).

Nesse ponto merece ressalva o art. 833, § 3.º, CPC, o qual determina que a impenhorabilidade também recai sobre equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes a produtores rurais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, *exceto* se tais bens foram objeto de contrato de financiamento e estejam vinculados em garantia neste negócio jurídico ou se trate de execução por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

A primeira ressalva diz respeito à relação jurídica que deu origem ao crédito, ora, se o bem foi adquirido com os recursos fornecidos pelo exequente e foram dados em garantia daquela operação de crédito seria despropositado que sobre eles recai-se a impenhorabilidade.

A segunda diz respeito ao direito material tutelado pelo crédito, as dívidas de natureza alimentar, trabalhista e previdenciária tem preferência legal face ao impacto social do descumprimento destas obrigações.

9. O seguro de vida. Garante-se aqui a impenhorabilidade do capital expectativo do executado como benefício de seguro de vida em caso de morte que terceiro lhe garantiu e estipulou antes da morte do segurado, bem como não podendo ser objeto de penhora, para pagamento das dívidas do próprio segurado, o valor retido em seguro de vida. Assim, enquanto não incorporado ao patrimônio do beneficiário a verba do seguro não é penhorável e o prêmio que assegura essa verba também não.

Na doutrina existe alguma polêmica quanto à extensão da norma, se ela atingiria também o beneficiário do seguro após recebimento do valor.

No sentido de que, mesmo após recebido e incorporado ao patrimônio do beneficiário, o valor do seguro continuaria impenhorável posicionam-se Amílcar de Castro,⁸⁶ Bruno Garcia Redondo e Mário Vitor Suarez Lojo,⁸⁷ Daniel Roberto Hertel e Rodrigo Reis Mazzei e Sarah Merçon-Vargas.⁸⁸

No sentido de que apenas o direito expectativo à importância segurada será insuscetível de penhora, bem como os valores referentes ao prêmio já adimplido pelo segurado, Pontes de Miranda e Fredie Didier Jr.

Com razão estes últimos: “É possível a constituição de um capital ou renda impenhorável em

favor de terceiro (art. 813 do Código Civil, já examinado), fato que se subsume à hipótese do inciso I do art. 833, bem impenhorável por declaração de vontade, ou à hipótese do inciso IV, renda de natureza alimentar. A regra do inciso VI do art. 833 do CPC cuida de outra situação, não prevista nos incisos anteriores: a penhora de um crédito futuro, de um direito expectativo; ela é uma repercussão do comando do art. 426 do Código Civil, e serve para impedir a postura ‘corvina’ – semelhante à de um corvo, que aguarda o óbito para consumir o defunto”.⁸⁹

Nada impede, contudo, que, na estipulação do seguro, as demais hipóteses de impenhorabilidade venham a ser somadas à hipótese legal aqui prevista, ampliando-se a impenhorabilidade para atingir o eventual patrimônio incorporado em razão do seguro, quer por expressa declaração de impenhorabilidade (art. 833, I, CPC), quer pela modalidade de seguro ser constituída como garantia alimentar (art. 833, IV, CPC). Mas há necessidade de pactuação expressa nesse sentido. Não se pode presumir que todo o seguro de vida estipulado em favor de terceiro beneficiário tenha natureza alimentar em relação a este.⁹⁰

10. Materiais empregados em obra. Trata-se aqui da impenhorabilidade de todos os materiais empregados e destinados em obras em andamento, exceto se a própria obra estiver sendo objeto de penhora. É assegurada a função social da propriedade, no sentido de que estes materiais quando utilizados na obra agregarão muito mais valor social e econômico do que se fossem considerados sozinhos.

11. Pequena propriedade rural. Considera-se impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Tal regramento consolida a impenhorabilidade constitucional prevista no art. 5.º, XXVI, da CF/1988, o qual determina que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

O CPC atribui dois requisitos para a impenhorabilidade desses bens: a) a propriedade deve ser considerada pequena; e, b) deve ser objeto do trabalho familiar (*pro labore*).

12. Recursos públicos recebidos por instituição privada. Nos termos da Constituição Federal as instituições privadas podem receber recursos públicos para desempenhar atividades de interesse público. A aplicação destes recursos será compulsória nas áreas da educação, saúde e assistência social (arts. 199, § 1.º e 213 da CF/1988). Dessa forma, buscou-se proteger o interesse público primário, de que é titular a coletividade, no sentido de garantir a destinação social desses recursos públicos recebidos por instituições privadas. Além disso, como os recursos são públicos sobre eles incide a impenhorabilidade absoluta e são igualmente indisponíveis, por estarem afetados à finalidade legal.

13. Caderneta de poupança. Coloca-se nesse inciso a salvo da execução os valores depositados em uma ou mais cadernetas de poupança (STJ, 3ª Turma, REsp 1.231.123/SP, rel. Min. Nacy Andrichi, j. 02.08.2012), com limite máximo de até 40 salários mínimos. A principal discussão que ocorre nessa seara é se seria possível ou não que essa impenhorabilidade atinja também outras formas de investimento ou ainda conta-corrente e valores guardados em papel-moeda. Recente precedente do STJ aponta para possibilidade de que esse valor de 40 salários mínimos atinja outras situações de investimento (STJ, 2ª Seção, EREsp 1.330.567/RS, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 10.12.2014), nesse sentido, é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

Também incide sobre esse inciso o art. 833, § 2.º, primeira parte, sendo possível que este valor de até 40 salários mínimos seja objeto de penhoras execuções em que se discuta obrigação de prestar pensão alimentícia.

14. Recursos de Fundo Partidário recebido por partidos políticos. Ainda são considerados

impenhoráveis os recursos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o qual segundo o art. 38 da Lei 9.096/1995 é constituído por: “I – multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; II – recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; III – doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; IV – dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995”. A finalidade partidária decorrente dos investimentos públicos transcende aos interesses dos dirigentes e dos membros do partido, razão pela qual acertada a regra. Contudo, não se pode esquecer que os demais recursos *não* públicos continuam penhoráveis, cabendo inclusive o procedimento da penhora on-line (art. 854, § 9.º).

15. Créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária. Essa previsão não existia no CPC/1973, sendo inserida como uma das novidades em relação ao instituto da penhora. Assim, atualmente, os créditos resultantes da alienação de unidades imobiliárias vinculados à obra de incorporação imobiliária em andamento (art. 28 e ss. da Lei 4.591/1964) não podem ser objeto de execução, sendo óbvio que essa restrição só ocorrerá enquanto a obra estiver em andamento; depois de finalizada, tais créditos poderão sim ser objeto de penhora. Sua finalidade social é clara, evitar que a penhora possa impedir a conclusão da obra, gerando prejuízos a terceiros de boa-fé.

16. Restrição à impenhorabilidade. Ao longo da exposição, nos itens acima, tratamos das hipóteses de restrição da restrição à penhorabilidade previstas no art. 833, §§ 2.º e 3.º, ainda existe uma restrição geral à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 1.º, CPC. Essa exceção à regra determina que *serão penhoráveis bens tidos como impenhoráveis quando, a execução for relativa a dívida contraída para aquisição do próprio bem ou ainda dívida relativa ao próprio bem e de obrigações acessórias que o acompanham* (v.g., taxas).

Uma das mudanças mais importante no modelo de tutela de crédito é permitir a transparência dos ativos dos contratantes, antes de se formalizarem as obrigações contratuais, de forma a permitir uma gestão prévia dos riscos. A transparência patrimonial tem sido objeto de debates no direito comparado como forma de melhorar a tutela do crédito. Assim, o futuro credor poderá obter informações para evitar a situação de insolvência, estimulando uma relação mais sadia com o crédito.⁹¹

Assim, além das hipóteses típicas, como já afirmado, poderemos ter como hipóteses atípicas o afastamento da impenhorabilidade por negócio processual (art. 190 c/c art. 200) e o afastamento da impenhorabilidade por decisão com fundamentação adequada do juiz, fundada no art. 139, IV, CPC.

Art. 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis.

1. Penhorabilidade dos frutos e rendimentos de bens inalienáveis. O dispositivo prevê a possibilidade de que na falta de bens a serem nomeados para a penhora, os frutos e rendimentos provenientes de bens considerados como inalienáveis são penhoráveis, a partir disso, conclui-se que a inalienabilidade de um bem, não acarreta, *a priori*, também na impenhorabilidade de seus frutos e rendimentos.⁹²

Dessa forma, frutos são considerados os bens e utilidades provenientes de outro bem, sem que a separação destes com o bem principal cause a deterioração ou destruição deste (*fructus est quid ex re nasci et renasci solet*). Já os rendimentos são as utilidades periódicas que são oriundas do bem principal, v.g. aluguéis ou juros.⁹³

A norma prevê uma penhorabilidade condicionada, somente no caso de não existirem outros bens, estes frutos e rendimentos passarão a ser penhoráveis.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

- I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;**
- II – títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;**
- III – títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;**
- IV – veículos de via terrestre;**
- V – bens imóveis;**
- VI – bens móveis em geral;**
- VII – semoventes;**
- VIII – navios e aeronaves;**
- IX – ações e quotas de sociedades simples e empresárias;**
- X – percentual do faturamento de empresa devedora;**
- XI – pedras e metais preciosos;**
- XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;**
- XIII – outros direitos.**

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no *caput* de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

1. Ordem preferencial da penhora. O artigo traz uma ordem de bens que deve ser preferencialmente seguida, quando da realização da penhora sobre a universalidade de bens do executado (art. 789 do CPC/2015), nosso diploma processual adotou uma técnica de execução por graus,⁹⁴ partindo da presunção relativa da liquidez do bem. Também é evidente que tal ordem, tem o intuito de, por um lado, garantir a satisfação integral e em tempo razoável do crédito do exequente (art. 797 do CPC/2015), e, por outro, garantir a menor onerosidade no patrimônio do executado (art. 805, CPC). Preservam-se assim os dois vetores privados principais da execução. Há também uma preocupação com o interesse público, tanto na escolha de meios que exigem menor comprometimento do Poder Público para avaliação, depósito e expropriação, quanto na preservação dos interesses sociais, como a função social da empresa, visto que quotas sociais e o percentual do faturamento são encartados no rol depois de outros bens preferenciais.

Vale aduzir que, como o direito será de regra disponível, as partes podem convencionar sobre a ordem da penhora por negócio processual (art. 190 do CPC/2015). Isto efetivamente ocorre quando as partes estabelecem por convenção garantia real, pois neste caso (*e.g.* hipoteca) a garantia real preferirá a todos os demais bens listados (art. 835, § 3.º), constituindo-se em espécie de negócio processual típico.

No que diz respeito às alterações em relação ao CPC/1973, Marcelo Abelha resume com precisão que “[n]o tocante à ordem de preferência dos bens penhoráveis o legislador alterou a sequência prevista no art. 655 do CPC/1973 tendo em vista a presunção, sempre relativa, da liquidez do

referido bem. Assim, trouxe os incs. IX e X do art. 655 do CPC/1973 para o topo da lista dos bens com maior liquidez, passando a ocupar os incs. II e III do art. 835 do NCPC (Lei 13.105/2015). Além disso, incluiu um novo dispositivo, o inc. XII que trata da penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia” e o inc. XIII que é norma de encerramento.”⁹⁵

2. Não obrigatoriedade da Ordem. Como o próprio dispositivo aponta, a ordem prevista é preferencial, deve ser seguida como um norte em relação à penhora, assim, caso um bem que esteja mais abaixo na ordem em relação a outro e possibilite mais eficazmente a satisfação do crédito, deve tal bem ser penhorado, com exceção do dinheiro – que será sempre prioritário, mas não tem caráter absoluto – como veremos na sequência (art. 835, § 1.º, do CPC/2015). Nesse sentido já apontava o STJ: “A ordem legal estabelecida para a nomeação de bens à penhora não tem caráter rígido, absoluto, devendo atender às circunstâncias do caso concreto, à satisfação do crédito e à forma menos onerosa para o devedor, ‘a fim de tornar mais fácil e rápida a execução e de conciliar quanto possível os interesses das partes’. A gradação legal há de ter em conta, de um lado, o objetivo de satisfação do crédito e, de outro, a forma menos onerosa para o devedor. A conciliação desses dois princípios é que deve nortear a interpretação da lei processual” (STJ, 4.ª T., REsp 167.158/PE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 17.06.1999, também cf., STJ, 1.ª Turma, Ag Rg no REsp 1.229.390/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02.04.2013). Existem precedentes no STJ que determinam que “[n]a execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto” (Súmula 417, STJ).

No próprio texto do art. 835 do CPC/2015 podemos conferir tal característica, por exemplo, a penhora sobre percentual do faturamento de empresa (inciso X) está acima dos metais ou pedras preciosos (inciso XI). Entretanto, o art. 866 do CPC/2015, estabelece que a penhora sobre percentual do faturamento de empresa só será efetivada caso não existam outros bens a serem penhorados, sendo assim, existiria a possibilidade de que metais ou pedras preciosos fossem penhorados antes do faturamento empresarial. No caso, a lógica que determinaria a inversão seria justamente o interesse público na função social da empresa previsto no art. 866.

3. Penhora de dinheiro. É nítida a prioridade da penhora de dinheiro em detrimento dos demais bens, isso fica claro tanto na leitura do próprio art. 835 do CPC/2015 que coloca a pecúnia no máximo patamar (inciso I) e também do § 1.º, que determina ser *prioritária a penhora em dinheiro*.

Além disso, é evidente também que o dinheiro é a forma mais eficaz e efetiva de quitar o crédito do exequente, pois, não necessita expropriação. Na tríplice hierarquia de interesses da execução a penhora de dinheiro atende à finalidade da tutela do crédito de forma mais adequada, tanto no interesse do exequente, como no interesse público, uma vez que atua sem onerar o Poder Judiciário com o procedimento excessivamente lento e custoso de expropriação, especialmente se efetuada mediante o procedimento da penhora *on-line* (art. 854, CPC/2015).

Outrossim, cremos que em função do art. 835, § 1.º, o enunciado da Súmula 417 do STJ (“*Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto*”) somente pode ser interpretado à luz da preferência da garantia real (art. 835, § 3.º do CPC/2015) ou de preferência decorrente de negócio processual (art. 190, CPC/2015). Neste sentido, não havendo norma convencional em sentido contrário será prioritária a penhora em dinheiro.”⁹⁶

4. Fiança bancária e seguro garantia judicial. O art. 835, § 2.º do CPC/2015 estabelece que pode acontecer a substituição da penhora quando for oferecida fiança bancária ou seguro garantia judicial em valor não inferior ao débito inicial acrescido de 30% (trinta por cento), sendo que tais garantias equiparam-se ao dinheiro em relação a prioridade, logo, podem substituir qualquer outro bem, inclusive o dinheiro, nessa perspectiva já apontava a jurisprudência do STJ (REsp 1.116.647/ES, 3.ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 15/3/2011, DJe 25/3/2011).

5. Penhora e garantia real. Quando a execução for de crédito com garantia real, a penhora deverá ser feita sobre a coisa dada em garantia, inclusive se esta pertencer a terceiro, o qual será também intimado da penhora (§ 3.º do art. 835 do CPC/2015). Esta regra excepciona a ordem do

art. 835 do CPC, como regra geral, e constitui exemplo de negócio processual típico.

Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

§ 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnece a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica.

§ 2º Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz.

1. Utilidade da tutela executiva. O texto legal em questão trabalha com a devida compreensão do *princípio da utilidade da execução*, o qual determina que a atividade executiva somente deve ser levada adiante caso se vislumbre uma mínima satisfação do crédito de que é titular o exequente, caso contrário não faz sentido realizarem-se os atos executivos⁹⁷.

Diante disso, não ocorrerá a penhora quando for evidente que o produto da expropriação dos bens do executado será absorvido integralmente pelo pagamento das custas da execução. Nesse sentido quanto à execução fiscal de baixo valor, cf. art. 20 da Lei 10.522/2002.⁹⁸

2. Execução Fiscal e REsp 1.111.982/SP. O valor da execução fiscal é determinante para o seu processamento. A verificação de que alguns créditos eram mais caros para a Fazenda Pública executar em juízo do que deixar de executar fizeram com que a própria Fazenda Pública lançasse orientações internas para a dispensa da execução, culminando com a edição da Lei 10.522/2002, alterada nos limites pela Lei 11.033/2004. O STJ acabou por encampar o entendimento de que se as execuções não são ajuizadas também não poderiam ser processadas, quando já houvessem sido ajuizadas. Em razão disto fixou precedente no sentido que “[a]s execuções fiscais relativas a débitos iguais ou inferiores a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição. Exegese do artigo 20 da Lei 10.522/2002, com a redação conferida pelo art. 21 da Lei 11.033/2004” (STJ, REsp repetitivo 1111982/SP, rel. Min. Castro Meira, 1.ª Seção, j. 13.05.2009).

Isto não impede a reunião de execuções contra a mesma parte que possa superar este valor (art. 780, CPC/2015).

Claramente devemos evoluir na execução para um modelo misto, no qual estejam autorizadas as execuções iniciadas diretamente pela administração pública e mesmo por agentes privados, com controle de garantias residual pelo juiz.

As execuções são caras porque o procedimento judicial de execução é caro. A ausência de recuperação destes créditos inferiores a dez mil reais é grave, mas muito mais grave é saber que muitos destes créditos se tratam de dívidas decorrentes de deveres descumpridos, como multas ambientais, pagamentos de tributos e outras sanções administrativas. O sistema, assim, estimula a irresponsabilidade pela ausência da sanção atribuída a comportamentos ilícitos, criando um ambiente de baixa respeitabilidade da lei (sobre os modelos de execução no direito comparado e a tendência mundial pela adoção de um modelo misto, cf. introdução, 2.4).

O CNJ realizou extensa pesquisa sobre execuções fiscais, comprovando estatisticamente a ineficiência do processo de execução para cobrança de dívidas em valores inferiores aos custos do processo. A pesquisa é uma das poucas estatísticas que temos para comprovar a ineficiência do nosso processo de execução do ponto de vista econômico.⁹⁹ É possível que se ampliássemos o espectro da pesquisa identificássemos que também as execuções civis estão onerando o sistema de justiça com um custo maior do que os valores recuperados. Esta conclusão nos leva a reafirmar a necessidade de implementarmos meios atípicos mais econômicos, reforços às práticas de autocomposição e, de *lege ferenda*, um modelo misto no qual o juiz tenha atuação residual na execução.

3. Procedimento. Caso não se encontrem bens passíveis de penhora, o oficial de justiça descreverá em certidão quais os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento (§ 1.º do art. 836 do CPC/2015), posteriormente, nomeará o executado como depositário provisório de tais bens até posterior determinação judicial (§ 2.º do art. 836 do CPC/2015). Devem ser observadas aqui as regras sobre impenhorabilidade (art. 833, II e III, CPC/2015).

Subseção II Da documentação da penhora, de seu registro e do depósito¹⁰⁰

Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.

1. Penhora e os meios eletrônicos. O dispositivo possibilita que se comunique a penhora de dinheiro ou de bens imóveis e móveis por meio eletrônico, com o intuito de garantir uma maior efetividade ao procedimento executório. Tal dispositivo está em consonância com a cada vez maior informatização digital do processo e de seus atos, inclusive como prevê o art. 193 do CPC/2015.

Nesse sentido, vale destacar que a penhora *on-line* já é realizada com extremo sucesso devido ao convênio firmado entre o Banco Central e o Poder Judiciário, o denominado sistema do BACENJUD, ou seja: “Atualmente, a penhora é realizada eletronicamente pelos juízes dos principais Tribunais Estaduais e Federais, valendo-se estes da rede mundial de computadores (internet). Trata-se de espécie de *arresto executivo* comumente retratado pelo codinome penhora *on-line*, em que o juiz pode requisitar informações ao gestor do sistema bancário eletronicamente (CPC/1973, art. 659, § 6.º; CPC/2015, art. 837), determinando, a partir de então, a indisponibilidade dos recursos eventualmente encontrados em montante suficiente para satisfazer a execução. No Brasil, o instituto mostrou resultados surpreendentes, em termos de eficácia, junto à execução trabalhista, o que, paulatinamente, motivou sua aplicação excepcional à execução civil, com base em entendimentos jurisprudenciais e doutrinários. Somente por meio das reformas empreendidas pela Lei 11.382, de 06.12.2006, é que foi introduzido o dispositivo legal no Código de Processo Civil de 1973, seguindo o legislador uma tendência manifestada pelo ordenamento jurídico de outros países.”¹⁰¹ A penhora *on-line*, introduzida originalmente pela Reforma, foi prevista no art. 854 do CPC/2015.

Além do BACENJUD, estão sendo utilizados os sistemas RENAJUD (veículos) e INFOJUD, informações da Receita Federal. Há também a possibilidade da penhora de imóveis pelo site www.registradores.org, seguindo o padrão inaugurado pelo sistema ARISP, de São Paulo. Estes modelos de *e-justice* são eficientes e atendem a um só tempo os interesses do exequente e o interesse público em uma justiça civil mais ágil e econômica (cf., introdução, 2.4).

2. Jurisprudência do STJ. O STJ já se manifestou sobre a natureza jurídica do instituto: “No tocante à penhora *on-line*, trata-se de *procedimento por meio do qual o juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao valor devido*. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida ferramenta, foi o de, orientado pela *economia processual, imprimir maior celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual*, o que se percebe na própria exposição de motivos da Lei 11.382/2006, pela qual se demonstrou a prevalência pelo *informalismo*. Esta também foi a linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art. 665 do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bacen-jud), notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor,

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre outros).⁶. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos (...)” (REsp 1220410/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4.^a Turma, julgado em 09.06.2015, *DJe* 30.06.2015). A Resolução CNJ 61/2008, disciplina o uso do Bacen-Jud no âmbito judicial, a Resolução CNJ 236/2016 disciplina a possibilidade para convênios com instituições públicas ou privadas para os fins de tornar efetivas as atividades executivas, a obtenção de informações e o bloqueio de bens e direitos.

Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá:

I – a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita;

II – os nomes do exequente e do executado;

III – a descrição dos bens penhorados, com as suas características;

IV – a nomeação do depositário dos bens.

1. Aspectos formais da penhora. Trata-se aqui dos requisitos formais que devem estar previstos no auto ou termo da penhora. Nesse sentido caso algumas dessas formalidades não seja respeitada e comprovado o prejuízo à tutela dos direitos, o auto ou termo poderá ter sua nulidade decretada, nos termos que prevê o art. 277 do CPC/2015.

2. Lei de Registros Públicos. O registro ou averbação da penhora não é obrigatório para a validade do ato da penhora: “A Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/1975), em seus arts. 167, I, c/c 169, diz da obrigação do registro da penhora, do arresto, do sequestro (n. 5) e das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis (n. 21). É de convir-se, entretanto, que não se confundem obrigatoriedade e necessidade. Esta implica imprescindibilidade, o que conflitaria com o próprio sistema processual codificado brasileiro, que, ao contrário do que ocorre no direito europeu, não exige o registro para o aperfeiçoamento da penhora, contentando-se com a apreensão e depósito (art. 665, CPC).”¹⁰² Contudo, o registro permite a sua oposição inequívoca para terceiros.

3. Documentos do BACENJUD. O STJ possui jurisprudência no sentido de que os documentos gerados pelo sistema do BACENJUD substituem as formalidades da penhora previstas nos dispositivos em tela, vejamos: “É correto o entendimento que acaba por afastar o formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art. 665 do códex processual [art. 665 do CPC/1973]. 5. Isso porque os atos de constrição se materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. (REsp 1220410/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4.^a Turma, julgado em 09.06.2015, *DJe* 30.06.2015).

Este entendimento está corretíssimo e afasta as antigas considerações formais que fizeram do procedimento de execução um modelo bizantino, cheio de armadilhas para os advogados e fonte de constante frustração para as partes e para os julgadores (cf., *supra*, introdução, 2.4, indicando a necessidade de simplificação das formas na execução a partir dos modelos comparados).

Art. 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia.

Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais.

1. Realização da penhora e lavratura do auto. Somente será considerada realizada a penhora de bens quando realizados os atos inerentes a ela, são eles: *a apreensão e o depósito*. Nesse sentido, o ato de apreensão “designa a arrecadação do bem, no patrimônio do executado, para responder à execução”¹⁰³ e o depósito “consiste em ato complementar à penhora. Tem por função conservar o bem penhorado. Daí a razão pela qual a recusa do executado em assinar o auto ou termo de penhora na condição de depositário não invalida a penhora”¹⁰⁴.

O parágrafo único do dispositivo indica que os autos serão realizados em número idêntico a quantidade de penhoras a serem efetuadas.

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

I – as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;

II – os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

III – os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1º No caso do inciso II do *caput*, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

§ 3º As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.

1. Depósito judicial e os bens penhorados. O depósito judicial deve ser efetivado naquelas situações em que os bens penhorados necessitem de guarda e conservação, as quais serão efetivadas por meio da figura do depositário judicial. Assim, o dispositivo em comento determina que existe preferência em relação ao depósito; não se trata de situações que exigem obrigatoriedade em relação ao depósito.

2. Disposições gerais. Os incisos I, II e III do art. 840 do CPC/2015 estabelece o rol de bens que por suas peculiaridades devem ser preferencialmente depositados.

O inciso I aponta que as quantias em dinheiro, papéis de crédito e as pedras ou metais preciosos deverão ser depositados em bancos públicos, ou na falta destes, em quaisquer outras instituições de crédito a partir de designação judicial. “Voltando ao procedimento trilhado pelo Código de Processo Civil de 1973 e novo Código de Processo Civil de 2015, após formalizada a decretação de indisponibilidade, os recursos serão preferencialmente transferidos e depositados em um banco oficial (CPC/1973, art. 666, I; CPC/2015, art. 840, I) – Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou outro banco em que a União detenha mais da metade de seu capital social integralizado –, permanecendo à disposição do juízo até ulterior deliberação”.¹⁰⁵

Vale destacar que a doutrina critica essa preferência aos bancos públicos e admite solução diversa por negócio jurídico processual, “pois, o estabelecimento de ampla concorrência, com a participação de bancos privados, poderia ofertar melhores rendimentos ao dinheiro depositado. Há de ser analisada, inclusive, com mais atenção, a eventual inconstitucionalidade do dispositivo, pois cria uma reserva de mercado na contramão do princípio da livre-iniciativa. De toda a sorte, mesmo sem adentrar na questão da higidez constitucional da regra legal, não vemos óbice a que, em sede de negócio jurídico processual (art. 190 do CPC/2015) as partes estipulem depositários diversos do ditado no dispositivo comentado”.¹⁰⁶

No caso de ser um banco privado o exequente o negócio jurídico processual facilitaria em muito o trâmite do procedimento, escolhendo-se o próprio credor como depositário. Não vemos óbice inclusive na pactuação das taxas de remuneração do depósito, tudo nos termos do art. 190, CPC/2015.

Já o inciso II do art. 840 do CPC/2015 prescreve que o depósito de bens móveis, semoventes, imóveis urbanos e direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos deverá ser feito junto a um depositário judicial ou, em caso de sua ausência, junto ao exequente, nos termos do art. 840, § 1.º do CPC/2015. É necessário ressaltar que o enunciado da Súmula 319 do STJ determina que “[o] encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado”.

Finalmente, o inciso III do art. 840 do CPC/2015 dita que imóveis rurais, direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, máquinas, utensílios e instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, serão depositados em poder do executado, mediante a apresentação de caução idônea.

Nas situações em que exista a anuência do exequente, ou seja, difícil a remoção do bem, os bens penhorados poderão ficar em poder do executado (§ 2.º do art. 840 do CPC/2015). *Por outro lado, quando forem penhorados joias, pedras, metais ou outros objetos preciosos, o depósito judicial deverá ser realizado com a descrição e registro do valor estimado de resgate dos bens (§ 3.º).*

3. Precedentes do STJ. Já decidiu a Corte, formando precedente no regime dos recursos especiais repetitivos (art. 927, III, CPC/2015), que a discussão em relação à matéria de aplicação de juros e correção monetária sobre os bens depositados não necessita de ação específica em face da instituição depositária, *“a discussão quanto à aplicação de juros e correção monetária nos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário”* (STJ, REsp 1.360.212/SP, 1ª Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 12.06.2013, DJe 11.09.2013, regime dos recursos repetitivos).

Sendo que em relação a correção monetária a matéria já se encontra inclusive sumulada, no enunciado da Súmula 271 do STJ: *“A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário”* e no enunciado da Súmula 179 do STJ: *“O estabelecimento de crédito que recebe o dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”*.

Não cabe mais discussão sobre a prisão civil do depositário, em nenhuma espécie de depósito. A matéria foi soberanamente fixada no Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição à luz do Pacto de San Jose da Costa Rica, nos termos do enunciado da Súmula vinculante n. 25: “[é] ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”. Com a Súmula vinculante n. 25 deixa de ser vinculante a Súmula 304 do STJ, por criar exceção desnecessária.

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado.

§ 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

1. Intimação da penhora. Realizada e formalizada a penhora, deve ser feita, na sequência, a intimação do executado para que tome ciência do ato. Via de regra, a intimação será feita ao advogado do executado ou então à sociedade advocatícia que ele pertença (§ 1.º do art. 841 do

CPC/2015), caso não exista advogado constituído nos autos a intimação será feita ao próprio executado, que deverá ser intimado pessoalmente, de preferência por via postal (§ 2.º do art. 841 do CPC/2015).

Vale destacar que, caso o executado esteja presente no momento da realização da penhora não é necessário que se intime seu advogado, pois, nessas situações reputa-se realizada a intimação (§ 3.º do art. 841 do CPC/2015), que deverá ficar devidamente certificada. Finalmente, no que diz respeito a hipótese do art. 841, § 2.º do CPC/2015, considerar-se-á realizada a intimação quando o executado mudar de endereço sem informar previamente o juízo, nos termos que dispõe o art. 274, par. ún., CPC/2015, que trata da intimação às partes.

Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

1. Intimação do Cônjuge e bens imóveis. O artigo aprimora a redação do CPC, levando em conta expressamente o direito material envolvido na matéria, como não poderia deixar de ser.

Quando a penhora acontecer sobre bem imóvel ou sobre direito real de imóvel, deverá acontecer também, a intimação do cônjuge do executado, salvo nas situações em que o casamento seja em regime de separação absoluta de bens. Tal intimação acontecerá somente nessas situações. Quando forem outros os bens penhorados, por exemplo, títulos de crédito, torna-se desnecessária a intimação do cônjuge do executado, como já decidiu o STJ: “(...) no caso ora em análise, segundo a moldura fática soberanamente traçada pelo acórdão recorrido, a constrição não recaiu sobre bem imóvel, mas sobre direito creditício, mediante penhora no rosto dos autos, afastando a aplicabilidade do aludido preceito legal à espécie [necessidade de intimação do cônjuge do executado]” (AgRg no AgRg no REsp 1.339.501/MG, 4.ª Turma., rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJe* 03.02.2015).

Outrossim, a doutrina ainda releva que “o Código de Processo não determina a intimação do cotitular de eventual conta-corrente ou aplicação financeira em nome do executado. Além do devedor, o Código de Processo Civil impõe a intimação somente do cônjuge, tratando-se de penhora efetivada sobre bem imóvel (CPC/1973, art. 655, § 2.º; CPC/2015, art. 842). Esta situação pode, igualmente, interferir na incidência do prazo para os embargos de terceiro, uma vez que não se pode exigir de quem não foi parte o cumprimento de prazos processuais se não teve ciência inequívoca do ato que o originou. Dentro das mazelas do Poder Judiciário brasileiro, não é incomum o terceiro ter um bem seu constricto e não ter tido ciência do ato ou sequer da execução forçada.”¹⁰⁷

Há, portanto, homenagem ao cônjuge em relação aos bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis constrictos na penhora, devendo o mesmo ser intimado da penhora. Inclusive quanto a sua meação.¹⁰⁸

2. Espécies de regime de separação de bens. Questão importantíssima diz respeito às quais das espécies de regime de separação de bens a regra se aplicaria. Sabe-se que existem hoje duas espécies: (i) a separação de bens convencional, no qual a escolha é livre dos cônjuges para optarem por esse regime (arts. 1687 e 1688 do CC/2002); e, o (ii) a separação de bens obrigatória, que é impositivo em determinadas situações previstas em lei (art. 1641 do CC/2002). O art. 1.641, CC, estabelece como casos de separação legal obrigatória de bens: a) das pessoas que contraírem o casamento com inobservância das causas suspensivas da celebração; b) da pessoa maior de setenta anos; e c) de todos que dependerem para casar de suprimento judicial.

Nesse sentido, parcela da doutrina aponta que a regra da dispensa da intimação só deveria acontecer nos casos em que o regime for de separação de bens convencional de bens (arts. 1687 e 1688 do CC/2002), isso porque, quanto ao regime obrigatório de separação de bens, há comunhão de aquestos (o que foi adquirido após o casamento). Neste sentido aponta o enunciado da Súmula 377 do STF¹⁰⁹.

3. Impugnação do cônjuge por meio de embargos à execução ou embargos de terceiro. Permite-se ao cônjuge que, a depender da situação, apresente *embargos à execução* ou então *embargos de terceiro*. “Serve para que o cônjuge possa reagir diante da penhora realizada. O remédio adequado para tanto depende da situação posta em juízo: reconhecendo que, em tese, o bem penhorado ou a sua meação é suscetível de execução, pode o cônjuge valer-se de impugnação (art. 525, CPC/2015, no caso de cumprimento de sentença condenatória) ou de embargos à execução (art. 914, CPC/2015, no caso de execução autônoma de título extrajudicial); do contrário, entendendo que o bem penhorado ou a sua meação não se submete à execução, porque não responde pela dívida exequenda, pode o cônjuge valer-se de embargos de terceiro (art. 674, § 2.º, I, CPC/2015)”¹¹⁰.

O CPC/2015 alocou os embargos de terceiro entre os procedimentos judiciais de jurisdição contenciosa, nos arts. 674 a 681. O art. 674, prevê no § 2.º, I, que “o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843” terá legitimidade para os embargos de terceiro, considerando-o terceiro para os fins da ação de impugnação.

O STJ tem precedentes que resultaram no enunciado da Súmula 134, segundo o qual “[e]mbora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação”.¹¹¹

De ser observado que a ressalva quanto ao art. 843, CPC/2015, diz respeito à penhora de bem indivisível, “[t]ratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”, art. 843, que determina regra específica quanto à alienação do bem indivisível objeto de meação (cf. comentários ao art. 843, CPC/2015).

4. Intimação do companheiro e a união estável. Existe, ainda, discussão acerca da necessidade de intimação nas situações em que exista união estável. Acreditamos que esta deve se efetivar, principalmente, pela previsão expressa constitucional reconhecendo o instituto (art. 226, § 3.º da CF/1988 e art. 1.º do CPC) e do quanto previsto no art. 73, § 3.º, CPC/2015, quanto à outorga uxória. Portanto, ao equalizar a união estável com o casamento o CPC atendeu ao mandamento constitucional e garantiu o direito à meação mediante embargos de terceiro também para aquele que se encontre em união estável com o executado. A dificuldade aqui poderá ser a informação sobre a existência da união estável. Assim, a intimação da penhora apenas na pessoa do executado poderá ser considerada válida até que se prove a existência da alegada união estável pelo requerente.

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

1. Bem indivisível e Coproprietário/Cônjuge. Quando a penhora incidir sobre bem indivisível, ficará garantida à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge, que não impedirá realização da alienação do bem, mas receberá o equivalente a suas respectivas quotas-partes após a realização da alienação.

O CPC assim resolve uma pendência mal amparada no argumento do direito *de* propriedade pela jurisprudência do STJ, como se direito fundamental fosse.

A regra prevista no dispositivo vai contra orientação do STJ, ainda na vigência do art. 655-B do

CPC/1973, o qual fazia referência somente ao cônjuge e não a qualquer coproprietário, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE ENTRE IRMÃOS, SENDO APENAS UM DELES EXECUTADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 655-B DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embargos de terceiro opostos em 22.09.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 17.04.2013. 2. Recurso especial em que se discute o cabimento da aplicação analógica do art. 655-B do CPC à copropriedade, entre irmãos, de bem imóvel indivisível. 3. Consoante regra basilar de hermenêutica jurídica, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos. 4. *Não é possível a extensão da regra de penhorabilidade de bem comum e indivisível do casal, prevista no art. 655-B do CPC, para a copropriedade entre irmãos, na medida em que entre eles, ao contrário do que ocorre no caso dos cônjuges, inexistente presunção de que a dívida contraída por um tenha beneficiado o outro. O vínculo jurídico (de parentesco) que une irmãos simplesmente não autoriza tal suposição.* 5. *A incidência analógica do art. 655-B do CPC para irmãos implicaria violação do direito constitucional de propriedade – notadamente o direito de dispor – daquele que não figura no polo passivo da execução, que não pode ser compelido a renunciar à sua cota parte no imóvel apenas para facilitar a satisfação do crédito do exequente. O fato de o dispositivo legal assegurar ao expropriado o produto da arrematação até o limite do valor da sua parte ideal não afasta a ofensa ao direito de propriedade, que é mais amplo e continua a ser violado ao se obrigar a disposição do bem e a sua substituição involuntária por outro.* 6. Recurso especial provido” (STJ, 3.^a Turma, REsp 1.373.839/RS, Rel. Ministra Nancy Andrigli, j. 03.06.2014, DJe 17.06.2014, mais recentemente, STJ, 3.^a Turma, AgRg no REsp 1.566.627/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 16.02.2016, DJe 22.02.2016).

Ao incluir o coproprietário o legislador resolveu a questão. Assim, do ponto de vista dogmático, não se pode mais alegar a jurisprudência contra a lei nova. Como vimos, o direito fundamental à propriedade é diverso do direito fundamental *de* propriedade (cf. *supra*, introdução). O coproprietário tem direito a sua quota-parte, mas não pode evitar a alienação do bem por ser este indivisível. Alienado o bem, receberá a indenização. Ao mesmo tempo, a lei garante o direito de preferência deste para a adjudicação da integralidade do bem e evita alienação por preço inferior ao da avaliação.

2. Coproprietário/Cônjuge e o direito de preferência na arrematação. Tanto o coproprietário como o cônjuge não executados têm direito de preferência na arrematação do bem penhorado em iguais condições (§ 1.º do art. 843 do CPC/2015), devendo estes serem intimados em tempo hábil antes da alienação para que exerçam o direito de preferência.

3. Proteção do Coproprietário/Cônjuge. O bem penhorado não pode ser alienado por valor inferior ao da avaliação judicial e que não garanta ao coproprietário e ao cônjuge, alheios à execução, o montante referente a suas respectivas quotas-partes (§ 2.º do art. 843 do CPC/2015).

4. Execução Trabalhista e o cônjuge. Na execução trabalhista deve ser preservada a quota parte de bem indivisível do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, sendo-lhe assegurado o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. A Execução trabalhista segue a mesma premissa aqui prevista (329 FPPC).

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

1. Publicitação da penhora. O dispositivo aponta que para que exista presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser realizada pelo exequente a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, bastando para tanto a entrega de uma cópia do auto ou termo de averbação, sem a necessidade de mandado judicial. Pretende-se evitar aqui a ocorrência de fraude à execução (art. 792 do CPC/2015). Nesse sentido merece destaque também o art. 240 da Lei 6.015/1973, Lei de Registros Públicos: “*o registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior*”.

Vale destacar que os bens penhorados que não podem ser registrados, a partir da impossibilidade prática e concreta, não poderão adquirir a presunção absoluta do conhecimento

de terceiros a que faz referência o artigo em comento, não podendo se atribuir o mesmo efeito, sendo apenas passível de prova a presunção relativa de conhecimento. Nestes casos será necessária a prova da má-fé. O art. 828, *supra*, indicava a possibilidade de averbação da execução, este artigo trata da penhora, como ato posterior.

2. Ônus do exequente. Assim como prevê o art. 844 do CPC/2015, é ônus do exequente providenciar a averbação do bem penhorado junto ao registro público, entretanto, assim como aponta jurisprudência do STJ, o exequente poderá ser ressarcido pelo executado dos gastos que venha a ter na averbação (STJ, 3.^a Turma, REsp 300.044/SP, j. 26.11.2001, rel. Min. Menezes Direito).

Assim como também existem julgados no sentido de que: “Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4.º, do CPC” (STJ, REsp 956.943/PR, Corte Especial, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, j. 20/08/2014, *DJe* 01.12.2014, no mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 147.879/RJ, 4.^a Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 15.10.2015, *DJe* 22.10.2015; STJ, EREsp 655.000/SP, 2.^a Seção Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, j. 10.06.2015, *DJe* 23.06.2015; AgRg no AREsp 592.615/SP, 3.^a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 17.03.2015, *DJe* 24.03.2015).

Subseção III Do lugar de realização da penhora¹¹²

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

§ 2º Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.

1. Lugar da penhora. A penhora será realizada por termo nos autos com a apresentação da matrícula do imóvel ou o documento comprobatório do veículo pertencente ao executado.

A regra tende a se tornar obsoleta com a possibilidade de convênio efetuado com os registros de imóveis (a exemplo do ARISP e do site www.registradores.org.br)¹¹³ e o departamento nacional de trânsito (RENAJUD) para penhora on-line de imóveis e veículos. Essas iniciativas têm relação direta com a nova administração do Poder Judiciário centralizada pelo CNJ. A Resolução CNJ 236/2016, que trata do leilão eletrônico, também regulamenta os a possibilidade de convênios de penhora on-line. O ARISP e o [registradores.org.br](http://www.registradores.org.br) são sistema de consulta e penhora on-line de imóveis que permite as averbações de penhoras de bens imóveis junto aos escritórios imobiliários de São Paulo, regulamentado pelo Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 6/2009, progressivamente este sistema está sendo introduzido em todos os Estados através do site [registradores.org.br](http://www.registradores.org.br). O RENAJUD é um sistema on-line de consulta e restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). A penhora on-line é mais barata, rápida e eficiente. Há ainda, para fins de obtenção de informações, o INFOJUD, um convênio da Receita Federal com o CNJ que permite acesso às informações dos contribuintes. Os sistemas de *e-justice*, como vimos na introdução (cf. *supra*), são necessários para a efetivação do direito fundamental à tutela do crédito, com menor custo para o Poder Público e mais agilidade para os consumidores da justiça.

Neste sentido, bem observado pela doutrina, “[a] regra do art. 659, § 5.º, do CPC/1973, de que desde que apresentada certidão da respectiva matrícula a penhora do referido bem imóvel será feita por termo nos autos foi estendida para os veículos pelo art. 845, § 1.º, do NCPC (Lei 13.105/2015), ou seja, sendo apresentado o documento comprobatório do órgão público que ateste que o veículo pertence ao executado, esta poderá ser feita por termo nos autos. A rigor, em nosso

sentir estas normas tendem a se tornar obsoletas com a penhora on-line de imóveis e de veículos, por intermédio de convênio firmado do poder judiciário com os cartórios de registro de imóveis e com os departamentos de trânsito.”¹¹⁴ Uma vez realizada a penhora on-line basta a juntada do comprovante ou certidão nos autos para que seja a mesma publicitada nos mesmos.

Art. 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento.

§ 1º Deferido o pedido, 2 (dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis em que se presume estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência.

§ 2º Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens.

§ 3º Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria, para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência.

§ 4º Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação.

1. Penhora e a oposição do executado. O dispositivo em comento aponta que caso o executado dificulte a realização da penhora, por qualquer modo, o oficial de justiça deverá comunicar ao juízo e requerer-lhe uma ordem de arrombamento.

Caso seja deferido o pedido, o mandado de penhora será cumprido por dois oficiais de justiça, que poderão ser auxiliados por força policial, caso necessário (§ 2.º do art. 846 do CPC/2015), acontecerá o arrombamento dos cômodos e móveis em que se presumam estarem os bens a serem penhorados, lavrando o ato em auto circunstanciado, assinado por duas testemunhas presentes na diligência (§1.º do art. 846 do CPC/2015).

Outrossim, os oficiais de justiça ainda lavrarão dois autos da ocorrência quanto à impossibilidade de cumprimento da ordem judicial da penhora de forma espontânea, sendo uma via entregue ao chefe de secretaria e o segundo à autoridade policial, para apurar criminalmente a possível ocorrência dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desobediência (art. 330 do CP).

Dessa forma, percebe-se o quanto buscou o legislador pela garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5.º, XI da CF/1988) ao prever todas essas formalidades em relação à ordem de arrombamento, nesse sentido já apontava a doutrina, na vigência do CPC/1973: “(...) a grande maioria dos meios de ‘moderação’ dos atos executivos, tendentes a tornar a execução ‘menos gravosa’ para o devedor, já se encontra prevista no próprio Código, citando, como exemplos: (...) (b) as regras que impõem certos cuidados para que se possa proceder à penhora mediante arrombamento (art. 660 do CPC e seguintes)(...)”¹¹⁵

Subseção IV Das modificações da penhora¹¹⁶

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I – comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II – descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III – descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV – identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V – atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

§ 2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

§ 3º O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.

§ 4º O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.

1. Substituição da penhora pelo executado. O dispositivo em comento possibilita ao executado, e somente a ele, no prazo de dez dias contados da intimação da penhora, que apresente requerimento para a substituição do bem penhorado, devendo comprovar que a substituição lhe será menos onerosa (princípio da menor onerosidade ou do menor sacrifício possível, art. 805 do CPC/2015) e que não trará prejuízo ao exequente (uma vez que a execução se realiza no interesse do exequente, consoante o princípio da máxima efetividade da execução, *jurisdictio in sola executione consistit*, art. 797, CPC/2015). Como vimos na *supra* (cf. premissas, 1.1; introdução, 2.4.) o princípio da menor onerosidade somente incide nos casos em que for possível identificar que os meios executivos são igualmente efetivos. Não se pode arguir a menor onerosidade se um dos meios é mais vantajoso ao exequente; a execução tutela o crédito, não o executado. Por esta razão o dispositivo ao final afirma que a condição é que a nova penhora se comprove ser menos onerosa e não traga prejuízos ao exequente.

2. Procedimento da substituição. Para que seja deferida, a substituição da penhora, além dos requisitos previstos no *caput* do artigo 847 do CPC/2015, o executado deve preencher os requisitos previstos nos incs. I a V do § 1.º, do art. 847 do CPC/2015, dos quais ressaltamos o inciso V, que determina ao executado a atribuição de valor a cada um dos bens indicados para a substituição, além de especificar os ônus e encargos a que estes possam estar sujeitos.

Realizado o requerimento de substituição dos bens, o executado deverá: a) apontar onde se encontram os bens indicados à substituição e que estarão agora sujeitos à execução; b) exibir a prova de sua propriedade; e c) abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, em consonância à boa-fé processual e o princípio do *venire contra factum proprium* (art. 847, § 2.º, CPC/2015).

Além disso, quando o bem indicado a substituição for imóvel, o executado deverá apresentar a expressa anuência do cônjuge ou companheiro (união estável), salvo se tratar de regime de separação total de bens (art. 847, § 3.º, CPC/2015).

Na sequência, deve o exequente ser intimado para que se manifeste sobre o requerimento de substituição da penhora feito pelo executado, com o intuito de se garantir o contraditório e também a vedação à decisões-surpresas (arts. 9.º e 10 do CPC/2015). Conforme o art. 853, CPC/2015, o prazo típico para a oitiva nesta subseção será de três dias. Finalmente, preenchidas todas as formalidades previstas no dispositivo, o juiz proferirá decisão a respeito do requerimento feito pelo executado, podendo tal decisão ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos que prevê o art. 1.015, par. ún. CPC/2015.

A substituição consensual se revela um negócio processual típico, já que previsto na lei (art. 847, § 4.º, CPC/2015).

3. Substituição do bem penhorado e precatórios. Dispõe o enunciado da Súmula 406 do STJ: “A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”, sendo que tal orientação tem fundamento no fato de que o precatório não se iguala a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito. Assim, no que diz respeito a penhora, representaria um gravame para a situação do exequente, a Fazenda Pública, pelo que resultaria em contradição com o princípio de que a execução se realiza no seu interesse para a tutela do crédito (STJ, 1.^a Seção, REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, mais recentemente, STJ, 1.^a Turma, AgRg no REsp 1398161/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. em 15.12.2015, *DJe* 02.02.2016, no mesmo sentido, STJ, REsp Repetitivo 1.337.790/PR, 1.^a Seção, rel. Ministro Herman Benjamin, j. 12.06.2013, *DJe* 07.10.2013).

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

I – ela não obedecer à ordem legal;

II – ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;

III – havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV – havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

V – ela incidir sobre bens de baixa liquidez;

VI – fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou

VII – o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

1. Substituição da penhora. Diferentemente do art. 847 do CPC/2015, essa possibilidade de requerimento de substituição da penhora é aberta tanto ao executado como ao exequente e também não possui prazo para apresentação do requerimento, podendo ser feita, *em princípio*, a qualquer momento, devendo sempre se atentar para a duração razoável do processo (arts. 4.^o e 139, II do CPC/2015).

Dessa forma existem sete hipóteses em que se torna possível o requerimento de substituição da penhora, são elas: a) não obediência à ordem legal prevista no art. 835 do CPC (inciso I do art. 848 do CPC/2015); b) não incidência da penhora sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento (inciso II do art. 848 do CPC/2015); c) nas situações em que havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados (inciso III do art. 848 do CPC/2015); d) quando havendo bens livres, a penhora tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame (inciso IV); e) quando a penhora incidir sobre bens de baixa liquidez (inciso V do art. 848 do CPC/2015); f) quando for fracassada a tentativa de alienação do bem (inciso VI do art. 848 do CPC/2015); e g) ou quando o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (inciso VII do art. 848 do CPC/2015).

No que diz respeito ao inciso II do art. 848 do CPC/2015, incidência sobre bens vedados, pode decorrer também de negócio jurídico processual (art. 190 do CPC/2015). O próprio inciso fala de vedações legais e contratuais. Nesse sentido são admissíveis os negócios processuais que estabeleçam *pacto de impenhorabilidade* (19 FPPC)¹¹⁷ e *pacto de alteração de ordem de penhora e pré-indicação de bem penhorável preferencial* (art. 848, II, CPC, 490 FPPC).

Também nesse requerimento de substituição da penhora deve ser ouvida a parte contrária. O prazo geral de três dias é a regra, assim prevê o art. 853, CPC/2015, aplicável a todas as situações

previstas na Subseção IV “quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir”. Esta premissa está de acordo com o princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC/2015).

2. Fiança bancária e seguro garantia judicial. A fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a penhora de dinheiro. Assim como prevê o art. 835, § 2.º, CPC/2015, o art. 848 par. ún. do CPC/2015, também possibilita a *substituição dos bens penhorados por fiança bancária ou seguro garantia judicial*, em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). Esta possibilidade nada mais é que uma homenagem ao princípio de que a execução se realiza em benefício do exequente e da tutela do crédito, visto serem a fiança e o seguro mais eficazes do ponto de vista da tutela do que a penhora sobre bens que dependam de leilão público para a expropriação.

Art. 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo.

1. Formalidades na substituição da penhora. Caso ocorra a substituição dos bens inicialmente penhorados, deve-se seguir as mesmas formalidades quanto a penhora, previstas no art. 838 do CPC/2015. Nesse sentido deverá ser lavrado novo termo, para que constem os novos bens penhorados. Nesse sentido, “ocorrendo a substituição do bem penhorado, deve lavrar-se termo novo, com nova intimação das partes ainda não cientificadas dessa constrição.”¹¹⁸

Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa.

1. Ampliação ou redução da penhora e alteração do valor de mercado. Trata-se de novidade do CPC/2015, tal possibilidade não era possível no CPC/1973. Dessa forma, pode-se reduzir a penhora, inclusive com a substituição do bem penhorado, naquelas situações em que haja grande aumento no valor de mercado dos penhorados e também que ocorra a ampliação da penhora, nas situações em que o valor de mercados dos bens penhorados tenha sofrido brusca queda. Diante disso, afirma-se que sempre se deve ter em mente uma adequação ao binômio *valor da execução atualizado v. valor dos bens penhorados*.¹¹⁹

No mesmo sentido: “Embora a penhora marque o bem a ser alienado para a satisfação do crédito do exequente, esse ônus não tem estabilidade. Assim, havendo alteração do valor de mercado do bem penhorado, pode o juiz determinar a redução, a ampliação ou a substituição da penhora (art. 874, CPC), de modo a garantir o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797, CPC). Antes dessa modificação, o juiz deve permitir a oitiva das partes, que podem manifestar-se em três dias (art. 853, CPC). Dessa decisão do juiz, que modifica a penhora, cabe recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC).”¹²⁰

Sempre que for requerida a ampliação ou redução da penhora o juiz deverá ouvir a parte contrária, nos termos que prevê o art. 853 do CPC/2015, em garantia clara do contraditório como valor-fonte¹²¹ do processo civil (arts. 9.º e 10 do CPC/2015).

Enumerando as possibilidades quanto a ampliação ou redução da penhora, assevera Eduardo Talamini:

“A penhora pode ser: i) aumentada, se os bens penhorados são insuficientes para cobrir o débito (arts. 667, II, e 685, II, do CPC); ii) diminuída, se os bens têm valor maior que o do débito (art. 685, I); iii) substituída, nas duas hipóteses anteriores, para um bem de valor maior ou menor, respectivamente (art. 685, I e II, CPC); iv) substituída, se a primeira foi anulada (art. 667, I, CPC) – seja porque os bens eram impenhoráveis, seja porque pertenciam a terceiro não responsável pelo débito, seja ainda porque se reconheceu direito do credor ou devedor a que ela atinja outro bem; v) substituída, se o credor desistir dela porque os bens eram litigiosos ou já estavam onerados por algum outro motivo (art. 667, III); vi) substituída por dinheiro, a requerimento do devedor, a qualquer tempo (art. 668, CPC); vii) substituída por dinheiro resultante de alienação antecipada

dos bens (art. 670). E cabível nova penhora, além disso, quando o produto da alienação dos bens penhorados não tiver sido suficiente para a satisfação do crédito (art. 667, II).”¹²²

Releva-se ainda, conforme precedente do STJ, que não pode o juiz *ex officio*, determinar a substituição, redução ou ampliação da penhora. Deve existir requerimento de alguma das partes. Assim, “[o] reforço da penhora não pode ser deferido *ex officio*, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC (...). É que o princípio do dispositivo, que vigora no Processo Civil, pressupõe que as atividades que o juiz pode engendrar *ex officio* não inibem a iniciativa da parte de requerê-las, não sendo verdadeira a recíproca. Em consequência, por influxo desse princípio, nas atividades que exigem a iniciativa da parte, o juiz não pode agir sem provocação” (STJ, REsp 1.127.815/SP, rel. Ministro Luiz Fux 1.^a Seção, j. 24.11.2010).

Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I – a primeira for anulada;

II – executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III – o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.

1. Realização da segunda penhora. O dispositivo aponta que a regra geral é que uma vez realizada a penhora sobre bens suficientes para garantir a satisfação do direito do exequente, não será feita uma nova, exceto nas situações previstas nos incisos do artigo em comento, quais sejam: a) quando a primeira penhora for anulada (inciso I do art. 851 do CPC/2015); b) quando executados os bens, o produto da alienação não for suficiente para o pagamento do montante total da execução (inciso II do art. 851 do CPC/2015); e c) quando o exequente desistir da primeira penhora, por constatar que os bens penhorados são litigiosos ou estão submetidos à outra constrição judicial (inciso III do art. 851 do CPC/2015).

2. Segunda penhora e novos embargos. Nos casos em que for deferida e realizada a segunda penhora, deve-se abrir também a possibilidade a apresentação de nova impugnação quanto às formalidades no que diz respeito ao ato da penhora (STJ, 4.^a T., EDcl no AgRg no REsp 686942/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2012, *DJe* 7.12.2012). Já apresentados os embargos a segunda penhora também poderá ser impugnada por petição simples (art. 917, § 1.^o, CPC/2015).

Art. 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando:

I – se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração;

II – houver manifesta vantagem.

1. Alienação antecipada dos bens penhorados. É possível que o juiz determine a alienação antecipada dos bens penhorados nas duas hipóteses previstas no dispositivo: a) quando se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração (inciso I do art. 852 do CPC/2015); e b) ou quando houver manifesta vantagem (inciso II do art. 852 do CPC/2015).

Quanto a essas possibilidades aponta a doutrina: “A hipótese primeira indica situações em que a alienação antecipada evitará não só a curva de mercado decrescente, fazendo com que a equação valor da execução x avaliação dos bens fique desestabilizada negativamente (...) a manifesta vantagem, trazida no inciso segundo, deve ser vista como um indiscutível proveito econômico, na alienação antecipada, por exemplo, o aumento extraordinário no valor de mercado de determinados bens.”¹²³

Conforme defendemos na parte introdutória (cf. *supra*, introdução, 2.14 e 2.15), a adoção de medidas atípicas pode se justificar em razão do comportamento das partes, da complexidade do

litígio, do comportamento das autoridades envolvidas e do direito material ou bem jurídico tutelado. Enfrentado o teste de proporcionalidade, respeitados o contraditório efetivo e a fundamentação adequada, poderá ser alterado o procedimento de expropriação. Uma das hipóteses seria exatamente a alienação antecipada do bem, utilizando-se para tanto não somente o permissivo do art. 852, II, mas os deveres-poderes do juiz (art. 139, IV, CPC/2015). A alienação antecipada pode se revelar também uma forma de estímulo à conciliação, face as consequências concretas que representará para o devedor/executado recalcitrante. Assim, no nosso entendimento a vantagem manifesta não deve somente econômica, mas também relacionada as condições de manutenção do bem depositado e, principalmente, a aceleração do procedimento a partir da necessidade de tutela.

A possibilidade de alienação antecipada já existe no processo penal e é muito utilizada também nos casos de improbidade administrativa. A técnica também é muito utilizada na América Latina, por força do projeto BIDAL (Bienes Incautados y Decomisados en América Latina – projeto da OEA, voltado para aprimorar os processos e melhorar a capacidade técnica de funcionários encarregados de conduzir investigações financeiras e patrimoniais, aumentando a eficiência da gestão de ativos de origem ilegal).

Há manifesta vantagem nestes casos em que a alienação antecipada resulta de processos de interesse público, como ações coletivas, ações penais e ações de improbidade. A manifesta vantagem reside no elemento dissuasório e desarticulador das práticas ilícitas.

Com a resposta imediata ao ato ilícito, além de assegurar que os bens não sofrerão depreciação ou serão indevidamente utilizados no período da execução, ocorre o atingimento da finalidade dissuasória nestes processos (a prevenção geral), que justifica a aceleração do procedimento. Se o título decorre de termo de ajustamento de conduta, o direito material de fundo, direito do consumidor, direito ambiental, direito à saúde, direito à educação, poderá permitir a inversão do procedimento combinando-se as regras do art. 852 do CPC/2015 com o art. 139, IV, CPC/2015. É bom frisar que a eventual reversão da execução por ação autônoma ou embargos ensejará a devolução dos valores e eventuais perdas e danos, portanto, não se pode justificar a negativa da medida com a alegação de prejuízo flagrante do executado. Prejuízo, se houver, será ressarcido de forma objetiva.

Art. 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir.

Parágrafo único. O juiz decidirá de plano qualquer questão suscitada.

1. Contraditório obrigatório. Em todas as situações que houver requerimento de alguma das medidas previstas na Subseção IV (ampliação ou redução da penhora, realização de segunda penhora e alienação antecipada dos bens penhorados) o juiz deverá ouvir a outra parte no prazo de 3 (três) dias. Pretende-se aqui garantir o contraditório como valor-fonte¹²⁴ do processo civil (arts. 9.º e 10 do CPC/2015). O contraditório poderá ser diferido em situações excepcionais, desde que adequadamente justificada a exceção (art. 9.º, par. único, CPC/2015).

2. Decisões interlocutórias e agravo de instrumento. As decisões do juiz em relação aos ditos requerimentos da Subseção IV são consideradas decisões interlocutórias e poderão ser atacadas por meio de agravo de instrumento assim como prevê o art. 1.015, par. único do CPC/2015. Nesse sentido já apontava a doutrina: “Aditemos que a decisão judicial a respeito da permanência ou da substituição da penhora, tomada após ser ouvida em 3 dias a parte contrária (art. 657 do CPC/1973), é impugnável mediante agravo de instrumento.”¹²⁵

Subseção V Da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira¹²⁶

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.

1. Penhora de dinheiro. A penhora de dinheiro é o meio mais eficaz de garantir a satisfação do crédito do exequente, principalmente por não ser necessária a expropriação por leilão judicial, basta a penhora de quantia equivalente ao montante total da execução, para que posteriormente seja feita a transferência ao exequente, por isso, em diversos momentos o diploma processual brasileiro destaca a prioridade que deve ser dada a penhora de dinheiro (art. 835, I e § 2.º do CPC/2015), nesse sentido aponta a doutrina: “O direito à penhora eletrônica é corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, na medida em que esse tem como consequência imediata o direito ao meio executivo adequado à tutela do direito material. Não há dúvida que a penhora eletrônica é a principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente”¹²⁷. O procedimento, previsto neste artigo, também pode e deve ser utilizado nas execuções fiscais, como aconselha a seguinte passagem, “*A disciplina procedimental para penhora de dinheiro prevista no art. 854 é aplicável ao procedimento de execução fiscal*” (540 FPPC).

2. Penhora on-line inaudita altera parte. A partir dessas premissas, trata-se no dispositivo em análise de ato de bloqueio prévio a penhora de dinheiro por meio eletrônico, que ficou consagrada pela prática forense como, penhora *on-line*¹²⁸. A penhora para ser efetiva deverá ser *inaudita altera parte*, ou seja, nos termos do *caput*, “*sem dar ciência prévia do ato ao executado*”. Ora, a ciência prévia poderia esvaziar a eficácia prática do ato, por meio do subsequente esvaziamento da conta corrente do executado. Como a medida é constritiva será ofertado o contraditório diferido, no momento oportuno, mas quando o ato já não possa mais ser frustrado (art. 9.º, par. ún., CPC/2015).

Assim, o exequente tem o direito de requerer em juízo a penhora eletrônica de dinheiro, que se deferida pelo juiz, será realizada por ordem de bloqueio dos ativos do executado – ainda não se trata da penhora propriamente dita –, sem a prévia oitiva deste, com o intuito de garantir sua efetividade, pois, caso contrário, o executado poderia transferir seus recursos financeiros, o que esvaziaria a pretensão da medida judicial. Portanto, nessa situação particular, acreditamos que não há espaço para se falar em violação ao art. 10 do CPC/2015, como demonstra a doutrina: “La legge brasiliana considera prioritario il pignoramento di danaro (nuovo Codice, art. 835, § 1.º) e per facilitare la sua realizzazione permette al giudice di bloccare elettronicamente, attraverso la Banca Centrale, saldi bancari del debitore, per un valore sufficiente a coprire il credito in esecuzione. L’indisponibilità che prepara il futuro pignoramento è determinata ‘in limine litis’, su richiesta del creditore i senza previa conoscenza del debitore (art. 854). Questi avrà però, prima del perfezionamento del pignoramento, cinque giorni di tempo per dimostrare l’eventuale impignorabilità del saldo bancario o l’eccesso della misura costrittiva (art. 854, § 2.º).”¹²⁹

O procedimento, portanto, se desdobra em três fases. Na primeira fase realiza-se o bloqueio do numerário disponível na instituição financeira. Após, abre-se a oportunidade para o controle do juiz, em vinte e quatro horas, e para a impugnação do executado, no prazo de cinco dias. Somente depois da impugnação os valores bloqueados serão penhorados e transferidos para uma conta específica vinculada ao juízo da execução.

A doutrina internacional reconhece que a iniciativa brasileira poderá servir de modelo para outros ordenamentos jurídicos.¹³⁰

3. BACENJUD. A penhora eletrônica de dinheiro é efetivada por meio do sistema eletrônico gerido pelo Banco Central do Brasil, chamado de *BACENJUD* (§ 7.º do art. 854 do CPC/2015). Tal sistema foi criado a partir de um convênio realizado entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário, possibilitando assim, o acesso de juízes, a partir de senhas cadastradas, para que consultem informações e realizem a penhora *on-line* dos ativos do executado.

4. Procedimento da penhora eletrônica. Deferido requerimento feito pelo exequente, o juiz determinará em um primeiro momento somente o bloqueio dos ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando, tal bloqueio, ao montante total indicado na execução. Nesse primeiro momento ainda não foi realizada e efetivada a penhora, a qual só acontecerá, por meio de decisão judicial, após manifestação do executado sobre o requerimento.

Dessa forma, estabelece art. 854, § 1.º do CPC/2015 que o juiz poderá, de ofício, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, determinar o cancelamento de eventual ordem de bloqueio excessiva, a qual deverá ser realizada pela instituição financeira em igual prazo.

Na sequência, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, caso não possua patrono constituído nos autos (art. 854, § 2.º do CPC/2015), para se manifestar. Incube ao executado, no prazo de cinco dias contados da intimação, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são *impenhoráveis* (inciso I do art. 854 do CPC/2015); e b) subsiste *indisponibilidade excessiva* dos ativos financeiros (inciso II do art. 854 do CPC/2015) (art. 854, § 3.º, CPC/2015).

Em casos extraordinários, caberá ressalva quanto ao prazo estabelecido, pois, muitas vezes a comprovação de que as quantias bloqueadas são impenhoráveis poderá levar certo tempo. Portanto, a parte poderá requerer, justificadamente, uma dilação do prazo de cinco dias, devendo

o juiz estabelecer prazo razoável. O requerimento deverá ocorrer antes do término do prazo. Assim, segundo o art. 139, VI do CPC/2015, o juiz poderá “*dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito*”, lembrando que, segundo o parágrafo único do mesmo artigo, “*a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular*”.

Assim, acolhidas algumas das arguições previstas no art. 854, § 3.º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular, por ser a quantia impenhorável, ou excessiva, devendo a instituição financeira cumprir a ordem judicial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (art. 854, § 4.º, CPC/2015).

Caso o executado não apresente manifestação ou sendo esta rejeitada, a indisponibilidade dos ativos será convertida em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz determinar que a instituição financeira depositária transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, § 5.º, CPC/2015).

Nos termos do art. 841, CPC/2015, o executado deverá ser intimado da decisão que formaliza a penhora, podendo este impugná-la por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, “[t]ambém caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de (...) cumprimento, no processo de execução (...))”.

5. Pagamento por outro meio. Caso, o executado realize o pagamento por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, a notificação da instituição financeira para que cancele a indisponibilidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio do *BACENJUD* (§ 6.º do art. 854 do CPC/2015).

Pode-se perceber que o bloqueio age sobre o horizonte imediato da vida prática do executado.

Sentido sua eficácia sua disposição a solver o débito é maior. Por esta razão, o bloqueio dos ativos pode, também, ser um eficaz incentivo à conciliação, agindo sobre o *humor* do executado (art. 515, § 2.º, CPC/2015).

6. Responsabilidade da instituição financeira. A instituição financeira é responsável pelos prejuízos causados ao executado, em decorrência da indisponibilidade em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz e também nas hipóteses de não cancelamento da indisponibilidade, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), após ordem judicial para fazê-lo (§ 8.º do art. 854 do CPC/2015). Afirma-se que que “*a responsabilidade que trata o art. 854, § 8.º, é objetiva e as perdas e danos serão liquidadas de forma incidental, devendo ser imediatamente intimada a instituição financeira para preservação do contraditório*” (541 FPPC).

7. Penhora em dinheiro e partidos políticos. A responsabilidade civil pelos atos que praticados pelo partido político é exclusivamente deste, assim como prevê o art. 15-A da Lei 9.096/1995 (“*A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária*”). Dessa forma, nos casos de execução contra partido político o juiz determinará a indisponibilidade dos ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, por meio do *BACENJUD* (art. 854, § 9.º, CPC/2015). Não se pode esquecer que são *impenhoráveis* os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político (art. 833, XI, CPC/2015).

8. Multa Sancionatória. Caso intimado da execução, o executado não indicar dinheiro a penhora, e posteriormente, constatar o juízo que ele tinha ativos financeiros passíveis de penhora, poderá sofrer uma multa no valor de até 20% de seu débito, por ato atentatório à dignidade da jurisdição – *contempt of court* (art. 774, parágrafo único, CPC/2015).

9. Precedentes do STJ. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência dominante e precedentes afirmando que não há necessidade do exaurimento das diligências para a efetivação

da penhora *on-line*. Como vimos a penhora de dinheiro é preferencial e o bloqueio dos recursos seguido da penhora *on-line* é a técnica mais eficaz.

Contudo, a jurisprudência dominante do STJ exige a citação para o pagamento em antecedência à penhora.

É bom lembrar que um dos efeitos da citação é a possibilidade de satisfazer a dívida espontaneamente no prazo de 03 (três) dias, e, com isto, obter uma *sanção premial* consistente na redução dos honorários de advogado pela metade (art. 827 e § 1.º c/c 829, CPC/2015). A única exceção diz respeito a penhora *on-line* quando o réu não pode ser encontrado para a citação (AgRg no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, julgado em 23.06.2016, *DJe* 30.06.2016; REsp 1338032/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3.ª Turma, julgado em 05.11.2013, *DJe* 29.11.2013).¹³¹

Contudo, nas execuções fiscais de débitos tributários (art. 185-A, CTN) o entendimento do tribunal é pela necessidade de realização de prévias diligências antes da efetivação da penhora *on-line*. Assim, “*No julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, esta Corte ratificou a necessidade de interpretação sistemática dos artigos 655-A do CPC e 185-A do CTN, de modo a autorizar a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, após o advento da Lei 11.382/2006. 2. Apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: AgRg no AREsp 554.742/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.10.2014; AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4.2.2014. 3. Agravo regimental não provido.*” (STJ, AgRg no REsp 1.353.313/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1.ª Turma, julgado em 03.12.2015, *DJe* 14.12.2015).¹³²

Não parece que esta seja a melhor solução. O bloqueio que antecede a penhora permite o controle pelo juiz (no prazo de 24 – vinte e quatro – horas) e pelo executado (no prazo de 05 – cinco – dias). Neste prazo o juiz procederá de ofício para o cancelamento da penhora indevida e o executado poderá arguir a impenhorabilidade e o excesso. Só posteriormente haverá a conversão em penhora e encaminhado o montante para a conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, §§ 1.º a 5.º, CPC/2015).

A premissa deste trabalho é que a execução se faz para a tutela do crédito, logo não há razão para aumentar o risco ao exequente de uma dispersão dos valores à disposição do executado depositados em conta corrente ou em aplicações financeiras com a citação anterior ao bloqueio. O bloqueio serve como arresto *on-line*, ou seja, medida cautelar para assegurar o resultado prático da execução. Especialmente em razão da preferência do dinheiro na ordem de penhora prevista expressamente (art. 835, § 1.º, CPC).

Contudo, há enunciado de Súmula 560 do STJ, que vem sendo mantido pelo tribunal: “A decretação de indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran”.

Talvez seja o memento de rever, mesmo para as execuções de débito tributário, o precedente do STJ à luz do novo CPC.

Eventuais constrições abusivas devem ser de responsabilidade do exequente (que sempre deve *requerer* a penhora *on-line*, nos termos da responsabilidade geral por atos executivos previstos no art. 776 do CPC/2015, “[o] exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”, sendo irrelevante o dolo ou culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva) ou da instituição financeira, se for de sua responsabilidade o equívoco (art. 854, § 8.º do CPC/2015, “[a]

instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz”) nos limites dos prejuízos causados. A responsabilização se procederá em incidente processual, nos próprios autos do processo de execução (art. 777, CPC/2015).

Subseção VI Da penhora de créditos¹³³

Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I – ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II – ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

1. Penhora de créditos. Assim como no CPC/1973, foi mantida no CPC a previsão quanto à possibilidade de penhora dos créditos que o executado possa possuir. O dispositivo assevera que enquanto for realizado o procedimento de apreensão do título de crédito, será considerada realizada a penhora a partir do momento em que ocorrer a intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado (inciso I) ou ao executado, credor do terceiro, para que não disponha de seu crédito (inciso II).

Destaca-se que, caso realizada a intimação, o terceiro devedor efetue o pagamento da dívida ao executado, poderá responder perante o exequente pela quantia a pagar; na situação do inciso II, caso o executado disponha de seu crédito, tal ato poderá ser considerado como *fraude à execução* (art. 792, V do CPC/2015, *norma de encerramento*) e será considerado como ineficaz em relação ao exequente¹³⁴.

2. Desnecessidade de nomeação de depositário ou administrador. O STJ já decidiu que nas mesmas situações previstas no art. 855 do CPC não é necessário nomear depositário ou administrador, vejamos: “A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle sobre a boca do caixa, o que não é, evidentemente, a hipótese” (STJ, REsp 1035510/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.^a T., j. 02.09.2008). Isto ocorre porque a penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado perante o juízo.

3. Penhora de mão própria. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui precedente que autoriza a *penhora de mão própria* (*crédito que o executado possui frente ao próprio exequente*) naquelas situações que o terceiro devedor é o próprio exequente, sendo ambos os títulos certos, líquidos e exigíveis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE MÃO PRÓPRIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. PENHORA SOBRE ARRECADAÇÃO MENSAL DE CONDOMÍNIO. (...) Embora a lei não trate expressamente da penhora de mão própria, consistente na possibilidade da constrição recair sobre crédito que o executado possui frente ao próprio exequente, tal modalidade de penhora encontra viabilidade na dicção do art. 671, II, do CPC, apenas com a peculiaridade de que o terceiro devedor, nesta hipótese, é o próprio exequente. A penhora de mão própria só é possível se ambos os créditos forem certos, líquidos e exigíveis, hipótese em que, mais do que a garantia do juízo, haverá a compensação “ope legis”, até o limite do crédito do executado frente ao exequente” (...) (REsp 829.583/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.^a Turma, julgado em 03.09.2009, DJe 30.09.2009). Há, nestes casos, compensação entre débitos e créditos (art. 368 e ss., CC/2002).

4. Penhora de precatórios. Considera-se penhora de créditos, a penhora que incidir sobre

precatórios, assim como nos mostra o precedente do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria: “o regime aplicável à penhora de precatório é o da penhora de crédito, inclusive para efeitos de ordem de nomeação a que se referem o art. 655 do CPC/1973 [art. 835 do CPC/2015, ordem da penhora] e art. 11 da Lei 6.830/1980. Penhorado o crédito, cabe ao exequente optar pela sub-rogação ou pela alienação judicial do direito penhorado” (STJ, EREsp 870428/RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1.^a Seção, j. 27.06.2007 e também em: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 98.877/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.^a T., j. 03.05.2012; STJ, AgRg no Ag 1222903/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1.^a T., j. 11.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 233.359/PR, rel. Min. Eliana Calmon, 2.^a T., j. 17.10.2013).

Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

§ 1º Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância.

§ 2º O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.

§ 3º Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução.

§ 4º A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos.

1. Efetivação da penhora de crédito. Quando a penhora for representada por alguma das espécies de títulos de crédito (nota promissória, duplicata, cheque etc.), sua efetivação será feita pela apreensão do documento do título, estando ou não em poder do executado.

Vale destacar que naquelas situações em que o título não for apreendido, a confissão de terceiro em relação à dívida, este será considerado como depositário da importância (art. 856, § 1.º, CPC/2015), exonerando-se da obrigação no momento em que depositar o montante em juízo (art. 856, § 2.º, CPC/2015).

Caso o terceiro realize o pagamento de sua dívida junto ao executado em conluio, tal quitação será considerada como fraude à execução, sendo ineficaz, assim como prescreve a *norma de encerramento* do art. 792, V, § 1.º do CPC/2015 (art. 856, § 3.º, CPC/2015).

Finalmente, após requerimento do exequente, o juiz poderá determinar o comparecimento do executado e do terceiro, em audiência, a fim de que sejam tomados seus depoimentos e se apure eventual responsabilidade de ambos, principalmente na situação de conluio descrita acima (art. 856, § 4.º do CPC/2015).

Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.

§ 1º O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora.

§ 2º A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens.

1. Possibilidades em decorrência da penhora de crédito. Realizada a penhora sobre direito ou ação do executado, e não sendo apresentados embargos ou impugnações ou sendo estes julgados improcedentes, o exequente ficará sub-rogado em relação aos créditos do executado até o montante total da execução.

Caso seja da preferência do exequente, é possível que ao invés da sub-rogação, aquele prefira a alienação dos créditos penhorados, devendo para tanto, manifestar sua vontade no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de realização da penhora (art. 857, § 1.º, CPC/2015). Outrossim, a sub-rogação não impede o exequente de dar continuidade a execução nos mesmos autos, caso não venha a receber os créditos do executado que foram penhorados (art. 857, § 2.º, CPC/2015).

A sub-rogação do crédito é medida que pressupõe uma sucessão processual, logo, deve ser pensada com parcimônia, pois os riscos para o exequente são evidentes. É bom lembrar que há possibilidade de conciliação ampla, inclusive envolvendo terceiros não constantes do título e objeto diverso ao nele previsto (art. 515, § 2.º, CPC/2015, cf. introdução, 2.16), por exemplo, mediante sub-rogação convencional (art. 347, CC/2002).

Art. 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento.

1. Penhoras parciais e subseqüentes de juros, rendimentos e prestações. O dispositivo prevê a possibilidade quando a penhora incida sobre dívidas de dinheiro a juros, rendimentos ou prestações periódicas possam ser levantados à medida que forem depositados pelo executado, sendo tais quantias abatidas em relação ao crédito principal. Para tanto, serão aplicadas as regras de imputação do pagamento, previstas nos arts. 352 a 355 do CC/2002. Especialmente o caso do art. 354, que determina primeiro a imputação dos juros e rendimentos (*“[h]avendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”*).

Art. 859. Recaindo a penhora sobre direito a prestação ou a restituição de coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução.

1. Penhora sobre coisa determinada e a redação equivocada do dispositivo. Como é de conhecimento geral, o legislador buscou no Livro da Execução substituir as expressões “credor” e “devedor” por “exequente” e “executado”. Ocorre que a mudança realizada no dispositivo em comento foi equivocada, pois, o art. 676 do CPC/1973 não se referia ao devedor executado, mas sim ao devedor da obrigação de entrega da coisa determinada, ou seja, a terceiro. A correção é necessária, pois a regra não se refere ao próprio executado.

Assim, vale ressaltar que a intimação não deve ser feita ao próprio executado, mas sim na pessoa do *devedor* (terceiro), que é quem deve depositar em juízo o bem até o prazo do vencimento. O texto trata, portanto, do comportamento do devedor da obrigação de entrega da coisa determinada que deve para o executado.

Logo, onde está escrito que a penhora será sobre o direito a prestação ou a restituição de coisa determinada quem será intimado será o devedor da obrigação de direito material, que, no vencimento, irá depositá-la em juízo para que sobre ela corra a execução.

Evidentemente que o executado será intimado, mas será o terceiro que estará obrigado a depositá-la em juízo, aplicando-se aqui a mesma lógica dos artigos anteriores.

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

1. Penhora no rosto dos autos. O regramento estabelece que poderão ser averbados créditos que o executado esteja pleiteando por meio de ação judicial. Este procedimento é chamado de *penhora no rosto dos autos*.

Dessa forma, caso o executado tenha ações para cobrança de créditos em juízo, os direitos

discutidos nestas demandas poderão ser objeto de penhora, para uma possível futura expropriação, caso sejam julgadas procedentes.

2. Jurisprudência do STJ. Quanto à competência, o STJ já decidiu “Em se tratando de penhora no rosto dos autos, a competência será do próprio juízo onde efetuada tal penhora, pois é nele que se concentram todos os pedidos de constrição. Ademais, a relação jurídica processual estabelecida na ação em que houve as referidas penhoras somente estará definitivamente encerrada após a satisfação do autor daquele processo. Outro ponto que favorece a competência do juízo onde realizada a penhora no rosto dos autos é sua imparcialidade, na medida em que nele não tramita nenhuma das execuções, de modo que ficará assegurada a total isenção no processamento do concurso especial” (STJ, REsp 976.522-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.02.2010).

Já no que toca ao pedido de desistência nas ações em que o executado é exequente, cabe a oitiva do beneficiário da constrição: “havendo penhora no rosto dos autos, não cabe homologação de pedido de desistência da execução sem a audiência da beneficiária da constrição” (STJ, REsp 1418549/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª T., j. 06.05.2014). Esta regra vale, igualmente, para a desistência da ação de conhecimento.

Subseção VII Da penhora das quotas ou das ações de sociedades personificadas¹³⁵

Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:

I – apresente balanço especial, na forma da lei;

II – ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;

III – não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

§ 1º Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.

§ 2º O disposto no *caput* e no § 1º não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso.

§ 3º Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do *caput*, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.

§ 4º O prazo previsto no *caput* poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:

I – superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou

II – colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária.

§ 5º Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do *caput* seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.

1. Penhora de quotas ou ações de sociedades personificadas. O dispositivo pela primeira vez disciplina o procedimento da penhora de quotas ou ações de sociedades personificadas.

Trata-se de novidade em relação ao CPC/1973, que somente permitia a penhora de quotas ou

ações de sociedades personificadas, mas não possuía previsão quanto ao procedimento de tal penhora, portanto, o dispositivo vem em boa hora para de uma vez por todas resolver essa problemática, como aponta Marcelo Abelha: “ao tratar do tema o legislador do CPC/2015 (Lei 13.105/2015) decidiu ir um pouco mais além, qual seja, em ser um pouco mais minudente e abriu uma seção no capítulo da penhora apenas para tratar da penhora de cotas ou ações de sociedades personificadas, posto que não entendeu como suficiente a regra da penhorabilidade (art. 835, IX, do CPC/2015) e a regra da preferência dos sócios na adjudicação (art. 876, § 7.º, do CPC/2015)”¹³⁶.

2. Procedimento. Dessa forma, quando a penhora incidir sobre quotas ou ações de sociedades empresariais ou simples, o juiz deverá determinar em prazo não superior a três meses, que a sociedade, por meio de seu representante legal: a) apresente balanço especial (inciso I do art. 861 do CPC/2015); b) ofereça as quotas ou ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual (inciso II do art. 861 do CPC/2015); e c) caso não exista interesse destes na aquisição, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro (inciso III do art. 861 do CPC/2015).

A sociedade personificada poderá adquirir as próprias quotas ou ações com a utilização de reservas para manutenção da tesouraria, quando isso não resultar em redução do capital social (art. 861, § 1.º, CPC/2015). Existe controvérsia quanto a essa possibilidade da própria sociedade adquirir suas quotas ou ações, entretanto, com base no art. 30, § 1.º, *b* da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976), assim como também aponta o Enunciado 391 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF): “A sociedade limitada pode adquirir suas próprias quotas, observadas as condições estabelecidas na Lei de Sociedade por Ações”¹³⁷.

Quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto, o disposto no *caput* e no § 1.º do art. 861 do CPC/2015 não será aplicado, devendo as ações serem adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme a conveniência do caso (§ 2.º do art. 861 do CPC/2015). Assim como, na situação de alienação das quotas ou ações penhoradas a que faz referência o inciso III, poderá ser nomeado administrador a requerimento do exequente ou da sociedade, devendo este submeter à aprovação judicial plano a respeito da forma como será feita a liquidação (§ 3.º do art. 861 do CPC/2015).

Outrossim, o juiz poderá dilatar o prazo de até 3 (três) meses, previsto no *caput* do artigo, nas seguintes situações (§ 4.º do art. 861 do CPC/2015): a) quando o pagamento das quotas ou ações superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital, ou por doação (inciso I); e b) quando o pagamento das quotas ou ações colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária (inciso II).

Finalmente, poderá o juiz determinar o leilão judicial das quotas ou ações da sociedade empresarial ou simples, quando nenhuma das opções previstas no dispositivo se efetivarem na prática (§ 5.º). Esta é uma alternativa residual por força da função social da empresa, que governa a interpretação deste meio de execução.

Subseção VIII Da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes¹³⁸

Art. 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração.

§ 1º Ouvidas as partes, o juiz decidirá.

§ 2º É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação.

§ 3º Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador.

§ 4º Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se se tratar de construção financiada, por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes.

1. Penhora sobre estabelecimentos e bens semoventes. O dispositivo permite que seja realizada a penhora sobre estabelecimentos comerciais, industriais e agrícolas, assim como em bens semoventes, plantações ou edifícios em construção. É necessário para tanto que seja nomeado um administrador-depositário que seguirá a risca o plano de administração. O enunciado da súmula 451 do STJ determina ainda que “é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.

2. Administrador-Depositário. O Administrador-Depositário será nomeado pelo juiz e deverá apresentar em 10 (dez) dias um plano de administração. Após a apresentação deste, o juiz abrirá a possibilidade das partes se manifestarem quanto à nomeação e ao plano de administração (§ 1.º do art. 862 do CPC/2015).

Existe ainda a possibilidade, em consonância a norma fundamental de solução consensual dos litígios (art. 3.º, § 2.º do CPC/2015), que as próprias partes escolham o administrador depositário e ajustem seu plano de administração, devendo o juiz apenas homologar a indicação realizada (art. 862, § 2.º, CPC/2015). Trata-se de um negócio processual típico no processo de execução, devendo o juiz proceder na homologação com o controle da validade do ato.

Enfim, como bem aponta a doutrina, em qualquer caso, “a função do ‘administrador-depositário’ é garantir, mesmo após a constrição, que a empresa desempenhe sua atividade, de forma lucrativa, os semoventes sigam cuidados e alimentados, as plantações remanesçam cultivadas e os edifícios em construção tenham sua obra levada adiante”¹³⁹. Enfim, a função do administrador é garantir a normalidade e o exercício da função social da empresa de forma a, obtendo sucesso, saldar os débitos do executado.

3. Penhora sobre edifícios em construção. Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora não poderá atingir as unidades que já tenham sido comercializadas pelo incorporador (art. 862, § 3.º, CPC/2015). Garante-se o direito adquirido dos compradores de boa-fé em detrimento das pretensões expropriatórias da execução. Outrossim, poderá acontecer o afastamento do incorporador da administração do edifício, caso em que assumirá uma comissão de representantes formada pelos adquirentes das unidades autônomas (art. 862, § 4.º, CPC/2015).

Nesse sentido, destaca Marcelo Abelha: “A novidade trazida pelo NCPC (Lei 13.105/2015) está nos §§ 3.º e 4.º do art. 862 do CPC, nas regras referentes a edifícios em construção, caso em que a penhora só poderá recair sobre as unidades não comercializadas, o que nos parece óbvio, sob pena de atingir a esfera patrimonial de terceiros, e de que sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se se tratar de construção financiada, por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra. Neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes deve ser ouvida”¹⁴⁰.

A solução é adequada, por preservar aqueles que adquirentes de boa-fé não devem responder pela execução.

Art. 863. A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á, conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário, de preferência, um de seus diretores.

§ 1º Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador-depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de

frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

§ 2º Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão.

1. Penhora de empresa que presta serviço público mediante concessão ou autorização. Foi mantida a possibilidade quanto à penhora de empresa prestadora de serviço público mediante concessão ou autorização. Dessa forma é possível que sejam penhorados todo o patrimônio, determinados bens ou valores da empresa, devendo para tanto ser nomeado um administrador-depositário, que será preferencialmente algum dos diretores da empresa.

Também é imprescindível apontar que, assim como todas as espécies de penhora previstas nessa subseção, cabe ao exequente demonstrar a não existência de forma mais eficaz de se efetivar a satisfação da dívida (art. 865 do CPC/2015, “[a] penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito”). A finalidade da norma é proteger a função social da empresa. Preserva-se a regra geral de proporcionalidade prevista no art. 805 do CPC/2015 (princípio do meio menos gravoso), mas também a regra da eficiência que rege o princípio de que a execução serve à tutela do crédito, adequada, tempestiva e efetiva (art. 797, CPC/2015).

2. Penhora sobre rendas e bens. Prevê o art. 862 do CPC/2015 que o administrador-depositário ficará responsável por gerenciar os bens a partir do plano de administração e também deverá apresentar em juízo a forma como ocorrerá o pagamento da dívida a partir da penhora sobre as rendas da empresa (art. 863, § 1.º, CPC/2015).

3. Penhora v. interesse público na prestação do serviço. Quando a penhora recair sob todo o patrimônio da empresa prestadora de serviço público mediante concessão ou autorização, o ente público que concedeu autorização ou concessão deverá ser ouvido antes da efetivação da arrematação ou adjudicação da empresa, com o intuito de se preservar e garantir o efetivo funcionamento do serviço público prestado apesar da atividade executiva. Aqui poderá ser inclusive aventado um negócio processual atípico com o ente, para permitir a continuação da atividade executiva, sem prejuízo do serviço público (art. 190 do CPC/2015).

Art. 864. A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continuem navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos.

1. Penhora sobre Navio e Aeronave. Assim, como os demais bens previstos nesta subseção, a penhora sobre navio ou aeronave só se efetivará caso não existe outro meio eficaz de satisfação do crédito (art. 865, CPC/2015). Sendo assim, pelas características peculiares desses bens – alto valor, potencial de rendimento e potencial depreciação em caso de não utilização –, eles devem continuar em atividade para que possam produzir.

Torna-se necessário para tanto autorização judicial, a qual somente será concedida caso o executado – considerado como depositário do bem – faça um seguro contra possíveis riscos que a aeronave ou navio possam correr ao voltar à atividade. Poderá também ser determinada a administração destes bens por terceiro, inclusive por convenção entre as partes (art. 190, CPC/2015).

Art. 865. A penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito.

1. Excepcionalidade da penhora de empresa, outros estabelecimentos, bens semoventes, navios e aeronaves. O dispositivo dispõe sobre o caráter residual da penhora dos bens previstos nesta Subseção, no sentido de que ela não deve ser realizada caso existe outro meio eficaz para a satisfação do crédito.

Trata-se da materialização do chamado *princípio do menor sacrifício possível*, o qual como

vimos está previsto no art. 805 do CPC e determina que a execução deverá ser realizada pelo modo menos gravoso para o executado.

Além disso, também é corolário da tutela adequada, efetiva e tempestiva dos direitos (art. 4.º, CPC/2015), pois, primeiramente irá se buscar sempre na execução pelo meio mais eficaz para a efetivação do crédito de que é titular o exequente. Mais, atende, também, ao interesse público, à medida que as atividades aqui descritas envolvem, em grande parte, servidores públicos, agentes privados e atividade cartorária intensa que será suprimida se for utilizado um meio mais eficiente. Por fim, é desdobramento do princípio da função social da empresa, pois ao evitar a penhora haverá um estímulo à continuidade das atividades regulares da empresa com proteção dos trabalhadores e dos direitos coletivos envolvidos, a regra, neste sentido, deve ser aplicada aos arts. 861 a 869, CPC/2015. Trata-se de importante inovação do CPC e exige fundamentação adequada do juiz na decisão que analisar o caso concreto (art. 489, § 1.º, CPC/2015).

São, portanto, três os beneficiários da residualidade desta regra: o executado, o exequente e o interesse público (órgão público responsável pela execução e a coletividade – função social da empresa).

Subseção IX Da penhora de percentual de faturamento de empresa¹⁴¹

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

1. Penhora de percentual de faturamento de empresa. Na esteira da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 158.436/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4.ª Turma, julgado em 27.03.2014, *DJe* 04.04.2014), o dispositivo aponta que a penhora sobre parte do faturamento de empresa é excepcional e só deve ser realizada caso não existam outros bens penhoráveis, ou se existindo, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Há aqui residualidade, preferem-se os outros meios antes deste. Os argumentos válidos para o art. 865 do CPC/2015 também devem ser expendidos aqui, além de existirem outros meios mais ágeis e econômicos de penhora a penhora prevista neste dispositivo pode criar embaraço ao desempenho da função social da empresa, pelo que, sempre que possível, deve ser evitada.

2. Procedimento da penhora. Nesse sentido, o juízo fixará um percentual levando em consideração a satisfação do crédito do exequente (considerando-se um tempo razoável) e, também, os interesses do executado, de forma que tal penhora não impossibilite o exercício da atividade desenvolvida pela empresa (§ 1.º do art. 866 do CPC/2015), nesse sentido aponta a jurisprudência dominante do STJ (REsp 1.130.972/PR, 2.ª Turma., rel. Min. Castro Meira, j. 22.03.2011; AgRg no AREsp 242.970/PR, 1.ª Turma., rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012; AgRg no AREsp 483.558/SP, 4.ª Turma., rel. Ministro Raul Araújo j. 20.11.2014) e a doutrina: “Destarte, no embate entre a efetividade da tutela jurisdicional executiva e o princípio da menor onerosidade da execução que favorece o devedor, o juiz deve sopesar as circunstâncias e adotar a posição que se lhe mostrar mais justa e equânime com o ordenamento jurídico. A título exemplificativo, a penhora que recai sobre o dinheiro da pessoa jurídica, por conformar seu capital de giro e comprometer os recursos necessários à continuidade de seu regular funcionamento, pode, muitas vezes, trazer grande prejuízo não somente para o devedor, mas

também para a sociedade civil em sua totalidade, ao comprometer o exercício da função social da empresa. Tanto isso é veraz que o Novo Código de Processo Civil admite a penhora de percentual de faturamento se o executado “não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”¹⁴².

Outrossim, da mesma maneira que ocorre em outras situações, o juiz deverá nomear administrador-depositário, o qual ficará responsável por submeter ao juízo a forma de sua atuação e a prestação de contas, a qual deverá ser mensal. Além disso, deve depositar em juízo as quantias recebidas, em razão dos pagamentos dos percentuais penhorados do faturamento judicial (art. 866, § 2.º do CPC/2015).

O administrador-depositário poderá ser escolhido consensualmente entre as partes (19 FPPC; art. 190, CPC/2015).

Finalmente, destaca-se que essa forma de penhora observará o disposto quanto ao regime da Subseção X, da *penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel*, prevista nos arts. 867 a 869 do CPC/2015 (art. 866, § 3.º, CPC/2015).

3. Penhora de crédito de cartão de crédito. O tema da penhora do cartão de crédito é polêmico e já foi enfrentado pela jurisprudência do STJ. “(...) 1. Controverte-se a respeito da decisão que manteve a penhora de percentual incidente sobre os créditos vincendos, a serem pagos por administradoras de cartão de crédito. 2. A recorrente defende a tese de que esses créditos são pagos em dinheiro, razão pela qual devem receber o tratamento idêntico ao dispensado à penhora de aplicações financeiras via Bacen-Jud – isto é, penhora em dinheiro, nos termos do art. 655, I, do CPC [art. 835, I, do CPC] – e, portanto, sem limitação percentual (construção sobre a integralidade dos valores). 3. O Tribunal a quo equiparou a medida constritiva, para fins processuais, à penhora sobre faturamento, razão pela qual, diante da verificação da existência de penhora similar deferida em outros processos judiciais, manteve a penhora determinada pelo juízo de primeiro grau, mas a limitou a 3% do montante a ser repassados pelas operadoras de cartão de crédito. (...). 8. Atualmente, a maior parte das relações obrigacionais possui expressão monetária e, por essa razão, em dinheiro é naturalmente extinta. Assim, quer o pagamento seja feito em dinheiro, cheque ou cartão de crédito, em última instância, *sempre haverá a conversão do bem em dinheiro*. 9. Fosse esse o raciocínio, portanto, não haveria sentido no estabelecimento de uma ordem preferencial de bens, para efeitos de construção judicial, uma vez que qualquer um deles (metais preciosos, imóveis, veículos etc.) será, com maior ou menor dificuldade, transformado em dinheiro. 10. Os recebíveis das operadoras de cartão de crédito, naturalmente, serão pagos em dinheiro – tal qual ocorre, por exemplo, com o precatório judicial –, mas isso não significa que o direito de crédito que o titular possui possa ser imediatamente considerado dinheiro. 11. Por essa razão, *os valores vincendos a que a empresa recorrida faz jus, tendo por sujeito passivo as administradoras de cartão de crédito, possuem natureza jurídica de direito de crédito*, listado no art. 11, VIII, da Lei 6.830/1980 e no art. 655, XI, do CPC [art. 835, XIII do CPC]. 12. É correta a interpretação conferida no acórdão recorrido, que, embora acertadamente não confunda a penhora do crédito com a do faturamento, confere uma equiparação entre ambos, para fins estritamente processuais (isto é, de penhora como instrumento de garantia do juízo). 13. Isso porque é legítima a suposição de que os recebíveis das administradoras de cartão de crédito têm por origem operações diretamente vinculadas à atividade empresarial do estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los no conceito de faturamento (isto é, como parte dele integrante). 14. Assim, a construção indiscriminada sobre a totalidade desses valores tem potencial repercussão na vida da empresa – quanto maior a sua representatividade sobre o faturamento global do estabelecimento, maior a possibilidade de lesão ao regular desempenho de suas atividades. 15. Não bastasse isso, as questões relacionadas à efetivação de penhora pelo mecanismo ora apreciado possuem consequências que ultrapassam a relação jurídica existente entre as partes credora e devedora, o que justifica a cautela adotada pelo Tribunal a quo. 16. Dada a larga difusão, no sistema financeiro, da utilização do denominado ‘dinheiro de plástico’, a autorização para a penhora do montante total a ser repassado pelas administradoras de cartão de crédito acarretaria, de certo, sensível abalo no sistema financeiro, pois, de um lado, haveria forte queda, no terceiro setor, na aceitação dessa forma de pagamento. De outro lado, a realidade mostra que o forte segmento financeiro não arcará, ao final, com o prejuízo daí decorrente, o que significa dizer, a

exorbitante taxa de juros já praticada tenderia a aumentar, como forma de absorver o impacto social” (STJ, REsp 1.408.367/SC, 2.ª T., j. 25.11.2014, rel. Ministro Herman Benjamin).

O juiz, portanto, poderá determinar a penhor sobre os recebíveis do cartão de crédito em percentual a ser fixado que permita ao mesmo tempo: a) a satisfação do crédito em prazo razoável; e b) que não torne inviável o exercício da atividade empresarial do executado.

A possibilidade de estabelecer o percentual é um elemento de controle pelo juiz da tipicidade da penhora no caso concreto, sendo um desdobramento do art. 139, IV, CPC/2015, em benefício ao mesmo tempo do interesse do credor e do interesse público. Pode-se dizer, em última análise, que a depender da situação concreta também será do interesse do exequente que a empresa continue suas atividades, sem o que pode ser impossível satisfazer a execução em sua integralidade.

Subseção X Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel¹⁴³

Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.

1. Penhora de Frutos e Rendimentos. Permite-se ao juiz penhorar os frutos e rendimentos de bem móvel ou imóvel quando preenchidos os requisitos previstos no dispositivo em comento, são eles: a) eficiência no recebimento do crédito; e, b) a menor gravidade ao executado. Tais critérios são considerados como conceitos jurídicos indeterminados e devem ser interpretados a partir do caso concreto. Vale lembrar, como já reafirmamos por diversas vezes, que a atividade executiva deve ser estruturada para a tutela do crédito, adequada, efetiva e tempestiva e pensada de forma a não custar excessivamente para os órgãos responsáveis pela execução e para a sociedade.

Assim, há um triplice interesse: a) do executado, em não sofrer execução excessiva; b) do exequente, em receber de forma pronta e efetiva a tutela do crédito; e, c) do órgão de execução, em desempenhar a atividade executiva de forma eficiente e econômica (cf. *supra*, premissas, 1.2.).

2. Substituição da expressão “usufruto” (CPC/1973). O CPC/2015 alterou a redação do artigo substituindo adequadamente a expressão “usufruto” que era utilizada fora de contexto pela expressão “penhora dos frutos e rendimentos”. O usufruto é instituto civil, de direito real, regulado pelo art. 1.390 e ss., CC/2002.

3. Eficiência do recebimento de crédito. Já decidiu o STJ nesse sentido: “o princípio da economicidade não pode superar o princípio da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exequendo” (STJ, 1.ª Turma, REsp 419.151/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.11.2002, DJ 10.03.2003, p. 97).

Art. 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

§ 1º A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis.

§ 2º O exequente providenciará a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.

1. Penhora de frutos e rendimentos e seu procedimento. Uma vez ordenada a penhora de frutos e rendimentos, assim como em outras situações já vistas, nomear-se-á um administrador-depositário, que terá todos os poderes concernentes a administração do bem e também da fruição de seus frutos e utilidades.

Ressalta-se que, nesses casos, o executado perde o direito de gozo sobre o bem penhorado até o momento em que efetivado o pagamento do montante total da execução. Assim, essa medida

judicial terá eficácia em relação aos terceiros no momento da publicação da decisão no diário oficial ou, em se tratando de bens imóveis, no momento de sua averbação junto ao cartório de registro imobiliário (art. 868, §§ 1.º e 2.º, CPC/2015).

Parte da doutrina tem criticado essa previsão de eficácia perante terceiros com a mera publicação da decisão no diário oficial de justiça, isso porque, ela não teria o potencial de levar ao conhecimento de terceiros que não sejam as partes do processo¹⁴⁴. Haveria, assim, um vício de publicidade com a consequente ineficácia perante os terceiros de boa-fé.

Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função.

§ 1º O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente.

§ 2º Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem.

§ 3º Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador.

§ 4º O exequente ou o administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado.

§ 5º As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida.

§ 6º O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas.

1. Procedimento da penhora. Quando o juízo determinar a penhora de frutos e rendimentos de bens do executado, deverá nomear um administrador-depositário, o qual poderá ser o exequente, o executado, ou profissional qualificado para desempenhar a função nos casos em que não ocorra consenso entre as partes.

Assim como ocorre em diversas espécies de penhora, o administrador-depositário deverá apresentar ao juiz, um plano de administração do bem (art. 869, § 1.º, CPC/2015); havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, caberá ao juiz estabelecer a melhor forma de administração (art. 869, § 2.º, CPC/2015).

Nas situações em que o bem estiver locado ou arrendado a inquilino ou terceiro, este deverá ser informado de que efetuará o pagamento junto ao administrador (art. 869, § 3.º, CPC/2015) ou caso ainda não tenha ocorrido a nomeação, pagará diretamente ao exequente.

Sendo que tais quantias recebidas pelo administrador-depositário deverão ser entregues ao exequente. Com a entrega já serão imputadas no pagamento da dívida, objeto da execução (art. 869, § 5.º, do CPC/2015). Deverá o exequente, por meio de termo nos autos, dar quitções parciais das quantias recebidas (art. 869, § 6.º, CPC/2015).

Finalmente, ainda é possível que o exequente ou o administrador-depositário celebrem contrato de locação do imóvel ou móvel, após ser ouvido o executado (art. 869, § 4.º, CPC/2015). Trata-se de uma modalidade típica de negócio processual (art. 190, CPC/2015, cf. *supra*, introdução, 2.17).

Subseção XI Da avaliação¹⁴⁵

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

1. Avaliação. A avaliação é o ato pelo qual se dimensiona qual o valor econômico exato do bem penhorado, ou seja, atribui-se um preço ao bem penhorado. Tal ato é indispensável para que posteriormente se proceda à expropriação do bem.

Essa avaliação tem íntima relação ao devido processo justo (*fair trail, giusto processo, procès équitable*) previsto no art. 5.º, LIV, da CF/1988, pois garante-se a parte que a privação a seus bens ocorra exatamente na medida da dívida que o executado possui com a restituição dos valores superiores à dívida para o seu patrimônio e, para isso, torna-se imprescindível que se determine um valor exato para o bem que será expropriado.¹⁴⁶ Sem saber a avaliação do bem, todos os demais atos seriam prejudicados; por essa razão, a avaliação passou a ser determinada desde o início da atividade executiva para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa já com o mandado de citação, penhora e avaliação (art. 829. “O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1.º. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”, CPC/2015).

2. Avaliação por oficial de justiça. No que diz respeito ao ato da avaliação, via de regra, ele é feito por oficial de justiça avaliador, como determina o *caput* do dispositivo e também preveem os arts. 154, V, e 829, § 1.º, do CPC/2015. A necessidade de treinamento e preparo profissional dos avaliadores é um dos temas mais debatidos na doutrina internacional (cf., *supra*, a atividade dos agentes de execução, *baillifs* e *houssiers*, na tradição do *common law* e no direito europeu, introdução, 2.4).

3. Avaliação por avaliador. Ocorre que, quando é necessário conhecimento técnico especializado para que se proceda à avaliação, o juiz deverá nomear um avaliador, o qual terá um prazo máximo de 10 (dez) dias para realizar a avaliação.

Insta ressaltar também a previsão de que não se procederá à nomeação de avaliador caso o valor da execução não comporte sua realização, ou seja, naquelas situações em que o montante a ser executado seja incompatível com a quantia que deveria ser paga ao avaliador pelo serviço prestado, deve-se realizar a avaliação por oficial de justiça.

Outrossim, vale destacar que, nas comarcas ou subseções em que não há avaliador, o juiz nomeará um perito de sua confiança que possua conhecimentos técnicos para realizar a avaliação, caso contrário, não sendo demonstrada a qualificação técnica do avaliador, será considerada como nula a avaliação, sendo nesse sentido a jurisprudência do STJ (STJ, REsp 351.931, 1.ª Turma, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.2001, DJ 04.03.2002; STJ, RMS 10.994/PE, 4.ª Turma, rel. Min. Jorge Scatezzini, j. 21.10.2004).

A nomeação de avaliador pelo juiz é colaboração de agente privado com a atividade executiva. Porém, a necessidade de centralizar a atividade no juiz torna o procedimento mais lento. O modelo misto de execução poderia colaborar para maior agilidade e economia nesta atividade, a participação dos órgãos públicos e privados na execução poderia gerar maior qualificação e especialização dos avaliadores, independentemente da participação do juiz (cf., *supra*, introdução, 2.4).

Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

I – uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;

II – se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

III – se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou

publicação no órgão oficial;

IV – se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem.

1. Desnecessidade de realizar a avaliação. O dispositivo traz 4 (quatro) situações em que não é necessária a realização de avaliação, sendo que apenas o inc. IV é regramento novo, que não encontrava correspondente no Código de Processo Civil de 1973. São elas: a) quando alguma das partes acolhe o valor estimado pela outra, ou seja, quando há consenso entre os litigantes, tratando-se de típico caso de negócio processual (inc. I); b) quando os bens penhorados forem títulos ou mercadorias que tenham cotação em bolsa e possuírem a devida comprovação por meio de certidão ou publicação no órgão oficial (inc. II); c) quando os bens penhorados forem títulos da dívida pública, ações de sociedades e títulos de crédito negociáveis em bolsa e cujo valor puder ser comprovado pela cotação oficial do dia a partir de certidão ou publicado no órgão oficial (inc. III); d) quando os bens penhorados forem veículos automotores ou outros cujo o preço médio possa ser conhecido a partir de pesquisas realizadas em órgãos oficiais ou em anúncios de venda divulgados nos meios de comunicação, cabendo a parte que fizer a nomeação comprovar a cotação em mercado, a qual deve ser aceita pela comunidade de maneira geral (inc. IV).

Nesse sentido, um exemplo dessa situação pode ocorrer quando se pesquisa o preço de mercado de veículo automotor na “Tabela FIPE” (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), a qual tem elevado grau de prestígio junto à sociedade. A “Tabela FIPE” é utilizada, inclusive, para a avaliação e contratação de seguro de veículos automotores, sendo, claramente, um parâmetro de mercado.

Existe, na doutrina, quem entenda ser a melhor solução para a questão uma previsão geral de dispensa da avaliação naquelas situações em que o juízo entender ser esta desnecessária, devendo tal dispensa ser devidamente fundamentada, assim “[a] rigor, em nosso sentir, seria melhor que o legislador fixasse uma cláusula genérica de desnecessidade de avaliação sempre que o magistrado entendesse como adequada ou justa a avaliação apresentada pelas partes”.¹⁴⁷

Tratando-se de decisão fundamentada de atipicidade (art. 139, IV, CPC/2015), entendemos que esta solução já é possível, respeitado o contraditório (art. 10, CPC/2015, cf., *supra*, introdução, 2.14 e 2.15). Esse resultado pode ser obtido mediante a conciliação ou mediação em juízo (arts. 139, V, e 515, § 2.º, CPC/2015).

2. Dúvida e presunção relativa. Quando houver fundada dúvida por parte do juiz quanto ao valor atribuído por consenso entre as partes ao bem penhorado poderá ser feita avaliação, devendo o juízo fundamentar e comprovar a necessidade da realização desta (arts. 10 e 489, § 1.º, CPC/2015).

Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I – os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II – o valor dos bens.

§ 1º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

§ 2º Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento,

as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.

1. Requisitos para o laudo de avaliação. O oficial de justiça, quando do cumprimento de mandado de penhora/avaliação, deverá realizar vistoria dos bens, apresentando, no prazo fixado pelo juízo, laudo que conterá a especificação destes quanto às características e ao estado em que se encontram e, principalmente, o valor desses bens, da mesma forma deverá proceder também o avaliador nomeado pelo juízo.

É bom ter presente que a apresentação do laudo de avaliação é obrigatória e indispensável (STJ, REsp 351.931/SP, 1.^a Turma, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.2001, *DJ* 04.03.2002, p. 207), sendo que seu conteúdo deve ser adequado ao previsto no art. 872 do CPC/2015, caso contrário deverá ser considerado nulo e outra avaliação deverá ser realizada.

2. Imóvel passível de divisão. Quando o bem penhorado for passível de divisão, o oficial de justiça ou o avaliador deverão realizar o laudo de avaliação em partes, tendo em vista o valor da execução, fazendo sugestão a respeito do mais benéfico desmembramento a ser feito no momento da alienação. Sendo que, caso o bem não possa ser repartido, sua alienação deve ocorrer a partir da integralidade do mesmo (STJ, REsp 798.143/MA, 4.^a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, *DJU* 26.02.2007, p. 596; STJ, REsp 31.234/MG, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 29.11.1993, p. 25.885).

3. Contraditório e avaliação. Tal disposição foi inserida pelo legislador no CPC e vem comprovar que atualmente o contraditório deve estar presente durante todo o arco processual (arts. 9.^o e 10 do CPC/2015), devendo ser compreendido como direito de influência e dever de debates, de forma que, também o juiz, na decisão, deva levar em consideração as manifestações das partes, vedada a decisão surpresa (art. 10, CPC/2015). Dessa forma, agiu corretamente o legislador ao prever abertura para manifestação das partes no prazo de 5 (cinco) dias da realização da avaliação. Há homenagem ao contraditório como valor-fonte do processo civil.¹⁴⁸ A decisão do juiz sobre a avaliação será agravável (art. 1.015, parágrafo único, CPC/2015).

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do *caput* deste artigo.

1. Hipóteses de nova avaliação. Primeiramente, vale destacar que cabe ao juiz, durante toda execução, controlar a penhora e o valor dos bens penhorados sempre tendo em vista o montante total a ser expropriado (STJ, REsp 299.120/MS, 3.^a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 12.04.2005, *DJ* 09.05.2005, p. 388). Nesse sentido, o dispositivo traz hipóteses em que é possível realizar nova avaliação do bem penhorado, para se saber se ainda está compatível com o valor a ser executado. As hipóteses para realização de nova avaliação são: a) quando ficar comprovado erro ou dolo por parte do avaliador (inc. I); b) quando o bem penhorado tiver seu valor modificado (inc. III); c) quando o juiz tiver fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem penhorado na primeira avaliação (cf., *infra*, comentários ao art. 870).

Quando o juiz tiver dúvida fundada sobre a primeira avaliação deverá determinar nova avaliação, utilizando-se, para tanto, das regras previstas no art. 480 do CPC/2015, referentes à realização de segunda perícia (cf., *infra*, comentários ao art. 873, parágrafo único, CPC/2015).

Segundo o texto do artigo: “art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1.^o A

segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2.º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3.º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra”.

Portanto, a segunda avaliação poderá: a) ser determinada de ofício ou a requerimento da parte; b) terá por objeto os mesmos bens; c) destina-se a corrigir os eventuais equívocos por omissão ou inexatidão da avaliação anterior (que deverão ser, preferencialmente, especificados pelo juiz e pelas partes); d) rege-se pelas mesmas disposições da primeira avaliação; e e) não substitui a primeira, cabendo ao juiz decidir qual será aplicável.

2. Jurisprudência do STJ. Quanto à segunda avaliação, o STJ já decidiu que “(...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, *in casu*, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão” (REsp 1.014.705/MS, 3.ª Turma, rel. Min. Massami Uyeda, j. 24.08.2010, *DJe* 14.09.2010).¹⁴⁹

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I – reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II – ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

1. Redução ou alteração da penhora. Realizada a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do executado, reduzir a penhora ou transferi-la para outros bens, quando o valor atribuído na avaliação for superior ao montante total da execução ou ampliar a penhora ou transferi-la para bens mais valiosos, a requerimento do exequente, nas situações em que ficar comprovado que o valor atribuído na avaliação é bem inferior ao valor a ser expropriado (cf., *infra*, comentários ao art. 850 do CPC/2015).

Para tomar tais ações, o juiz deve sempre garantir o contraditório (arts. 9.º e 10 do CPC/2015), possibilitando a parte contrária que se manifeste sobre o requerimento de ampliação ou redução no valor total da penhora.

2. Reforço *ex officio* da penhora. Não é cabível o reforço da penhora *ex officio*.

Já decidiu o STJ sobre a questão: “O reforço da penhora não pode ser deferido *ex officio*, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC.” (...) Destarte, consoante a dicção dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC, não é facultada ao Juízo a determinação de substituição ou reforço da penhora, ao fundamento de insuficiência do bem constrito. 5. É que o princípio do dispositivo, que vigora no Processo Civil, pressupõe que as atividades que o juiz pode engendrar *ex officio* não inibem a iniciativa da parte de requere-las, não sendo verdadeira a recíproca. Em consequência, por influxo desse princípio, nas atividades que exigem a iniciativa da parte, o juiz não pode agir sem provocação (...).” (REsp 1127815/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1.ª Seção, j. 24.11.2010, *DJe* 14.12.2010).¹⁵⁰

Essa conclusão é reforçada pelo princípio da responsabilidade objetiva na execução decorrente da penhora excessiva. Não sendo o exequente o requerente, a penhora excessiva seria de responsabilidade do juízo.

Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.

1. Início dos atos expropriatórios. Ressalta-se que só se dará início aos atos expropriatórios quando devidamente realizadas a penhora e a avaliação. Para isso, é necessário que constem nos autos: a) o termo de penhora com respeito a todos os requisitos previstos no art. 838 do CPC/2015;

b) laudo de avaliação que possibilite a identificação do exato valor atribuído ao bem penhorado, nos termos do art. 872 do CPC/2015.

Seção IV - Da expropriação de bens

Subseção I - Da adjudicação¹⁵¹

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II – por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III – por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos.

§ 2º Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 274, parágrafo único.

§ 3º Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1º.

§ 4º Se o valor do crédito for:

I – inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II – superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

§ 7º No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.

1. Definição. A adjudicação é técnica processual executiva típica voltada à satisfação do crédito em execução por quantia certa, ao lado da alienação por iniciativa particular e da alienação por leilão público. Por meio de um procedimento expropriatório, bem(ns) móvel(is) ou imóvel(is) de propriedade do executado são transferidos ao patrimônio do exequente. Há também a adjudicação alienação, quando um terceiro adjudica o bem pagando o preço da avaliação.

Há, portanto, uma dúplici finalidade na adjudicação: a) forma de pagamento ao credor-exequente (art. 876, *caput* c/c art. 904, II, CPC/2015); b) (art. 876, § 5.º e 7.º, c/c art. 904, I, CPC/2015).

Na doutrina: “(...) a adjudicação *pode* ser *também* forma de pagamento ao credor-exequente (art. 904, II, CPC/2015), caso ele seja o adjudicatário (art. 876, *caput*, CPC/2015): a obrigação executada é satisfeita com a transferência da coisa adjudicada ao patrimônio do exequente, no limite do valor da respectiva avaliação. Quando a transferência é feita a terceiro não exequente (art. 876, § 5.º e 7.º, CPC/2015), a adjudicação serve ao exercício de um direito de preferência que

a lei lhe outorga; nesse caso, a satisfação da obrigação ocorrerá com a entrega do dinheiro pago pelo terceiro ao exequente (art. 904, I, CPC/2015). Há, aqui, uma alienação judicial sem hasta pública [leilão público], em que se garante um direito de preferência a certos sujeitos. A adjudicação pode ser tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. Bem penhorado que possa ser alienado pode ser adjudicado (...)"¹⁵²

Não há que se confundir a *adjudicação*, modalidade de aquisição do bem por expropriação, com: a) a *execução de entrega de coisa ou ação de imissão de posse*, pois enquanto nestas o bem em si é que se revela objeto da execução, na adjudicação é o crédito;¹⁵³ (b) com a *dação em pagamento*, pois enquanto esta é um instituto de direito material (arts. 356 a 359, CC) que necessita de consentimento para que o bem seja transferido, na adjudicação o bem penhorado é transferido coativamente.¹⁵⁴

Nada impede, contudo, que por conciliação as partes aceitem no curso da execução a dação em pagamento do bem penhorado, caso em que não haverá adjudicação (art. 515, § 2.º, CPC/2015). Sabendo a parte executada que o exequente tem interesse na adjudicação e estando de acordo poderá ser acelerado o procedimento mediante a conciliação, abreviando-se o tempo do processo (cf., *supra*, introdução, 2.16).

2. Preferencialidade da adjudicação como técnica expropriatória. A posição topológica da adjudicação no Código denota o seu caráter preferencial em relação às demais técnicas expropriatórias previstas.¹⁵⁵ Trata-se de uma opção legislativa fundamentada na maior simplicidade do procedimento adjudicatório comparativamente aos demais. Em assim sendo, após realizada a avaliação, o bem penhorado deverá, preferencialmente, ser adjudicado, desde que não seja oferecido preço inferior ao da avaliação, bastando, portanto, o requerimento dos exequentes e/ou legitimados neste sentido.

3. Legitimados. A legitimidade para requerer a adjudicação é do exequente e também de terceiros interessados – tais como credores com garantia real, sejam eles credores pignoratícios, hipotecários, anticréticos ou fiduciários (art. 876, § 5.º c/c art. 889, II a VIII, ambos do CPC/2015); credores concorrentes que eventualmente tenham penhorado o mesmo bem, cônjuge, companheiro(a) e descendentes ou ascendentes do executado. Nos casos de concorrência de pretendentes à adjudicação, será aberto procedimento licitatório e terá prioridade aquele que apresentar o melhor preço. Ainda, no caso em que persistirem ofertas iguais, terá preferência, nesta ordem, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente (art. 876, § 6.º, CPC/2015). Há ainda uma hipótese típica de preferência estabelecida no art. 876, § 7.º, CPC/2015, nos casos de sócios que queiram adjudicar quotas sociais penhoradas por terceiro alheio à sociedade, hipótese na qual, em prestígio à *affectio societatis*, a sociedade será intimada.¹⁵⁶

4. Intimação do executado. É necessária a intimação do executado do requerimento de adjudicação, prevendo o Código taxativamente como deverá ocorrer esta intimação (art. 876, § 1.º, CPC/2015): a) se o executado for representado por advogado constituído nos autos, a intimação ocorrerá por meio do *Diário Oficial da Justiça* (inc. I); b) se o executado não tiver advogado constituído nos autos ou for representado pela Defensoria Pública, a intimação ocorrerá por carta com aviso de recebimento (inc. II); c) se o executado for empresa pública ou privada com cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, a intimação ocorrerá por meio eletrônico (inc. III c/c art. 246, § 1.º). A intimação será dispensada em duas hipóteses: a) quando o executado mudar de endereço sem comunicar ao juízo previamente (§ 2.º); ou b) quando o executado foi citado por edital e não constituiu patrono nos autos (§ 3.º).

5. Preço da adjudicação. A adjudicação tem que respeitar o preço da avaliação. Caso o valor do crédito seja inferior ao bem adjudicado, o exequente deverá depositar judicialmente a diferença, a qual poderá ser levantada pelo executado. Caso o valor do crédito seja superior ao bem adjudicado, a execução prosseguirá em relação ao crédito remanescente (art. 876, § 4.º, I e II, CPC/2015). No que tange à possibilidade de adjudicação de direitos hereditários do executado, o STJ decidiu que “ante a natureza universal da herança, a adjudicação dos direitos hereditários não pode ser de um ou alguns bens determinados do acervo, senão da fração ideal que toca ao herdeiro devedor” (REsp 1330165/RJ, 3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2014, *Dje*

02.06.2014).

Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.

§ 1º Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

I – a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II – a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel.

§ 2º A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão.

§ 3º No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido.

§ 4º Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no § 3º será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.

1. Prazo de manifestação até a lavratura do auto de adjudicação. O auto de adjudicação deverá ser lavrado após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da última intimação e da decisão de eventuais questões pendentes (art. 877, *caput*, CPC/2015). É a lavratura do auto – com as assinaturas do juiz, do adjudicatário, do escrivão ou do chefe de secretaria e do executado (se presente) – que consolida a adjudicação, tendo-a por perfeita e acabada (art. 877, § 1.º, CPC/2015).

2. Após a lavratura do auto de adjudicação. Caso o bem seja imóvel, será expedida a carta de adjudicação, conjunto de documento responsável pela instrumentalização da adjudicação, e o respectivo mandado de imissão na posse (art. 877, I, CPC/2015). Se o bem for móvel, basta a expedição de mandado de entrega da coisa ao adjudicante (art. 877, II, CPC/2015). A carta de adjudicação serve como título de aquisição e, portanto, necessita de registro junto à matrícula do imóvel para transferir o domínio da propriedade.¹⁵⁷ O mesmo raciocínio é aplicável aos bens imóveis que demandam registro, no que será utilizado o mandado de entrega da coisa para fins de registro, por exemplo, nos casos de automóveis, junto ao RENAVAM do veículo (arts. 1.227 e 1.245, CC).

3. Remição e bem adjudicado. Enquanto não for lavrado o auto de adjudicação, é possível remir da execução (art. 826, CPC/2015). A remição do bem pelo executado “retornou das cinzas” em hipóteses específicas:¹⁵⁸ se o bem for hipotecado, o executado poderá fazê-lo oferecendo preço igual ao da avaliação, ou então, inexistindo licitantes, oferecendo preço igual ao maior lance oferecido (art. 877, § 3.º, CPC/2015). Em situações de falência ou insolvência do devedor hipotecário, a remissão do bem hipotecado será deferida à massa ou aos credores em concurso, ficando vedada ao exequente a recusa do preço de avaliação do imóvel (art. 877, § 4.º, CPC/2015).

Art. 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação.

1. Momentos da adjudicação. A adjudicação é técnica processual expropriatória que é preferencial em relação às demais e poderá ser requerida pelo exequente após a avaliação do bem móvel ou imóvel. Contudo, caso o exequente opte pela alienação do bem por iniciativa particular ou por leilão público e estas tentativas se mostrarem frustradas no decorrer do processo, haverá uma nova oportunidade para que a adjudicação seja realizada. Nada impede, ainda, que seja o

bem reavaliado para adequá-lo a uma eventual desvalorização que tenha sofrido com o transcurso do tempo.

Subseção II Da alienação¹⁵⁹

Art. 879. A alienação far-se-á:

I – por iniciativa particular;

II – em leilão judicial eletrônico ou presencial.

1. Modalidades de alienação judicial. Alienação é gênero da qual são espécies a alienação por iniciativa particular e a alienação em leilão judicial. A diferença entre ambas pode ser verificada na intensidade da participação do Poder Judiciário no procedimento de alienação do bem.¹⁶⁰ A alienação por iniciativa particular, reintroduzida no sistema processual pátrio com a Reforma do Código de Processo Civil de 1973 (Lei 11.383/2006) como alternativa à alienação por hasta pública, vigente à época, hoje, ao leilão público,¹⁶¹ conta com menos participação do Poder Judiciário, que apenas estabelece os parâmetros pelos quais a alienação deve ser feita, controlando a sua respectiva legalidade. É um importante instrumento de efetividade da execução.

Há possibilidade de negócio processual determinando a preferência pela alienação por iniciativa particular (art. 190, CPC, cf., *supra*, introdução, 2.17); assim como esta poderá ser determinada pelo juiz caso se afigure mais efetiva, ainda que de forma antecipada (art. 139, IV, CPC, cf., *supra*, introdução, 2.14 e 2.15), especialmente se se mostrar mais vantajosa (art. 852, II, CPC/2015). A alienação por leilão judicial, por sua vez, vale-se da estrutura do próprio Poder Judiciário para realizar a alienação. Ademais, a alienação por leilão judicial foi subdividida em duas outras espécies: o leilão judicial eletrônico e o leilão judicial presencial.

Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

§ 1º O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.

§ 2º A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se:

I – a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II – a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel.

§ 3º Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos.

§ 4º Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3º, a indicação será de livre escolha do exequente.

1. Alienação por iniciativa particular. Trata-se de técnica processual alternativa à adjudicação – a qual goza de *status* prioritário neste quesito – e que, levando em consideração a ordem topológica estabelecida pelo Código, é preferencial em relação à alienação por leilão judicial. A técnica já era da tradição brasileira, existente à época do Código de Processo Civil de 1939, mas foi abolida no Código de Processo Civil de 1973.¹⁶² A abolição se justifica por que a técnica não poderia subsistir em um ambiente totalmente público de processo. Assim, por ter sido criticada por seu privatismo, o Código de Processo Civil de 1973, que era um monumento à técnica processual e ao direito público, e pretendia sanear as atividades privadas que não condiziam com

a função pública do processo, deu cabo a essa técnica expropriatória. Obrava em erro, há evidente combinação de interesses públicos e particulares na execução. Mais, o interesse público na execução fomenta a sua efetividade (tutela do direito fundamental ao processo efetivo, processo justo e tutela do crédito, cf., *supra*, premissas, 1.1, introdução, 2.4 a 2.9). Em boa hora voltou a técnica nas Reformas (Lei 11.382/2006).

No atual Código percebe-se que a sua colocação topológica é um consectário lógico que busca dar maior efetividade à execução a partir de uma comunidade de trabalho estabelecida entre os sujeitos processuais (*princípio da cooperação*, art. 6.º, CPC/2015). A maior participação do Poder Judiciário na alienação por leilão judicial onera sobremaneira a máquina judiciária se comparada às demais modalidades expropriatórias, além de muitas vezes representar uma forma mais cara e menos eficiente de alienação, pois o preço obtido no leilão judicial poderá ser menor pelas características específicas do procedimento e será muito menos ágil diante das diversas formalidades exigidas. A alienação particular atende, portanto, aos ideais do art. 4.º do CPC/2015 de tutela adequada e efetiva. No mundo todo, diga-se de passagem, as figuras mistas de atividade pública e privada, judicial e extrajudicial, estão sendo buscadas para permitir mais economia e efetividade nos atos executivos.¹⁶³

A alienação por iniciativa particular poderá ser feita pelo próprio exequente ou por leiloeiro público devidamente credenciado junto ao Poder Judiciário.

Embora a redação do dispositivo diga que o exequente é que deverá requerer a alienação judicial por iniciativa particular, nada impede que o juiz a determine de ofício e até mesmo o devedor a requiera quando se mostrar um expediente menos gravoso.¹⁶⁴

As partes também poderão convencionar, mediante negócio processual anterior ao processo ou no curso do processo, sobre a alienação por iniciativa particular (art. 190, CPC/2015, cf., *supra*, introdução, 2.17). Como vimos, além das partes, o juiz tem poderes de direção do processo para garantia da adequação e efetividade do procedimento e poderá determinar a alienação antecipada por iniciativa particular, quando isto se afigurar mais razoável aos interesses e direitos em jogo no processo, obedecendo aos critérios de ônus argumentativo e proporcionalidade mencionados na parte introdutória (art. 139, IV, c/c art. 852, CPC/2015, cf., *supra*, introdução, 2.14 e 2.15).

2. Condições de realização da alienação por iniciativa particular. A alienação por iniciativa particular conta com uma participação menos intensa do Poder Judiciário, devendo o juiz estabelecer os parâmetros pelos quais o procedimento deverá ser realizado e, eventualmente, controlar a sua legalidade. Para tanto, caso impossível a adjudicação ou assim não opte o exequente, este deverá requerer a sua realização.

Ato contínuo, o juiz fixará prazo, forma de publicidade, preço mínimo, condições de pagamento, garantias e, caso necessário, a comissão de corretagem (art. 880, § 1.º, CPC/2015). O prazo deverá ser fixado à luz da razoável duração do processo, propiciando que a alienação seja realizada de maneira adequada e tempestiva (art. 4.º do CPC/2015), facultando, portanto, que a natureza do direito material tutelado seja critério observado neste momento (*posta in gioco; what is at stake in the dispute*). Aqui há um sinal da *adequação* ao direito material como regra do procedimento executivo, como defendido na introdução deste trabalho (cf., *supra*, premissas, 1.3, introdução, 2.14 e 2.15).

A publicidade é critério de transparência da alienação, devendo ser estipulada uma publicação ampla das datas de sua realização. O preço mínimo não necessariamente deverá corresponder ao valor da avaliação, o que não equivale a afirmar que o valor da avaliação não deverá ser considerado quando da estipulação do preço mínimo. Isto ocorre porque a alienação do bem não pode ser obstaculizada pelo preço mínimo estipulado, devendo a execução prezar pela efetividade da satisfação do crédito, ainda que parcialmente, caso assim deseje o executado e desde que não caracterize preço vil (art. 891, CPC/2015).

A vontade do executado poderá ser dispensada para a satisfação da tutela do crédito, desde que justificada a alienação e não caracterizado o preço vil. Este é um desdobramento necessário da

premissa de que a atividade de execução deve ser voltada para a tutela do crédito.

3. Formalização da alienação por iniciativa particular. A alienação será reduzida a termo nos autos, com a assinatura do juiz, exequente, adquirente e executado, caso presente. A formalização da alienação será concluída, nos casos de bem imóvel, com a expedição de carta de alienação e mandado de imissão na posse; ou, nos casos de bem móvel mediante ordem de entrega ao adquirente (art. 880, § 2.º, CPC/2015). A assinatura do juiz constitui ato de homologação da alienação, ratificando, portanto, a legalidade do procedimento.¹⁶⁵ Assim como nos casos de adjudicação, a carta de alienação e a ordem de entrega deverão ser registradas para fins de transferência do domínio (arts. 1.227 e 1.245, CC).

4. Regulamentação da alienação por iniciativa privada pelos Tribunais de Justiça estaduais. O Código faculta aos Tribunais locais que regulamentem a alienação por iniciativa privada, medida importante para atender às particularidades regionais e, se for o caso, desburocratizar o procedimento – respeitadas as exigências-quadro previstas no Código de Processo Civil. Assim, poderão os tribunais admitir concurso de meios eletrônicos e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, exigindo o exercício profissional de pelo menos 03 (três) anos (art. 880, § 3.º, CPC/2015). Caso não haja corretores ou leiloeiros públicos credenciados, o exequente poderá indicar um (art. 880, § 4.º, CPC/2015), ato que é passível de controle de legalidade pelo juiz. Há também a possibilidade de negócio processual nesta matéria, pois os corretores poderão ser escolhidos consensualmente pelas partes antes ou mesmo durante o processo de execução (art. 190, c.f., *supra*, introdução, 2.17). A possibilidade de adequação do procedimento às peculiaridades regionais é um requisito essencial da adequação do processo de execução em um país continental como o Brasil; o Código de Processo Civil segue, portanto, a previsão constitucional na matéria (art. 24, XI).¹⁶⁶

Aponta, nessa esteira, o Enunciado 192 do FPPC que, *a priori*, a alienação particular não deve ser invalidada se o corretor ou leiloeiro não for credenciado pelo órgão judiciário (“Alienação por iniciativa particular realizada por corretor ou leiloeiro não credenciado perante o órgão judiciário não invalida o negócio jurídico, salvo se o executado comprovar prejuízo”).

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.

§ 1º O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público.

§ 2º Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público.

1. Ordem de preferência. A alienação por meio de leilão judicial é possível quando não houver interesse do exequente na adjudicação e na alienação por iniciativa particular. É, portanto, técnica processual expropriatória de *caráter residual*. O Código abandonou a expressão “hasta pública”, que remontava ao direito romano, e utiliza unicamente a expressão “leilão judicial” para definir a modalidade de alienação feita pelos órgãos públicos.¹⁶⁷

2. Diferença entre praça e leilão? O Código não mais diferencia praça (leilão de bens imóveis) e leilão (para bens móveis) como espécies do gênero alienação judicial. Encerrada a burocrática alienação por “hasta pública”, prevista no Código de Processo Civil de 1973, também deve ser simplificada a linguagem. O apuro técnico serve apenas a uma finalidade no processo: à tutela dos direitos.

Art. 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial.

§ 1º A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla

publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital.

§ 3º O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz.

1. Leilão judicial. A alienação judicial por leilão comporta duas modalidades: o leilão eletrônico, de caráter prioritário, e o leilão presencial. Essa ordem de preferência, mais uma vez acentuada no Código, busca dar maior efetividade e celeridade ao processo de execução por meio da modernização tecnológica do procedimento expropriatório. A técnica serve à tutela dos direitos.

2. Leilão eletrônico. O leilão eletrônico tem como vetores os requisitos da publicidade, autenticidade e segurança. Foi editada pelo CNJ a Resolução 236/2016 para regulamentar o leilão eletrônico, tratando dos requisitos e documentos necessários ao credenciamento dos leiloeiros judiciais e corretores (arts. 1.º a 4.º), exigindo que os leiloeiros credenciados junto ao Poder Judiciário estejam em exercício da função por pelo menos 03 (três) anos (art. 880, § 3.º, CPC/2015). A resolução tratou ainda de especificar alguns parâmetros para a realização do procedimento do leilão eletrônico (arts. 12 a 34) e, por fim, dos registros eletrônicos de penhora (arts. 35 e 36).

3. Local de realização do leilão. Cabe ao juiz designar o local em que ocorrerá o leilão presencial (art. 883, § 3.º, CPC/2015), preferencialmente no local onde estejam os bens alienados (art. 884, II, CPC), mas sempre levará em consideração o local que possua maior eficiência para a satisfação do crédito (art. 4.º, CPC/2015).

Art. 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.

1. Indicação do leiloeiro. O exequente poderá indicar o leiloeiro, mas será o juiz que deverá designá-lo. Trata-se de uma diferença sutil, mas relevante. O juiz deverá zelar, neste caso, pela idoneidade do leilão público. Há um direito de escolha do leiloeiro, pertencente ao exequente, mas não há um direito de que o leiloeiro indicado seja designado (STJ, RMS 38.987/SP, 3.ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.08.2013, *DJe* 22.08.2013). Aqui caberá também o negócio processual: antes ou durante o processo de execução. As partes poderão, portanto, estipular convencionalmente o leiloeiro que entenderem mais conveniente de forma consensual. Após a realização do negócio o controle de validade da indicação do leiloeiro pelas partes será realizado pelo juiz (art. 190, CPC, cf., *supra*, introdução, 2.17).

Art. 884. Incumbe ao leiloeiro público:

I – publicar o edital, anunciando a alienação;

II – realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz;

III – expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;

IV – receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto da alienação;

V – prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.

Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz.

1. Deveres do leiloeiro. O art. 884 do CPC/2015 estabelece um rol de deveres a serem cumpridos pelo leiloeiro público, tais como a publicação do edital para anúncio da alienação, a realização do leilão no local onde se encontram os bens ou no lugar designado pelo juiz, a exposição dos bens aos pretendentes, o recebimento e depósito do produto da alienação dentro do prazo de 01 (um) dia, além da prestação de contas nos 02 (dois) dias após o depósito. Além das obrigações estipuladas pelo Código, o art. 5.º da Resolução 236/2016 do CNJ estabelece outras responsabilidades do leiloeiro, firmadas mediante assinatura de um Termo de Credenciamento e

Compromisso para o exercício de suas funções junto ao Poder Judiciário, a saber: a) o dever de remoção, depósito, guarda e conservação dos bens, na condição de depositário judicial (art. 5.º, I); b) o dever de ampla divulgação do edital do leilão público, por meio de mídia impressa, mala direta, publicação em jornais e na rede mundial de computadores (art. 5.º, II); c) o dever de exposição dos bens guardados em horário comercial – das 8h às 18h –, facultado o agendamento de visitas (art. 5.º, III); d) o dever de responder ou justificar a impossibilidade de resposta às indagações do órgão jurisdicional (art. 5.º, IV); e) o dever de comparecer com antecedência e de planejar o leilão (art. 5.º, V); f) o dever de comprovação documental das despesas com a remoção, guarda e depósito do bem (art. 5.º, VI); g) o dever de exclusão do leilão de bens ordenados pelo juiz (art. 5.º, VII); h) o dever de comunicação sobre eventuais avarias ao bem guardado (art. 5.º, VIII); i) o dever de comparecimento ou nomeação de prepostos para participação de reuniões no órgão jurisdicional e/ou Tribunal (art. 5.º, IX); j) o dever de atualização dos dados cadastrais (art. 5.º, X); l) o dever de criação e manutenção de *site* eletrônico para viabilização e divulgação do leilão eletrônico (art. 5.º, XI); m) o dever de comunicação ao órgão jurisdicional sobre a impossibilidade de realização do leilão (art. 6.º, *caput*), de disponibilização da estrutura planejada para não prejudicar a realização do processo (art. 6.º, § 1.º) e de justificativa documental (art. 6.º, § 2.º), tudo sob pena de descredenciamento.

2. Comissão do leiloeiro. Em contrapartida aos deveres assumidos, será devida ao leiloeiro uma comissão estabelecida pelo juiz ou definida em lei (art. 884, parágrafo único, CPC/2015). Trata-se de um *direito subjetivo* do leiloeiro que surge somente quando efetivamente realizado leilão e arrematado o bem; em caso de não arrematação do bem, o leiloeiro faz jus somente ao ressarcimento dos seus custos com a atividade, ou seja, dos gastos dispendidos com publicidade, remoção, guarda e depósito do bem, desde que juntados os documentos comprobatórios neste sentido, na esteira do art. 40 do Dec. 21.981/1932 (STJ, REsp 1179087/RJ, 4.ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2013, *DJe* 04.11.2013). O valor mínimo da comissão do leiloeiro é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação do bem (art. 24, parágrafo único, Dec. 21.981/1932) e “não há limitação quanto ao percentual máximo a ser pago ao leiloeiro a título de comissão. Não há que se falar na exigência de negociação prévia acerca da remuneração do leiloeiro, pois, com a publicação do edital, o arrematante teve ciência de todos os seus termos, oportunidade em que poderia ter impugnado o valor referente à comissão” (STJ, REsp 680.140/RS, 5.ª Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j. 02.02.2006, *DJ* 06.03.2006).

Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.

1. Condições de pagamento, garantias e parâmetros do leilão judicial. O juiz deverá estabelecer o preço mínimo do leilão, o qual não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) de avaliação do bem, sob pena de ser considerado vil (art. 891, parágrafo único, CPC/2015). Eventuais condições de pagamento e garantia deverão ser estabelecidas à luz das circunstâncias de mercado e do caso concreto. Influência local da execução, além do tipo de bem objeto de alienação.¹⁶⁸

Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:

I – a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II – o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

III – o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados;

IV – o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V – a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro;

VI – menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.

Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.

1. Requisitos do edital para o leilão judicial. Os requisitos previstos no art. 886 do CPC/2015 deverão constar do edital para o leilão público – seja bem móvel ou imóvel, já que a expressão “hasta pública” foi suprimida e com ela a diferença entre “praça” e “leilão”. Trata-se de um rol minucioso que visa disponibilizar o máximo de informações necessárias à ampla publicidade do procedimento expropriatório. Neste sentido, o edital conterá: a) informações relativas às características e situação registral do bem penhorado (inc. I); b) informações relativas ao preço de avaliação, preço mínimo, condições de pagamento e comissão do leiloeiro (inc. II); c) informações relativas ao local do bem penhorado (inc. III); d) informações relativas ao sítio eletrônico e ao período e local em que será realizado o leilão (incs. IV e V); e e) informações relativas a eventuais gravames judiciais ou extrajudiciais eventualmente incidentes sobre os bens penhorados (inc. VI).

2. Nulidade da arrematação. A inobservância dos requisitos previstos para a publicação do edital gera a sua respectiva nulidade. A nulidade do edital, contudo, segue a regra geral das nulidades previstas no Código de Processo Civil (por exemplo, arts. 281, 282 e 283, CPC) e ocorrerá tão somente se verificada “inequívoca demonstração de prejuízo” (STJ, REsp 520.039/RS, rel. Min. Eliana Calmon, 2.^a Turma, j. 21.09.2004, DJ 29.11.2004). Ademais, considerando que o conteúdo mínimo do edital visa *resguardar interesses dos potenciais arrematantes*, a nulidade é possível de ser decretada unicamente quando a omissão aproveitar “apenas ao arrematante e depende da demonstração da existência de prejuízo, sendo incabível tal alegação pelo devedor que não foi prejudicado” (STJ, REsp 1316970/RJ, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.05.2013, DJe 07.06.2013). Ou seja, a parte a quem aproveita o ato não pode alegar a sua nulidade se este atingiu sua finalidade ou se a própria parte deu causa à nulidade (arts. 276 e 277, CPC/2015). A nulidade é uma exceção e deve ser demonstrada a partir do efetivo prejuízo (art. 4.^o, CPC). A doutrina processual contemporânea já ultrapassou as nulidades meramente formais, características do modelo do Código de Processo Civil de 1973.¹⁶⁹

Inclusive o Enunciado 193 do FPPC (“Não justifica o adiamento do leilão, nem é causa de nulidade da arrematação, a falta de fixação, pelo juiz, do preço mínimo para a arrematação”) aconselha que a falta de fixação de preço mínimo para arrematação pelo juiz não deve ser causa para a nulidade da arrematação.

3. Aplicação à execução fiscal. As regras da alienação por leilão público são aplicáveis à execução fiscal “em tudo que não venha a macular a norma especial em suas peculiaridades finalísticas” (STJ, REsp 1198127/RJ, 2.^a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 02.09.2010, DJe 22.09.2010). Porém, há necessidade de que o devedor seja intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão (cf. enunciado da Súmula 121 do STJ: “na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”). Aplica-se o Código de Processo Civil supletiva, subsidiária e residualmente ao que não contrariar a Lei 6.830/1980.

Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação.

§ 1º A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão.

§ 2º O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial.

§ 3º Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.

§ 4º Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2º.

§ 5º Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios.

§ 6º O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução.

1. Divulgação do leilão judicial. Cabe ao leiloeiro divulgar amplamente as informações relativas à realização do leilão. Enquanto o Código de Processo Civil 1973 se restringia a exigir que o edital do leilão fosse afixado no átrio do fórum, o Código de Processo Civil de 2015 exige a publicação do edital na rede mundial de computadores, com informações detalhadas do bem e da natureza do leilão, não importando se presencial ou eletrônico (art. 887, § 2.º, CPC/2015). A novidade legislativa reside na divulgação do leilão eletrônico. Perceba-se a grande extensão dessas novidades que poderão representar uma publicidade muito maior e em uma muito maior efetividade do leilão, sem que isto represente qualquer aumento de trabalho ou onere economicamente o poder público.

2. Maximização da divulgação do leilão pelo juiz. O juiz tem ampla abertura para maximizar a divulgação do edital, permitindo, assim, a maior publicidade possível: quando o modo divulgação for insuficiente ou inadequado, poderá determinar a afixação do edital em local de costume e jornal de grande circulação local quando não for possível a publicação na rede mundial de computadores (art. 887, § 3.º, CPC/2015), ou, ainda, divulgar em local de ampla circulação de pessoas e em emissora de rádio ou televisão local (art. 887, § 4.º, CPC/2015), tudo isso em seção e preferencialmente específicos a tal finalidade (art. 887, § 5.º, CPC/2015).

Art. 888. Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887.

Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 (cinco) dias a 3 (três) meses, em procedimento administrativo regular.

1. Transferência. Impedida a realização do leilão por qualquer motivo que seja, o juiz determinará a sua publicação no sítio eletrônico respectivo, ou, subsidiariamente, nos locais utilizados para a divulgação do edital (art. 887, § 2.º, CPC/2015). O dispositivo do parágrafo único usa a expressão “transferência” no sentido de adiamento culposo do leilão.¹⁷⁰

2. Responsabilidade pelo adiamento do leilão. O escrivão, o chefe de secretaria e/ou o leiloeiro arcarão com as despesas de nova publicação caso verificada a culpabilidade dos mesmos para a transferência do leilão, sendo possível, ainda, a aplicação de penalidade de 05 (cinco) dias a 03 (três) meses (art. 888, parágrafo único, CPC/2015). Antes o limite máximo da penalidade era de 30 (trinta) dias.¹⁷¹ O aumento da penalidade corresponde à seriedade que exige o ato e ao investimento de tempo necessário para a sua preparação.

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I – o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos

autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

II – o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;

III – o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais;

IV – o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais;

V – o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

VI – o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;

VII – o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

VIII – a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado.

Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.

1. Publicidade do leilão e intimações obrigatórias. O art. 889 do CPC/2015 estabelece um rol de todos os sujeitos processuais que deverão ser intimados do leilão, com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência, a fim de dar máxima publicidade à convocação realizada.

2. Intimação do executado. A intimação do executado é imprescindível para a realização do leilão por se tratar de ato de efetivação da expropriação patrimonial, devendo o mesmo ser intimado para permitir o acompanhamento do procedimento e, eventualmente, controlar a sua legalidade por meio do exercício da ampla defesa e do contraditório. Neste sentido, é necessária a sua intimação, seja ela por meio de seu procurador, se tiver, ou pessoalmente, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo (art. 889, I, do CPC/2015). O STJ decidiu, por exemplo, que o telefone não é meio idôneo para a intimação (AgRg nos EDcl no REsp 1427316/SC, 3.^a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014, DJe 02.09.2014).

Contudo, a intimação por edital do executado para o leilão será considerada válida quando o mesmo for revel e não tiver patrono constituído nos autos do processo ou quando o executado não for encontrado no endereço que figura nos autos (art. 889, parágrafo único, CPC/2015).

3. Intimação de outros sujeitos interessados. O art. 889, II a VII, torna-se necessário para tutelar o respectivo direito no bem penhorado e é passível de nulidade quando não observada (art. 804, CPC/2015). No caso específico de bem tombado (art. 889, VIII, CPC/2015), o Enunciado 447 do FPPC destaca que “o exequente deve providenciar a intimação da União, Estados e Municípios no caso de penhora de bem tombado”.

Art. 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção:

I – dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade;

II – dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados;

III – do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade;

IV – dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta;

V – dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados;

VI – dos advogados de qualquer das partes.

1. Legitimidade para oferta de lances. A regra geral é a de que poderá oferecer lance todo aquele sujeito de direito que estiver livremente administrando seus bens (art. 890, *caput*, CPC/2015). Contudo, alguns sujeitos de direito, em razão da qualidade jurídica que ostentam, poderão obter algum tipo de vantagem com o leilão, razão pela qual o Código restringiu, vedando, a oferta de lances aos: a) tutores, curadores, testamentários, administradores ou liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade (art. 890, I, CPC/2015); b) mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados (art. 890, II, CPC/2015); c) juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão, chefe de secretaria e demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade (art. 890, III, CPC/2015); d) servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta (art. 890, IV, CPC/2015); e) leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados (art. 890, V, CPC/2015) e f) advogados das partes (art. 890, VI, CPC/2015). Sobre o tema, há decisão do STJ no sentido de que “o impedimento de arrematar diz respeito apenas ao serventuário da Justiça que esteja diretamente vinculado ao juízo que realizar o praxeamento, e que, por tal condição, possa tirar proveito indevido da hasta pública que esteja sob sua autoridade ou fiscalização” (REsp 774161/SC, 2.^a Turma, rel. Min. Castro Meira, DJ 19.12.2005). Finalmente, “na hipótese de expropriação de bem por arrematante arrolado no art. 890, é possível o desfazimento da arrematação” (Enunciado 542 do FPPC).

Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

1. Preço vil. O preço vil deixou de ser um conceito jurídico indeterminado e passou a contar com critérios legais de caráter objetivo para aferi-lo.

Nos termos do Código de Processo Civil, são duas as hipóteses em que o preço será considerado vil: a) quando o preço for inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital; e b) não tendo sido fixado preço mínimo, quando o preço for inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, CPC/2015).

O legislador abraçou a jurisprudência dominante do STJ, que à luz do Código de Processo Civil de 1973 decidiram que “se caracteriza preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação” (AgRg no REsp 1308619/RS, 2.^a Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 15.05.2012, DJe 21.05.2012). Em igual sentido, “interpretando o art. 692 do CPC [1973], a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera inserida no conceito de preço vil a alienação realizada com lance inferior a 50% do valor de avaliação do bem. Entretanto, o referido parâmetro jurisprudencial não impõe uma regra absoluta. (EDcl no AgRg no REsp 1428764/SP, 2.^a Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 27.10.2015, DJe 12.11.2015). Ademais, o STJ decidiu que é nulo a hasta pública – *rectius*: agora, o leilão judicial – que aliena bem a preço vil (AgRg no REsp 1211413/PR, 2.^a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2010, DJe 04.02.2011).

Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser

realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.

§ 1º Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exhibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

§ 2º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem.

§ 3º No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os Municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta.

1. Arrematação. Arrematar é adquirir em leilão público. Quando se fala em arrematar um determinado bem significa especificamente adquiri-lo em leilão público.¹⁷²

Na doutrina, amparado em Pontes de Miranda, consta belíssima descrição da arrematação: “Arrematar é pôr fim à hasta pública, ‘pôr o remate, o termo, o ponto final’. Havia o costume de o pregoeiro/leiloeiro dizer: ‘Há quem mais dê? Se não, arremato’. ‘Quer dizer, considerava findo, entregava o ramo, que em alguns países o porteiro tinha à mão’: nesse momento, o Estado aceita a oferta do licitante e consuma o negócio jurídico de transferência do domínio sobre a coisa. A arrematação, embora encerre a hasta pública, não é o último ato no procedimento de alienação judicial do bem: ainda há o *auto de arrematação*, que a torna ‘perfeita, acabada e irretratável’ (art. 694, CPC), e a *carta de arrematação*. A *arrematação* é, portanto, o negócio jurídico de direito público, pelo qual o Estado, no exercício de sua soberania, transfere, ao licitante vencedor, o domínio da coisa penhorada, mediante o pagamento do preço.”¹⁷³

2. Pagamento do lance vencedor. Quem arrematar o bem deverá imediatamente promover o pagamento do preço por meio de depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, *caput*, CPC/2015). Caso o lance vencedor do leilão seja o exequente – o qual está permitido de participar do leilão em igualdade de condições –, não há necessidade de exibição de preço. Porém, se o valor do bem arrematado ultrapassar o valor do crédito, deverá o exequente depósito a diferença no prazo de 03 (três) dias, sob pena de ineficácia da arrematação (art. 892, § 1.º, CPC/2015). Foi acolhido entendimento já sedimentado pelo STJ neste sentido (AgRg no REsp 1353705/MS, 3.ª Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.09.2014, DJe 01.10.2014).

3. Licitação e preferência. O Código define duas hipóteses taxativas de preferência legal à arrematação do bem penhorado. Na primeira hipótese, caso haja mais de um pretende à arrematação do bem, o Código determina a realização de uma licitação para que o bem seja definitivamente arrematado por aquele que ofertar o maior lance. Persistindo a igualdade de ofertas, a preferência será, nesta ordem, do cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado (art. 892, § 2.º, CPC/2015). A segunda hipótese versa sobre arrematação de bem tombado, oportunidade na qual a preferência será, nesta ordem, da União, Estados e Municípios (art. 892, § 3.º, CPC/2015). Assim, ao invés de adjudicar de imediato aqueles que tem preferência legal poderão aguardar o leilão público e só então exercer, talvez por preço menor que a avaliação, o seu direito de preferência em igualdade de condições com a melhor oferta.

Art. 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles.

1. Pluralidade de bens. Quando houver diversos bens objeto do leilão e mais de um lançador, a preferência será daquele cuja proposta é de arrematar todos os bens em conjunto. Porém, a preferência em questão é condicionada a dois pontos: a) deverá o lançador oferecer preço igual ao da avaliação para os bens que não tiverem lance; b) deverá o lançador oferecer para os demais bens preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido

oferecido para eles. O objetivo deste dispositivo é dar maior efetividade e celeridade ao referido procedimento expropriatório.¹⁷⁴

Art. 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução.

§ 1º Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade.

§ 2º A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado.

1. Alienação parcial de bem imóvel. Com o objetivo de dar maior efetividade ao procedimento expropriatório, o Código autoriza que o bem imóvel seja dividido, para fins de alienação, se possível, quando satisfizer o crédito e despesas da execução (art. 894, *caput*, CPC/2015). Para que isso ocorra, há necessidade de requerimento das partes (exequente e/ou executado) a tempo de permitir avaliação das frações do imóvel, fazendo constar do edital, cabendo ao executado instruir o requerimento com a planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado (art. 894, § 2.º, CPC/2015). Porém, inexistindo interessado na fração do bem, o bem imóvel será alienado integralmente (art. 894, § 1.º, CPC/2015).

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I – até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II – até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1º A proposta conterà, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.

§ 3º (Vetado).

§ 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

§ 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.

§ 6.º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.

§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:

I – em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor;

II – em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.

§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.

1. Pagamento em prestações. Aquele interessado na aquisição do bem penhorado de forma parcelada poderá formular: a) proposta por um valor não inferior ao da avaliação até o início do 1.º leilão (art. 895, I, CPC/2015); ou, b) proposta por um valor que não seja considerado vil – menos de 50% do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, CPC/2015) – até o início do 2.º leilão (art. 895, II, CPC/2015).

Em ambos os casos, a proposta deverá oferecer ao menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e divisão do saldo remanescente em 30 (trinta) parcelas iguais e subsequentes, garantida por caução idônea no caso de bens móveis e por hipoteca do próprio bem no caso de bens imóveis (art. 895, § 1.º, CPC/2015). Ademais, a proposta indicará prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do valor (art. 895, § 2.º, CPC/2015).

2. Prevalência de ofertas de pagamento em prestações. Em que pese a possibilidade de se oferecer o pagamento parcelado, a proposta de pagamento do lance à vista sempre terá prioridade, a fim de dar maior efetividade e tempestividade à satisfação do crédito (art. 895, § 7.º, CPC/2015).

Nos casos em que houver mais uma proposta de pagamento parcelado, será do juiz a decisão por aquela mais vantajosa, havendo critérios objetivos para tanto: a) em primeiro lugar, será vencedora a proposta de maior valor (art. 895, § 7.º, I, CPC/2015); b) em segundo, se iguais as condições das propostas, será vencedora a proposta formulada em primeiro lugar (art. 895, § 7.º, II, CPC/2015).

3. Inadimplênciadas prestações. O inadimplemento de quaisquer prestações é motivo para: a) incidência de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação em aberto somada às prestações vincendas (art. 895, § 4.º, CPC/2015); b) autorizar o exequente a requerer a resolução da arrematação (art. 895, § 5.º, primeira parte, CPC/2015); c) autorizar o exequente a promover a execução do valor inadimplido mediante requerimento formulado nos mesmos autos em que ocorrida a arrematação (art. 895, § 5.º, segunda parte, CPC/2015).

4. Texto vetado. O art. 895 § 3.º foi vetado pela Presidente da República. O dispositivo legal possuía a seguinte redação: “As prestações, que poderão ser pagas por meio eletrônico, serão corrigidas mensalmente pelo índice oficial de atualização financeira, a ser informado, se for o caso, para a operadora do cartão de crédito”. Razões do veto: “O dispositivo institui correção monetária mensal por um índice oficial de preços, o que caracteriza indexação. Sua introdução potencializaria a memória inflacionária, culminando em uma indesejada inflação inercial”. A sombra da inflação não permite a indexação, com razão, pois iria onerar a economia, criando indesejável efeito inercial.

5. Aplicabilidade na Justiça do Trabalho. É possível que a aquisição parcelada seja aplicada também na Justiça do Trabalho, em consonância ao art. 15 do CPC/15, assim como aconselha também o Enunciado 330 do FPPC (“Na Justiça do trabalho, o juiz pode deferir a aquisição parcelada do bem penhorado em sede de execução, na forma do art. 895 e seus parágrafos”).

Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano.

§ 1º Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão.

§ 2º Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo.

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel

no prazo do adiamento.

§ 4º Findo o prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão.

1. Suspensão de leilão de imóvel de incapaz. O juiz suspenderá o leilão de imóvel que for de titularidade de pessoa incapaz quando não atingido pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) do valor da avaliação. Portanto, a alienação de imóvel de incapaz por menos de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação é considerada preço vil.¹⁷⁵

Nesta situação, será confiada a depositário idôneo a guarda e administração do bem e assinalado prazo de 01 (um) ano para realização de novo leilão (art. 896, *caput*, CPC/2015), período no qual está autorizada a locação do bem (art. 896, § 3.º, CPC/2015). O objetivo do dispositivo é a preservação do interesse do incapaz.¹⁷⁶ Nestes procedimentos sempre deverá ocorrer a intervenção do Ministério Público, sendo nula a realização de leilão sem a sua participação que resultar em prejuízo para o incapaz (art. 178, II, c/c art. 279, § 1.º e 2.º, CPC).

2. Pretendente. O juiz deve autorizar a arrematação do bem imóvel do incapaz a qualquer pessoa que se manifestar interessada na sua aquisição pelo preço da avaliação durante o período de adiamento, independente de estar locado ou não, desde que preste caução idônea (art. 896, § 1.º, CPC/2015). Caso o pretendente se mostre arrependido, ser-lhe-á aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor da avaliação, a ser revertido a favor do incapaz. Esta decisão, inclusive, é considerada título executivo para tal finalidade (art. 896, § 2.º, CPC/2015).

Art. 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.

1. Inadimplemento do arrematante ou fiador e proibição de arrematar. Inadimplentes o arrematante ou o seu fiador dentro do prazo estabelecido, o juiz imporá sanção aos remissos: a) o exequente receberá a caução; b) os bens penhorados retornarão a um novo leilão; e c) serão proibidos de participar o exequente e o fiador remissos.

2. Caução. A referência à caução no dispositivo, a princípio, parece ser um erro de revisão do texto durante o procedimento legislativo, na medida em que equivale ao texto do Código de Processo Civil de 1973, nada obstante o antigo art. 690 do CPC/1973 não ter sido reproduzido (“A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante caução” – art. 690 do CPC/1973), a caução pode ser uma condição imposta pelo juiz quando fixadas “as condições de pagamento”.

Isto porque, antes do leilão, o candidato que pretende arrematar ou o próprio exequente poderá apresentar ao órgão jurisdicional um plano de compra do bem penhorado, o qual será submetido ao juiz, que poderá exigir uma caução para garantir as prestações constantes do plano de pagamento, neste caso a norma se afigura muito útil.

Outra hipótese dogmática de leitura útil seria a perda do pagamento antecipado na execução parcelada de que trata o art. 895 do CPC/2015. Neste caso, o adquirente e seu fiador remissos perderiam os vinte e cinco por cento adiantados sobre o valor do lance à vista (art. 895, § 1.º, CPC/2015).¹⁷⁷

Art. 898. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida.

1. Fiador. O fiador do arrematante fica sub-rogado na arrematação do bem caso pague o valor do lance e da multa. Contudo, o pedido de transferência da arrematação deve ser expresso, pois não necessariamente o pagamento do valor significa que o fiador pretende adquirir o bem.¹⁷⁸ Releva-se ainda que “o termo ‘multa’ constante no art. 898 refere-se à perda da caução prevista no art. 897” (Enunciado 589 do FPPC).

Art. 899. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for

suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução.

1. Suspensão da arrematação e satisfação do crédito. Caso a alienação dos bens penhorados seja suficiente para saldar o crédito do exequente, incluídas as despesas da execução, a arrematação será suspensa. Trata-se de disposição que visa não onerar mais o patrimônio do executado, ainda que outros bens de sua titularidade tenham sido penhorados.

Art. 900. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense.

1. Prosseguimento do leilão. O Código estabeleceu que o leilão que ultrapassar o horário do expediente forense será interrompido e retomado o seu prosseguimento no dia útil subsequente, independente de novo edital. A determinação do dispositivo (art. 900, CPC/2015) é dirigida somente aos leilões realizados no edifício do Fórum, de modo que os leilões designados em locais diversos poderão ser realizados das 6h às 20h (art. 212, CPC/2015).¹⁷⁹

Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§ 1º A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.

§ 2º A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame.

1. Auto de arrematação. A arrematação do bem penhorado será lavrado em auto que conterá a descrição das condições de alienação do bem, requisito necessário à perfectibilização do ato (art. 903, CPC/2015). É autorizado constar no auto de arrematação bens penhorados em mais de uma execução (art. 901, *caput*, CPC/2015). O STJ fixou entendimento de que a arrematação é um ato complexo “que se vê perfeita e acabada depois de assinado o auto pelo juiz” (REsp 437.573/SP, 5.^a Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j. 15.04.2004, DJ 24.05.2004, p. 324).

2. Ordem de entrega e carta de arrematação. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, são procedimentos que deverão ser precedidos pelo depósito do preço, oferecimento de garantias e pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1.º, CPC/2015). Frise-se que a aquisição do bem deverá aguardar o transcurso do prazo de 10 (dez) dias para impugnar a arrematação (art. 903, § 3.º, CPC/2015). A expedição da ordem de entrega ou da carta de arrematação, contudo, não está condicionada a qualquer espécie de requerimento do arrematante, seja no bojo da própria execução ou por meio de ação autônoma de imissão na posse. (STJ, EDcl no REsp 469.678/RS, 1.^a Turma, rel. Min. José Delgado, j. 18.03.2003, DJ 14.04.2003, p. 193).

3. Conteúdo da carta de arrematação. No auto de arrematação deverá constar a descrição completa do imóvel, o que inclui o número da matrícula e de seus registros cartorários, a cópia do auto de arrematação e, ainda, a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (art. 901, § 2.º, CPC/2015). São todos estes requisitos necessários à individualização do bem para fins de registro.

Art. 902. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido.

Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no *caput* defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.

1. Leilão e remição de bem hipotecado. O bem objeto de hipoteca que foi levado a leilão poderá ser remido pelo executado até o ato de assinatura do auto de arrematação, desde que seja ofertado preço equivalente ao maior lance oferecido (art. 902, *caput*, CPC/2015). Destaque, contudo, que é o caso de resgate, pagamento (remição) e não de renúncia, perdão (remissão).¹⁸⁰ Porém, se o executado for falido ou insolvente, o direito de remição é deferido à massa ou aos credores em concurso, oportunidade na qual está vedada a recusa pelo exequente do preço de avaliação do imóvel (art. 902, parágrafo único, CPC/2015).

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2º O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1º, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3º Passado o prazo previsto no § 2º sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4º Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

§ 5º O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:

I – se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital;

II – se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º;

III – uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação.

§ 6º Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do bem.

1. Concretização da arrematação. A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, seja nos casos de leilão presencial ou eletrônico (art. 903, *caput*, 1.ª parte, CPC/2015). Ademais, a arrematação permanece válida e eficaz ainda que procedente o julgamento dos embargos do executado ou a ação autônoma que busquem anulá-la (art. 903, *caput*, 2.ª parte, CPC/2015), o que se impõe em atenção à tutela do interesse jurídico de terceiro adquirente de boa-fé (STJ, AgRg no REsp 1328153/SP, 4.ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJe* 02.12.2014; AgRg no REsp 1454444/SE, 2.ª

Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 26.05.2015, *DJe* 02.06.2015), sem prejuízo da responsabilidade de reparação por prejuízos eventualmente experimentados (art. 903, *caput*, 3.^a parte, CPC/2015).

2. Vícios da arrematação. A arrematação poderá ser: a) *invalidada*, caso tenha sido realizada por preço vil ou inquinada de outros vícios, como, por exemplo, a ausência de intimação prévia em relação à penhora (art. 903, § 1.º, I, CPC/2015); b) *ineficaz*, quando não observadas as regras de intimação do art. 804 do CPC/2015 (art. 903, § 1.º, II, CPC/2015); c) *resolvida*, quando não quitado o preço ou prestada a caução (art. 903, § 1.º, III, CPC/2015). A decisão do juiz sobre as hipóteses de desconstituição da arrematação (art. 903, § 1.º, CPC/2015) será proferida no caso de provocação neste sentido em prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir do aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2.º, CPC/2015). Ambos são exemplos de oposição extraordinária.¹⁸¹ Porém, se não houver provocação do interessado, expedir-se-á a respectiva carta de arrematação com ordem de entrega ou mandado de imissão na posse (art. 903, § 3.º, CPC/2015). Em relação ao Código de Processo Civil de 1973, acabou-se com os embargos à arrematação, de modo que eventual desconstituição da arrematação poderá ser provocada por meio de *simples petição*, caso suscitada antes da assinatura do auto.¹⁸² Porém, se ultrapassado o prazo para impugnação da arrematação, a sua validade poderá ser discutida em *ação autônoma* na qual o arrematante figurará no polo passivo como litisconsorte necessário (art. 903, § 4.º, CPC/2015).

3. Desistência da arrematação. Há possibilidade de desistência da arrematação em três hipóteses taxativas: a) quando o arrematante provar a existência de ônus real ou gravame omitidos no edital, em 10 (dez) dias (art. 903, § 5.º, I, CPC/2015); b) quando o executado alegar a ocorrência de alguma das situações de desconstituição da arrematação previstas no art. 903, § 1.º, CPC/2015 (art. 903, § 5.º, II, CPC/2015); c) quando o arrematante, citado na ação autônoma (art. 903, § 4.º, CPC/2015), requerer a desistência da arrematação no prazo de defesa cabível (art. 903, § 5.º, III, CPC/2015).

Em todas as situações o dinheiro será imediatamente devolvido ao arrematante (art. 903, § 5.º, *caput*, CPC/2015). A comissão do leiloeiro também será devolvida, devidamente corrigida (STJ, RMS 33.004/SC, 2.^a Turma, rel. Min. Castro Meira, j. 27.11.2012, *DJe* 06.12.2012). O Código estabelece uma penalidade àquele que suscitar vício sem justificativa no intuito de provocar a desistência do arrematante, ato considerando atentatório à dignidade de justiça e passível de condenação ao pagamento de multa fixada pelo juiz e revertida em favor do exequente, no valor não superior a 20% (vinte por cento) da quantia atualizada do bem, sem prejuízo, ainda, de responsabilidade por perdas e danos (art. 903, § 6.º, CPC/2015).

4. Ação autônoma de impugnação da arrematação e além. O Código de Processo Civil é expresso em reconhecer a ação autônoma de arrematação. Art. 903, § 4.º, afirma que: “[a]pós a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”. Assim, na ação autônoma proposta, figurará como litisconsorte necessário o arrematante, face ao relevante prejuízo que poderá sofrer com a invalidação é obrigatória a sua presença no módulo processual em contraditório.

A ação autônoma aqui prevista acaba revelando outra peculiaridade do processo de execução, como se trata de processo resultante de cognição sumária poder-se-á discutir a qualquer questão em ação autônoma que não chegou a ser apreciada ou suscitada, não somente os vícios da arrematação como está expresso.

Essa premissa, além de encontrar franco amparo teórico da alta dogmática e também histórico da experiência formativa dos títulos executivos extrajudiciais, também é reforçada pelo art. 966, § 4.º, segundo o qual “Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. Ora, ao expressamente admitir-se a ação anulatória para os atos homologatórios praticados no curso da execução, está o legislador reconhecendo a possibilidade ampla de impugnação por ação autônoma, mesmo que perdido o prazo dos embargos do executado.

Na doutrina: “o art. 903, § 4.º, do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento de ação autônoma por parte do executado, a qual poderia ser fundada não apenas nos vícios da arrematação ou adjudicação (como consta expressamente do dispositivo), mas igualmente quanto a qualquer questão decidida com base em cognição sumária e no tocante a qualquer questão que não chegou a ser suscitada e apreciada, pois também encontraria abrigo no art. 966, § 4.º. Não deve causar estranheza o fato de a estabilidade das questões na execução ser menos intensa. Ao adotar, em sede executiva, a prevalência da cognição sumária com inversão de contraditório, o ordenamento prestigiou a tempestividade em detrimento da efetividade (...)”.¹⁸³

O entendimento aqui afirmado é a tendência jurisprudencial dominante no STJ (STJ, REsp 100.706/RO, 4.ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 29.10.1998; STJ, REsp 130.911/SP, 2.ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.12.2004; STJ, REsp 1006875/RS, 2.ª Turma, rel. Min. Castro Meira, j. 19.06.2008; STJ, AgRg no CC 116.338/SE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 1.ª Seção, j. 08.02.2012; STJ, REsp 1219329/RJ, 3.ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.03.2014).

Para a doutrina, com razão, o STJ “baseia-se na compreensão de que a perda do prazo para opor embargos à arrematação ou embargos à adjudicação (art. 746 do CPC/1973) não impede que o executado se valha da ação anulatória autônoma para alegar a mesma matéria. A supressão desses ‘embargos de segunda fase’ no Código de Processo Civil de 2015 e as diferenças de redação do art. 966, § 4.º, em relação ao dispositivo equivalente no diploma anterior não bastam para afastar esse entendimento”.¹⁸⁴

*Seção V - Da satisfação do crédito*¹⁸⁵

Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á:

I – pela entrega do dinheiro;

II – pela adjudicação dos bens penhorados.

1. Satisfação do crédito. A satisfação do crédito é o ato para o qual é voltado todo o procedimento executivo, seja ele oriundo de título executivo extrajudicial ou judicial, considerada a tutela do direito de crédito (direito à propriedade) e a tutela processual pela atividade executiva normas fundamentais do processo civil brasileiro (art. 4.º, CPC/2015). O Código estabelece que a tutela executiva em relação ao crédito é satisfeita quando houver a adjudicação do bem penhorado ou entrega do dinheiro produto de alienação por iniciativa particular ou alienação por leilão público (art. 904, I e II, CPC/2015). Vale ressaltar, ainda, a hipótese de pagamentos diretos decorrentes da penhora de parcela do faturamento, frutos e rendimentos e outros créditos. Em relação ao Código de Processo Civil de 1973, o usufruto foi eliminado como hipótese de satisfação do crédito, tendo em vista que era a apropriação do dinheiro dele derivado que satisfazia o credor e não o usufruto em si, extremando-se os institutos do direito material dos meios executivos.¹⁸⁶

Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando:

I – a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados;

II – não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora.

Parágrafo único. Durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos.

1. Levantamento do dinheiro. O exequente poderá levantar o dinheiro depositado a título de penhora, produto da alienação dos bens penhorados ou do faturamento, frutos e outros rendimentos da empresa quando a execução for movida somente em seu benefício (art. 905, I,

CPC/2015) e os bens alienados não estiverem gravados com privilégios e preferências a outros credores anteriores à penhora (art. 905, II, CPC/2015).

2. Honorários advocatícios. O levantamento do dinheiro compreende não só o montante exequendo, devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária, como também a quantia depositada a título de honorários advocatícios.

3. Plantão judiciário. O Código veda o levantamento de dinheiro e valores e/ou liberação de bens apreendidos em plantão judiciário, tendo em vista a ausência de urgência.¹⁸⁷ Há, contudo, quem pregue que o dispositivo é inconstitucional porque a lei não pode proibir concessão de tutela de urgência (aparência do direito e risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação), violando, assim, a garantia do acesso à Justiça (art. 5.º, XXXV, CF/1988).¹⁸⁸

Note-se que a questão é mais simplória. Não se trata de vedação da tutela de urgência, mas de seu condicionamento. Logo, em princípio a regra é constitucional, contudo, havendo urgência no caso concreto que justifique o deferimento da medida esta poderá ser concedida. Há, neste caso, um duplo juízo de proporcionalidade: em abstrato a norma é constitucional; em concreto poderá não sê-lo.

Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga.

Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.

1. Quitação e levantamento do dinheiro. A quitação do valor exequendo será dada pelo exequente por meio de termo nos autos após recebimento do mandado de levantamento do dinheiro, o qual poderá ser substituído por transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao órgão jurisdicional ou em outra conta de preferência do exequente (art. 906, parágrafo único, CPC/2015). Uma vez satisfeito integralmente o crédito, a execução será extinta (art. 924, II, c/c 925, CPC/2015). Caso o levantamento do dinheiro não seja suficiente para quitar o crédito exequendo, o exequente deverá requerer o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente (art. 876, § 4.º, II, CPC).

Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado.

1. Satisfação do crédito e menor onerosidade possível para o executado. Será devolvida ao executado a quantia excedente ao valor exequendo em sua integralidade, assim considerado o montante do crédito principal, acrescidos de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. Trata-se de medida que visa não onerar abusivamente o patrimônio do executado (art. 805, CPC/2015), equilibrando a atividade executiva. A tutela do crédito deve se dar nos limites do crédito existente e da necessidade de atender aos interesses legítimos do exequente.

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

1. Concurso de credores ou exequentes. Pode ocorrer de um mesmo bem ser objeto de diversas penhoras, oportunidade na qual o dinheiro será distribuído de acordo com a respectiva regra de preferência para recebimento do crédito (art. 908, *caput*, CPC/2015). Na execução, há um concurso singular de credores – em que todos os credores perseguem um bem específico do

patrimônio do devedor – e não um concurso universal tal qual ocorre na falência (Lei 11.101/2005) – em que a concorrência recai sobre todo o patrimônio do devedor. A execução universal de pessoa física, insolvência civil, continua regulada pelo Código de Processo Civil de 1973 e será tratada por lei específica (arts. 797 e 1.052, CPC).¹⁸⁹

2. Ordem de preferência. O primeiro passo é identificar se há entre os credores algum crédito privilegiado na ordem de penhora, ou seja, se o direito material é dotado de preferência em relação aos demais créditos.

São dotados de privilégio: a) créditos trabalhistas, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e créditos oriundos de acidente de trabalho (art. 83, I, Lei 11.101/2005); b) crédito real até o limite do bem gravado (art. 83, II, Lei 11.101/2005, garantia real); c) créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias¹⁹⁰ (art. 83, III, Lei 11.101/2005; art. 187, *caput*, CTN). O concurso de credores somente se verificada entre pessoas jurídicas de direito público, devendo ser observada a seguinte ordem: primeiramente, a União Federal; a seguir, os Estados e o Distrito Federal, conjuntamente e *pro rata*; em terceiro lugar, os Municípios, conjuntamente (art. 83, III, Lei 11.101/2005; art. 187, parágrafo único, CTN);¹⁹¹ d) créditos com privilégio especial (art. 83, IV, Lei 11.101/2005: (d.1) os créditos previstos no art. 964 do CC; (d.2) créditos definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição em sentido contrário da Lei Falimentar; (d.3) créditos que a lei confere direito de retenção sobre a coisa dada em garantia; e) créditos com privilégio geral (art. 83, V, Lei 11.101/2005): (e.1) créditos mencionados no art. 965 do CC; (e.2) créditos referidos no art. 67, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, a saber, as obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial; (e.3) créditos previstos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição em sentido contrário da Lei Falimentar; f) créditos quirografários (art. 83, VI, Lei 11.101/2005): (f.1) por exclusão, créditos não previstos nos demais incisos do referido dispositivo; (f.2) saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; (f.3) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inc. I do *caput* do referido dispositivo; g) créditos de multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias (art. 83, VII, Lei 11.101/2005); h) créditos subordinados (art. 83, VIII, Lei 11.101/2005): (h.1) créditos assim previstos em lei ou em contrato; (h.2) créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. A preferência pode ser estabelecida por convenção processual (art. 190, CPC).

3. Sub-rogação do crédito. Os créditos que eventualmente recaiam sobre o bem, inclusive de natureza *propter rem* (obrigações próprias da coisa: dívidas tributárias como o IPTU, por exemplo, além de dívidas condominiais), sub-rogam-se sobre o seu preço independentemente do modo pelo qual o bem foi expropriado – alienação ou adjudicação, observada a ordem de preferência (art. 908, § 1.º, CPC/2015).

4. *Prior tempore potior in iure*: anterioridade da penhora. Ausentes os credores com créditos privilegiados ou devidamente satisfeitos os credores com créditos privilegiados, o dinheiro será distribuído de acordo com a anterioridade da penhora (art. 908, § 2.º, CPC/2015). Trata-se do segundo momento na aferição de preferência em relação ao concurso de credores. Assim, conforme a ordem prevista no dispositivo, em primeiro lugar, verifica-se quem tem crédito privilegiado no tocante à natureza do direito material; em segundo lugar, afere-se no plano processual quem primeiro gravou o bem com a penhora. Trata-se de “preferência de direito material à de direito processual consagrada na máxima *prior tempore potior in iure*” (STJ, REsp 871.190/SP, 1.ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 07.10.2008, DJe 03.11.2008).

Nesta segunda hipótese, o credor que primeiro registrar a penhora sobre o bem terá um direito de preferência na adjudicação ou no recebimento do produto via alienação dele decorrente.

No entanto, o tema era até o presente vacilante na jurisprudência do STJ, que já decidiu em “havendo pluralidade de penhora sobre o mesmo bem, devem ser analisadas duas situações: em primeiro lugar, a existência de crédito privilegiado, em decorrência de previsão legal; afastada essa hipótese, em segundo lugar, a anterioridade da penhora. Na hipótese da existência de privilégio em virtude da natureza do crédito, deve o credor privilegiado, a fim de exercer a

preferência legalmente prevista, demonstrar que promoveu a execução, e que penhorou o mesmo bem objeto de outra constrição judicial” (REsp 660.655/MG, rel. Min. Denise Arruda, 1.ª Turma, j. 17.04.2007, DJ 24.05.2007, p. 312). Em outra situação, o STJ decidiu que “o crédito trabalhista prefere a todos os demais, inclusive aos que estão garantidos com penhora antecedente (precedentes do STJ). No concurso de credores estabelecem-se duas ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os com garantia real, nesta ordem; em um segundo momento, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente ao concurso, observando-se entre eles a ordem cronológica da constrição. Na dicção do art. 711 do Código de Processo Civil, a Fazenda, independentemente de penhora, prefere aos demais credores com penhora antecedente” (REsp 594.491/RS, 2.ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 02.06.2005, DJ 08.08.2005, p. 258).

Ainda, “na hipótese da existência de privilégio em virtude da natureza do crédito, deve o credor privilegiado, a fim de exercer a preferência legalmente prevista, demonstrar que promoveu a execução, e que penhorou o mesmo bem objeto de outra constrição judicial, conforme prevê o art. 711 do CPC” (REsp 655.233PR, 1.ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, DJ 17.09.2007, p. 210).

Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá.

1. Incidente de concurso singular de credores e cognição do juiz. É possível a instauração de incidente de concurso singular de credores cuja cognição é restrita à aferição da ordem de preferência e anterioridade da penhora.

Neste incidente, os credores postularão suas pretensões e o juiz proferirá decisão interlocutória. A execução/cumprimento de sentença ficará suspensa até quando a decisão for prolatada.¹⁹²

Em relação ao Código de Processo Civil de 1973, há uma mudança no que tange ao procedimento deste incidente, pois o art. 712 previa a possibilidade de requerer provas para produção em audiência, o que foi acertadamente suprimido no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a matéria não desafia produção probatória na medida em que passível de comprovação por via de prova documental ou documentada.¹⁹³

NOTAS DE RODAPÉ

2

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 779-780; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 824 a 826 do CPC)*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 724-727; Rodrigo Barioni, Arts. 824 a 830 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1174-1176; Elton Venturi, Arts. 824 a 826 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.), 2. ed., *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 1990-1996; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil Anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 638; Antônio Mota, Arts. 824 a 826 do CPC. In: Lênio Luiz Steck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1080-1084; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros*

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1171-1173; Enrico Tullio Liebman, *Processo de Execução*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 117-122; Alcides de Mendonça Lima, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. VI, Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 587-631; Marcelo Lima Guerra, *Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil*, São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 147-177; Humberto Theodoro Jr., *Processo de execução e cumprimento de sentença*, 25. ed., São Paulo: Leud, 2008, p. 233-241; Cândido Rangel Dinamarco, *Execução civil*, 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 314-343; Miguel Teixeira de Sousa, *A reforma da acção executiva*, Lisboa: Lex, 2004, p. 105-122; Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual de Execução Civil*, 5. ed., Rio de Janeiro, 2015, p. 273-279; Araken de Assis, *Manual de Execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 881-890; Andrea Proto Pisani, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, Napoli: Joveni, 2002, p. 717-729.

3

Para estas ideias, de forma muito próxima, cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 779; Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero, *Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo*, São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 653.

4

Como corretamente observou Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de Direito Processual Civil*, p. 550.

5

Felipe Balzano, *A penhora on-line e o prazo dos embargos de terceiro*, São Paulo: Ed. RT, 2016, n. 252, p. 167-205.

6

Marcelo Abelha Rodrigues, *O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 2 – Continuação)*, São Paulo: Ed. RT, 2015, n. 245, p. 151-222.

7

Michele Taruffo. A atuação executiva: perfis comparados. In: Michele Taruffo. *Processo Civil Comparado: Ensaios*, São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 85-117.

8

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 779-780.

9

Como já defendido na doutrina, *a função social da empresa é um desdobramento da função social da propriedade* (Eros Roberto Grau, *A ordem econômica na Constituição de 1988*, 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 267-268; Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de

Oliveira, *Curso de Direito Processual Civil. Execução*, vol. 5, 6. ed., Salvador: Juspodivm, 2014, p. 282). Em razão disso, as exceções de direitos fundamentais do exequente podem ser fundadas em direitos fundamentais do executado e de terceiros afetados pela atividade do executado. A jurisprudência do STJ já reconheceu a função social da empresa considerando impenhorável parcela do faturamento de pessoa jurídica empresária como forma de garantir seu funcionamento (STJ, 1ª Turma, REsp 803.435/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 18.12.2006, já citado por Idem, p. 553.

10

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 779-780; Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero, *Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo*, cit., p. 653.

11

Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira, *Curso de Direito Processual Civil. Execução*, vol. 5, 7. ed., Salvador: Juspodivm, 2016, *no prelo*, texto gentilmente cedido pelos autores.

12

Paulo Henrique dos Santos Lucon, Comentários aos arts. 870 a 909. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.), *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, cit.

13

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 818-820.

14

“*Usufruto judicial*. O art. 647, IV, do CPC/1973 cometia uma dupla impropriedade sistemática e conceitual no trato da expropriação executiva de bens, ao dispor que “a expropriação consiste (...) no usufruto de bem móvel ou imóvel”. A primeira dessas imperfeições, de caráter sistemático, consistia em valer-se, na disciplina de um ato processual, de uma categoria de direito privado, que é o usufruto. A imposição de uma constrição sobre bens no processo de execução é um ato estatal imperativo, que nada tem a ver com o usufruto. A segunda imperfeição, de cunho conceitual, decorre do fato de que a fruição de rendimentos de um bem é, lá no direito privado que a regula, conceituada como anticrese e não como usufruto (CC, art. 1.506 – “pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos”). A doutrina vinha fazendo esses reparos àquele equivocado dispositivo e o novo Código de Processo Civil, atento a isso, afastou-se dessa linguagem inadequada para falar agora em “apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens” (art. 825, III).” Candido Rangel Dinamarco. *O Novo Código de Processo Civil Brasileiro e a Ordem Processual Civil Vigente*. São Paulo: Revista de Processo, 2015, p. 63-103, n. 247. Próximos, cf. Marcelo Abelha Rodrigues. *O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 2 – Continuação)*. São Paulo: Revista de Processo, 2015, p. 151-222, n. 245; Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula

15

Já citados por Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 780.

16

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 780.

17

Para a doutrina a remição da execução não se confunde com a remição dos bens. Remição de bens, como resgate dos bens por membros da família do executado está prevista hoje no art. 875, § 5.º, CPC. Marcelo Abelha Rodrigues. *Manual da Execução Civil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 190.

18

Assim, “art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1.º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do *caput*, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Segundo a doutrina, “A rigor, quando esta hipótese de remição é comparada com a anterior tratar-se de um cumprimento de sentença, portanto, lastreada em um título judicial, a remição da execução pelo executado nesse caso é infinitamente melhor do que a que se encontra presente no art. 827, § 1.º, dos títulos extrajudiciais (...) além de 15 dias, e não três (...) o executado que paga nesse quinquídio se livra integralmente dos honorários advocatícios (...)” Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual da Execução Civil*, p. 192.

19

Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual da Execução Civil*, p. 194; Idem, O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 2 – Continuação), *Revista de Processo*, São Paulo, 2015, n. 245, p. 151-222.

20

J. J. Calmon de Passos. Da Responsabilidade por Custas e Honorários de Advogado na Execução de Títulos Extrajudiciais, *Revista de Processo*, São Paulo, 1976, n. 3, p. 22-31.

21

Nelson Nery Jr., *Código de Processo Civil Comentado*, op. cit., art. 826. A doutrina menciona ainda a exceção do art. 275 da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015/1973, que prevê para os casos de remição o recurso de apelação, na parte que trata da remição do imóvel hipotecado. Nos termos da Lei de Registros Públicos: “das sentenças que julgarem o pedido de remição caberá o recurso de apelação com ambos os

efeitos” (art. 275).

23

Sobre as sanções premiais ou positivas, decorrem da função promocional do direito, pela qual o ordenamento jurídico estimula determinados comportamentos que entende vantajosos do ponto de vista do interesse tutelado pela norma jurídica. Assim, “[q]uando lo stato intende incoraggiare certe attività economiche (ma non soltanto economiche) si vale sempre più spesso del procedimento del premio, cioè del procedimento della sanzione positiva. Orbene questo procedimento consiste proprio in un vantaggio offerto a chi osserva la norma, mentre l’inosservanza della stessa norma non ha alcuna conseguenza giuridica, al pari dell’osservanza delle norme rafforzate da una sanzione negativa. In sostanza, la differenza fra la tecnica dell’incentivazione e quella tradizionale della sanzione negativa sta proprio nel fatto che il comportamento avente conseguenze giuridiche non è l’inosservanza ma l’osservanza.” cf. Norberto Bobbio, *Dalla Struttura alla Funzione*, Roma/Bari: Laterza, 2007, p. 88-89; Idem, *Da Estrutura à Função. Novos Estudos de Teoria do Direito*. Trad. Daniela Beccaccia Versiani, Barueri: Manole, 2007.

24

Não se confundindo com o protesto cautelar de que trata o art. 301, que tem finalidade assecuratória e revela-se medida de urgência. O protesto na fase de cumprimento e execução é protesto com finalidade coercitiva, para fins de efetivação da obrigação ou dever de pagar quantia certa.

25

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 780-781.

26

Idem, ibidem.

27

Idem, ibidem.

28

Edilton Meireles, Medidas sub-rogatórias, coercitivas, mandamentais e indutivas no Código de Processo Civil de 2015, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, 2015, n. 247, p. 231-246.

29

Marcelo Abelha Rodrigues. *O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva*, cit., n. 245, p. 151-222.

31

A leitura do art. 792 é esclarecedora no tópico, pois no inc. II se percebe a importância da averbação de

que trata o presente artigo: “art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução (...) II – quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 (...) § 1.º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente”. Sobre a fraude à execução, na doutrina, cf. Gilberto Gomes Bruschi; Rita Dias Nolasco; Rodolfo da Costa Manso Real Amadeo, *Fraudes Patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015*, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 89-119.

32

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 781-783.

33

Idem, *ibidem*.

34

Idem, *ibidem*.

35

Assim, na doutrina “[n]inguém pode exercer uma ‘faculdade’, onerando serviço público, graciosamente, salvo nos casos de gratuidade legal. É conveniente que o custo do serviço de averbação deva incluir o do seu cancelamento, que será pago pelo requerente, que deflagra o processo que gera providência iniciais e posteriores, e seus custos” Nelson Nery Jr.; Rosa Maria Andrade Nery, *Código de Processo Civil Comentado*, op. cit., art. 828.

36

Com as alterações do CPC o valor da causa passou a ser disciplinado no art. 292 e, mesmo nas ações indenizatórias fundadas em dano moral, deverá ser expresso o valor pretendido (art. 292, V, CPC).

37

O *princípio da concentração*, por sua volta, de aplicação no RGI, implica em fazer constar na matrícula do imóvel todos os fatos e atos que possam resultar a alteração jurídica do bem ou da pessoa nele interessada, mesmo em caráter secundário, mas que possa ser oponível, sem que, para isso, seja necessário buscar alhures informações. Funda-se no fato de que o registro imobiliário deve ser completo, ágil, seguro e universal, em homenagem ao *fólio real*. Está previsto nos arts. 167, II, item 5, e 246, *caput*, da Lei 6.015/1973. A relação deste princípio com o princípio da publicidade é de suporte recíproco, na medida em que é através da concentração que a publicidade poderá atender à completude da divulgação através de um só documento. No caso específico dos imóveis desempenha papel importantíssimo a matrícula, devendo dela constar todas as informações sobre o imóvel, consistindo em verdadeiro “DNA” de sua origem e desenvolvimento e assim garantida através da concentração das informações a ele pertinentes a publicidade devida. A base dogmática da publicidade encontra previsão expressa no art. 16 até 21 e no art. 172 da Lei 6.015/1973 e também é prevista no art. 1.º da Lei 8.935/1994, consistindo na ficção de

conhecimento para a universalidade e na garantia de oponibilidade *erga omnes* dos direitos originados a partir da realização de um ato registral (matrícula, registro e/ou averbação) para os quais são organizados técnica e administrativamente os serviços notariais.

38

Defendendo entendimento diverso, na doutrina: “A ausência da comunicação ao juízo autoriza o demandado a requerer o seu cancelamento. Trata-se de prazo próprio, com o que a sua inobservância gera preclusão temporal. A ausência de comunicação ao juízo gera ineficácia da averbação. Averbação não comunicada não tem o condão de caracterizar alienações e onerações posteriores como fraudulentas. A ausência de comunicação da averbação ao juízo no prazo legal autoriza o demandado a requerer o imediato cancelamento da anotação da propositura da ação ou do requerimento de cumprimento de sentença condenatória no registro em que realizada.” Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 781-783. O que autoriza o cancelamento é a averbação indevida, por excessiva ou não correspondente à realidade. Os prejuízos decorrentes da averbação excessiva ou abusiva geram direito à indenização.

39

Idem, ibidem.

40

Idem, ibidem.

41

Marcelo Abelha Rodrigues, *O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva*, cit., p. 151-222.

42

Rodrigo Barioni, *O parcelamento de crédito exequente no novo CPC*, São Paulo: Ed. RT, 2015, n. 244, p. 153-164.

43

Nelson Nery Jr.; Rosa Maria Andrade Nery, *Código de Processo Civil Comentado*, op. cit., art. 829.

44

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 785-786.

45

Idem, ibidem.

46

Idem, p. 783-785.

47

Destaca, nesse sentido, Araken de Assis: “Preenchidos os pressupostos cabíveis, a realização da pré-penhora dispensa temperamentos, porque, baseada na ausência do executado, das duas uma: ou (a) o executado se oculta movido pelo propósito desesperado de resistir à expropriação, quiçá dissipando bens, ou, por qualquer motivo, (b) o executado não permanece no círculo de suas atividades habituais. A pré-penhora, nas duas hipóteses, não configura abuso e excesso, pois ninguém assegura, no caso de a ausência decorrer de motivo justificável, a custódia de parcela do patrimônio do devedor desaparecido não lhe atender, outrossim, interesse próprio na conservação dos bens abandonados. Decerto a medida satisfaz o interesse do exequente, enquanto o executado transeunte visita, v.g., as ilhas do Caribe” (Araken de Assis, *Manual de Execução Civil*, cit., versão online).

48

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 785-786.

49

Idem, ibidem.

50

Marcelo Abelha Rodrigues. *O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva*, cit., p. 151-222.

51

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 785-786.

52

Felipe Balzano, *A penhora on-line e o prazo dos embargos de terceiro*, São Paulo: Ed. RT, 2016, n. 252, p. 167-205.

53

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 785-786.

54

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; MITIDIERO, Daniel. *Novo Código de Processo Civil*

Comentado, cit., p. 786-791; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 831 a 836)*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 734-745; Rodrigo Mazzei; Sara Merçon-Vargas, Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1183-1199; Bruno Garcia Redondo, Comentários aos arts. 831 a 836 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.), *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, cit., p. 2009-2021; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil Anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 644-648; Alexandre Gois de Victor, Arts. 831 a 836 do CPC. In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, cit., p. 1094-1106; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, cit., p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por artigo*, cit., p. 1179-1198; Enrico Tullio Liebman, *Processo de Execução*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 123-141; Humberto Theodoro Jr., *Processo de Execução e Cumprimento de Sentença*, 25. ed., São Paulo: Leud, 2008, p. 243-301; Alberto Camiña Moreira, Patrimônio de Afetação e Penhora. In: Fredie Didier Jr. *Execução Civil*, cit., p. 7-28; Miguel Teixeira de Sousa, *A Reforma da Ação Executiva*, cit., p. 139-175; Marcelo Abelha, *Manual de Execução Civil*, cit., p. 317-350; Araken de Assis, *Manual de Execução*, cit., p. 908-920.

55

Marcelo Abelha, *Manual de Execução Civil*, cit., p. 318. Nesse sentido, também destaca Araken de Assis: “A penhora isola bens no patrimônio excutido, e, em consequência, afeta o bem penhorado à atividade da expropriação (art. 824) por meio do expediente de imprimir a marca da ineficácia no poder de disposição do executado, preservando, assim, o caráter instrumental do ato. Este sinal não é um “sogello”, mas o corolário da ineficácia dos atos de disposição, que, de resto, se afiguram existentes, válidos e eficazes no plano do direito material” (Araken de Assis, *Manual de Execução Civil*, cit.).

56

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas, Artigo 832 do CPC/2015, cit., p. 1185.

57

Idem, p. 1186.

58

Perceba-se aqui que se trata da mesma norma de direito fundamental que legitima algumas impenhorabilidades como a hipoteca – que exclui todos os demais bens da lista de bens penhoráveis (art. 835, § 3.º, CPC).

59

A origem do princípio é atribuída à *Lex Poetelia Papiria* (entre 326 e 331 a.c.), cf. Heitor Sica. *Cognição do Juiz na Execução Civil*, op. cit., p. 36. Sobre a responsabilidade patrimonial, o amplo estudo de Thiago Ferreira Siqueira. *A Responsabilidade Patrimonial no Novo Sistema Processual Civil*. São Paulo: Ed. RT,

2016. Thiago Siqueira critica a redução de todo modelo executivo ao princípio da patrimonialidade (como já fizemos na introdução a este volume), partindo das conhecidas ideias de Ovídio A. Baptista da Silva e da tendência contemporânea já apontada para a tutela específica e o reconhecimento das medidas coercitivas como meios de execução forçada, conclui: “Não se trata, é certo, de retirar a importância que certamente tem a responsabilidade patrimonial. É fundamental entender, todavia, que se trata de apenas *uma*, dentre várias formas de atuação executiva dos direitos” (idem, p. 139).

60

Estamos tratando da execução singular do devedor solvente, e não dos regimes especiais da execução universal (falência e insolvência) ou da tutela do consumidor superendividado. As distinções são relevantes, pois nestes casos muda o regime jurídico e os interesses do exequente sofrem abrandamento em função de interesses sociais e econômicos tutelados pela norma (cf. *supra*, premissas, 1.2).

61

Assim, por exemplo, podem ser consideradas hipóteses de impenhorabilidade absoluta as hipóteses do art. 833, mesmo que apresentem, no próprio texto de lei situações de restrição à impenhorabilidade como: a) a exceção do “elevado valor” ou “médio padrão de vida” (art. 833, II, III e § 3.º, naquilo que os vencimentos ou salários etc. superarem o valor de 50 salários mínimos), caso em que o excesso poderá ser penhorado; b) a exceção da “dívida relativa ao próprio bem” (art. 833, § 1.º e § 3.º); c) a exceção do “pagamento de pensão alimentícia”. Algumas dessas situações irão representar uma impenhorabilidade relativa em relação ao objeto ou a determinados sujeitos (ex. dívidas decorrentes de alimentos ou relativas ao próprio bem e dívidas da pequena propriedade rural que não seja qualificada pelo trabalho da própria família), outras poderão representar uma impenhorabilidade parcial.

62

Para a doutrina, a hipótese da impenhorabilidade relativa está indicada no art. 834 quanto aos frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, somente penhoráveis na hipótese de falta de outros bens. Mas como vimos anteriormente, como o conceito está relacionado ao objeto e às pessoas, outras hipóteses do art. 833 e incisos poderiam ser incluídas nessa categoria, quando das hipóteses de relativização.

63

“(…) não são todos os bens do executado que respondem pela execução. Há bens que não podem ser penhorados. A restrição à penhora de certos bens chama-se *impenhorabilidade* (…). Há casos de impenhorabilidade absoluta, quando o bem não puder ser penhorado em nenhuma hipótese, o que é raro (por exemplo: o seguro de vida, art. 649, VI, CPC) e de impenhorabilidade relativa, quando o bem puder ser penhorado na execução de certos créditos (…). A diferença entre essas regras está no âmbito de oponibilidade do direito à impenhorabilidade: a qualquer credor, no caso da impenhorabilidade absoluta, a alguns credores, no caso da relativa”, Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira. *Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 547.

64

As classificações sobre a impenhorabilidade são variadas na doutrina e partem de diversos critérios (cf.

Araken de Assis. *Manual da Execução*. 18. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 315-322). A escolha pela classificação mediante os dois pares conceituais entre absoluta e relativa (quanto aos sujeitos e ao objeto) disponível e indisponível, não elimina os demais critérios, mas procura simplificar a abordagem permitindo uma compreensão da teoria das impenhorabilidades a partir dos direitos fundamentais. O Código estabelece expressamente que os bens impenhoráveis e inalienáveis são insuscetíveis à execução e faz ressalvas quanto à impenhorabilidade na própria lei. Assim, por exemplo, a ressalva prevista quanto às dívidas relativas ao próprio bem, incluída aquela contraída para sua aquisição (art. 833, § 1.º, CPC) e aquela referente aos implementos e máquinas agrícolas pertencentes ao pequeno proprietário rural com posse qualificada pelo serviço de sua família que serão penhoráveis quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária (art. 833, § 3.º). Doutrina há que defenda um triplice regime jurídico para a impenhorabilidade: a) bens absolutamente impenhoráveis, art. 833, CPC, ressalvada a dívida contraída em razão do próprio bem; b) bens relativamente impenhoráveis, 834, CPC; c) impenhorabilidade do imóvel residencial (Lei 8.009/1990), que não se confundiria com o bem de família (arts. 1.711 e 1.715, CC), Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, cit., p. 345 e ss. Na doutrina portuguesa, a partir da classificação do próprio Código de Processo Civil português, Miguel Teixeira de Sousa sugere a tripartição entre: a) impenhorabilidade absoluta (art. 736); b) impenhorabilidade relativa (art. 737); c) impenhorabilidade parcial (art. 738), cf. Miguel Teixeira de Sousa. *A Reforma da Acção Executiva*, p. 140 e ss. (atentar para o fato de que o livro trata da reforma e que a numeração não corresponde aos artigos atuais, retrocitados).

65

Assim, “[p]enhora sobre bem impenhorável *disponível*. Intimado a defender-se, o executado não a questiona, deixando de exercer o seu direito de não ter aquele bem penhorado. Há, no caso, preclusão, pois a invalidade do ato deve ser requerida no primeiro momento em que couber à parte falar nos autos [art. 278]”, Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira. *Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 551.

66

Cf. Thiago Ferreira Siqueira. *A Responsabilidade Patrimonial no Novo Sistema Processual Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 163.

67

A impenhorabilidade deve ser tratada no âmbito da teoria das restrições a direitos fundamentais. A impenhorabilidade pode ser renunciada, desde que esta renúncia não atinja o núcleo essencial dos direitos fundamentais. “A impenhorabilidade é um direito do executado, que pode ser renunciado se o bem impenhorável for disponível.” Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira. *Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 550. Desta premissa decorre que não pode ser considerada norma de ordem pública, se “a impenhorabilidade é disponível, *não* pode ser considerada de *ordem pública* (...) é pensamento que contraria a lógica jurídica”. Idem, p. 550.

68

No original, “Lo que hasta ahora se ha descrito, el nivel de la regla y el de los principios, no proporciona

un cuadro completo del sistema jurídico. Ni los principios ni las reglas regulan por sí mismos su aplicación. Ellos representan sólo el costado passivo del sistema jurídico. Si se quiere obtener un modelo completo, hay que agregar al costado passivo un activo, referido al procedimiento de la aplicación de las reglas y principios. Por lo tanto, los niveles de las reglas y principios tienen que ser completados con un tercer nivel. Em un sistema orientado por el concepto de la razón práctica, este tercer nivel puede ser sólo el de un procedimiento que asegure la racionalidade. De esta manera, surge un modelo de sistema jurídico de tres niveles que puede ser llamado <<modelo reglas/principios/procedimiento>>”. ALEXY, Robert. *El concepto y la validez del derecho*. Barcelona: Gedisa, 1997, p. 173-174.

69

Nesse sentido: “em um modelo combinado de regras, princípios e procedimentos (Robert Alexy e Humberto Ávila), defendemos, que *as regras, em relação aos princípios, pela própria razão de serem as regras normas determinativas, valem prima facie como razões tudo-ou-nada* não podendo ser afastadas se incidirem e forem válidas do ponto de vista constitucional por efeito dos *princípios representativo e do devido processo legal legislativo (princípios formais de seu estabelecimento)*, assim, as normas constitucionais e leis exaradas como regras no âmbito de conformação do legislador democrático recebem um ônus favorável a sua aplicação do ponto de vista argumentativo”. Hermes Zaneti Jr., *O Valor Vinculante dos Precedentes*.

70

Conforme Letícia Campos Velho Martel: “Com o exercício do direito geral de liberdade (ou de outros direitos), há a possibilidade de dispor de posições jurídicas subjetivas dos demais direitos, ou mesmo do direito geral de liberdade. Quando vislumbrada a tese como um todo – desde a aceitação de um direito geral de liberdade, a divisão das normas constitucionais em regras e princípios, a colisão e a metodologia para solucioná-la, percebe-se que as posições jurídicas de direito fundamental serão *prima facie* disponíveis no plano normativo e não no conceitual.” Isso significa dizer que: “Evidentemente, algumas posições jurídicas subjetivas de direito fundamental poderão ser considerados indisponíveis. Mas, para isso, ter-se-á que arcar com o ônus argumentativo e demonstrar que se trata de restrição e não de violação do direito geral de liberdade. Ou seja, para que a disposição seja proibida ou regulada é necessário que seja cumprido o ônus argumentativo, a fim de caracterizar uma restrição e não uma violação de direitos fundamentais”. Letícia de Campos Velho Matel, *Direitos Fundamentais Indisponíveis: Os Limites e os Padrões do Consentimento para a Autolimitação do Direito Fundamental à Vida*. Tese de Doutorado. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Orientação: Luís Roberto Barroso. Defesa em 18 de março de 2010, p. 113.

71

Sobre a renúncia a direitos fundamentais: “O ato renunciatório se apresenta sob uma dupla dimensão: pode ser considerado como exercício do próprio direito fundamental renunciado combinado com a garantia de liberdade e livre desenvolvimento da personalidade, além de ser condizente como forma de auto-restrição, autolimitação ou como permissão de interferência do Estado no direito fundamental renunciado (...). A renúncia pode ocorrer sob duas modalidades distintas, ou seja, ser relativa apenas ao exercício do direito fundamental renunciado ou sobre o direito em si. A diferenciação assume relevância no momento em que são definidos os limites para cada uma das modalidades, havendo maior liberdade na renúncia ao exercício apenas e limites mais rígidos na renúncia ao direito fundamental em si” cf. Pedro

72

Sobre o problema das restrições aos direitos fundamentais cf. Robert Alexy, *Teoria dos Direitos Fundamentais*, cit., p. 276-340. Sobre a teoria dos direitos fundamentais cf. Ingo W. Sartlet; Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero. *Curso de Direito Constitucional*, cit., p. 299-399; Robert Alexy, *Teoria dos Direitos Fundamentais*, *passim*.

73

Ver, sobre este tema, Luigi Ferrajoli. *Principia Iuris*, cit., p. 229-230. Cf., *supra*, introdução, 2.1.

74

Não há homogeneidade nesta classificação. Seguimos aqui o entendimento de Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira. *Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 546 e ss.

75

Idem, p. 547.

76

Defendendo a adequada justificação de direitos fundamentais para as restrições, cf. Marcelo Lima Guerra, *Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil*, cit., p. 165.

77

A doutrina afirma, contudo, a tipicidade dos casos de impenhorabilidade. Araken de Assis, *Manual da Execução*, cit., p. 216/217; Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., art. 833.

78

Para exemplos, Marcelo Lima Guerra, *Direito Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil*, cit., p. 166-167.

79

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas, Artigo 833 do CPC/2015, cit., p. 1187.

80

Sobre o tema, cf. Ignacio M. Poveda Velasco, *A Execução do Devedor no Direito Intermédio. Beneficium*

Competentiae, São Paulo: Livraria Paulista, 2002; Idem, *A Execução do Devedor no Direito Romano*, São Paulo: Livraria Paulista, 2002. Ora, inicialmente a ideia de impenhorabilidade surgiu a partir da necessidade de humanização do direito romano, extremamente severo com o devedor e com as sanções pessoais ao executado (cf., *supra*, introdução, 2.3.1.). A mesma lógica não se pode aplicar hoje. Mesmo no passado existem dúvidas se os rigores da Lei das XII Tábuas teriam chegado a ser praticados de verdade, sua função era principalmente intimidatória, dissuasória.

81

Márcio Lima Guera, *Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil*, cit.

82

Doutrina há quem defenda um triplice regime jurídico para a impenhorabilidade a) bens absolutamente impenhoráveis, art. 833, CPC, ressalvada a dívida contraída em razão do próprio bem; b) bens relativamente impenhoráveis, 834, CPC; c) impenhorabilidade do imóvel residencial (Lei 8.009/1990), que não se confundiria com o bem de família (arts. 1.711 e 1.715, CC), Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, cit., p. 345 e ss.

83

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., art. 833.

84

Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira. *Curso de Direito Processual Civil*, cit., p. 551.

85

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas, Artigo 833 do CPC/2015, cit., p. 1188.

86

Amílcar de Castro. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Vol. 8. São Paulo: Ed. RT, 1974, p. 203.

87

Bruno Garcia Redondo; Mário Vitor Suarez Lojo. *Penhora*. São Paulo: Método, 2007, p. 109-110.

88

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1190-1191.

Fredie Didier Jr.; Leonardo Carneiro da Cunha; Paula Sarno Braga; Rafael Alexandria de Oliveira. *Curso de Direito Processual Civil. Execução*. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 834-835, já com a devida referência à doutrina que se posiciona em sentido contrário.

Em sentido contrário, partindo exatamente dessa presunção: “Ao excluir da execução o seguro de vida, a lei visa a preservar a reserva financeira que o segurado desejou destinar a terceiro após a sua morte. Pressupõe, a regra, que o valor recebido propiciará a subsistência dos beneficiários, tendo, portanto, caráter alimentar, o que justifica a impenhorabilidade”, Thiago Ferreira Siqueira. *A Responsabilidade Patrimonial no Novo Sistema Processual Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 173. O próprio autor demonstra a seguir que uma hipótese como essa permitiria o controle judicial, caso essa fosse a justificativa da impenhorabilidade, visto que “o juiz, no caso concreto, afaste sua incidência, ou reduza o montante imune à execução, sempre em atenção a outros direitos fundamentais porventura conflitantes. Imagine-se, por exemplo, que se trate de execução de alimentos, imprescindíveis, no caso, para a subsistência do exequente, e que o executado tenha recebido vultoso valor como beneficiário de seguro de vida, caso em que se pode determinar a penhora de parte deste montante” (idem, ibidem).

Nesse sentido, em diversas passagens, cf. C.H. Van Rhee; A. Uzelac (org.), *Enforcement and enforceability. Tradition and reform*, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010.

Álvaro Pérez Ragone, *General report. The conflicts between the fundamental rights of the creditor and the debtor*, International Association of Procedural Law – IAPL – Seoul Conference, 2014.

Fredie Didier Júnior. *Subsídios para uma Teoria das Impenhorabilidades*. São Paulo: Revista de Processo, 2009, p. 30-50, n. 174.

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 789.

Idem, p. 790.

Marcelo Abelha Rodrigues. O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 2 – Continuação). São Paulo: *Revista de Processo* n. 245, 2015, p. 151-222.

Na doutrina há quem defenda o cancelamento do enunciado da Súmula 417, por força do art. 835, § 1.º, CPC. Sobre a aplicação dos precedentes ao processo de execução cf. introdução, 2.18.

“A penhora não será levada a efeito quando for evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução (art. 659, § 2.º, do CPC/1973), já que, nesta hipótese, não trará nenhum resultado útil. Nessas circunstâncias, o oficial de justiça deverá descrever, na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, sem penhorá-los (art. 659, § 3.º, do CPC/1973). Essa providência faz com que a eventual alienação de tais bens possa configurar fraude à execução.” (, Antonio Adonias A. Bastos. A (In)eficácia da compensação do crédito penhorado. São Paulo: *Revista de Processo* n. 230, 2014, p. 93-124.)

“Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Como tivemos a oportunidade de apontar em outro estudo: “Unfortunately, the statistics available are not yet enough to address the most basic questions necessary for a correct understanding of the performance of the Brazilian Judiciary. Basic questions like the duration and cost of proceedings in Brazil are not yet clearly answered. As an exception to the general state of disinformation, an official study identified the average duration of tax enforcement proceedings in federal courts. According to the study, the average duration of judicial tax enforcement proceedings is 8 years, 2 months, and 9 days per proceeding, and the average cost is about R\$ 4,685.39 per proceeding, approximately U\$ 1,976 dollars. Since the average collection claim is R\$ 22,507.51 (about U\$ 9,537 dollars), the average cost of tax enforcement proceedings in Brazil represent almost a quarter of the average value of the lawsuit. Considering that the cost is merely the expense incurred by the Judiciary (it does not include the cost incurred by the Administration) and the value refers to the total value of the claim (not the amount actually collected), this data reveals that the judicial service in tax enforcement proceedings is very expensive, contrary to the reality of civil proceeding between private parties and among private parties and the public sector. This demonstrates that it is necessary to correct something in the investment in access to justice, where we could spend less and obtain a more efficient justice system. These studies are part of the movement started by the three branches of the Brazilian government in search for a more efficient and secure Judiciary, but the results are as yet inconclusive.” GIDI, Antonio; ZANETI JR., Hermes. Brazilian Civil Procedure in the “Age of Austerity”? Effectiveness, Speed, and Legal Certainty: Small Claims, Uncontested Claims, and Simplification of Judicial Decisions and Proceedings.*ELR (Erasmus Law Review)*. December,

nº 4, 2015.

Felipe Balzano. A Penhora On Line e o Prazo dos Embargos de Terceiro. São Paulo: *Revista de Processo* n. 252, 2016, p. 167-205.

102

Fabiano Carvalho; Patrícia de Almeida Campos Christianini. São Paulo: *Revista de Processo* n. 200, 2011, p. 483-507.

103

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 839 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1200.

104

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 792.

105

Felipe Balzano. A Penhora On Line e o Prazo dos Embargos de Terceiro. São Paulo: *Revista de Processo* n. 252, 2016, p. 167-205.

106

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 839 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1201-1202.

107

Felipe Balzano. A Penhora On Line e o Prazo dos Embargos de Terceiro. São Paulo: *Revista de Processo* n. 252, 2016, p. 167-205.

108

Marcelo Pacheco Machado. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Dos Embargos de Terceiro até da Restauração dos Autos. Arts. 674 a 718. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 53.

109

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 842 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1204.

110

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 795.

111

Na doutrina: MACHADO, Marcelo Pacheco. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Dos Embargos de Terceiro até da Restauração dos Autos. Arts. 674 a 718. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 53.

113

Para a consulta do manual sobre a penhora on-line de imóveis cf. [www.oficioeletronico.com.br/Downloads/manual_penhora.pdf].

114

Marcelo Abelha Rodrigues. O Novo CPC e a tutela Jurisdicional Executiva (Parte 2 – Continuação). São Paulo: *Revista de Processo* n. 245, 2015, p. 151-222.

115

André de Luiz Correia. Em Defesa da Penhora On Line. São Paulo: *Revista de Processo* n. 125, 2005, p. 92-152.

117

Pedro Henrique Nogueira. *Negócios Jurídicos Processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 226-228.

118

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 800.

119

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 850 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1215.

120

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 800.

121

Na doutrina, defendendo o contraditório como valor-fonte, Hermes Zaneti Jr. *A Constitucionalização do Processo*. 2.^a ed. São Paulo: Atlas, 2014.

122

Eduardo Talamini. Embargos do Executado. São Paulo: *Revista de Processo*, 1999, p. 90-108, n. 93.

123

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 852 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1217.

124

Na doutrina, defendendo o contraditório como valor-fonte, Hermes Zaneti Jr. *A Constitucionalização do Processo*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.

125

Athos Gusmão Carneiro. A “nova” Execução dos Títulos Extrajudiciais. Mudou muito? São Paulo: *Revista de Processo* n. 143, 2007, p. 115-129.

127

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 803.

128

Sobre o tema: “Ora, descoberto dinheiro sob a forma de depósito ou aplicação financeira (art. 835, I), inexistente a necessidade de atuação do oficial de justiça. Realizado o ato de indisponibilidade do ativo financeiro, a teor do art. 854, caput, a penhora em si realiza-se na forma eletrônica, segundo critérios uniformes do CNJ (art. 837), documentada sob a forma de termo de penhora. Às vezes, os ativos financeiros do executado concentram-se em ações negociadas em bolsa. Existem registros disponíveis da Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), órgão equivalente à *Depository Trust & Clearing Corporation* norte-americana, localizados através do número de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal – informados no requerimento e na petição inicial (art. 524, I e art. 798, II, *b*), embora os negócios na bolsa realizem-se em nome da corretora de valores” (Araken de Assis. *Manual de Execução Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016, *versão on-line*).

129

Humberto Theodoro Júnior. Compimento della Sentenza nel CPC Brasiliano, specialmente nei Casi di Obbligazioni di Somma di Danaro. São Paulo: *Revista de Processo* n. 253, 2016.

130

Álvaro Pérez Ragone. *General Report. The Conflicts between the Fundamental Rights of the Creditor and the Debtor*. International Association of Procedural Law – IAPL – Seoul Conference, 2014, p. 659-660.

Assim, “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- “1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)” (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, *DJe* 15.08.2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem. (REsp 1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05.11.2013, *DJe* 29.11.2013.)

No mesmo sentido, AgRg no AREsp 563.280/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.11.2015, *DJe* 26.11.2015; AgRg no AREsp 705.435/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.08.2015, *DJe* 04.09.2015; AgRg no REsp 1496150/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05.02.2015, *DJe* 12.02.2015; AgRg no REsp 1489460/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.12.2014, *DJe* 19.12.2014; AgRg no REsp 1461412/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21.10.2014 ; AgRg no AREsp 321.310/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.12.2013, *DJe* 03.02.2014; 21.10.2014, *DJe* 27.11.2014).

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 855 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1222.

Marcelo Abelha Rodrigues. O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 2 – Continuação). São Paulo: *Revista de Processo* n. 245, 2015, p. 151-222.

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 861 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1227.

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 862 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1229.

Marcelo Abelha Rodrigues. O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 2 – Continuação). São

142

Felipe Balzano. A Penhora On Line e o Prazo dos Embargos de Terceiro. São Paulo: *Revista de Processo* n. 252, 2016, p. 167-205.

144

Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Artigo 868 do CPC/2015. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1235.

146

Luis Guilherme Aidar Bondioli, Artigo 870 do CPC/2015, in: Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer (coord.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1238.

147

Marcelo Abelha Rodrigues, *O Novo CPC e a tutela jurisdicional executiva* (Parte 2 – Continuação), *Revista de Processo*, n. 245, São Paulo: 2015, p. 151-222.

148

Hermes Zaneti Jr., *A constitucionalização do processo*, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2014.

149

No mesmo sentido, AgRg no AREsp 606.014/SC, 4.^a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 16.04.2015,

DJe 15.05.2015; AgRg no REsp 1282195/RS, rel. Min. Humberto Martins, 2.^a Turma, j.10.02.2015, *DJe* 19.02.2015.

150

Neste sentido: REsp 958.383/PR, 1.^a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j.18.11.2008, *DJe* 17.12.2008; REsp 413.274/SC, 2.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.06.2006, *DJ* 03.08.2006; REsp 394.523/SC, 2.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.04.2006, *DJ* 25.05.2006; REsp 475.693/RS, 1.^a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 25.02.2003, *DJ* 24.03.2003; REsp 396.292/SC, rel. Min. Garcia Vieira, *DJ* 03.06.2002; REsp 53.652/SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, *DJ* 06.02.1995; REsp 53.844/SP, rel. Min. Hélio Mosimann, *DJ* 12.12.1994).

152

Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira, *Curso de direito processual civil*, Execução, 7. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. 5, no prelo, texto gentilmente cedido pelos autores.

153

Paulo Henrique dos Santos Lucon, Comentários aos arts. 870 ao 909, in: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas (coord.), *Breves comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

154

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 818-820.

155

Cândido Rangel Dinamarco, O Novo Código de Processo Civil brasileiro e a ordem processual civil vigente, *Revista de Processo*, n. 247, São Paulo: 2015, p. 63-103.

156

Marcelo Abelha Rodrigues, O Novo CPC e a tutela jurisdicional executiva (Parte 2 – Continuação), *Revista de Processo*, n. 245, São Paulo: 2015, p. 151-222.

157

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 820-821.

158

Marcelo Abelha Rodrigues, O Novo CPC e a tutela jurisdicional executiva (Parte 2 – Continuação). *Revista de Processo*, n. 245, São Paulo: 2015, p. 151-222.

160

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 822.

161

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao art. 879, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

162

Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução*, p. 156.

163

Humberto Theodoro Jr., Compimento della Sentenza nel CPC Brasiliano, specialmente nei Casi di Obbligazioni di Somma di Danaro, *Revista de Processo*, n. 253, São Paulo: 2016 (cf. introdução, 2.4.)

164

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 822-823.

165

Paulo Henrique dos Santos Lucon, Comentários aos arts. 870 ao 909, in: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas (coord.), *Breves comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

166

Paula Sarno Braga, *Norma de processo e norma de procedimento*. O problema da repartição de competência legislativa no direito constitucional brasileiro, Salvador: JusPodivm, 2016.

167

Paulo Henrique dos Santos Lucon, Comentários aos arts. 870 ao 909, in: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas (coord.), *Breves comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

168

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 825.

169

Antonio do Passo Cabral, *Nulidades no processo moderno*. Contraditório, proteção da confiança e validade *prima facie* dos atos processuais, Rio de Janeiro: Forense, 2009; Renzo Cavani, *La nulidad en el Proceso Civil*, Lima: Palestra, 2014.

170

Helder Moroni Câmara, Comentários ao art. 888, in: Lênio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1154.

171

Marcelo Abelha Rodrigues, O Novo CPC e a tutela jurisdicional executiva (Parte 2 – Continuação). *Revista de Processo*, n. 245, São Paulo: 2015, p. 151-222.

172

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 829-830.

173

Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira, *Curso de direito processual civil*. Execução, 6. ed., Salvador: JusPodivm, 2014, vol. 5, p. 647; Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, t. 10, p. 260-267.

174

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao art. 893, Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

175

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 832.

176

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao art. 896, Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

177

É dever registrar que ambas as propostas dogmáticas para aproveitamento do referido dispositivo partiram de um diálogo no FPPC entre Fredie Didier Jr. e Fabiano Carvalho, aos quais o autor agradece o debate franco.

178

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao art. 898, Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

179

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao art. 900, Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

180

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao art. 902, Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

181

Marcelo Abelha Rodrigues, O Novo CPC e a tutela jurisdicional executiva (Parte 1). *Revista de Processo*, n. 244, São Paulo: 2015, p. 87-150.

182

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao art. 903, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

183

Heitor Sica, *Cognição e execução no sistema da tutela jurisdicional civil brasileiro*, p. 326-327. Sobre o ponto, ver também, já citado por Heitor Sica, Italo Andolina, *Cognizione ed esecuzione forzata nel sistema della tutela giurisdizionale*, p. 23.

184

Heitor Sica, *Cognição e execução no sistema da tutela jurisdicional civil brasileiro*, p. 327.

186

Marcelo Abelha Rodrigues, O Novo CPC e a tutela jurisdicional executiva (Parte 2 – Continuação), *Revista de Processo*, n. 245, São Paulo: 2015, p. 151-222.

187

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao art. 905, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

188

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 837.

189

“Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973.” É bom lembrar, como já anotado, que o superendividamento não se confunde com a insolvência civil, mas podendo, contudo, dar lugar a um concurso universal de credores.

190

Súmula 563 do STF: “O concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do art. 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no art. 9.º, I, da Constituição Federal”.

“[1]. O crédito tributário de autarquia federal goza do direito de preferência em relação àquele de que seja titular a Fazenda Estadual, desde que coexistentes execuções e penhoras. (...) 2. A instauração do concurso de credores pressupõe pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, por isso que apenas se discute a preferência quando há execução fiscal e recaia a penhora sobre o bem executado em outra demanda executiva. (...) 6. Deveras, verificada a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem em executivos fiscais ajuizados por diferentes entidades garantidas com o privilégio do concurso de preferência, consagra-se a prelação ao pagamento dos créditos tributários da União e suas autarquias em detrimento dos créditos fiscais dos Estados, e destes em relação aos dos Municípios, consoante a dicção do art. 187, parágrafo único, c/c art. 29 da Lei 6.830/1980 (STJ, REsp Repetitivo n. 957.836/SP, 1.ª Seção, j. 13.10.2010, rel. Min. Luiz Fux).

Paulo Henrique dos Santos Lucon, Comentários aos arts. 870 ao 909, in: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas (coord.). *Breves comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao art. 909, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

Com as reformas legais ocorreu um renovado interesse pela execução civil, publicando-se uma série de trabalhos coletivos: Fredie Didier Jr. (coord.), *Execução civil: estudos em homenagem ao professor Paulo Furtado*, Rio de Janeiro: 2006; Paulo, Hoffman; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro (coord.), *Processo de execução civil*, São Paulo: Quartier Latin, 2006; Ernane Fidélis dos Santos; Luiz Rodrigues Wambier; Nelson Nery Jr.; Teresa Arruda Alvim Wambier (coord.), *Execução civil: estudos em homenagem ao professor Humberto Theodoro Júnior*, São Paulo: Ed. RT, 2007; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (coord.), *A nova execução de títulos extrajudiciais. Comentários à Lei 11.382/2006*, Rio de Janeiro: 2007; Idem, *A nova execução. Comentários à Lei 11.232/2005*, Rio de Janeiro: Forense, 2006; Carlos Henrique Bezerra Leite; Lorena de Mello Rezende Colnago; Luiz Eduardo Gunther (coord.), *Execução trabalhista: uma homenagem ao professor Wagner Giglio*, São Paulo: LTr, 2015.

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 780-786; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*, cit.; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 728-733; Rodrigo Barioni, Arts. 824 a 830 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1177-1183; Carlos Augusto de Assis, Comentários aos arts. 827 a 830 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.), 2. ed., *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, cit., p. 1997-2008; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil*

Anotado, cit., p. 639-644; Antônio Carvalho Filho, Arts. 827 a 830 do CPC. In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1084-1094; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello (coord.), *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*, cit., p. 1174-1178; Araken de Assis, *Manual de Execução*, cit., p. 896-899.

30

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, cit., p. 785-786.

100

Cf. Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 791-796; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 837 a 844)*. São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão on-line*, p. 746-750; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1199-1209; Leonardo de Faria Beraldo. Comentários aos arts. 837 a 846 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2022-2029; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 648-653; Guilherme Lage. Arts. 837 a 846 do CPC. In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1106-1112; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1199-1206; Humberto Theodoro Jr. *Processo de Execução e Cumprimento de Sentença*. 25ª ed. São Paulo: Leud, 2008, p. 301-315; Araken de Assis. *Manual de Execução*. 18ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 921-957; Donaldo Armelin; Marcelo J. M. Bonicio; Mirna Cianci; Rita Quartieri. *Comentários à Execução Civil: Título Judicial e Extrajudicial (artigo por artigo)*. São Paulo: Saraiva: 2008, p. 236-245.

112

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 796-798; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 845 a 846)*. São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão on-line*, p. 751-752; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1209-1211; Leonardo de Faria Beraldo. Comentários aos arts. 837 a 846 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2029-2031; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 653-655; Guilherme Lage. Arts. 837 a 846 do CPC. In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1112-

1114; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1206-1208.

116

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 798-801; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 847 a 853)*. São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 753-757; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1211-1218; Rodolfo da Costa Manso Real Amadeo. Arts. 847 a 853 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2032-2041; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 655-660; Marina França Santos. Arts. 847 a 861 do CPC In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1114-1118; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1208-1218.

126

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 802-805; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (art. 854)*. São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 758-760; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1218-1222; Luiz Fernando Casagrande Pereira. Art. 854 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2042-2054; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 660-666; Marina França Santos. Arts. 847 a 861 do CPC In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1118-1121; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1218-1223; Araken de Assis. *Manual de Execução*. 18ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 957-961; Donaldo Armelin; Marcelo J. M. Bonicio; Mirna Cianci; Rita Quartieri. *Comentários à Execução Civil: Título Judicial e Extrajudicial (artigo por artigo)*. São Paulo: Saraiva: 2008, p. 214-222.

133

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 805-807; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários*

ao Código de Processo Civil (arts. 855 a 860). São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão on-line*, p. 761-763; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1222-1225; Guilherme Peres de Oliveira. Arts. 855 a 869 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2055-2060; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 666-668; Marina França Santos. Arts. 847 a 861 do CPC In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1121-1124; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1223-1228; Araken de Assis. *Manual de Execução*. 18ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 962-981.

135

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 808-809; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (art. 861)*. São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão on-line*, p. 764-765; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1225-1227; Guilherme Peres de Oliveira. Arts. 855 a 869 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2060-2062; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 668-670; Marina França Santos. Arts. 847 a 861 do CPC In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1124-1126; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1229-1231.

138

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 809-811; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 862 a 865)*. São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão on-line*, p. 766-768; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1227-1232; Guilherme Peres de Oliveira. Arts. 855 a 869 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2062-2064; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 670-671; Fábio Victor da Fonte Monnerat. Arts. 862 a 869 do CPC. In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1126-1129; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015,

p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1232-1235; Araken de Assis. *Manual de Execução*. 18ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 983-991.

141

Cf. Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 811-812; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (art. 866)*. São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão on-line*, p. 769-770; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1232-1233; Guilherme Peres de Oliveira. Arts. 855 a 869 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2065-2066; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671-673; Fábio Victor da Fonte Monnerat. Arts. 862 a 869 do CPC. In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1129-1130; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1236.

143

Cf. Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 812-814; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 867 a 869)*. São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão on-line*, p. 771-772; Rodrigo Mazzei; Sarah Merçon-Vargas. Arts. 831 a 869 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1233-1237; Guilherme Peres de Oliveira. Arts. 855 a 869 do CPC. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2066-2068; Cássio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 673-675; Fábio Victor da Fonte Monnerat. Arts. 862 a 869 do CPC. In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1130-1133; Alexandre de Freitas Câmara. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1237-1239; Araken de Assis. *Manual de Execução*. 18ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 993-1003.

145

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 814-818; Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 870 a 875)*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina,

Novo Código de Processo Civil comentado, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 777-779; Luis Guilherme Aidar Bondioli, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer (coord.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1238-1243; Paulo Henrique dos Santos Lucon, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas (coord.), *Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2069-2074; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 675-678; Helder Moroni Câmara, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Lênio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (org.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1133-1138; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Freitas da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Artigo por artigo, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1239-1243; Marcelo Abelha, *Manual de execução civil*, 5. ed., Rio de Janeiro, 2015, p. 352-368; Araken de Assis, *Manual de execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 1051-1063.

151

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 818-821; Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil* (arts. 876 a 878), São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 777-779; Luis Guilherme Aidar Bondioli, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer (coord.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1243-1249; Paulo Henrique dos Santos Lucon, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas (coord.), *Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2075-2080; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 679-681; Helder Moroni Câmara, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Lênio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (org.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1138-1145; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Freitas da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello (coord.), *Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Artigo por artigo, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 1244-1251; Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 142-173; Humberto Theodoro Jr., *Processo de execução e cumprimento de sentença*, 25. ed., São Paulo: Leud, 2008, p. 317-337; Marcelo Abelha, *Manual de execução civil*, 5. ed., Rio de Janeiro, 2015, p. 369-376; Araken de Assis, *Manual de execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 1088-1101.

159

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 822-836; Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil* (arts. 879 a 903), São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 780-792; Luis Guilherme Aidar Bondioli, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer (coord.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1249-1276; Paulo Henrique dos Santos Lucon, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas (coord.), *Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo:

Ed. RT, 2016, p. 2080-2101; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 681-700; Helder Moroni Câmara, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Lênio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (org.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1145-1167; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Freitas da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Artigo por artigo, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1251-1280; Marcelo Abelha, *Manual de execução civil*, 5. ed., Rio de Janeiro, 2015, p. 376-397; Araken de Assis, *Manual de execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 1102-1165.

185

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 836-839; Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil* (arts. 904 a 909), São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão on-line, p. 793-796; Luis Guilherme Aidar Bondioli, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer (coord.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1276-1280; Paulo Henrique dos Santos Lucon, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas (coord.), *Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2101-2111; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 700-702; Helder Moroni Câmara, Arts. 870 a 909 do CPC, in: Lênio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (org.), *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1167-1172; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Freitas da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Artigo por artigo, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1280-1284; Araken de Assis, *Manual de execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 1166-1185.

© desta edição [2018]

Capítulo V. Da Execução contra a Fazenda Pública

1

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535.

1. Execução contra a Fazenda Pública. A execução contra a Fazenda Pública é uma execução de caráter especial, contendo regras próprias, tendo em vista que: a) o regime de pagamento de suas dívidas pecuniárias ocorre por meio de precatório (art. 100 da CF/1988); b) são inalienáveis os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial (arts. 100 do CC/2002), sendo passíveis de alienação apenas os bens públicos dominicais, na forma da lei (art. 101 do CC/2002).²

Para os fins do presente artigo, entende-se por Fazenda Pública a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, além de suas respectivas autarquias e fundações. Não integram este rol as sociedades de economia mista e as empresas públicas, pois submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado.³

2. Execução de crédito por título executivo judicial ou extrajudicial. O regime executivo do art. 910 do CPC/2015 e do art. 100 da CF/1988 diz respeito tão somente à execução de crédito, consistente na obrigação da Fazenda Pública pagar quantia certa. Caso a execução contra a Fazenda Pública tenha por objeto entrega de coisa ou obrigação de fazer, desfazer ou não fazer, serão obedecidos, respectivamente, os regimes próprios dos arts. 806 a 813 e dos arts. 814 a 823 do CPC/2015.

Sendo assim, caberá execução de crédito (pagamento de quantia certa) contra a Fazenda Pública por: a) título executivo judicial, quando reconhecida a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. Nesta oportunidade, correrá o procedimento executivo mediante cumprimento de sentença que (art. 534 e 535 do CPC/2015); ou b) título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC/2015), que seguirá o regime do art. 910 do CPC/2015 e do art. 100 da CF/1988. O enunciado da Súmula 279 do STJ diz que “é cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública” (art. 927, IV do CPC/2015). Não há mais polêmica sobre o assunto, superada pelos precedentes e pela nova legislação, que os seguiu, em salutar relação circular: do direito interpretado e positivado por precedentes, para o direito legislado e positivado pela lei.

3. Citação para oposição de embargos. Considerando que os bens públicos são inalienáveis (art. 100 do CC) e impenhoráveis (art. 833, I do CPC/2015), a citação não é para que a Fazenda Pública promova o pagamento do débito, sob pena de penhora, mas para opor embargos, no prazo

de 30 (trinta) dias (art. 910, *caput* do CPC/2015), contados a partir da data de juntada do mandado de citação (art. 231, II do CPC/2015). Se a despeito de regularmente citada, a Fazenda Pública se mantiver inerte, deverá ser expedido o precatório ou o RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor do exequente, nos moldes do art. 100 da CF/1988. Isto ocorre porque se presume que não há defesa a ser oposta, contudo ainda caberá ação autônoma.

Importante no ponto é salientar que a Fazenda Pública não pode pagar a obrigação de pagar quantia certa consistente em título executivo judicial salvo por precatório ou RPV, logo, o procedimento se torna obrigatório.

4. Ação autônoma de impugnação. Os embargos são uma faculdade da Fazenda Pública. O prazo dos embargos serve também para oportunizar a defesa que impede o prosseguimento da execução, suspendendo-o. Contudo, caso não sejam opostos os embargos a Fazenda Pública ainda assim poderá impetrar ação autônoma que pretenda impugnar o título extrajudicial.

Neste sentido: “[a]inda, por serem os embargos uma faculdade da Fazenda Pública, nada impede que promova depois do prazo dos embargos, caso não tenha interposto essa oposição, uma ação autônoma que pretenda declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional supostamente contida no título executivo”.⁴

5. Efeito suspensivo dos embargos. Em regra, os embargos não têm efeito suspensivo (art. 919, *caput* do CPC/2015), mas como a execução de crédito contra a Fazenda Pública segue regime especial, a mera oposição de embargos é motivo para suspender a execução.

Esta conclusão é possível pelo fato de que somente é possível expedir precatório ou RPV, depois do trânsito em julgado da decisão que rejeitá-los (art. 910, § 1.º do CPC/2015).⁵

Este dispositivo está consoante o art. 100, § 5.º, da CF/1988: “é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”.

6. Conteúdo dos embargos. A execução de crédito contra a Fazenda Pública lastreada em título executivo extrajudicial possui ampla cognição, facultado ao ente público, em sede de embargos, alegar qualquer matéria deduzível no processo de conhecimento (art. 910, § 2.º do CPC/2015).

Assim, por “se tratar de execução fundada em título extrajudicial, os embargos da Fazenda Pública podem versar sobre qualquer matéria que poderia ser alegada numa contestação”.⁶

7. Embargos parciais e parcela incontroversa do crédito. Se os embargos forem parciais, ou seja, se a Fazenda Pública não impugnar uma parcela do crédito, a execução prosseguirá em face do valor incontroverso, expedindo-se o respectivo precatório ou RPV, se for caso.

Nesta situação, não há que se falar em fracionamento do precatório, vedado pelo art. 100, § 8.º, da CF/1988, visto que não configura uma conduta do exequente que visa repartir o precatório para receber o dinheiro através do RPV.

Como ressalta a doutrina, “não é devido processo aquele em que a parte se vê obrigada a aguardar a satisfação de um direito que é incontroverso apenas porque o processo tem ainda de se desenvolver para solucionar fração da causa que exige ainda maior delonga para o seu julgamento. A demora na satisfação de direito incontroverso constitui dilação indevida e está expressamente vedada no Estado Constitucional (art. 5.º, LXXVIII, CF)”.⁷

Por analogia, aplica-se aqui o procedimento comum: “art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso [...] § 2.º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito [...] se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva”, CPC/2015.

Trata-se do cumprimento do disposto no art. 318, parágrafo único do CPC/2015.

8. Rejeição liminar dos embargos. Os embargos opostos pela Fazenda Pública poderão ser rejeitados liminarmente em 04 (quatro) hipóteses: a) quando intempestivos (art. 918, I do CPC/2015); b) quando inepta a petição inicial e improcedente liminarmente o pedido (art. 918, II c/c arts. 330, § 1.º, e 332 do CPC/2015); c) quando manifestamente protelatórios (art. 918, III do CPC/2015), o que é passível de multa por configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 77 c/c 918, parágrafo único do CPC/2015); d) quando alegado excesso na execução sem apontar a quantia excedente (art. 917, § 4.º, I do CPC/2015).

Pode ser cogitada a aplicação do quanto afirmado no item anterior ao julgamento liminar de parcela da matéria embargada, naquilo que couber.

9. Procedimento. O juiz receberá os embargos e intimará o exequente para sobre eles se manifestar, em 15 (quinze) dias. Ato contínuo, o juiz julgará imediatamente o pedido dos embargos ou designará audiência, oportunidade em que, encerrada a instrução, proferirá sentença (art. 920 do CPC/2015).

10. *Exceptio declinatoria quanti* (excesso na execução). O CPC/2015 não mais admite a alegação genérica de excesso na execução. Nos termos do art. 535, § 2.º do CPC/2015 (“*quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição*”), aplicável expressamente no processo de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública por força do art. 910, § 3.º do CPC/2015, caberá ao impugnante declarar o valor que entende correto no momento da impugnação, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

O ônus de impugnação será do executado, a ele cabe opor a *exceptio declinatoria quanti* (exceção por excesso de execução). Esta é a regra geral para a execução em face da Fazenda Pública.

Como vimos a regra resulta da conjugação dos dispositivos do art. 910, § 3.º com os arts. 534 e 535, por expressa disposição do primeiro.

Como a menção é expressa sinaliza o legislador que exige também da Fazenda Pública o comportamento que exigirá dos demais executado. Não socorre mais aqui a decisão do STJ, no regime de recursos repetitivos, proferida no REsp 1.387.248/SC.⁸

Como é sabido, os precedentes, por mais vinculantes que sejam, não devem impedir seu afastamento pela legislação.

A nova legislação é fato novo, servindo como elemento de distinção (art. 489, § 1.º, VI do CPC).

Assim, os juízes não estão mais vinculados pelo referido precedente (REsp 1.387.248/SC). Não importa que o regime de recursos repetitivos tenha sido recepcionado como precedente normativo formalmente vinculante, falta-lhe aqui o caráter normativo.⁹

O tribunal poderá, ao analisar novamente a questão, conferir novo colorido interpretativo à luz da nova lei e criar distinções e exceções razoáveis não previstas na legislação, interpretando-a; poderá, igualmente, se fosse o caso, decretar a sua inconstitucionalidade e desaplicar a nova lei.

Só não pode ignorá-la e afirmar a vinculatividade do precedente por si só, o que seria subverter a separação de poderes e o regime jurídico brasileiro de sua aplicação. Além de ir contra a melhor doutrina.

Nos casos em que for necessária *dilação probatória*, a regra geral poderá ser afastada justamente por não se constituírem hipóteses de excesso de execução, mas de dívida ilíquida, pois o conhecimento do valor dependerá de cognição. Nesse sentido, na doutrina “*rigorosamente tais hipóteses não constituem hipóteses de excesso de execução*, revelando-se como situações de

iliquidez da obrigação, afastando-se, portanto, o ônus da alegação, por parte do executado, do valor correto. Ao executado caberá, isto sim, apontar a iliquidez da obrigação, indicando a necessidade de uma liquidação por artigos ou por arbitramento”.¹⁰

11. Honorários Advocatícios. Sempre foi objeto de discussão nos Tribunais Superiores se são ou não devidos honorários advocatícios em execuções fundadas em título extrajudicial contra a Fazenda Pública (STJ, REsp Repetitivo 1.406.296/RS, 1ª Seção, rel. Ministro Herman Benjamin, j. 26.02.2014, *DJe* 19.03.2014; STJ, REsp 1.347.736/RS, 1ª Seção, rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, j. 09.10.2013, *DJe* 15.04.2014), entretanto, com a entrada em vigor no CPC/2015, ficou claro que são devidos honorários advocatícios nessas execuções, conforme prevê o art. 85, § 3.º do CPC/2015. Nesse sentido Enunciado 240 do FPPC (“São devidos honorários nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública, a serem arbitrados na forma do § 3.º do art. 85”).

NOTAS DE RODAPÉ

2

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 839-844.

3

Rita Dias Nolasco, Comentários ao art. 910, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

4

Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual de Execução Civil*, p. 415.

5

Leonardo Carneiro da Cunha, Comentários ao art. 910, In: Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p.1173.

6

Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual de Execução Civil*, p. 414.

7

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 839-844.

8

Leonardo Carneiro da Cunha, Comentários ao art. 910, In: Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes, Leonardo

Carneiro da Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1174, no mesmo sentido.

9

Hermes Zaneti Jr., *O Valor Vinculante dos Precedentes*, Cap. 4, *passim*.

10

Leonardo Carneiro da Cunha, Comentários ao art. 910, In: Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1174.

1

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 839-844; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil (art. 910)*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão online*, p. 797; Eduardo José da Fonseca Costa, Art. 910 do CPC. In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1281-1282; Rita Dias Nolasco, Art. 910 do CPC, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2112-2117; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil Anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 702-713; Leonardo Carneiro da Cunha, Art. 910 do CPC, In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1172-1175; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1284-1285; Humberto Theodoro Jr., *Processo de Execução e Cumprimento de Sentença*. 25. ed., São Paulo: Leud, 2008, p. 379-389; Marcelo Abelha, *Manual de Execução Civil*, 5. ed., Rio de Janeiro, 2015, p. 405-415; Araken de Assis, *Manual de Execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 1357-1401.

© desta edição [2018]

Capítulo VI. Da Execução de Alimentos

¹

Art. 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, os §§ 2º a 7º do art. 528.

1. Título executivo e obrigação de pagar alimentos. Os alimentos civis destinam-se a fazer frente a toda a necessidade da vida humana, gêneros alimentícios ou não, servem para a garantia da dignidade da pessoa humana. Podem ser: a) *legítimos*, devidos em razão de parentesco, casamento ou união estável (art. 1.694 do CC/2002); b) *voluntários*, decorrentes de negócio jurídico (e.g., art. 1.928 do CC/2002); c) *indenizativos*, devidos em razão da prática de ato ilícito (e.g., arts. 948, II e 950 do CC/2002). Não há mais sentido na *vetera* distinção entre alimentos provisionais e provisórios. Na doutrina, afirma-se que a “diferença, todavia, perdeu utilidade, especialmente diante da generalização da antecipação de tutela satisfativa. Porque todos os alimentos provisórios são também provisionais, não há mais razão para se estabelecer diferença entre alimentos provisionais e provisórios.”² Provisionais, na nomenclatura do art. 1.706 do CC/2002; ou, provisórios, na nomenclatura do CPC, ambos têm o mesmo efeito para fins de meios executivos.

Alinhamo-nos com o entendimento doutrinário de que não interessa a espécie, mas sim o gênero. “Não interessa a espécie – interessa o gênero. Havendo necessidade de alimentos, não há razão para distinguir técnicas processuais atinentes somente a essa ou àquela espécie: a necessidade dos alimentos é a mesma. Seu fundamento último também: a dignidade da pessoa humana”.³

Sob a égide do Código anterior, a execução de prestação alimentícia seguiria sempre o procedimento dos arts. 732 ao 735 do CPC/1973, independentemente se lastreada em título executivo judicial ou extrajudicial. O CPC/2015, por sua vez, estabelece uma distinção metodológica adequada à tutela mais efetiva e tempestiva do direito aos alimentos (art. 4.º do CPC/2015) quando determina que a obrigação de pagar alimentos pode constar de título executivo judicial ou extrajudicial. No primeiro caso, o pagamento será exigido através do cumprimento de sentença (arts. 528 ao 533 do CPC/2015); no segundo, cobrar-se-á o pagamento mediante execução do título, conforme o procedimento disposto nos arts. 911 ao 913 do CPC/2015. O estímulo à política de autocomposição, inclusive extrajudicial, tende a aumentar as hipóteses deste tipo de execução (art. 3.º, §§ 2.º e 3.º; art. 5.º, Resolução CNMP 118/2014).

2. Citação do executado. Recebida a petição inicial fundada em título executivo extrajudicial no qual consta obrigação de pagar alimentos, o juiz ordenará a citação do executado para, no prazo de 03 (três) dias: a) realizar o pagamento das prestações anteriores ao início da execução, bem como, das prestações que se vencerem no curso da execução; b) comprovar que efetuou o referido pagamento; ou, c) justificar a impossibilidade de fazer o referido pagamento (art. 911, *caput* do CPC/2015).

3. Alimentos, dignidade da pessoa humana e técnicas processuais executivas. O fundamento constitucional para o pagamento de alimentos é a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III do CF/1988). Não há dignidade na indigência e na fome. O direito aos alimentos, em muitos aspectos, traduz um mínimo existencial (evidentemente que os alimentos civis poderão corresponder a mais que o mínimo existencial por força do binômio necessidade e possibilidade). Deste modo, o órgão jurisdicional deverá utilizar todas as técnicas processuais executivas disponíveis para que a tutela do direito aos alimentos seja prestada de forma adequada, efetiva e tempestiva (art. 4.º do CPC/2015). A doutrina tem elencado uma série de técnicas processuais executivas que podem servir ao atingimento de tal finalidade, tais como: a) o desconto em folha (arts. 529 e 912 do CPC/2015); b) o desconto em parcela de faturamento de empresa (art. 866 do CPC/2015); c) o desconto em frutos e rendimentos (arts. 867-869 do CPC/2015); d) a constituição de capital (art. 533 do CPC/2015); e) a expropriação (art. 913 do CPC/2015); e f) a prisão civil do devedor (arts. 5.º, LXVII da CF/1988, e 528 do CPC/2015).⁴

A prisão civil do devedor de alimentos é uma hipótese constitucionalmente autorizada de *prisão civil por dívida*: art. 5.º, LXVII, “*não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia [...]*”. Perceba-se aqui claramente a conexão entre a dívida alimentícia voluntária e inescusável e a dignidade da pessoa humana, a suportar historicamente esta exceção expressa.

Não se pode esquecer, ainda, que o juiz tem o poder de utilizar meios atípicos de execução, ou seja, que não estão previstos taxativamente na legislação positiva, cabendo-lhe “*determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária*” (art. 139, IV do CPC/2015).

Porém, considerada a amplitude de medidas à disposição do órgão jurisdicional, sempre deverá ser escolhida a técnica processual executiva menos gravosa ao executado (art. 805 do CPC/2015); observando-se a proporcionalidade da medida e as submáximas ou sub-regras da adequação (meio e fim), necessidade (inexistência de outro meio menos gravoso) e proporcionalidade em sentido estrito (não supressão do núcleo fundamental do direito em sentido oposto).

4. Prisão civil. A restrição à liberdade individual do executado por débito alimentar é autorizada pela Constituição no art. 5.º, LXVII: “*não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia [...]*”.⁵

A prisão civil não está expressa no texto do art. 911 do CPC, ela decorre da aplicação do art. 528, §§ 2.º a 7.º, determinada pelo parágrafo único do artigo em comento. O art. 528, § 7.º do CPC/2015, que disciplina o cumprimento da sentença que condena a pagar alimentos e é também aplicável à execução de alimentos por força do art. 911, parágrafo único do CPC/2015, prescreve que a prisão civil do executado é possível quando o débito alimentar compreender “*as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo*”, corroborando assim o entendimento cristalizado no enunciado de Súmula 309 do STJ (“*o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo*”). Houve, evidentemente, uma recíproca influência entre a legislação e os precedentes do STJ, circularidade virtuosa em um ordenamento de corte predominantemente legislativo.

O eventual ajuizamento de ação revisional do débito alimentar pelo executado, não obsta o prosseguimento da execução e tampouco o decreto de prisão civil (STJ – HC 44270/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 03.10.2005; AgRg no RHC 45.494/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.09.2014, DJe 11.09.2014).

A prisão terá prazo fixado entre 01 (um) a 03 (três) meses, art. 528, § 3.º do CPC (“se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial [...] decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”. O preso deverá ficar separado dos presos comuns e será cumprida em regime fechado, art. 528, § 4.º (“a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns”).

Ademais, o cumprimento da pena de prisão não eximirá o executado de promover o devido pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5.º do CPC/2015).

Por fim, seja a prestação a prestação alimentícia for devidamente quitada, a ordem de prisão será suspensa (art. 528, § 6.º do CPC/2015).

5. Prisão civil e alimentos devidos em razão de ato ilícito. A doutrina e a jurisprudência entendem que não caberá a prisão civil, quando os alimentos tiverem por natureza a dívida decorrente de indenização por ato ilícito. Assim, o “débito alimentar decorrente de ato ilícito guarda diferença com os alimentos devidos pelo vínculo familiar [...]”.⁶ Portanto, aplicar-se-iam os entendimentos do STJ no sentido que: “é ilegal a prisão civil decretada por descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em razão de ato ilícito” (HC 182.228/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.03.2011, *DJe* 11.03.2011); “a possibilidade de determinar-se a prisão, para forçar ao cumprimento de obrigação alimentar, restringe-se a fundada no direito de família. Não abrange a pensão devida em razão de ato ilícito.” (REsp 93.948/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, j. 02.04.1998, *DJ* 01.06.1998, p. 79), entre outros.

Não nos parece que este seja o entendimento mais correto à luz da dignidade da pessoa humana que está a base da exceção procedimental que possibilita a prisão civil por dívida. Logo, no caso concreto, justificadamente, entendemos que também para as obrigações de pagar quantia certa, referentes a alimento devedor por ato ilícito, deverá ser admitida a prisão civil como medida coercitiva. Ademais, não fosse pela previsão do presente artigo e da norma constitucional, deve ser lembrado, ainda, o dever-poder do juiz de garantir a efetividade da execução através dos meios atípicos (art. 139, IV do CPC).

O CPC já deu indícios da inexistência de distinção de origem nos débitos alimentares, quando excepcionou para o seu adimplemento a regra da impenhorabilidade dos salários e da poupança (art. 833, § 2.º do CPC/2015, o qual determina que impenhorabilidade: “[...] *não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem* [...]”).

6. Impossibilidade de revisão dos alimentos indenizatórios. A doutrina afirma que será impossível rever os débitos decorrentes de condenação judicial transitada em julgado, quando se tratarem de alimentos resultantes de ato ilícito.

Esta seria mais uma diferença entre os alimentos no direito de família e os alimentos decorrentes de ato ilícito. Neste sentido, “[o]utra diferença reside no fato de que no direito de família os alimentos podem ser alterados caso as condições financeiras do alimentante ou do alimentando se modifiquem no tempo, dando ensejo à possibilidade de *revisão da prestação alimentícia*. Tratando-se de alimentos indenizatórios, essa possibilidade não existe”.⁷ No ponto, não há o que reparar. Contudo, é preciso marcar que a obrigação, mesmo decorrente de sentença transitada em julgado, poderá ser alterada consensualmente, novada pelas partes envolvidas, substituindo o vínculo anterior por nova avença.

Art. 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia.

§ 1º Ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício.

§ 2º O ofício conterà os nomes e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração.

1. Desconto em folha de pagamento do executado. É possível que o pagamento da obrigação

de pagar alimentos seja quitado através do desconto em folha de pagamento, quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, assim como empregado sujeito à legislação do trabalho (art. 912, *caput* do CPC/2015). Embora o dispositivo diga que se trata de medida a ser requerida pelo exequente, nada impede que o juiz a determine, quando verificada a condição do executado, conforme narrado no texto legal (art. 139, IV do CPC/2015).

Ademais, absolutamente pertinente à tutela do direito de alimentos que o desconto nos honorários profissionais e rendimentos também ocorra quando o executado possuir fonte de renda estável, fixa e periódica, como, por exemplo, os profissionais liberais.⁸

Aqui, neste artigo, ocorre uma exceção à regra da impenhorabilidade dos salários (art. 833, IV, “[s]ão impenhoráveis [...] os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2.º”). A regra geral é, portanto, de que salários são impenhoráveis, um desdobramento histórico do *beneficium competentiae*: essa regra nasce justamente da preocupação de que o devedor não seja reduzido a indigência.⁹

Assim, a mesma dignidade da pessoa humana autoriza, no sentido oposto, o desconto em folha como medida executiva para efetivar a prestação alimentícia. Nada mais lógico, se o benefício surgiu para beneficiar a família do devedor/executado, também deverá ser afastado quando for necessário para beneficiar a família do exequente. A questão na prática é ainda mais gritante, pois, na maior parte das vezes, percebe-se que a execução de alimentos é para o benefício da própria família do executado.

Por esta razão a impenhorabilidade do art. 833, IV, constou com inovação ao reconhecer que a impenhorabilidade do salário não se aplica à prestação alimentícia, não importando a sua origem, se alimentos legítimos, convencionais ou indenizativos: “[o] disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a restrição observar o disposto no art. 528, § 8.º e no art. 529, § 3.º”.

O CPC traz novidade ainda maior, pois o desconto em folha não se limita mais à prestação de alimentos, mas poderá ocorrer sempre que as importâncias excedam a cinquenta salários mínimos (art. 834, § 2.º c/c art. 528, § 8.º e art. 529, § 3.º do CPC, cf. comentários sobre o art. 834, CPC, *supra*). Como defendemos nos comentários ao art. 834 esta hipótese é a hipótese típica de exceção à regra da impenhorabilidade do salário; poderão, ainda, ocorrer hipóteses atípicas, nos termos do art. 139, IV do CPC, desde que devidamente fundamentadas pelo julgador.

No processo coletivo para tutela do patrimônio público, o afastamento desta regra decorre do microsistema, nos termos do art. 14, § 3.º da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965), assim: “[q]uando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público”.

2. Dever de cooperação e boa-fé de terceiros para a tutela do direito de alimentos. O juiz deverá emitir ordem à autoridade, à empresa ou ao empregador do executado através de ofício para proceder ao desconto em folha de pagamento a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (art. 912, § 1.º do CPC/2015). Trata-se do destinatário do ofício que deverá cumprir a ordem, sob pena de configurar o crime de desobediência (art. 330 do CP). Trata-se de um dever de cooperação e boa-fé processual de terceiro participante do processo, com vistas à tutela do direito (arts. 5.º e 6.º do CPC/2015).

O referido ofício deverá ser preenchido com todas as informações necessárias, a saber: os nomes e o número de inscrição no CPF do exequente e do executado, o valor do montante que será descontado mensalmente, a conta bancária para a qual será realizada a transferência ou o depósito e, se for o caso, o tempo de duração do desconto (art. 912, § 2.º do CPC/2015).

3. Tempo de duração. O art. 912, § 2.º, *in fine*, determina, se for o caso, que seja indicado, no ofício do juiz, o tempo de duração da obrigação alimentícia. O tempo de duração se torna importante em duas situações: a) maioria ou fim da idade universitária do exequente, quando deve cessar o desconto; b) obrigações alimentícias com prazo fixado na sentença ou título executivo extrajudicial como as que normalmente decorrem de ilícito civil. Pode tratar-se, aqui, de um negócio processual realizado entre as partes, estabelecendo até quando subsistirá a prestação de alimentos. No caso do processo de execução de alimentos inaugurado com título executivo extrajudicial, o prazo será o constante do título. Qualquer obrigação que exceder ao título, subsistindo ao prazo nele previsto, deverá ser discutida em ação própria ou repactuada no curso da própria execução.

4. Limite de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos. Novidade do CPC é a possibilidade de se executar os valores vincendos e também os valores vencidos até o limite de cinquenta por cento dos vencimentos do executado. É o que resulta da combinação da disciplina do cumprimento da sentença com o processo executivo (arts. 513 c/c 771 do CPC). Segundo o art. 529, § 3.º do CPC (*“[s]em prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.”*).

5. Protesto do título executivo extrajudicial. Uma das técnicas de coerção indireta ao pagamento adotada pelo CPC é a possibilidade de protesto da decisão judicial transitada em julgado (art. 517 do CPC/2015). No caso da obrigação de pagar alimentos, o texto do art. 528, § 1.º do CPC/2015, é expresso, segundo o qual o juiz *“mandará protestar o pronunciamento judicial”*. Ora, se é possível o protesto do pronunciamento judicial, por força das normas de regência dos registros públicos, também deverá ser permitido o protesto do título executivo extrajudicial (art. 513 c/c 771 do CPC/2015), inclusive por força da possibilidade de determinação de medidas atípicas que se afigurarem adequadas (art. 139, IV do CPC).

Art. 913. Não requerida a execução nos termos deste Capítulo, observar-se-á o disposto no art. 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaiando a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

1. Opção pela expropriação patrimonial. O exequente poderá optar em não usufruir das técnicas processuais executivas do regime especial (prisão civil e desconto em folha de pagamento), hipótese na qual a execução de alimentos seguirá o caminho de expropriação patrimonial do executado (art. 913 c/c 824 do CPC/2015). Esta possibilidade também pode ser verificada, analogamente, no cumprimento de sentença de alimentos (art. 528, § 8.º do CPC/2015).

2. Penhora e levantamento do dinheiro. Nada obstante a opção do credor pela expropriação patrimonial, a natureza alimentícia do débito autoriza o levantamento mensal da quantia relativa à prestação quando houver penhora de dinheiro, mesmo que concedido efeito suspensivo aos embargos (art. 913, *caput* do CPC/2015). Esta exceção justifica-se pela natureza da obrigação alimentícia.

3. Duplicidade de regimes executivos. Pode ocorrer do exequente executar as últimas três parcelas vencidas mediante o procedimento da execução com pedido de prisão civil e os valores vencidos a mais tempo mediante os demais procedimentos, para desconto em folha (art. 912 do CPC/2015) ou para pagamento de quantia certa (art. 824 e ss. do CPC/2015).

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, p. 559/560.

3

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, p. 560.

4

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 844-847.

5

O enunciado da Súmula vinculante 25 do STF “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”, reduziu o âmbito do art. 5.º, LXVII apenas a prisão por dívida decorrente do não pagamento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, objeto destes comentários. É preciso deixar evidenciado, contudo, que o requisito aqui não é o descumprimento da ordem judicial, mas a prisão como meio executivo de cobrança da dívida. Daí restringir a Constituição a “prisão por dívida”. Nada obsta a possibilidade de prisão civil por outros motivos que não a dívida, como por exemplo, a prisão por descumprimento voluntário e inescusável, após o devido processo legal e as tentativas de outros meios coercitivos, por força do descumprimento de ordem determinada pela autoridade judicial (*contempt of court*). Na doutrina, defendendo a prisão civil por *contempt of court* no Brasil, Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. 2, p. 733/738, citando a distinção já existente em Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967* (arts. 153, § 2º-159), 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1971. vol., 5., p. 253; Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela Inibitória*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000; Sérgio Cruz Arenhart, *A Tutela Inibitória da Vida Privada*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 206; Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da Tutela Inibitória Coletiva*, São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 384; Marcelo Lima Guerra, *Execução Indireta*, São Paulo: Ed. RT, 1998, p. 245/246. Como já adiantamos, o art. 139, IV, CPC, como cláusula geral de atipicidade da execução, poderá permitir a prisão civil por descumprimento de ordem judicial – mesmo que proferida em atividade executiva – desde que esta não tenha relação direta com a obrigação de pagar quantia certa.

6

Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual de Execução Civil*, p. 421.

7

Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual de Execução Civil*, p. 421.

8

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 847-848.

Sobre o tema, suas origens romanas e o seu renascimento no direito comum e luso-brasileiro, Ignácio M. Poveda Velasco, *A Execução do Devedor no Direito Intermédio (Beneficium Competentiae)*; Id. *A Execução do Devedor no Direito Romano (Beneficium Competentiae)*, passim.

1

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 844-848; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 911 a 913)*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão online, p. 798-799; Rodolfo Kronenberg Hartmann, Arts. 911 a 913 do CPC, In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1282-1283; Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos, Arts. 911 a 913 do CPC, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas(coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2118-2122; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil Anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 714-715; Marcelo de Faria Câmara, Arts. 911 a 913 do CPC, In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1175-1177; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1285-1287; Humberto Theodoro Jr., *Processo de Execução e Cumprimento de Sentença*, 25. ed., São Paulo: Leud, 2008, p. 389-395; Marcelo Abelha, *Manual de Execução Civil*, 5. ed., Rio de Janeiro, 2015, p. 417-432; Araken de Assis, *Manual de Execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 1295-1307.

Título III. Dos Embargos a Execução

1

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

1. Natureza jurídica dos embargos à execução. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento devido a uma série de características:

a) porque possuem ampla cognição, permitindo que sejam alegadas quaisquer matérias deduzíveis a título de defesa em processo de conhecimento (art. 917 e incisos do CPC/2015, em especial, poderá o executado alegar *“qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”*, art. 917, IV do CPC/2015);

b) porque são oponíveis à execução de título executivo extrajudicial, processo executivo, dada a incompatibilidade procedimental entre a execução e a defesa. Esta incompatibilidade procedimental dá-se em razão de ser o processo de execução um processo de desfecho único (como regra geral de cognição sumária), e, portanto, consistir em ilogicidade permitir a defesa incidental de caráter amplo nos próprios autos a perturbar o resultado almejado. Ademais, os embargos têm amplo espectro, permitindo o questionamento formal e material da execução instaurada;

c) porque distribuídos por dependência, tramitando em apartado (art. 914, § 1.º do CPC/2015), pressupondo a existência de execução lastreada em título executivo extrajudicial, mas sendo dela relativamente independentes. Por exemplo, o art. 775, II do CPC/2015, determina que a desistência, após a oposição de embargos, dependerá da concordância do embargante, quando estes embargos não tratarem apenas de questões processuais.

2. Nomenclatura. A nomenclatura do instituto é tecnicamente mais adequada em relação à expressão “embargos do devedor” utilizada no CPC/1973, porquanto movidos pelo executado (figura do direito processual), e não necessariamente pelo devedor (figura do direito material).² As pessoas do executado e do devedor podem não se confundir, muito embora a regra geral seja a de que será o devedor a responder pela execução com todos os seus bens (art. 789 do CPC/2015, *princípio da patrimonialidade*).

3. Defesas do executado. Os embargos à execução consistem no meio típico de defesa do executado para impugnar a execução de título extrajudicial (STJ, REsp 654.583/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 14.02.2006, DJ 06.03.2006, p. 177). Existem ainda outros institutos hábeis ao exercício de defesa do executado, tais como: a) a petição simples (art. 917, § 1.º

do CPC/2015); b) a exceção de pré-executividade; e, c) a ação impugnativa declaratória ou desconstitutiva autônoma.

4. Simples petição. O executado poderá, através de simples petição, arguir que a penhora ou a avaliação foram realizadas de maneira incorreta (art. 917, § 1.º do CPC/2015). Nos termos do artigo: “A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. O prazo preclusivo para a impugnação por petição autônoma é de quinze dias. A necessidade de prazo diferenciado e de se impugnar por petição avulsa se dá em razão de que já poderá ter transcorrido o prazo para os embargos, quanto for realizada a penhora. Assim, a penhora poderá ser impugnada conjuntamente aos embargos do executado ou em quinze dias a partir da ciência do ato.

5. Exceção de pré-executividade. Trata-se de meio de defesa atípico do executado que poderá ser movida a qualquer tempo para suscitar questões de direito processual cognoscíveis de ofício, como, por exemplo, pressupostos processuais, condições da ação, prescrição, decadência (STJ, AgRg no Ag 775.393/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, j. 21.11.2006, DJ 14.12.2006, p. 272) e questões relativas a fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que documentalmente pré-constituídos (STJ, REsp 745.962/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª Turma, j. 07.06.2005, DJ 05.09.2005, p. 389). Na doutrina, a discussão sobre a terminologia correta foi extensa,³ hoje este não é mais um tema excepcional, tendo sido reconhecida a sua possibilidade amplamente pelos tribunais.

O CPC, nos termos previstos no art. 803, elencou algumas das hipóteses de nulidade da execução, pelo qual não haverá necessidade de oposição de embargos do executado. A nulidade poderá ser requerida por simples petição e pronunciada de ofício. Nos termos do dispositivo: “art. 803. É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II – o executado não for regularmente citado; III – for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” Observe-se ainda que, sendo de ofício, incide aqui a vedação da decisão surpresa, corolário da submissão do juiz ao contraditório como direito de influência e dever de debates, com a necessária intimação das partes para se manifestarem sobre a possível nulidade encontrada. No termos do art. 10 do CPC, “[o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Com a oportunidade de manifestação, as partes poderão apresentar argumentos ou sanar os vícios apontados, evitando a extinção da execução. A medida, de cunho eminentemente prático e dialético, também tem por finalidade a redução dos recursos.

6. Ação impugnativa declaratória ou desconstitutiva autônoma. Trata-se, também, de um meio de defesa atípico do executado, corolário do direito constitucional de ação, que tem por objetivo se antecipar à execução do título executivo e pugnar em caráter preventivo a declaração de sua nulidade ou a inexistência da obrigação dele decorrente (STJ, CC 89.267/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 14.11.2007, DJ 10.12.2007, p. 277). Tratamos do tema mais amplamente nos comentários ao art. 903, § 4.º do CPC/2015, que expressamente reconhece as *ações autônomas* de impugnação: “[a]pós a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”. Lá demos outros exemplos dogmáticos e ampliamos os comentários para todas as ações autônomas de impugnação (cf. comentários ao art. 903, § 4.º).

7. “Embargos de segunda fase”: impugnação à adjudicação e à arrematação (art. 903, §§ 1.º e 2.º). O art. 903, § 1.º prevê que: “[r]essalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução”. Esta impugnação não está prevista nos róis dos arts. 917 e 525 do CPC. Serve, contudo, a ambos. A modalidade de defesa prevista no art. 903, § 1.º

poderá ser aplicada tanto no cumprimento de sentença, quanto no processo de execução. O juiz decidirá a impugnação se for provocado até dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

Esta previsão substitui o antigo instituto dos embargos à arrematação e à adjudicação, também chamados “*embargos de segunda fase*”, por serem posteriores à penhora e à avaliação e não poderem tratar de matéria já preclusa.

Portanto, trata-se de defesa em relação a ato específico do procedimento executivo relacionado à adjudicação ou à arrematação do bem. Somente os atos executivos posteriores à penhora e à avaliação poderão ser objeto destes embargos, reconhecendo a doutrina que os atos anteriores estariam preclusos. Poderiam ser alegados ainda vícios para os quais não há que se falar em preclusão. Nestes termos: “[a]ssim, só os atos executivos da arrematação e adjudicação, além é claro de vícios outros de ordem pública sobre a validade e regularidade do procedimento (art. 518).”⁴

Esta impugnação pode ensejar a desistência do arrematante ou adquirente do bem. Basta, para tanto que este, uma vez tomando conhecimento da impugnação, assim se manifeste, nos termos do art. 903, § 5.º (“[o] arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: [...] II – se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1.º [...]”).

Caso isto ocorra, haverá necessária responsabilidade objetiva do impugnante temerário. A condenação será por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das perdas e danos, pois, segundo o art. 903, § 6.º: “[c]onsidera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.” (cf. comentários ao art. 903).

8. Desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos. Os embargos à execução podem ser movidos a despeito de penhora, depósito ou caução (art. 914, *caput* do CPC/2015). Porém, a atribuição de efeito suspensivo exige como um de seus requisitos que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1.º do CPC/2015). O STJ, contudo, decidiu sobre a sistemática de julgamento de casos repetitivos que a dispensa da garantia, como condicionante dos embargos, *não se aplica às execuções fiscais* em decorrência de dispositivo específico que expressamente a exige: o art. 16, § 1.º, da Lei 6.830/1980 (STJ, EDcl no AREsp 637.447/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 06.10.2015, *DJe* 14.10.2015). Nos termos do dispositivo do art. 16, § 1.º, da Lei 6.830/1980: “[n]ão são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

9. Distribuição por dependência, autuação em apartado e instrução com cópia de documentos relevantes. Os embargos serão distribuídos por dependência e autuados em apartado à execução contra a qual se insurge o executado (art. 914, § 1.º do CPC/2015). A conexão entre a execução e os embargos define a competência funcional absoluta do juiz, que processa a execução para julgamento dos embargos do executado.

A autuação em apartado é determinação que visa eliminar eventual confusão entre os atos da execução e dos embargos, mormente considerando a possibilidade de que atos executivos continuem sendo realizados, em virtude de não ter sido postulado ou concedido efeito suspensivo aos embargos. Ademais, os embargos serão instruídos com cópias das peças processuais relevantes ao seu julgamento (art. 914, § 1.º do CPC/2015). Esta medida se impõe por ser necessária à organização do processamento do feito, com vistas, inclusive, à eventual fase recursal, na qual os embargos poderão ser remetidos ao tribunal para julgamento sem a remessa da execução.

Como o dispositivo não especificou quais documentos serão considerados relevantes para o processamento dos embargos, caberá ao juiz oportunizar seja promovida a juntada de documentos que não constam nos embargos e que considera relevantes. Trata-se de um dever de auxílio, por força do princípio da cooperação (arts. 6.º e 321 c/c 318, parágrafo único do CPC/2015).

Porém, é possível verificar, desde logo, algumas peças essenciais à propositura dos embargos tais como: a) cópia da petição inicial da ação de execução; b) as procurações dos advogados do embargante e do embargado; c) o ato de citação do embargante e certidão da sua respectiva juntada; d) o auto de penhora, avaliação e depósito,⁵ quando houver.⁶

10. Declaração de autenticidade das peças e responsabilidade pessoal do advogado. O advogado poderá declarar a autenticidade das peças processuais que instruirão os embargos, sob pena de sua responsabilização pessoal (art. 914, § 1.º do CPC/2015). Caso não queira assumir o dever de veracidade, poderá autenticar as peças em cartório, com a certificação de que conferem com os originais por parte do servidor público. Na prática é muito mais rápido e prático creditar a fidedignidade ao advogado. Não se trata de novidade, mas de valorização da responsabilidade profissional do advogado que foi introduzida no ordenamento processual com a alteração do art. 365, IV do CPC/1973, alterado pela Lei 11.382/2006. Esta disposição foi mantida integralmente pelo art. 425, IV do CPC/2015, segundo o qual *“as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade”*, farão a mesma prova que os originais.

11. Execução por carta precatória. A necessidade da execução por carta precatória é uma decorrência da necessidade de se localizarem bens do executado capazes de suportar a execução. A execução será feita por carta sempre que o executado não tiver bens no foro do processo (art. 845, § 2.º do CPC/2015). Havendo bens no foro do processo em quantidade suficiente para suprir a execução, estes serão preferidos em relação aos demais.

Há, contudo, regras alusivas à propositura e competência para julgamento dos embargos: a) a propositura dos embargos será possível tanto no juízo deprecante quanto no juízo deprecado (art. 914, § 2.º, primeira parte, do CPC/2015); b) a competência para julgamento dos embargos: b.1) via de regra, será do juízo deprecante; b.2) excepcionalmente, quando versarem sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens no juízo será do juízo deprecado (art. 914, § 2.º, segunda parte, do CPC/2015).

O dispositivo em questão confirma o entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 46 do STJ, segundo o qual: “na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens”. O julgamento do enunciado da súmula ocorreu pela Corte Especial do STJ em 13.08.1992, com somente agora sua incorporação a legislação processual. Como já afirmamos, é muito salutar, quando o precedente é replicado pelo legislador, passando então a substituir a vinculação do precedente pela vinculação à lei, em homenagem ao princípio da legalidade.

Assim, caso uma execução esteja sendo processada na cidade de Vitória (ES) e o executado tenha bens somente em Porto Alegre (RS), eventuais embargos, via de regra, deverão ser opostos pelo executado na cidade de Vitória (ES). Porém, se os embargos impugnarem a penhora, avaliação ou alienação de bens, deverão ser opostos em Porto Alegre (RS).

É bom lembrar que excepcionam-se as hipóteses de comarcas contíguas, de fácil comunicação e naquelas pertencentes a mesma região metropolitana (art. 782, § 1.º do CPC/2015).⁷ Nestas hipóteses, não haverá necessidade de expedição de carta para o cumprimento dos atos executivos, concentrando-se no mesmo juízo.

A doutrina entende que a incompetência neste caso não gera a extinção, devendo ser alegada no prazo de quinze dias, e, caso reconhecida, remetidos os autos ao juiz competente. O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4.º do CPC/2015) orienta no sentido de que não será reconhecida a incompetência do juízo, se for possível a análise da causa, valendo a regra geral também para a execução. Assim, incidem os arts. 64, §§ 3.º e 4.º e 340, § 1.º do CPC, segundo os quais: a) caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente, sempre que possível com o aproveitamento dos atos praticados pelo juiz incompetente; b) *a contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa*. O embargante poderá ajuizar os embargos tanto no juízo deprecante, quanto

no juízo deprecado. O ônus de indicar correta e precisamente o juízo em que os embargos serão decididos não pesa, portanto, integralmente sobre o embargante, não tendo consequências peremptórias. Assim, “não tem o embargante o ônus de indicar correta e precisamente o juízo em que os seus embargos serão decididos. Poderá ajuizá-los tanto no juízo deprecante quanto no juízo deprecado. Caberá aos juízes a tarefa de verificar o juízo competente para julgar os embargos. Eventual erro na distribuição dos embargos autoriza as partes a alegarem a incompetência do juízo, no prazo de quinze dias, a partir do ato que atribuiu a um dos juízes a competência para julgá-los, aplicando-se aqui, de forma analógica, o que preveem os arts. 64 e 340 do CPC”.⁸

12. Inexistência de diferenciação ontológica na oposição: diferenças de extensão pela natureza do título e pelo direito material afetado. É preciso analisar a profundidade da distinção entre título judicial e extrajudicial, para saber se a defesa propiciada nos embargos altera-se com a natureza do título. Para Salvatore Satta, *não há diferença ontológica entre o título judicial e o título extrajudicial* para fins de defesa do executado. Aderimos ao mesmo entendimento.

Prova disso é que *a)* de um lado o *direito a proceder com a execução forçada é assegurado por um título*. Aqui, vale lembrar o que já vimos na introdução a este trabalho, sobre a fundamentação histórica da passagem através dos conceitos de *executio parata* (execução aparelhada) e de *instrumenta guarentegiata* (instrumentos de confissão reconhecidos em cartório) surgidos na idade média a partir do desenvolvimento da noção de *executio per officium iudicis* (poder de execução atribuído ao juiz, como desdobramento de suas atribuições, cf. introdução, 2.3).

De outro, que *b)* a *defesa prevista na lei precisa propiciar os instrumentos necessários para a destruição do título* (ou a limitação da atividade processual sobre determinados bens e valores), em condições de permitir resistir a execução forçada por razões pertinentes ao direito material ou processual.

Nas palavras de Satta: “[...] la dottrina comune parte da uma contrapposizione tra diritto e titolo, cioè da um dualismo che non esiste se non nell’astrazione. Nel concreto il titolo esecutivo appartiene alla dinamica del diritto, senza la quale neppure si può concepire: esso è il diritto, quale risulta dalla attribuzione che la legge fa a determinati atti dell’azione esecutiva, onde giustamente si può e si deve dire che chi ha il titolo ha il diritto [...] In altre e più semplice parole, nella dinamica del concreto bisogna distruggere il titolo per impedire che il concreto si determini attraverso l’azione: e a questo tende l’opposizione all’esecuzione, termine assai proprio, perché nella sua concretezza quel che chiamiamo diritto non è che il diritto a procedere all’esecuzione forzata”.⁹

Por exemplo, quanto à impenhorabilidade, a defesa poderá ser afastada em razão da natureza da obrigação consistente no título. Isto porque não há abstração causal como regra nos títulos executivos. A regra é exatamente a oposta. Respeita-se a causalidade na alegação de impenhorabilidade (relação entre direito material e o título dele originário) e, portanto são penhoráveis os bens adquiridos ou em razão dos quais se adquiriu a dívida. Nos termos do Código, “[a] impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição” (art. 833, § 1.º, CPC/2015).

Outro exemplo importante diz respeito à causalidade do título. A causalidade será importante apenas nos títulos de crédito que não circularam. Naqueles que circularam, as defesas pessoais e referentes à relação jurídica material que deu ensejo ao título, não poderão ser levantadas.¹⁰ Assim, os embargos à execução fundados em título executivo extrajudicial cambial ou cambiariforme, nos termos do art. 784, I do CPC (títulos de crédito: a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque),¹¹ que circularam para terceiros, tem cognição parcial, ou seja, cognição horizontalmente limitada e exauriente. A limitação da cognição deriva da necessidade da abstração da *causa debendi* para a tutela dos terceiros adquirentes do título. Assim, por força do direito material, há impossibilidade de alegação de defesas pessoais e causais.

Por esta razão, correta a crítica da doutrina que aponta como um dos problemas na atividade executiva no Brasil, decorrente do não reconhecimento da atividade judicial de controle durante a

execução, resulta da “indevida generalização do requisito da abstração, presente apenas nos títulos de crédito não causais, para todos os títulos executivos”.¹²

13. Binômio conhecimento-execução e a defesa do executado. A evolução histórica da execução, já abordada na introdução a este volume (cf. 2.3), resulta de três movimentos distintos em relação à precedência da atividade cognitiva à atividade executiva.¹³

Temos assim o a) *momento romano*, com a necessidade de esgotamento prévio do conhecimento e de ajuizamento de uma nova ação (*actio iudicati*), caso não houvesse o adimplemento específico, com oportunidade de defesa; o b) *momento germânico*, com a precedência da execução ao conhecimento e, na idade média, com o surgimento dos *instrumenta guarentegiata* e das *lettres obligatoires* com novas formas de dispensa do processo de conhecimento por força da confissão perante o notário (*confessus in iure habetur pro condemnato*); e o c) a evolução para a convergência, na qual, ao legislador, cabe escolher os casos em que é necessário ou não a atividade de conhecimento prévia e, não existindo esta atividade, a previsão de meios de impugnação adequados.

Neste sentido, podemos falar de a) *princípio-tese* – direito romano – só se executa, forçadamente, a pretensão, depois de ter havido cognição completa e coisa julgada “princípio da executabilidade forçada dependente da cognição completa” (título executivo judicial); b) *princípio-antítese* – títulos instrumentais, com força de confissão, surgidos a partir do séc. XIII, com a necessidade de diminuir a interposição do Estado para *conhecer* as disputas na era comercial mercantilista que se iniciava. Permitiam a execução imediata independentemente de cognição;¹⁴ c) *síntese* – diferentes soluções que as leis processuais adotam para atender a regulação da execução sem completa cognição, com definição ou enumeração de casos de cognição incompleta que formem títulos executivos extrajudiciais, permitindo a atividade executiva de forma direta com posterior abertura para a defesa.¹⁵

Assim, ao unificar o procedimento de execução para os títulos judiciais e extrajudiciais, o legislador do CPC/1973 conferiu uma importância extraordinária à cognição para conceber procedimentos diferenciados para a mais efetiva tutela dos direitos, inclusive na execução.¹⁶ Naquela época, a interposição dos embargos necessitava de penhora – a garantia do juízo, e sua mera interposição, uma vez garantido o juízo, era suficiente para suspender o processo de execução, criando lides imortais, pois extremamente morosas.

Com as reformas, contudo, já no início da década de 1990 e depois em 2005 e 2006, ocorreu um rompimento da “autonomia processual” como técnica isoladora das funções jurisdicionais¹⁷ (Livro I – cognição; Livro II – execução; Livro III – cautelar), pensada por Alfredo Buzaid. Isso acarretou como consequência uma radical mudança de mentalidade. Passaram-se a admitir as defesas independentemente da segurança do juízo e não era mais uma consequência natural a suspensão dos embargos, dependendo o efeito suspensivo da demonstração dos requisitos de urgência: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, necessários à cautela/antecipação de tutela em favor do devedor.

O CPC/2015 mantém o mesmo sentido das reformas, mas permite atividades atípicas dentro do procedimento de execução para pagar quantia e, até mesmo, em substituição ao procedimento típico. Agora, com o art. 139, IV, CPC, nos casos em que, adequadamente comprovada a necessidade de interferência no rito, poderá ser incrementada a aceleração por atipicidade também do processo de execução de título extrajudicial para pagamento de quantia certa.

Assim, muito embora seja ofertada a oportunidade de defesa ao executado, esta não altera a finalidade do processo de execução (e da atividade executiva em geral), sendo a sua possibilidade uma decorrência do devido processo legal (processo justo, *fair trail*, *giusto processo*, *procès équitable*). Neste sentido, não se inverte a presunção legal do título apenas pelo exercício da defesa. A defesa não resulta, necessariamente, em uma preferência da cognição instaurada com os embargos sobre a execução, porque, se houvesse preferência, deveria ser interrompida a tramitação do processo de execução em todas as hipóteses. Ao contrário, continua-se com a preferência da execução, inclusive permitindo-se o encerramento da execução, ainda que não encerrados os meios de defesa. Pode-se dizer, portanto, que, nos casos em que a lei prevê atividade

executiva, a defesa (exceção de pré-executividade, embargos à execução, petição simples ou ação autônoma) não gera, por si só, uma preferência pela cognição por ela instaurada. Há preferência, como regra geral, da atividade executiva, sem a supressão do contraditório pelos meios disponíveis.¹⁸

Ademais, assim como não há mais um processo autônomo e abstrato de conhecimento, pois existe a possibilidade de concessão de tutela antecipada, antes mesmo do título executivo ser formado. Trata-se de atuação satisfativa do direito do autor ainda no processo de conhecimento. Também não há mais autonomia e abstração do processo de execução, pois este admite cognição, naquilo que for necessário, ao exercício da tutela do direito de crédito ou ao direito de defesa do executado.¹⁹

Na doutrina, a presença contínua das atividades de cognição em execução foi bem marcada, “[n]ão há distinção ontológica entre ‘ação de conhecimento’ e ‘ação de execução’ o que existe, ao contrário, é uma preponderância da atividade executiva ou da atividade de conhecimento, conforme o caso. Assim, se “por um lado as atividades executivas já haviam penetrado a seara do chamado ‘processo de conhecimento’, sobretudo por força de tutelas provisórias, a presente tese se propôs a percorrer o caminho inverso e a detectar a existência das atividades cognitivas em sede de execução, por meio da identificação e do tratamento do objeto litigioso”.²⁰

14. Juízo Arbitral e Embargos. Dois enunciados do FPPC destacam-se em relação à arbitragem e às matérias de defesa que podem ser alegadas, são eles: Enunciado 543 do FPPC (“*Em execução de título executivo extrajudicial, o juízo arbitral é o competente para conhecer das matérias de defesa abrangidas pela convenção de arbitragem*”); Enunciado 544 do FPPC (“*Admite-se a celebração de convenção de arbitragem, ainda que a obrigação esteja representada em título executivo extrajudicial*”).

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.

§ 2º Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado:

I – da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens;

II – da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4º deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo.

§ 3º Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229.

§ 4º Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.

1. Prazo para oposição de embargos. É de 15 (quinze) dias o prazo para oposição de embargos (art. 915, *caput* do CPC/2015). O termo inicial do referido prazo fluirá: a) a partir da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando feita pelo correio (art. 231, I do CPC/2015);²¹ b) da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando feita por oficial de justiça (art. 231, II do CPC/2015); c) da data de ocorrência da citação, quando feita por ato do escrivão ou chefe de secretaria (art. 231, III do CPC/2015); d) do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando feita por edital (art. 231, IV do CPC/2015); e e) do dia útil seguinte à consulta e ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta, quando feita

eletronicamente (art. 231, V do CPC/2015).

2. Litisconsórcio e contagem do prazo. Em regra, a contagem do prazo para oposição de embargos à execução é individual, razão pela qual o termo inicial para cada qual é assinalado a partir da data de juntada do respectivo comprovante de citação (art. 915, § 1.º, primeira parte do CPC/2015).

Porém, caso os embargantes sejam cônjuges ou companheiros, o termo inicial será contado a partir da data de juntada do último comprovante de citação (art. 915, § 1.º, segunda parte do CPC/2015).

Ademais, em caso de haver litisconsortes com diferentes procuradores, não se aplica o prazo em dobro para oposição de embargos tal qual no processo de conhecimento (art. 915, § 3.º do CPC/2015), tendo em vista a natureza de ação autônoma.²²

3. Execuções por carta precatória. As execuções por carta precatória possuem um regime especial de contagem de prazo para oposição de embargos.

Nos casos em que os embargos impugnarem exclusivamente a penhora, avaliação ou alienação dos bens, o prazo de 15 (quinze) dias será contado a partir da juntada da certificação da citação na carta precatória (art. 915, § 2.º, I do CPC).

Nos demais casos, o prazo de 15 (quinze) dias será contado: a) a partir da data de juntada do comunicado da citação nos autos de origem do processo de execução, conforme o art. 915, § 4.º do CPC/2015; b) a partir da data de juntada da carta precatória devidamente cumprida (art. 915, § 2.º, II do CPC/2015).

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos *docaput*, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.

§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos.

§ 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora.

§ 5º O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:

I – o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos;

II – a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas.

§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos.

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

1. Parcelamento. Trata-se de uma hipótese específica de remição da execução, a qual já estudamos nos comentários ao art. 826 do CPC/2015, que traz o regime geral de remição. Regularmente citado, o executado poderá reconhecer o crédito exequendo constante do título

executivo extrajudicial no prazo de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos e requerer o seu respectivo parcelamento (art. 916, *caput* do CPC/2015). Outrossim, como aponta o Enunciado 331 do FPPC, “*o pagamento da dívida objeto de execução trabalhista pode ser requerido pelo executado nos moldes do art. 916*”, dessa forma, também poderá ser aplicada na Justiça do Trabalho a disposição prevista no art. 916 do CPC/2015, em consonância com o art. 15 do CPC/2015.

A rigor, o dispositivo em questão não deveria estar topologicamente situado dentro do espaço destinado aos embargos, visto não se tratar de uma defesa do executado, mas de técnica processual cujo objetivo é estimular o executado a reconhecer o crédito e promover o seu respectivo pagamento.²³ É, portanto, uma medida indutiva.²⁴

Não à toa, a possibilidade de parcelamento do crédito restringe-se às execuções de título executivo extrajudicial (art. 916, § 7.º do CPC/2015). Quanto ao cumprimento de sentença, o eventual reconhecimento e parcelamento do crédito mostra-se incompatível pelo fato de tal fase já pressupor uma definição acerca da obrigação na qual o título executivo judicial funda-se com ampla cognição e respeito às garantias do devido processo legal.

Por fim, o exercício da opção pelo executado do parcelamento do crédito implica renúncia ao direito de discuti-lo, seja através de embargos, de exceção de pré-executividade ou de ação autônoma (art. 916, § 6.º do CPC/2015).

2. Requisitos legais. O executado deve cumprir 04 (quatro) exigências previstas no dispositivo legal (art. 916, *caput* do CPC/2015): a) reconhecer o crédito exequendo constante do título executivo extrajudicial; b) comprovar o depósito de 30% (trinta) por cento do valor da execução devidamente atualizado e acrescido de custas processuais e honorários advocatícios; c) requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 (seis) prestações acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e correção monetária (art. 916, *caput*, CPC); d) realizar todos estes atos no prazo de 15 (quinze) dias previstos para opor embargos.

3. Decisão de deferimento ou indeferimento. O juiz deverá intimar o exequente para se manifestar sobre o cumprimento dos requisitos exigidos ao parcelamento do crédito, medida que se impõe em respeito ao contraditório e ampla defesa do exequente (art. 9.º e 10 do CPC/2015).

Considerando que o dispositivo legal silenciou em relação à duração, a manifestação do exequente deverá ser feita em 05 (cinco) dias (art. 218, § 3.º do CPC/2015) e, de regra, limitar-se-á ao preenchimento dos pressupostos legais do parcelamento.

Após o transcurso do prazo ou da manifestação anterior do exequente, o juiz proferirá decisão sobre o requerimento de parcelamento do crédito em 05 (cinco) dias (art. 916, § 1.º do CPC/2015).

Neste período em que o juiz ainda não tenha decidido, o executado deverá continuar depositando as parcelas vincendas e o exequente poderá levantar as quantias depositadas (art. 916, § 2.º do CPC/2015). Trata-se de previsão normativa que contribui a um processo jurisdicional mais célere ao permitir a satisfação do crédito, máxime porque o crédito já foi reconhecido expressamente pelo executado (art. 4.º do CPC/2015). Este levantamento parcial deve ser considerado pagamento parcial e é facultado ao exequente, podendo ser autorizado pelo julgador. No entanto, o deferimento do requerimento como um todo pelo juiz é imprescindível ao levantamento definitivo do dinheiro a ser depositado e para a suspensão dos atos executivos (art. 916, § 3.º do CPC).

De outro giro, o requerimento será indeferido, caso o executado não cumpra qualquer um dos quatro requisitos legais mencionados no *caput* do art. 916 do CPC/2015, sendo que os atos executivos continuarão a ser praticados e o depósito já efetuado será convertido em penhora (art. 916, § 4.º do CPC) ou considerado parte do pagamento se já levantado.

4. Discordância do exequente e máxima efetividade da execução. Poderá ocorrer que a penhora sobre o valor total já tenha sido realizada *online*, em dinheiro, antes da oportunidade da remição. Poderá ocorrer ainda outras situações que ensejem ao exequente um evidente prejuízo

no aguardo da quitação parcelada, quando já for possível divisar a capacidade do executado de solver integralmente a dívida.

Nestes casos, extraordinários com certeza, será possível ao juiz, em observância do princípio de que a execução se faz no interesse do credor, sendo a atividade executiva voltada para a tutela do crédito, adequada, efetiva e tempestiva e desde que devidamente fundamentado, determinar a inadmissibilidade do parcelamento, utilizando-se dos seus deveres-poderes (art. 139, IV do CPC). Garantindo, assim, a efetividade da atividade executiva.

O problema já havia sido apontado pela doutrina: “excepcionalmente é possível que o juiz indefira o pedido de remição parcelada feito pelo executado, ainda que este tenha preenchido os requisitos objetivos descritos no dispositivo legal, desde que o exequente se manifeste contrariamente à remição pretendida e demonstre que o parcelamento é medida que lhe ofertará um resultado pior do que aquele que ele tem ou terá em menor tempo com a atividade executiva, por exemplo, nos casos em que o pedido de remição da execução seja feito após a penhora (completa) de dinheiro do executado, tal como acontece nas execuções contra bancos para valer-se de exemplo mais comum”.²⁵

5. Inadimplemento e sanções. Eventual inadimplência do executado em relação às prestações importará, de maneira cumulativa (art. 916, § 5.º do CPC/2015), no seguinte: a) no vencimento das prestações subsequentes e a retomada dos atos executivos do processo; b) na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações em aberto.

Além do mais, o executado está proibido de embargar da execução, decorrência da preclusão lógica oriunda do reconhecimento do crédito e deferimento do parcelamento (art. 916, § 6.º do CPC/2015).

Também não caberá o ajuizamento de ação de impugnação autônoma. Entendemos que, caso ocorra, trata-se de comportamento contraditório o ajuizamento de ação autônoma posterior ao inadimplemento, uma vez que já requerido o parcelamento. Assim, sendo este comportamento contrário à boa-fé objetiva (art. 5.º do CPC/2015) e inadmissível a ação.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I – inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II – penhora incorreta ou avaliação errônea;

III – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV – retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI – qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I – o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II – ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III – ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV – o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V – o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I – serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II – serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5º Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.

§ 6º O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7º A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

1. Cognição dos embargos. Em razão da natureza de ação dos embargos à execução, o seu conteúdo pode versar sobre toda e qualquer matéria que seria lícito ao embargante deduzir como defesa em processo de conhecimento (art. 917, VI). O art. 917 elenca um rol de matérias típicas a serem arguidas em sede de embargos, mas o rol é meramente exemplificativo.

Há casos em que o direito material impõe um corte na cognição dos embargos, como no caso de execuções fundadas em títulos de crédito que tenham eventualmente circulado (cf. comentários ao art. 914, *supra*). Nestas hipóteses, será vedada discussão sobre a causa subjacente ao título, em prestígio à abstração e autonomia que lhe são inerentes (art. 22, Lei Uniforme de Genebra; STJ, 4ª Turma, REsp 2.814/MT, Rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, j. 19.06.1990, DJ 06.08.1990, p. 7.342).²⁶

2. Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação. A primeira matéria de defesa prevista legalmente é a alegação de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação (art. 917, I do CPC/2015). Estas questões transitam em planos distintos: a inexequibilidade trata de aspectos processuais do título executivo e a inexigibilidade trata de aspectos materiais do título executivo.

No primeiro caso, a alegação de inexequibilidade do título estaria calcada na ausência de características essenciais para que um título executivo extrajudicial fosse classificado como tal. É o que se vê, por exemplo, das hipóteses em que não preenchidas as características exigidas pela lei para a formação de título executivo, lhe faltando as características de título previsto no art. 784 do CPC.

No segundo caso, a alegação de inexigibilidade da obrigação se concentraria na falta de requisitos essenciais da relação obrigacional, como a sua respectiva liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC/2015.

A doutrina afirma que a defesa baseada no art. 917, I, do CPC/2015, em suma, impugna “um dos requisitos de formação e desenvolvimento válido do processo executivo, demonstrando que o exequente simplesmente não tem direito à atividade jurisdicional satisfativa com base naquele

documento”.²⁷

3. Penhora incorreta ou avaliação errônea. A segunda matéria de defesa prevista legalmente é a alegação de penhora incorreta ou avaliação errônea (art. 917, II do CPC/2015).

A penhora pode ser realizada de maneira equivocada, com excesso ou impondo constrição a bem impenhorável (art. 833 do CPC/2015). De igual modo, a avaliação do bem penhorado pode não guardar correspondência com o seu valor real.

Há possibilidade de suscitar a incorreção da penhora ou da avaliação (e tão somente esta matéria) após o transcurso do prazo de embargos que o executado possui. Neste caso, deverá o mesmo suscitar as questões acima mencionadas mediante simples petição no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência do ato (art. 917, § 1.º do CPC/2015).

4. Excesso na execução. A terceira matéria de defesa prevista legalmente é a alegação de excesso na execução (art. 917, III, primeira parte, do CPC/2015).

O art. 917, § 4.º, do CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para verificar o excesso na execução, a saber: a) quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (tutela do direito de crédito); b) quando a execução recai sobre coisa diversa daquela declarada no título (tutela do direito à coisa); c) quando a execução se processa de modo diferente do que foi determinado no título (tutela de imposição de fazer ou não fazer); d) quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado (inexigibilidade da obrigação); e) quando o exequente não prova que a condição se realizou (inexigibilidade da obrigação).²⁸

O Código veda a afirmação genérica de excesso na execução. Por tal razão, na hipótese em que o exequente pleiteia quantia superior à constante do título, deverá indicar na petição inicial o saldo excedente e apresentar demonstrativo discriminando o valor atualizado de seu cálculo (art. 917, § 3.º, do CPC/2015).

Este dever de apresentação discriminada do cálculo, inclusive, se estende à Fazenda Pública (STJ, AgRg no REsp 1095610/RS, 2ª Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 01.09.2009, *DJe* 16.09.2009; (REsp 1085948/RS, 6ª Turma, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, j. 16.06.2009, *DJe* 01.07.2009). Ademais, o STJ já se manifestou que “a ausência de apresentação da planilha atualizada do débito, por si só, não acarretará o indeferimento liminar dos embargos do devedor” (AgRg no AREsp 261.207/PE, 3ª Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 14.05.2013, *DJe* 03.06.2013).

Esta medida impõe-se como um consectário da boa-fé processual (art. 5.º, do CPC/2015), evitando-se alegações temerárias e infundadas com o objetivo de tornar o processo mais tempestivo²⁹ e voltado para o seu escopo primordial: a tutela do crédito. Não por acaso, o art. 917, § 4.º, do CPC/2015 estabelece que, não indicado precisamente o *quantum* excedente, os embargos serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, quando esta for a única alegação; ou serão processados em relação a outro fundamento, dispensada a análise da alegação de excesso na execução, quando houverem outros fundamentos.

O STJ já se manifestou que “o pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (...) e de excesso de execução (...) com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito” (REsp 1365596/RS, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 10.09.2013, *DJe* 23.09.2013).

5. Cumulação indevida de execuções. A quarta matéria de defesa prevista legalmente é a alegação de cumulação indevida de execuções (art. 917, III, segunda parte, do CPC/2015).

O regime jurídico aplicável ao presente caso é ditado pelo art. 780 do CPC/2015, cuja redação autoriza a cumulação de execuções desde que: a) os executados sejam os mesmos; b) o mesmo órgão jurisdicional seja competente para o processamento e julgamento; c) o procedimento seja

idêntico.

No caso das execuções propostas contra diferentes executados, deverá ser fornecido prazo ao exequente para dizer com qual ação prosseguirá a perseguição do seu crédito. No caso de execução formulada em juízo absolutamente incompetente ou que está utilizando inadequadamente o procedimento, esta deverá ser extinta.³⁰

Quanto ao procedimento ser idêntico, a regra no CPC ainda é a do modelo germânico, estudado na introdução (cf. 2.4), quando analisamos os modelos comparados a partir dos meios executivos disponíveis.³¹ Assim, para fins de procedimento, para cada espécie de obrigação, existe uma espécie de execução (modelo germânico).

Este é o caso, por exemplo, de cumulação de execuções de obrigações de pagar quantia certa com execuções de obrigações de fazer ou não fazer, que estaria vedada pelo dispositivo (arts. 917, III c/c 780, *in fine*, do CPC/2015).

Caso os embargos sejam julgados procedentes com base na alegação de cumulação indevida de execuções; entendemos, contudo, que não se deve extinguir a execução, pois o dever de cooperação impõe que seja assinalado prazo ao exequente para que exerça uma opção entre as execuções indevidamente cumuladas (art. 6.º, do CPC/2015).³²

Somente a inércia do exequente importa, aí sim, a extinção completa da execução.

Gostaríamos de ir um pouco além, nesta matéria, por duas razões: a) a existência de atipicidade potencial dos meios executivos (cf. introdução, 2.14 e 2.15); b) a insubsistência da autonomia e abstração da execução em relação ao processo de conhecimento e a obrigação que deu origem ao título. Assim, diante da atipicidade dos meios executivos (art. 139, IV, do CPC/2015) e da possibilidade de conversão de um procedimento de execução em outro, por exemplo na impossibilidade de prosseguir com a execução específica ou pelo resultado prático equivalente (e.g., art. 823, parágrafo único, do CPC/2015), a regra da impossibilidade de cumulação de execuções com ritos distintos tende a ser progressivamente superada. Esta regra era muito importante, quando os procedimentos eram estanques e o padrão era a conversão em dinheiro e o procedimento para expropriação. Hoje a incongruência de não ser permitida a cumulação de execuções com ritos distintos, revela-se inclusive pela falta de autonomia e abstração da atividade executiva em relação ao processo de conhecimento. Se é possível cumular pedidos condenatórios e de obrigação de fazer e não fazer no processo de conhecimento, é incongruente não permitir a execução para cumprimento de sentença (execução fase) no mesmo procedimento, quando a sentença, ao mesmo tempo, reconhece obrigação de fazer e de pagar quantia certa. Nesse caso, deveria ser possível progredir na execução de ambas obrigações conjuntamente. O mesmo se diga em relação aos títulos executivos extrajudiciais que permitem a cumulação das obrigações. Somente se o caso concreto justificar a separação, o magistrado determinará o prosseguimento daquela execução que estiver mais adiantada, extinguindo a outra, de forma que a parte a proponha em procedimento autônomo. Em nenhuma hipótese, poderá o magistrado extinguir ambas as execuções (art. 4.º CPC/2015), sob pena de atentar contra a economia processual e efetividade do processo.

6. Retenção por benfeitorias. A quinta matéria de defesa prevista legalmente é a alegação de retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa (art. 917, IV, do CPC/2015).

O direito de retenção de um bem por benfeitorias nele realizadas está encartado nos arts. 96, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, do CC/2002. São úteis as benfeitorias que “aumentam ou facilitam o uso do bem” (art. 96, § 2.º, do CC/2002); são necessárias as benfeitorias que “têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (art. 96, § 3.º, do CC/2002).

A execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa está regulada pelos arts. 806 a 810 do CPC/2015. O executado será citado com ordem de busca e apreensão ou imissão na posse do bem, momento no qual poderá exercer o seu direito de retenção do bem por benfeitorias em sede

de embargos, devendo individualiza-las e descrevê-las (STJ, REsp 4.073/SP, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 30.10.1990, *DJ* 19.11.1990, p. 13.260).

Diante dos embargos de retenção por benfeitorias,³³ é facultado ao exequente: a) pugnar a compensação do valor das benfeitorias com o valor dos frutos e dos danos devidos pelo executado (arts. 368 a 380, do CC/2002). O juiz, caso assim ocorra, deverá nomear o perito competente para apuração dos valores, na forma do art. 464 do CPC/2015 (art. 917, § 5.º, do CPC/2015); b) ser imitado na posse da coisa, desde que prestada a caução suficiente ou depositada a quantia devida pelas benfeitorias ou produto da compensação (art. 917, § 6.º, do CPC).

7. Incompetência absoluta ou relativa. A sexta matéria de defesa prevista legalmente é a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (art. 917, V, do CPC/2015).

Sob a égide do CPC/1973, havia dúvida se a matéria relativa à incompetência do juízo deveria ser alegada através de embargos ou de exceção de incompetência (arts. 741, VII; 742, do CPC/1973). Agora, com o CPC/2015, a discussão está encerrada.

O executado poderá arguir a incompetência do juízo da execução nos embargos, seja ela absoluta ou relativa. A incompetência absoluta é cognoscível de ofício pelo juiz (art. 64, § 1.º, do CPC/2015), mas é questão que deve ser submetida ao contraditório, evitando-se a decisão surpresa (art. 10, do CPC/2015).

8. Qualquer matéria. Por fim, o dispositivo ora analisado deixa claro que o executado poderá alegar em sede de embargos à execução qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento (art. 917, VI, do CPC).

Pode-se alegar, assim, tanto questões de direito material, como também de direito processual. Como se manifestou o STJ: “a matéria dos embargos à execução por título extrajudicial é muito ampla (...), não sendo possível o veto judicial genérico” (STJ, REsp 172.750/SC, 3ª Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j. 24.06.1999, *DJ* 09.08.1999, p. 167).

9. Impedimento e suspeição. Quanto à alegação de impedimento ou suspeição, o art. 917, § 7.º, do CPC/2015, reflete a opção pelo processamento em incidente apartado, nos termos dos arts. 146 a 148 do CPC/2015. Alegações neste sentido, portanto, não são oponíveis em sede de embargos à execução, mas por incidente.

10. Matéria de Defesa. “Processo civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-C, do CPC. Processo judicial tributário. Embargos à execução fiscal. Compensação tributária pretérita alegada como matéria de defesa. Possibilidade. Artigo 16, 3º, da LEF, C/C artigos 66, da Lei 8.383/91, 73 e 74, da Lei 9.430/96. 1. A compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo do contribuinte (oponível em sede de embargos à execução fiscal), em havendo a concomitância de três elementos essenciais: (i) a existência de crédito tributário, como produto do ato administrativo do lançamento ou do ato-norma do contribuinte que constitui o crédito tributário; (ii) a existência de débito do fisco, como resultado: (a) de ato administrativo de invalidação do lançamento tributário, (b) de decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou (d) de ato do próprio administrado, quando autorizado em lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior homologação do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e (iii) a existência de lei específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação, *ex vi* do artigo 1700, do CTN. [...] 4. A alegação da extinção da execução fiscal ou da necessidade de dedução de valores pela compensação total ou parcial, respectivamente, impõe que esta já tenha sido efetuada à época do ajuizamento do executivo fiscal, atingindo a liquidez e a certeza do título executivo, o que se deduz da interpretação conjunta dos artigos 170, do CTN, e 16, 3º, da LEF, sendo certo que, ainda que se trate de execução fundada em título judicial, os embargos do devedor podem versar sobre causa extintiva da obrigação (artigo 714, VI, do CPC). [...] 6. Consequentemente, a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da

existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário. [...] 10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (STJ, REsp Repetitivo 1.008.343/SP, 1ª Seção, rel. Ministro Luiz Fux, j. 09.12.2009, *DJe*, 01.02.2010).

11. Demonstrativo do débito e os requisitos do par. único do art. 798, CPC. Enunciado 590 do FPPC (“*O demonstrativo de débito a que alude o § 3.º do art. 917 deverá observar os mesmos requisitos dos incisos do parágrafo único do art. 798*”).

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I – quando intempestivos;

II – nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III – manifestamente protelatórios.

Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

1. Rejeição liminar dos embargos. Os embargos dos executados poderão ser liminarmente rejeitados em 04 (quatro) hipóteses: a) quando intempestivamente propostos, ou seja, fora do prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231 (art. 918, I c/c 915, *caput*, do CPC/2015); b) quando for o caso de indeferimento da petição inicial (art. 918, II, primeira parte c/c art. 330, do CPC/2015); c) quando for o caso de improcedência liminar do pedido (art. 918, II, segunda parte c/c art. 332, do CPC/2015); d) quando forem manifestamente protelatórios (art. 918, III, do CPC/2015).

2. Indeferimento da petição inicial. A primeira hipótese de rejeição liminar dos embargos é quando a petição inicial for indeferida. São hipóteses de indeferimento da petição inicial: a) a sua inépcia (art. 330, I, do CPC/2015); b) a ilegitimidade da parte (art. 330, II, do CPC/2015); c) a ausência de interesse processual (art. 330, III, do CPC/2015); d) a ausência de declaração do endereço, número de inscrição na OAB e nome da sociedade de advogados da qual participa em relação ao advogado que está postulando em causa própria (art. 330, IV c/c art. 106, I, do CPC/2015); e) a ausência de comunicação ao juízo qualquer mudança de endereço em relação ao advogado que está postulando em causa própria (art. 330, IV c/c art. 106, II, do CPC/2015); f) quando a parte, regularmente intimada para sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, não emendar a inicial (art. 330, IV c/c art. 321, do CPC/2015).

3. Improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido é “técnica de aceleração do processo”³⁴ que autoriza um julgamento favorável ao réu – no caso, o embargado – sem que o mesmo exerça o seu direito resposta quando o pedido formulado na petição inicial for manifestamente improcedente.

Deste modo, verificados os requisitos para a rejeição liminar dos embargos por improcedência liminar do pedido, deverá o juiz dispensar a citação do embargado e proferir sentença julgando improcedentes os embargos. A sentença desafiará apelação (art. 1.009, do CPC/2015) e o juiz poderá se retratar em 05 (cinco) dias após a sua respectiva interposição (art. 332, § 3.º, do CPC), oportunidade em que os embargos serão regularmente processados (art. 332, § 4.º, do CPC/2015).

Os requisitos da improcedência liminar do pedido, em atenção ao art. 332 do CPC/2015, são: a) a causa dispensar instrução probatória, isto é a matéria fática estar provada documentalmente nos documentos instruem a petição inicial dos embargos; b) o pedido contrariar os *precedentes* que deram origem ao enunciado de súmula do STF ou do STJ (art. 332, I c/c arts. 926, § 2.º e 927, IV, do CPC/2015); os *precedentes* firmados pelo STF e STJ respectivamente em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos (art. 332, II c/c art. 927, III, do CPC/2015); os *precedentes* firmados em IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) ou IAC (Incidente de Assunção de Competência) (art. 332, III c/c art. 927, III, do CPC/2015); os *precedentes* que deram origem ao enunciado da súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local (art. 332, IV c/c art. 927, IV e V, do CPC/2015); c) verificada desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição (art. 332,

§ 1.º, do CPC/2015).

Aqui é necessário frisar que o núcleo da teoria de precedentes adotada pelo CPC exige a conferência dos aspectos formais, ou seja, estar no rol do art. 927 do CPC, e materiais, tais como a identidade de fundamentos determinantes (circunstâncias fáticas e solução jurídica) no caso precedente e no caso atual, a inexistência de distinção ou superação (arts. 926 e 489, § 1.º, V e VI, do CPC/2015, cf. introdução, 2.18).³⁵

4. Manifesto propósito protelatório. Também serão rejeitados liminarmente os embargos manifestamente protelatórios (art. 918, III, do CPC/2015), ou seja, os embargos cujas razões e fundamentos são desprovidos de plausibilidade do direito alegado.

Esta situação jurídico-processual é considerada ato atentatório à dignidade da justiça (art. 918, parágrafo único, do CPC/2015) e enseja multa que pode chegar a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, a ser revertido em favor do exequente (art. 774, parágrafo único, do CPC/2015).

O termo “manifestamente protelatório” é um conceito jurídico indeterminado cuja hipótese fática não é descrita na estrutura da norma jurídica, cabendo aos Tribunais, portanto, reconstruir o ordenamento jurídico através do modelo de precedentes normativos formalmente vinculantes (arts. 489, § 1.º, V e VI, 926 e 927, do CPC/2015), dando consistência ao conceito para que possa haver um referencial normativo de aplicação.³⁶

Nos casos concretos levados aos Tribunais, em que configuradas hipóteses de procrastinação das execuções com o manejo de embargos protelatórios, deverão estes receber uma solução universalizável, ou seja, uma solução fático-jurídica que será aplicada a todos os casos similares e análogos futuros, contribuindo assim para uma ordem jurídica mais racional em que atos da mesma natureza sejam desestimulados.

Inclusive destaca o Enunciado 586 do FPPC que “*o oferecimento de impugnação manifestamente protelatória é ato atentatório à dignidade da justiça que enseja a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC*”.

5. Não recolhimento das custas. Também serão rejeitados liminarmente os embargos, quando não houver recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, conforme precedente do STJ: “Recurso especial representativo de controvérsia. Processual civil. Complementação de ações. Cumprimento de sentença. Custas da impugnação. Recolhimento intempestivo. Possibilidade de convalidação. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp: 1361811 RS 2013/0004194-9, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. CE – Corte Especial, DJ 04.03.2015, Data de Publicação: DJe 06.05.2015).

6. Aplicação à impugnação. Enunciado 545 do FPPC (“*Aplicam-se à impugnação, no que couber, as hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 918 e no seu parágrafo único*”).

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo,

em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

1. Ausência de efeito suspensivo dos embargos. Desde a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006, os embargos à execução não contavam com efeito suspensivo *ope legis*, ou seja, a mera oposição dos embargos não suspenderia a execução (art. 739-A), dependendo a suspensão de decisão judicial a partir do preenchimento de determinados requisitos (art. 739-A, § 1.º).

O CPC/2015 manteve a regra geral de não suspensividade dos embargos à execução (art. 919, *caput*, do CPC/2015), condicionando a paralisação dos atos executivos à caracterização dos requisitos previstos no § 1.º do art. 919. Os requisitos são os da tutela provisória, inovando o CPC, pois não se trata mais apenas da tutela de urgência, mas também da hipótese de tutela da evidência.

De acordo com a doutrina, esta opção legislativa busca partilhar o ônus do tempo do processo entre as partes, concretizando assim um processo cuja duração seja razoável (art. 4.º, do CPC/2015; art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988).³⁷

2. Requisitos para concessão do efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos é *ope judicis* e exige 03 (três) pressupostos à sua concessão: a) requerimento do embargante; b) requisitos da tutela provisória; c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.º, do CPC).

3. Requerimento do embargante. Em relação ao primeiro requisito, deve haver necessariamente expresso requerimento do embargante para concessão de efeito suspensivo aos embargos, ficando vedada a concessão oficiosa pelo juiz. Este requisito se justifica em razão da atribuição de responsabilidade objetiva pelas perdas e danos causados pela suspensão ao executado.

4. Pressupostos da tutela provisória. Em relação ao segundo requisito, deve se ter em mente que a tutela provisória é gênero que comporta as espécies tutela de urgência e tutela de evidência.

Conforme o art. 311 do CPC/2015, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*), bastando a configuração das situações previstas nos incs. I a IV do aludido dispositivo legal.

Conforme o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando presente a probabilidade do direito alegado (*fumus boni iuris*) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*).

A probabilidade do direito alegado será feita a partir de uma análise sumária e perfunctória das razões apresentadas na petição inicial dos embargos e dos documentos que os instruíram.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não pode ser fundado nas consequências derivadas da própria execução, tal qual a possibilidade de expropriação do patrimônio do embargante. Como atesta a doutrina “fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios”.³⁸

Em assim sendo, o perigo de dano deve refletir uma característica singular do bem cuja

expropriação pode causar um dano atípico ao executado, se ele for de natureza impenhorável, se ele for um bem infungível, se ele for um bem imprescindível ao sustento do executado ou de sua família etc.

5. Caução, depósito e penhora. Por fim, o último requisito necessário é a segurança do juízo através de penhora depósito ou caução, exigência que é uma garantia tanto ao executado, pela suspensão, quanto ao exequente, pela penhora.³⁹

No CPC/1973, o art. 736 dispensava a garantia do juízo para oposição dos embargos, o que levou o STJ a decidir sob a sistemática do julgamento de recurso especial repetitivo que esta dispensa não era aplicável às execuções fiscais em razão do regime de especialidade, mormente considerando a exigência expressa da LEF neste sentido (STJ, REsp 1272827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.05.2013, *DJe* 31.05.2013).

Com o advento do CPC/2015, seja a execução comum ou a execução fiscal, exige-se a garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo.

6. Modificação e revogação da decisão que concedeu efeito suspensivo. O efeito suspensivo dos embargos poderá ser modulado de acordo com as circunstâncias da execução, inexistindo preclusão consumativa para o juiz analisar a pertinência acerca da permanência ou não da suspensividade dos atos executivos (art. 919, § 2.º, do CPC/2015).

Sendo assim, cessadas as situações que embasaram a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos ou surgida uma nova situação que agora exija a suspensão dos atos executivos, poderá o juiz ser provocado pela parte a revogar ou modificar a sua decisão anterior.

7. Efeito suspensivo: critérios objetivos e subjetivos. O efeito suspensivo dos embargos poderá ser parcialmente concedido de acordo com as circunstâncias da execução em relação ao seu objeto e sujeitos.

Se apenas uma parcela da execução preencher os requisitos do art. 919, § 1.º, do CPC/2015, a execução ficará paralisada exclusivamente em relação ao valor ou bens por ela representada e os atos executivos continuarão sendo realizados quanto ao saldo ou bens remanescentes (art. 919, § 3.º, do CPC/2015).

De outro lado, quando houver mais de um executado, o efeito suspensivo dos embargos de um deles não aproveitará nem prejudicará os demais (art. 919, § 4.º, do CPC).

8. Alcance do efeito suspensivo. Eventual concessão de efeito suspensivo não impede que se dê continuidade aos atos de constrição e avaliação do patrimônio do executado, fazendo cessar tão somente os atos executivos relacionados à expropriação e satisfação do crédito (art. 919, § 5.º, do CPC/2015).

Deste modo, ato de substituição, reforço ou redução de penhora, assim como avaliação de bens, poderão ser realizados mesmo que os embargos estejam sob efeito suspensivo.

9. Tutela de Urgência/Evidência. Enunciado 80 (“A tutela antecipada prevista nestes dispositivos (art. 919, § 1.º e art. 969) pode ser de urgência ou de evidência”).

10. Efeito suspensivo dos embargos. Enunciado 546 (“O efeito suspensivo dos embargos à execução pode ser requerido e deferido a qualquer momento do seu trâmite, observados os pressupostos legais”); Enunciado 547 (“O efeito suspensivo dos embargos à execução pode ser parcial, limitando-se ao impedimento ou à suspensão de um único ou de apenas alguns atos executivos”).

Art. 920. Recebidos os embargos:

I – o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II – a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III – encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

1. Resposta do embargado. Devidamente recebidos os embargos, se não for o caso de rejeição liminar, deverá o juiz intimar o embargado para oferecer resposta aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC/2015).⁴⁰

Como a resposta do embargado tem natureza de contestação, é aplicável o regime jurídico previsto nos arts. 335 ao 342 do CPC/2015, no que couber, por força da aplicação subsidiária do art. 318, parágrafo único, do CPC/2015.

Entretanto, convém salientar que a despeito da impossibilidade de o embargado reconvir, porquanto pleiteado a tutela do crédito na ação de execução, poderá formular pedido contraposto de compensação no bojo dos embargos de retenção por benfeitoria (art. 917, § 5.º, do CPC/2015).

2. Eventual revelia do embargado. Se o embargado, regularmente citado, se mantiver inerte e não oferecer resposta aos embargos, operam-se os efeitos da revelia com presunção *iuris tantum* de veracidade acerca dos fatos alegados nos embargos (arts. 344, do CPC/2015).

Neste caso, há uma particularidade no que diz respeito à presunção de veracidade do alegado nos embargos, tendo em vista que a existência de um título executivo extrajudicial gera a presunção da relação obrigacional nele constante. Deste modo, eventual impugnação do embargante é necessariamente acompanhada do seu ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito do embargado consubstanciado no título executivo (art. 350, do CPC/2015).

Parcela da doutrina tem defendido que o título executivo apenas conta a presunção de veracidade em relação à exequibilidade da obrigação, de forma que a revelia operaria presunção em relação às demais questões que fogem à alçada do exequível.⁴¹ Assim, “se o embargante alega ter adimplido a obrigação e o embargado não contesta os embargos, o juiz não poderá presumir que o pagamento tenha ocorrido. Ainda assim, caberá ao embargante provar que adimpliu, incumbindo-lhe o encargo probatório”.⁴²

3. Julgamento imediato dos embargos ou designação de audiência de instrução. Após a apresentação de resposta do executado, o juiz poderá: a) julgar de imediato os embargos, uma vez desnecessária a dilação probatória; b) sendo necessária a produção de provas, designar audiência de instrução (art. 920, II, do CPC/2015). Realizada a fase de instrução, o juiz proferirá a sentença (art. 920, III, do CPC/2015), desafiando apelação em caso de inconformismo de uma das partes com o resultado final (art. 1.009, do CPC/2015).

4. Honorários advocatícios. Tendo em vista a natureza de ação dos embargos à execução, caberá condenação em honorários advocatícios, conforme o regime jurídico estabelecido no art. 85 do CPC.

NOTAS DE RODAPÉ

2

Antonio Adonias Aguiar Bastos, Comentários aos arts. 914 ao 920, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

3

Cf. José Carlos Barbosa Moreira, Exceção de pré-executividade: uma denominação infeliz. In: José Carlos Barbosa Moreira, *Temas de Direito Processual, Sétima Série*, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 119/121; Danilo Knijnik, *A Exceção de Pré-Executividade*, Rio de Janeiro: Forense, 2000; João Lacê Kuhn, *A Coisa Julgada na Exceção de Executividade*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

4

Marcelo Abelha, *Manual de Execução Civil*, p. 491.

5

Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao art. 914. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

6

É bom lembrar que na hipótese do art. 917, § 1.º, de regra, ainda não foi realizada a penhora quando da oposição dos embargos.

7

Nos termos do artigo, “art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1.º *O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana [...].*”

8

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *O Processo de Execução de Títulos Extrajudiciais*, p. 119.

9

Salvatore Satta, *Diritto Processuale Civile*. [1948] 9. ed., riveduta ed ampliata a cura di Carmine Punzi. Padova: CEDAM, 1981, p. 710/711.

10

Fernando Estavam Bravin Ruy, *Direito Econômico Financeiro. Crédito e Investimento*. Curitiba: Juruá, 2014.

11

Anteriormente, nos termos do art. 51 do Dec. 2.044, de 31.12.1908, determinava: “Na ação cambial, somente é admissível defesa fundada no direito pessoal do réu contra o autor, em defeito de forma do título e na falta de requisito necessário ao exercício da ação”. Bravin Ruy, *Direito Econômico Financeiro. Crédito e Investimento*, p. 688. Visa, portanto, do ponto de vista da ação cambial “[...] proporcionar o

pagamento sem a necessidade de enfrentamento sobre a declaração do direito” *Idem*, p. 689.

12

Heitor Vitor Mendonça Sica, *Cognição e Execução no Sistema de Tutela Jurisdicional Civil Brasileiro, Identificação e Tratamento do Objeto Litigioso em Sede Executiva*, 2016, Tese (Livre Docência), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2016, p. 333.

13

O tema da relação cognição-execução é de grande interesse. Recentemente: Heitor Vitor Mendonça Sica, *Cognição e Execução no Sistema de Tutela Jurisdicional Civil Brasileiro. Identificação e Tratamento do Objeto Litigioso em Sede Executiva*, 2016, Tese (Livre Docência), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2016.

14

Para isto também colaboraram os germânicos, com seu “temperamento impulsivo e individualista”, como vimos, na primeira fase, a atividade executiva começava de mão própria pelo credor, característica da vingança privada, e só posteriormente se formava o eventual juízo de conhecimento. Esta agilidade, contudo, influenciou o surgimento, na idade média, da *executio parata*, como decorrência da *executio per officium iudicis*, segundo a qual havendo a *precedência do processo contraditório e da condenação não havia necessidade de uma nova ação (actio iudicati)* pois a atividade executiva era um desdobramento da atividade cognitiva, “*sententiam habet paratam executionem*”, a sentença aparelhava a execução. Eliminavam-se as dúvidas quanto a produção probatória, vedando-se a reabertura da discussão no mérito já debatido.

15

Dinamarco, *Execução Civil*, § 2.º, p. 30/38; Kazuo Watanabe, *Da Cognição no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Perfil, 2005, p. 49/52.

16

Kazuo Watanabe, *Da Cognição no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Perfil, 2005, p. 53.

17

Marcelo Abelha, *Manual de Execução Civil*, 4. ed., revista e atualizada, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 65.

18

Sobre contraditório na execução e sua natureza constitucional, João Lacê Khun, *O Princípio do Contraditório no Processo de Execução*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

19

Assim, a dupla autonomia pregada por Dinamarco não deve mais ser acatada neste ponto, dizendo respeito a uma compreensão do problema à luz do CPC anterior. Cândido Rangel Dinamarco, *Execução Civil*, 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 361 e ss.

20

Heitor Vitor Mendonça Sica, *Cognição e Execução no Sistema de Tutela Jurisdicional Civil Brasileiro. Identificação e Tratamento do Objeto Litigioso em Sede Executiva*, 2016, Tese (Livre Docência), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2016, p. 334.

21

Vale destacar que ainda na vigência do CPC/1973 existia precedente do STJ (*“O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (STJ, REsp repetitivo 1.112.416/MG, 1.ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.05.2009)*). que afirmava ser o termo inicial para contagem do prazo para oposição de embargos nas execuções fiscais a data efetiva da penhora e não a da juntada do mandado cumprido, como se viu o CPC/2015 alterou a matéria, não devendo mais prevalecer tal compreensão.

22

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 851-852.

23

Antonio Adonias Aguiar Bastos, Comentários aos arts. 914 ao 920, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

24

Edilton Meireles, Medidas Sub-rogatórias, coercitivas, mandamentais e indutivas no Código de Processo Civil de 2015, *Revista de Processo*, São Paulo, 2015, p. 231-246, n. 247.

25

Marcelo Abelha, *Manual de Execução Civil*, p. 194.

26

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 853-857.

27

Antonio Adonias Aguiar Bastos, Comentários aos arts. 914 ao 920. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

28

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 853-857.

29

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 853-857.

30

Antonio Adonias Aguiar Bastos, Comentários aos arts. 914 ao 920. In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

31

Michele Taruffo, A atuação executiva: perfis comparados, In: Michele Taruffo, *Processo Civil Comparado: Ensaio*, São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 85/117.

32

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 853-857.

33

Sobre os embargos de retenção de benfeitorias, na doutrina cf. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, *Embargos de Retenção por Benfeitorias*, São Paulo: Ed. RT, 1999.

34

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento*, 17. ed., revista, atualizada e ampliada, Salvador: JusPodvim, 2015, p. 593.

35

Para a bibliografia sobre o tema cf. Hermes Zaneti Jr., *O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes*, 2. ed., revista e atualizada, Salvador: JusPodvim, 2016.

36

Hermes Zaneti Jr., *O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes*, 2. ed., revista e atualizada, Salvador: JusPodivm, 2016.

37

Antonio Adonias Aguiar Bastos, Comentários aos arts. 914 ao 920, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

38

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 858-860.

39

Antonio Adonias Aguiar Bastos, Comentários aos arts. 914 ao 920, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

40

“O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/1980, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada” (STJ, REsp Repetitivo 1.268.324/PA, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.10.2012).

41

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 860-862.

42

Antonio Adonias Aguiar Bastos, Comentários aos arts. 914 ao 920, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

1

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 849-862; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 914 a 920)*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão online*, p. 800-811; Lúcio Delfino, Arts. 914 a 920 do CPC, In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de*

Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1283-1294; Antônio Adonias Aguiar Bastos, Arts. 914 a 920 do CPC, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 2123-2155; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil Anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 715-727; Bruno Garcia Redondo, Arts. 914 a 920 do CPC, In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1177-1183; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1289-1304; Enrico Tullio Liebman, *Processo de Execução*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 214-224; Enrico Tullio Liebman, *Embargos do Executado: oposições de mérito no processo de execução*, Trad. J. Guimarães Menegale, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1968; Humberto Theodoro Jr., *Processo de Execução e Cumprimento de Sentença*, 25. ed. São Paulo: Leud, 2008, p. 397-442; João Batista Lopes, Defesa do Executado na Reforma da Execução Civil, In: Paulo Hoffman; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro (coord.). *Processo de Execução Civil*, São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 83-94; Marcelo Abelha, *Manual de Execução Civil*, 5. ed., Rio de Janeiro, 2015, p. 457-509.

© desta edição [2018]

TÍTULO IV. DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Capítulo I. Da Suspensão do Processo de Execução

1

Art. 921. Suspende-se a execução:

I – nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II – no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III – quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV – se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V – quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

1. Suspensão da execução. O art. 921 do CPC/2015 trata das hipóteses em que a execução poderá ser suspensa. O rol não é taxativo (STJ, AgRg no Ag 161.254/RS, Rel. Ministro Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 13.10.1998, *DJ* 30.11.1998, p. 170). Foram incluídas novas situações que ensejam a suspensão da execução em relação ao CPC/1973, que a previa apenas quando os embargos fossem recebidos com efeito suspensivo, quando configuradas as hipóteses de suspensão do processo de conhecimento e quando inexistentes bens penhoráveis.

2. Hipóteses gerais de suspensão da execução. As hipóteses de suspensão previstas para o

processo de conhecimento também se aplicam à execução (art. 921, I, do CPC/2015). Desta forma, suspende-se a execução com (a) a morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador (art. 313, I, do CPC/2015); (b) convenção das partes (art. 313, II, do CPC/2015); (c) arguição de impedimento ou de suspeição (art. 313, III, do CPC/2015); (d) admissão de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) (art. 313, IV, do CPC/2015); (e) quando houver prejudicialidade em relação ao julgamento de outra demanda ou em relação à declaração de existência ou inexistência de relação jurídica discutida em outros autos (art. 313, V, *a*, do CPC/2015); (f) quando a sentença necessitar de verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro órgão jurisdicional (art. 313, V, *b*, do CPC/2015); (g) motivo de força maior (art. 313, VI, do CPC/2015); (h) quando o Código assim regular (art. 313, VII, do CPC/2015); (i) quando o objeto dos autos versar sobre acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo (art. 313, VIII, do CPC/2015); (j) se o mérito depender de verificação da existência de fato delituoso em apuração na Justiça Criminal (art. 315, do CPC/2015).

3. Efeito suspensivo concedido aos embargos. Em regra, a mera oposição de embargos à execução não têm o condão de suspender os atos executivos (art. 919, *caput*, do CPC/2015). Porém, a requerimento da parte, a execução poderá ser suspensa quando os embargos ou a impugnação ao cumprimento de sentença forem recebidos com efeito suspensivo, no todo ou em parte (art. 921, II, do CPC/2015), desde que (a) preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória; (b) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.º, do CPC/2015). Analogamente, considerando a aplicação subsidiária das regras da execução fundada em título extrajudicial ao cumprimento de sentença (art. 513 c/c art. 771, parágrafo único, do CPC/2015), o simples ajuizamento de impugnação ao cumprimento de sentença não suspenderá os atos executivos (art. 525, § 6.º, do CPC/2015), a não ser que a parte requeira efeito suspensivo e o juiz atribua conforme os requisitos do art. 525, § 6.º, parte final, do CPC/2015.

4. Ausência de bens penhoráveis. A execução poderá ser suspensa quando o executado não possuir bens passíveis de penhora (art. 921, III, do CPC/2015), o que pode compreender tanto a não localização de bens penhoráveis como a localização de bens impenhoráveis. O prazo de suspensão da execução será de 01 (um ano), período no qual também ficará suspensa a prescrição (art. 921, § 1.º, do CPC/2015). Transcorrido o mencionado prazo e não localizado no patrimônio do executado bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos (art. 921, § 2.º, do CPC/2015), que poderão ser desarquivados tão logo encontrados bens para fins de penhora (art. 921, § 3.º, do CPC/2015).

5. Falta de licitantes e desídia do exequente. Quando a alienação do bem penhorado não ocorrer por falta de licitantes e o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, não der prosseguimento à execução, quer requerendo a adjudicação ou indicando outros bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa (art. 921, IV, do CPC/2015). Esta hipótese de suspensão da execução é uma novidade em relação ao CPC/1973.

6. Prescrição intercorrente. Quando transcorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, caso o exequente não se manifeste, iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4.º, do CPC/2015). É necessário que o exequente seja cientificado do transcurso do prazo, quer devido ao dever de prevenção do órgão jurisdicional para com a parte decorrente da cooperação (art. 6.º), quer porque a prescrição pressupõe inércia do exequente, como diz a jurisprudência do STJ, o prazo só flui “se o credor não atender às diligências necessárias ao andamento do feito, uma vez intimado a realizá-las” (STJ, REsp 327.329/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 14.08.2001, DJ 24.09.2001, p. 316). O juiz poderá reconhecer a prescrição de ofício e extinguir a execução somente depois de oportunizar as partes sobre ela se manifestar em 15 (quinze) dias (art. 921, § 5.º, do CPC/2015), sob pena de caracterizada decisão-surpresa (art. 10, do CPC/2015).

7. Execução do devedor em recuperação judicial. “A respeito das execuções em que o devedor está em recuperação judicial, o STJ possui importante precedente, vejamos: “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.º,

caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005” (STJ, 2ª Seção, REsp Repetitivo 1.333.349/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2015).

8. Suspensão e Prescrição. Enunciado 190 (“A prescrição intercorrente pode ser reconhecida no procedimento de cumprimento de sentença”); Enunciado 195 (“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4.º, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1.º”). Enunciado 196 (“O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”); Enunciado 548 (“O simples desarquivamento dos autos é insuficiente para interromper a prescrição”); Enunciado 452 (“Durante a suspensão do processo prevista no art. 982 não corre o prazo de prescrição intercorrente”).

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomar o seu curso.

1. Moratória e suspensão da execução. É permitida a suspensão da execução quando as partes assim estipulam judicial ou extrajudicialmente, permitindo o exequente que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (art. 922, caput, do CPC/2015). A suspensão da execução, por sua vez, não autoriza a extinção da execução, tanto que o exequente poderá retomar seu curso caso o executado não tenha cumprido a obrigação no prazo assinalado (art. 922, parágrafo único, do CPC/2015). A duração do período de suspensão é aquele convencionado entre as partes (STJ, 4ª Turma, REsp 164.439/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 08.02.2000, DJ 20.03.2000, p. 76).

Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.

1. Prática de atos processuais urgentes. Somente poderão ser ordenados atos processuais urgentes durante a suspensão do processo a fim de “resguardar direitos e interesses que corram risco de perecimento em virtude do transcurso do tempo e da inércia das partes”,² o que engloba atos ligados à tutela cautelar e à tutela antecipatória baseada em urgência.³ Entretanto, caso a execução esteja suspensa por arguição de impedimento ou suspeição, sequer atos processuais urgentes poderão ser praticados.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 863-865; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 921 a 923)*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, versão online, p. 812-814; Ronaldo Cramer; Carolina Uzeda, Arts. 921 a 925 do CPC, In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295-1300; Gilson Delgado Miranda, Arts. 921 a 925 do CPC, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2156-2161; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil Anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 728-730; Guilherme Peres de Oliveira, Arts. 921 a 925 do CPC, In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes;

Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1183-1185; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1305-1309; Araken de Assis, *Manual de Execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 675-731.

2

Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao art. 923, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

3

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 864-865.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XIV - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO IV. DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO II. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Capítulo II. Da Extinção do Processo de Execução

¹

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente.

1. Extinção da execução. O art. 924 do CPC/2015 prevê as hipóteses de extinção da execução, trazendo como novidade em relação ao art. 794 do CPC/1973 os casos de indeferimento da petição inicial (art. 330, do CPC/2015) e prescrição intercorrente (art. 921, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015).

O recurso cabível em face da decisão que extingue a execução é a apelação (AgRg no AREsp 530.686/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.11.2015, *DJe* 09.11.2015; AgRg no AREsp 182.614/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2012, *DJe* 13.09.2012).

A extinção só produz efeito quando declarada por sentença (art. 925, do CPC/2015). Portanto, extinta a execução por sentença cabe apelação.

2. Rol exemplificativo. O rol é meramente exemplificativo, versando apenas sobre hipóteses típicas de extinção da execução. Cabe ainda a aplicação subsidiária das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito no processo de conhecimento (art. 485, do CPC/2015), por força do art. 771 do CPC/2015.

Ademais, há outras hipóteses de extinção da execução, como o pagamento de valor reclamado em execução fiscal em âmbito administrativo (STJ, REsp 151.191/PE, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 09.05.2000, *DJ* 12.06.2000, p. 90) e o acolhimento de exceção de pré-executividade.²

Contudo, uma parcela da doutrina tem criticado o dispositivo, afirmando que o Código poderia tratar da matéria com mais técnica, como nos casos de extinção por carência da ação, se constatada a ausência de título executivo hábil, ou ainda diferenciando sentença típica que declare extinta a relação jurídica processual executiva (satisfação do crédito) das sentenças atípicas que têm o mérito (direito material) resolvido durante a atividade ou relação jurídica processual executiva (transação, acordo, conciliação e renúncia ao direito no qual se funda a ação).³

3. Depósito judicial e extinção da execução. “Recurso especial representativo de controvérsia. Civil e processual civil. Complementação de ações. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Juros de mora e correção monetária. Encargo da instituição depositária. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação

extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp Repetitivo 1.348.640/RS, Corte Especial, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07.05.2014, *DJe* 21.05.2014)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

1. Extinção da execução. Apenas quando declarada por sentença que a execução é efetivamente extinta (art. 925, do CPC/2015), seja em razão das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC/2015, ou então por qualquer outro motivo, tais como decretação de nulidade (art. 276 e ss., do CPC/2015), falta de título ou seus requisitos (arts. 784 e 786, do CPC/2015), questões de ordem pública (art. 485, do CPC/2015). Em qualquer destes casos, extinta a execução por sentença, é possível impugná-la através de apelação (art. 1.009, do CPC/2015).

2. Retomada da execução. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é possível retomar através de simples petição o curso da execução extinta por sentença que declarou satisfeita a obrigação. Neste caso, a complementação do crédito deverá ser pleiteada pelo exequente via ação rescisória. (REsp 885.713/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.06.2010, *DJe* 28.06.2010). Assim, neste sentido, caberá ação rescisória para desconstituir a sentença executiva (art. 966, do CPC/2015).

3. Renúncia ao crédito exequendo remanescente e a necessidade de intimação. “A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. A extinção da execução, ainda que por vício *in judicando* e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petição em ação rescisória imune ao prazo decadencial. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no art. 794, I, do CPC [de 1973], é defeso reabri-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo” (STJ, REsp Repetitivo 1.143.471/PR, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. 03.02.2010).

NOTAS DE RODAPÉ

1

Cf.: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 865; Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil (art. 924 a 925)*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Miguel Garcia Medina, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, *versão online*, p. 815-817; Ronaldo Cramer; Carolina Uzeda, Arts. 921 a 925 do CPC, In: Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1300-1302; Gilson Delgado Miranda, Arts. 921 a 925 do CPC, In: Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 2161-2164; Cássio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil Anotado*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 730-732; Guilherme Peres de Oliveira, Arts. 921 a 925 do CPC, In: Lênio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1185; Alexandre de Freitas Câmara, *O Novo Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Atlas, 2015, p. 377-403; Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Freitas da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1309-1310; Araken de Assis, *Manual de Execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 733-786.

2

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 865.

3

Marcelo Abelha Rodrigues, O Novo CPC e a Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 2 – Continuação), *Revista de Processo*, São Paulo, 2015, p. 151-222, n. 245.

© desta edição [2018]

Referências Bibliográficas

- AARNIO, Aulis. *Essays on the Doctrinal Study of Law*. London/New York: Springer, 2011.
- ALEXY, Robert. *Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica*. 3. ed. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. Forense: Rio de Janeiro, 2013.
- _____. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.
- ALMEIDA, Gregório Assagra de. Execução Coletiva em Relação aos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos: Algumas Considerações Reflexivas. In: CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita (coord.). *Temas Atuais de Execução Civil: Estudos em Homenagem ao Professor Donaldo Armelin*. São Paulo: Saraiva, 2007.
- ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto (coord.). *A Nova Execução de Títulos Extrajudiciais*. Comentários à Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- _____. (coord.). *A Nova Execução*. Comentários à Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
- _____. A garantia do contraditório. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*, v. 15, p. 7-20, 1998.
- _____. O juiz e o princípio do contraditório. *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, ano 18, n. 71, p. 31-38, jul./set. 1993.
- _____. O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. In: _____. *Do formalismo no processo civil*. 2. ed. rev. e acrescida de apêndice. São Paulo: Saraiva, 2003.
- _____. *Teoria e Prática da Tutela Jurisdicional*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Arts. 847 a 853 do CPC. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- ARENHART, Sérgio Cruz. *A Tutela Inibitória da Vida Privada*. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- _____. *Perfis da Tutela Inibitória Coletiva*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- ARMELIN, Donaldo; BONICIO, Marcelo J. M.; CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita. *Comentários à Execução Civil: Título Judicial e Extrajudicial (artigo por artigo)*. São Paulo: Saraiva: 2008.
- ARONE, Ricardo. Direito à Propriedade. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. *Comentários à constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Freitas da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo*

Civil. Artigo por artigo. São Paulo: Ed. RT, 2015.

ASCARELLI, Tullio. *Lezioni di Diritto Commerciale*. Milano: Giuffrè, 1955.

ASSIS, Araken de. *Manual da Execução*. São Paulo: Ed. RT, 2007.

_____. *Manual de Execução*. 18. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

AZEVEDO, Luiz Carlos de; CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Lições de história do processo civil romano*. São Paulo: Ed. RT, 1996.

BALZANO, Felipe. A Penhora On Line e o Prazo dos Embargos de Terceiro. *Revista de Processo*. n. 252. p. 167-205. São Paulo: 2016.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Exceção de pré-executividade: uma denominação infeliz. In: _____. *Temas de Direito Processual*. Sétima Série. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 119/121.

_____. Tendências na Execução de Sentença e Ordens Judiciais. *Temas de Direito Processual*. Quarta Série. São Paulo: Saraiva, 1989.

BARONI, Rodrigo. Arts. 824 a 830 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Comentários aos arts. 914 ao 920. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

BERALDO, Leonardo de Faria. Comentários aos arts. 837 a 846 do CPC. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

BESSO, Chiara. *Il Processo Civile*. Nozione Generale. 2. ed. Torino: Giappichelli, 2015.

BETTETTO, Nina. Implementation of European Civil Procedural Regulations in the Case Law of Slovenian Courts. In: RHEE, C.H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. 103 e ss.

BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

_____. *Da Estrutura à Função*. Novos Estudos de Teoria do Direito. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Barueri: Manole, 2007.

_____. *Dalla Struttura alla Funzione*. Roma/Bari: Laterza, 2007.

BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Arts. 870 a 909 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

BOURGUIGNON, Álvaro Manoel Rosindo. *Embargos de Retenção por Benfeitorias*. São Paulo: Ed. RT, 1999.

BRASIL. Ministério da Justiça. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Prevenção e Tratamento do Superendividamento. Caderno de Investigações Científicas – Volume 1. Elaboração professora Cláudia Lima Marques e juízas Clarissa Costa Lima e Káren Bertoncello – Brasília: SDE/DPDC, 2010.

BRAVIN RUY, Fernando Estavam. *Direito Econômico Financeiro*. Crédito e Investimento. Curitiba: Juruá, 2014.

BRUSCHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. *Fraudes Patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

BUENO, Cássio Scarpinella. *Manual de Direito Processual Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

BUZAID, Alfredo. Exposição de motivos. *Código de Processo Civil*. Histórico da Lei. Brasília: Senado Federal, Secretaria de Edições Técnicas, 1974. v. I, t. I.

CABRAL, Antonio do Passo. *Convenções Processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016.

_____. Il principio del contraddittorio come diritto d'influenza e dovere di dibattito. *Rivista di Diritto Processuale*. anno 60. n. 2. p. 449-463. apr./giu., 2005.

_____. *Nulidades no Processo Moderno*. Contraditório, Proteção da Confiança e Validade Prima Facie dos Atos Processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

CADIET, Loïc. Introduction to french civil justice system and civil procedural law. *Ritsumeikan Law Review*. n. 28. p. 331/393. 2011.

CALDAS, Gilberto. *O latim no direito*. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.

CÂMARA, Alexandre Freitas. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015.

_____. Novo CPC ampliou sobremaneira os poderes do juiz. *Consultor Jurídico*. Disponível em: [http://www.conjur.com.br/2016-jun-23/alexandre-freitas-camara-cpc-ampliou-poderes-juiz#sdfotnote2sym] Acesso em: 08.08.2016.

CÂMARA, Helder Moroni. Arts. 870 a 909 do CPC. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.

CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva, 2014.

CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça: Conclusão de um Projeto Internacional de Investigação Jurídico-Sociológica. In: _____. *Processo, Ideologias e Sociedade*. Trad. Hermes Zaneti Junior. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2010. v. II.

_____. GARTH, Bryant. *Acesso à Justiça*. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988.

CARVALHO FILHO, Antônio. Arts. 827 a 830 do CPC. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.

CASTILLO, Aureo Yépez. *Roma*. Caracas: UCAB, 1995.

CAVANI, Renzo. *La Nulidad en el Proceso Civil*. Lima: Palestra, 2014.

CHARDON, M. How to Implement Common Standards of Enforcement Law? In: RHEE, C.H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. 113/124.

_____. Training Judicial Officers in France. In: RHEE, C.H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. 155/160.

CHIARLONI, Sergio. *Medidas Coercitivas y Tutela de los Derechos*. Trad. Aldo Zela Villegas. Lima: Palestra, 2005.

- _____. *Misure Coercitive e Tutela dei Diritti*. Milano: Giuffrè, 1980.
- CHIASSONI, Pierluigi. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007.
- CHIOVENDA, Giuseppe. Dell'azione nascente dal contratto preliminare. *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*. Milano: Giuffrè, 1993. v. 1.
- _____. Le Forme nella Difesa Giudiziale del Diritto [1901]. In: CHIOVENDA, Giuseppe. *Saggi di Diritto Processuale Civile*,. Giuffrè: Milano, 1993. v. I, p. 353 e ss.
- _____. Roman and german elements in continental civil procedure. Trad. Robert W. Millar. In: ENGELMANN, Arthur et al. *History of Continental Civil Procedure*. Boston: Little, Brown, and Company, 1927. p. 875 e ss.
- _____. Romanesimo e germanesimo nel processo civile. *Saggi di diritto processuale Civile (1900-1930)*. Roma: Il Foro Italiano, 1930.
- _____. Romanesimo e germanesimo nel processo civile [Universidade de Parma, 05 de dezembro de 1901]. In: CHIOVENDA, Giuseppe. *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*. Roma: Il Foro Italiano, 1930. v. 1, p. 181-224.
- COSTA, Eduardo José da Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2012. n. 212.
- _____. Art. 910 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- COSTA, Moacyr Lobo da. *Origem dos embargos no direito lusitano*. Rio de Janeiro: Borsó, 1973.
- CRAMER, Ronaldo; UZEDA, Carolina. Arts. 921 a 925 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. *Precedent in english law*. New York: Oxford University Press, 1991.
- CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Tempo e Processo*. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao art. 910. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle, CUNHA, Leonardo Carneiro da (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.
- DALMOTTO, Eugenio. Diritto alla equa riparazione per l'eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, Sergio (coord.). *Misure Acceleratorie e Riparatorie contro L'Irragionevole Durata dei Processi*. Torino: Giappichelli, 2002. p. 136-144.
- DELFINO, Lúcio. Arts. 914 a 920 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- DENTI, Vittorio. Il Processo di Cognizione nella Storia delle Riforme. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. p. 808. 1993.
- DIDIER JR., Fredie (coord.). *Execução Civil: Estudos em Homenagem ao Professor Paulo Furtado*. Rio de Janeiro: 2006.
- _____. *Curso de Direito Processual Civil*. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 1.
- _____. *Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil português*. Coimbra: Coimbra Editora, 2010.

_____. ZANETI JUNIOR, Hermes. *Curso de Direito Processual Civil*. Processo Coletivo. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.

_____. BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. *Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela*. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. 2.

_____. CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). *Negócios Processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 1. Coleção Grandes Temas do Novo CPC.

_____. CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. *Curso de Direito Processual Civil*. Execução. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2014. v. 5.

_____; _____. *Curso de Direito Processual Civil*. Execução. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. no prelo, texto gentilmente cedido pelos autores. v. 5.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Execução Civil*. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

_____. *Instituições de Direito Processual Civil*. São Paulo: Malheiros, 2004. v. IV.

_____. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro e a Ordem Processual Civil Vigente. *Revista de Processo*. n. 247. p. 63-103. São Paulo: 2015.

DUXBURY, Neil. *The nature and authority of precedent*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

DWORKIN, Ronald. *O império do direito*. 3. ed. Trad. Jéferson Luiz Camargo. Revisão técnica de Gildo Sá Leitão Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

EISENBERG, Melvin Aron. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

ENGELMANN, Arthur et al. *History of Continental Civil Procedure*. Boston: Little, Brown and Company, 1927.

FAORO, Raimundo. *Os Donos do Poder: A Formação do Patronato Político Brasileiro*. 3. ed. rev. Porto Alegre: Globo, 2001.

FERRAJOLI, Luigi. *Principia Iuris*. Teoria del diritto. Roma/Bari: Laterza, 2007.

_____. *A Cultura Jurídica e a Filosofia Jurídica Analítica do Século XX*. Trad. Alfredo Copetti Neto, Alexandre Salim e Hermes Zaneti Junior. São Paulo: Saraiva, 2015.

_____. *A Democracia Através dos Direitos*. O Constitucionalismo Garantista como Modelo Teórico e como Projeto Político. Trad. Alexander Araujo de Souza; Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, André Karam Trindade, Hermes Zaneti Junior e Leonardo Menin. São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____. Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa. *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*. n. 43. p. 290-304. 1966.

_____. *La Cultura Juridica nell'Italia Del Novecento*. Roma/Bari: Laterza, 1999.

_____. *Poteri Selvaggi: La Crisi della Democrazia Italiana*. Roma/Bari: Laterza, 2011.

_____. *Principia Iuris*. Teoria della Democrazia. Roma/Bari, 2007. v. II.

FISCHER, Luís Augusto. *Dicionário de palavras e expressões estrangeiras*. Porto Alegre: LPM, 2004.

FREUDENTHAL, Mirjan. Attitudes of European Union Members States towards Harmonisation

of Civil Procedure. In: RHEE, C.H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. 3 e ss.

GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método*. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Trad. Flávio Paulo Meurer. Nova revisão da tradução por Enio Paulo Giachini. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. v. I.

GAJARDONI, Fernando da Fonseca. A revolução silenciosa da execução por quantia. *Jota*. Disponível em: [<http://jota.uol.com.br/a-revolucao-silenciosa-da-execucao-por-quantia>]. Acesso em: 08.08.2016.

GELIO, Aulo. *Noches Aticas*. Trad. Francisco Navarro y Calvo. Buenos Aires: EJE, 1959.

GIDI, Antonio; ZANETI JUNIOR, Hermes. Brazilian Civil Procedure in the “Age of Austerity”? Effectiveness, Speed, and Legal Certainty: Small Claims, Uncontested Claims, and Simplification of Judicial Decisions and Proceedings. *ELR (Erasmus Law Review)*. n. 4. december 2015.

GILLISSEN, John. *Introdução histórica ao direito*. 2. ed. Trad. A. M. Espanha e L. M. Macaísta Malheiros. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1995.

GOODHART, Arthur L. Determining the ratio decidendi of a case. *Yale Law Journal*. v. 40. n. 2. p. 161/183. dec. 1930.

GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.

_____. *Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios*. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

GROSSI, Paolo. La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico. *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico*. Milano: Giuffrè, 1988.

_____. Proprietà e contratto. In: FIORAVANTI, M. (a cura di). *Lo Stato moderno in Europa*. Istituzioni e diritto. Laterza, Roma-Bari 2004.

GUASTINI, Riccardo. *Interpretare ed argumentare*. Milano: Giuffrè, 2011.

GUERRA, Marcelo Lima. *Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2003.

_____. *Execução Indireta*. São Paulo: Ed. RT, 1998.

HÄBERLE, Peter. Elementos teóricos de un modelo general de recepción jurídica. In: PEREZ LUÑO, Antonio-Henrique (coord.). *Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio*. Madrid: Marcial Pons, 1996.

HARTMANN, Rodolfo Kronenberg. Arts. 911 a 913 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

HAZARD JR., Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. *American Civil Procedure: An Introduction*. New Haven/London: Yale University Press, 1993.

HESS, Burkhard. Different Enforcement Structures. In: RHEE, C. H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. 41/63.

HOFFMAN, Paulo. *Razoável Duração do Processo*. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

_____. RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva (coord.). *Processo de Execução Civil*. São Paulo:

Quartier Latin, 2006.

IPPOLITO, Dario. Libertà e proprietà nella teoria dei diritti di Luigi Ferrajoli. *Ragion Pratica*. n. 44. p. 131. giugno 2015.

JOBIM, Marco Felix. *Direito à Duração Razoável do Processo: Responsabilidade Civil do Estado em Decorrencia da Intempestividade Processual*. São Paulo: Conceito, 2011.

JONGBLOED, A. W. The Dutch Court Bailiffs Act Eight Years after its Introduction. In: RHEE, C. H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. 179/206.

KASER, Max. *Direito privado romano*. Trad. Sumel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.

KNIJNIK, Danilo. A exceção de pré-executividade. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

KÖTZ, Hein; ZWEIGERT, Konrad. *Introduzione al Diritto Comaprato*. I Principi Fondamentali. Trad. Barbara Pozzo. Milano: Giuffrè, 1998.

KRAMER, Xandra. Enhancing Enforcing in the European Union. The European Order for Payment Procedure and Its Implementation in the Member States, Particularly in Germany, the Netherlands, and England. In: RHEE, C. H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. 17 e ss.

KUHN, João Lacê. *A Coisa Julgada na Exceção de Executividade*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

LAGE, Guilherme. Arts. 837 a 846 do CPC. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra; COLNAGO, Lorena de Mello Rezende; GUNTHER, Luiz Eduardo (coord.). *Execução Trabalhista: Uma homenagem ao professor Wagner Giglio*. São Paulo: LTr, 2015.

LIEBMAN, Enrico Tullio. *Embargos do Executado*. Oposições de Mérito no Processo de Execução. 2. ed. Trad. J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1968.

_____. Istituti del diritto comune nel processo civile brasiliano. In: LIEBMAN, Enrico Tullio. *Problemi del Processo Civile*. Napoli: Morano, 1962. p. 490-516.

_____. *Processo de Execução*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1980.

LIMA, Alcides de Mendonça. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. VI. Rio de Janeiro: Forense, 1985.

LOCKE, John. *A Letter Concerning Toleration* (1689). Huddersfield: J. Brook, 1796.

_____. *Two Treatises of Government* (1689). 5. ed. London: A. Bettsworth, MDCCXXVIII.

LOPES, João Batista. Defesa do Executado na Reforma da Execução Civil. In: HOFFMAN, Paulo; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva (coord.). *Processo de Execução Civil*. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Comentários aos arts. 870 ao 909. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

MACCORMICK, Neil. Coherence in legal justification. In: PECZENIK, Aleksander; LINDAHL, L.; VAN ROERMUND, G. C. (ed.). *Theory of Legal Science*. Dordrecht: Springer, 1984. p. 235/251.

- _____. *Legal Reasoning and Legal Theory*. New York: Oxford University Press, 1978. cap. VII e VIII, reprinted, 2003.
- _____. *Rhetoric and the Rule of Law*. A Theory of Legal Reasoning. New York: Oxford University Press, 2005.
- MANDRIOLI, Crisanto. *L'Azione Esecutiva*. Milano: Giuffrè, 1955.
- _____. L'Esecuzione Specifica dell'Ordine di Reintegração nel Posto di Lavoro. *Rivista di Diritto Processuale*. p. 23. 1975.
- MARINONI, Luiz Guilherme. Controle do Poder Executivo do Juiz. *Execução Civil: Estudos em Homenagem ao Professor Paulo Furtado*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 225.
- _____. *Julgamento nas Cortes Supremas*. Precedente e Decisão do Recurso diante do Novo CPC. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. *Precedentes obrigatórios*. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- _____. *Teoria Geral do Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- _____. *Tutela Inibitória*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- _____. *Tutela Inibitória: Tutela Individual e Coletiva*. São Paulo: Ed. RT, 1992.
- _____.; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 5. ed. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 736-803.
- _____.; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____.; _____.; _____. *Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum*. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. 2.
- _____.; _____.; _____. *Novo Curso de Processo Civil: Teoria do Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. v. 1.
- MARQUES, Cláudia Lima; CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli (coord.). *Direitos do Consumidor Endividado: Superendividamento e Crédito*. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- MARQUES, José Frederico. *Manual de Direito Processual Civil*. Campinas: Bookseller, 1997. v. IV.
- MARTINS, Argemiro; ROESLER, Cláudia; JESUS, Ricardo. A noção de coerência na teoria da argumentação jurídica de Neil MacCormick. *Novos Estudos Jurídicos*. v. 16. n. 2. p. 207-221. mar./ago. 2011.
- MAZZAMUTO, Salvatore. *L'Attuazione degli Obblighi di Fare*. Napoli: Jovene, 1978.
- MAZZEI, Rodrigo. Código de Processo Civil do Espírito Santo: Breve Notícia Histórica. In: *Código de Processo Civil do Espírito Santo*. Texto Legal e Breve Notícia Histórica. Vila Velha: Eppur Si Muove, 2014. p. 7/18.
- _____. MERÇON-VARGAS, Sarah. Arts. 831 a 869 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- _____. RAMOS, Glauco; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima; NEVES, Daniel Amorim Assunção.

Reforma do CPC 2. Leis 11.382/2006 e 11.341/2006. São Paulo: Ed. RT, 2007.

MEDINA, Miguel Garcia. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015. versão on-line.

MEIRELES, Edilton. Medidas sub-rogatórias, coercitivas, mandamentais e indutivas no Código de Processo Civil de 2015. *Revista de Processo*. n. 247. p. 231-246. São Paulo: 2015.

MELLO, Joaquim Munhoz. Notas. In: LIEBMAN, Enrico Tullio. *Processo de Execução*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 14.

MÉNDEZ, Francisco Ramos (dir.). *Hacia una Gestión Moderna y Eficaz de la Ejecución Procesal*. Barcelona: Atelier, 2014.

METZGER, Ernest (ed). *A Companion to Justinian's Institutes*. Bristol Classical Press, 2013.

_____. *A New Outline of the Roman Civil Trial*. USA: Oxford, 1998.

_____. *Litigation in Roman Law*. USA: Oxford University Press, 2005.

MILL, J. Stuart. *On Liberty*. 2. ed. London: John W. Parker and Son, MDCCCLIX.

MILLAR, Robert Wyness. *Los Principios Formativos del Procedimiento Civil*. Trad. Catalina Grossmann. Prólogo de Eduardo J. Couture. Buenos Aires: EDIAR, 1945.

_____. The formative principles of civil procedure. In: ENGELMANN, Arthur et al. *History of Continental Civil Procedure*. Boston: Little, Brown and Company, 1927. p. 3/81. Continental Legal History Series, v. VII.

MIRANDA, Gilson Delgado. Arts. 921 a 925 do CPC. In: WAMBIER ARRUDA ALVIM, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

MITIDIERO, Daniel Francisco. *Antecipação da Tutela*. Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória. São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____. *Colaboração no processo civil*. Pressupostos sociais, lógicos e éticos. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011.

_____. *Cortes Superiores e Cortes Supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente*. 2. ed., rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2014.

MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Arts. 862 a 869 do CPC. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.

MOREIRA, Alberto Camiña. Patrimônio de Afetação e Penhora. In: DIDIER Jr., Fredie. *Execução Civil: Estudos em Homenagem ao Professor Paulo Furtado*. Rio de Janeiro: 2006. p. 7-28.

MOTA, Antônio. Arts. 824 a 826 do CPC. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

NETO, Alfredo Copetti; ZANETI JUNIOR, Hermes. *Os deveres de coerência e integridade: a mesma face da medalha? A convergência de conteúdo entre Dworkin e MacCormick na teoria dos precedentes judiciais normativos formalmente vinculantes*. no prelo.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de direito processual civil*. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.

- NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. *Negócios Jurídicos Processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016.
- NOLASCO, Rita Dias. Art. 910 do CPC. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- NUNES, Dierle José Coelho. O princípio do contraditório: uma garantia de influência e de não surpresa In: DIDIER JR., Fredie; JORDÃO, Eduardo Ferreira (org.). *Teoria do processo*. Panorama doutrinário mundial. Salvador: JusPodivm, 2008. p. 151-174.
- NÚÑEZ OJEDA, Raúl; PÉREZ RAGONE, Álvaro; VARGAS PAVEZ, Macarena. *Hacia una mejor ejecución civil*. Rediseño orgánico procedimental para una justicia más eficiente, transparente, justa y accesible. Santiago: Legal Publishing Chile/Thomson Reuters, 2013.
- OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (coord.). *A Nova Execução de Títulos Extrajudiciais*. Comentários à Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- _____. (coord.). *A Nova Execução*. Comentários à Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
- _____. A garantia do contraditório. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. v. 15. p. 7-20. 1998.
- _____. O juiz e o princípio do contraditório. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT. ano 18, n. 71, p. 31-38, jul./set. 1993.
- _____. O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. In: _____. *Do formalismo no processo civil*. 2. ed. rev. e acrescida de apêndice. São Paulo: Saraiva, 2003.
- _____. *Do formalismo no processo civil*. 2. ed. rev. e acrescida de apêndice. São Paulo: Saraiva, 2003.
- _____. *Teoria e Prática da Tutela Jurisdicional*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- OLIVEIRA, Guilherme Peres de. Arts. 855 a 869 do CPC. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- PECZENICK, Aleksander. Certainty or coherence. In: KRAWIETZ, Werner et al (ed.). *The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justifiction*. Festschrift for Aulis Aarnio. Berlin: Duncker un Humblot, 2000.
- PEIXOTO, Ravi. *Superação do precedente e segurança jurídica*. Salvador: JusPodivm, 2015.
- PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande. Art. 854 do CPC. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- PÉREZ, Jesús González. *El Derecho a la Tutela Jurisdicional*. 3. ed. Madrid: Civitas, 2001.
- PEREZ RAGONE, Álvaro. El modelo orgánico de la ejecución civil desjudicializada desde el punto de vista del Derecho Comparado. Mitos y realidades de la desjudicialización. *Revista de Direito de la Pontificia Universidade Católica de Valparaíso*. n. XXXVIII. p. 394/395.
- _____. *General Report*. The Conflicts between the Fundamental Rights of the Creditor and the Debtor. International Association of Procedural Law – IAPL – Seoul Conference, 2014.
- PISANI, Andrea Proto. *Lezione di Diritto Processuale Civile*. 4. ed. Napoli: Jovane, 2002.

- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado das Ações*. São Paulo: Ed. RT, 1970. t. I.
- _____. *Comentários à Constituição de 1967 (arts. 153, § 2.º – 159)*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1971. v. 5.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. atualização legislativa de Sergio Bermudes. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 1.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. t. 10.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*, atualização legislativa de Sergio Bermudes. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 1.
- RAPISARDA, Cristina. *Profili della Tutela Civile Inibitoria*. Padova: Cedam, 1987.
- REDONDO, Bruno Garcia. Arts. 914 a 920 do CPC. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.
- _____. Comentários aos arts. 831 a 836 do CPC. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- REIS, José Alberto dos. *Processo de Execução*. Coimbra, 1943. v. I.
- RHEE, C. H. Van. The History of the “Huissier de Justice” in the Low Countries. In: ____; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. 161/178.
- ____; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010.
- ____; UZELAC, A. Enforcement and Enforceability. An Introduction. In: ____; ____.(org.). *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010. p. XXV/XXXII.
- RODOTÀ, Stephano. *Il terribile diritto*. Studi sulla proprietà privata. Bologna: Il Mulino, 1981.
- _____. *Libertà e Diritti in Italia dall'Unità ai Giorni Nostri*. Roma: Donzelli, 1997.
- RODRIGUES, Marcelo Abelha. *Manual da Execução Civil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- SALLES, Carlos Alberto. *Execução Judicial em Matéria Ambiental*. São Paulo: Ed. RT, 1998.
- SANTOS, Ernane Fidélis dos; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JUNIOR, Nelson. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (coord.). *Execução Civil: Estudos em Homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- SANTOS, Marina França. Arts. 847 a 861 do CPC. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.
- SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Curso de Direito Constitucional*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
- ____; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Curso de Direito Constitucional*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- SATTA, Salvatore. *Diritto Processuale Civile* [1948]. 9. ed. riveduta ed ampliata a cura di Carmine Punzi. Padova: Cedam, 1981.

- SCHAUER, Frederick. *Thinking like a lawyer*. A new introduction to legal reasoning. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- SHIMURA, Sérgio. *Título Executivo*. São Paulo: Saraiva, 1997.
- SICA, Heitor Vitor Mendonça. *Cognição e Execução no Sistema de Tutela Jurisdicional Civil Brasileiro*. Identificação e Tratamento do Objeto Litigioso em Sede Executiva. 2016. Tese de Livre-docência, São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 2016.
- SILTALA, Raimo. *A Theory of Precedent: From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy of Law*. Helsinki: University Printing House, 1998.
- SILVA, Celso de Albuquerque. *Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- SILVA, Ovídio A. Baptista da. *Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- SILVESTRI, Elisabetta. The *Devi lis* in The Details: Remarks on Italian Enforcement Procedures. In: RHEE, C. H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010.
- SOUSA, Miguel Teixeira de. *A Reforma da Acção Executiva*. Lisboa: Lex, 2004.
- SOUZA, Marcelo Alves Dias de. *Do precedente judicial à súmula vinculante*. Curitiba: Juruá, 2007.
- STRECK, Lênio Luiz; ABBoud, Georges. *O Que é Isto – O Precedente Judicial e as Súmulas Vinculantes?* 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
- _____. *Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- STÜRNER, Rolf; KERN, Christoph. Processo Civil Comparado – Tendências Recentes e Fundamentais. *Revista de Processo*. v. 200. p. 203. out. 2011.
- TARUFFO, Michele. A atuação executiva: perfis comparados. In: _____. *Processo Civil Comparado: Ensaios*. São Paulo: Marcial Pons, 2013. p. 85/117.
- _____. *A motivação da sentença civil*. Trad. Daniel Mitidiero, Rafael Abreu e Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2015.
- _____. *La motivazione della sentenza civile*. Padova: Cedam, 1975.
- THEODORO JR., Humberto. *Processo de Execução e Cumprimento de Sentença*. 24. ed. São Paulo: Leud, 2008.
- _____. NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. *Novo CPC: fundamentos e sistematização*. Forense: Rio de Janeiro, 2015.
- UZELAC, Alan. Privatization of Enforcement Services. A Step Forward for Countries in Transition? In: RHEE, C. H. Van; UZELAC, A. (org.). *Enforcement and Enforceability*. Tradition and Reform. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, 2010.
- VASCONSELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Arts. 911 a 913 do CPC. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- VELASCO, Ignacio M. Poveda. *A Execução do Devedor no Direito Intermédio. Beneficium Competentiae*. São Paulo: Livraria Paulista, 2002.

- _____. *A Execução do Devedor no Direito Romano*. São Paulo: Livraria Paulista, 2002.
- VENTURI, Elton. Arts. 824 a 826 do CPC. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). 2. ed. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____. *Execução da Tutela Coletiva*. São Paulo: Malheiros, 2000.
- VICTOR, Alexandre Gois de. Arts. 831 a 836 do CPC. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.
- WAMBOUGH, Eugene. *The Study of Cases*. 2. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1894.
- WATANABE, Kazuo. *Da Cognição no Processo Civil*. 3. ed. São Paulo: Perfil, 2005.
- WROBLÉWSKI, Józef. Legal decision and its justification. *Logique et Analyse*. n. 53-54. p. 409-419. 1971.
- ZANETI JUNIOR, Hermes. *A Constitucionalização do Processo*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
- _____. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o protocolo do Mercosul para cooperação jurisdicional em medidas cautelares: perfil de um processo transnacional para a efetividade. In: MITIDIERO, Daniel Francisco; ZANETI JUNIOR, Hermes. *Introdução ao estudo do processo civil: primeiras linhas de um paradigma emergente*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004. p. 231-272.
- _____. *O Valor Vinculante dos Precedentes: Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes*. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
- _____. Precedentes normativos formalmente vinculantes. In: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO, Lucas Buril de. *Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes*. Salvador: JusPodivm, 2015. v. 3, p. 407-425.
- _____; PEREIRA, Carlos Frederico Bastos. Teoria da Decisão no Código de Processo Civil: Uma Ponte entre Hermenêutica e Analítica? *Revista de Processo*. no prelo.

Índice Alfabético-remissivo

A

Ação autônoma, **914**, 5

Adjudicação, **825**, 3, **876**,

– Desconstituição da adjudicação ou alienação, **826**, 5

– Termo final: adjudicação ou alienação – ato jurídico perfeito, **826**, 4

Alienação, **825**, 4

– antecipada de bens penhorados, **852**,

– de imóvel de incapaz, **896**,

– em leilão particular, **881**,

– judicial parcial de bens, **894**,

– por iniciativa particular, **880**,

Alimentos, **911**, 1, 3

– Citação do executado, **911**, 2

– Desconto em folha de pagamento do executado, **912**, 1, 2, 3, 4,

– Expropriação, **913**, 1, 2, 3

– Prisão civil, **911**, 4, 5,

Aquisição do bem penhorado em prestações, **895**,

Arrematação, **892**, 1

– Licitação e preferência, **892**, 3

– Pagamento do lance vencedor, **892**, 2

Arresto cautelar, **830**, 2

– Conversão automática em penhora – Desnecessidade de intimação, **830**, 5

– Conversão automática em penhora, **830**, 4

Arresto de bens do executado, **830**,

Arrombamento, **846**,

Atipicidade, **introdução**, 2.14, 2.15

Auto de adjudicação, **877**,

Auto de arrematação, **901**,

Auto ou termo de penhora, **838**,

Avaliação, **870**, 1

- Avaliador, **870**, 3
- Contraditório, **872**, 3
- Desnecessidade, **871**, 1, 2
- Imóvel passível de divisão, **872**, 2
- Laudo, **872**, 1
- Nova avaliação, **873**, 1
- Oficial de justiça, **870**, 2

Averbação, **828**, **844**,

- Amplitude da averbação: sentença condenatória, arresto ou indisponibilidade cautelar anterior à execução, **828**, 3
- Cancelamento, **828**, 6
- Certidão – Desnecessidade de decisão, **828**, 10
- Conteúdo da certidão e órgão competente para certificar, **828**, 4
- Cumprimento de sentença, **828**, 11
- Desnecessidade da certidão, **828**, 12
- Dever de comunicação, **828**, 5
- Inaplicabilidade a fatos pretéritos, **828**, 9
- Ônus, **828**, 2
- Sanção, **828**, 7
- Tutelas provisórias de urgência, **828**, 8
- do arresto ou penhora, **844**,
- do processo de execução, **828**, 1

B

BACENJUD, **838**, 3

BACENJUD, **854**, 3

Bens impenhoráveis e inalienáveis, **832**, 1

Bens impenhoráveis, **833**,

Bens não sujeitos à execução, **832**,

C

Certidão para fins de averbação, **826**,

Ciência da alienação judicial, **889**,

Citação – Citation do executado e arresto e avaliação, **827**, 1

Citação – Decisão que determina, **829**, 3

Citação – Direito de indicação de bens pelo executado, **829**, 6

Citação – Indicação dos bens pelo exequente e dever de cooperação do executado, **829**, 2

Citação – Litisconsórcio passivo, **829**, 4

Citação – Penhora e avaliação, **829**, 5

Citação do executado, **829**,

Citação, **829**, 1

Citação, **830**, 3

Complexidade do litígio, **premissas**, 1.3

Comportamento das partes, **premissas**, 1.3

Comportamento do juiz, **premissas**, 1.3

Conciliação, **introdução**, 2.16

Concurso de credores – Anterioridade da penhora, **908**, 4

Concurso de credores – Incidente, **909**, 1

Concurso de credores – Ordem de preferência, **908**, 2

Concurso de credores – Sub-rogação do crédito, **908**, 3

Concurso de credores, **908**, 1

Contraditório sobre modificações da penhora, **853**,

D

Depósito de bens, **840**,

Descabimento de avaliação, **871**,

Designação do leiloeiro público, **883**,

Direito fundamental à propriedade, **premissas**, 1.1, **introdução**, 2.1

Direito fundamental à tutela processual do crédito, **premissas**, 1.1, **introdução**, 2.1

Direito fundamental *de* propriedade, **premissas**, 1.1, **introdução**, 2.1

Divulgação do edital, **887**,

E

Edital de leilão, **886**,

Efetivação da penhora, **839**,

E-justice – penhora *on-line* – BACENJUD, **854**, 3,

E-justice – penhora *on-line*, **854**,

E-justice, **introdução**, 2.4, **conclusões**, 3. 1, **837**, 1,

Embargos à execução: cabimento e competência, **914**,

Embargos à execução: efeito suspensivo, **919**,

Embargos à execução: matérias passíveis de arguição, **917**,

Embargos à execução: prazo, **915**,

Embargos à execução: procedimento, **920**,

Embargos à execução: rejeição liminar, **918**,

Embargos de Retenção por benfeitorias, **917**, 6

Embargos do executado – Ausência de efeito suspensivo, **919**, 1

Embargos do executado – Cognição dos embargos, **917**, 1

Embargos do executado – Cumulação indevida de execuções, **917**, 5

Embargos do executado – Defesas do executado, **914**, 3

Embargos do executado – Desnecessidade de penhora, **914**, 7

Embargos do executado – Embargos de segunda fase, **914**, 6

Embargos do executado – Excesso na execução, **917**, 4

Embargos do executado – Execução por carta precatória, **914**, 10

Embargos do executado – Execuções por carta precatória, **915**, 3

Embargos do executado – Honorários advocatícios, **920**, 4

Embargos do executado – Improcedência liminar do pedido, **918**, 3

Embargos do executado – Impugnação à adjudicação e à arrematação, **914**, 6

Embargos do executado – Incompetência absoluta ou relativa, **917**, 7

Embargos do executado – Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, **917**, 2

Embargos do executado – Juízo Arbitral e Embargos, **914**, 13

Embargos do executado – Litisconsórcio e contagem do prazo, **915**, 2

Embargos do executado – Manifesto propósito protelatório, **918**, 4

Embargos do executado – Matéria de Defesa, **917**, 10

Embargos do executado – Natureza jurídica, **914**, 1, 2, **917**, 8

Embargos do executado – Penhora incorreta ou avaliação errônea, **917**, 3

Embargos do executado – Prazo, **915**, 1

Embargos do executado – Rejeição liminar dos embargos, **918**, 1

Embargos do executado – Requisitos para concessão do efeito suspensivo, **919**, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Embargos do executado – Resposta do embargado, **920**, 1, 2, 3,

Embargos do executado – Indeferimento da petição inicial, **918**, 2

Exceção de preexecutividade, **914**, 4

Execução atípica, **introdução**, 2.14, 2.15

Execução contra a Fazenda Pública – Conteúdo dos embargos, **910**, 6

Execução contra a Fazenda Pública – Efeito suspensivo dos embargos, **910**, 5

Execução contra a Fazenda Pública – Embargos parciais, **910**, 7

Execução contra a Fazenda Pública – *Exceptio declinatoria quanti*, **910**, 10

Execução contra a Fazenda Pública – Rejeição liminar dos embargos, **910**, 8

Execução contra a Fazenda Pública, **910**, 1, 2, 3, 4, 9

Execução de alimentos fundada em título extrajudicial: citação inicial, **911**,

Execução de alimentos fundada em título extrajudicial: desconto em folha, **912**,

Execução de alimentos fundada em título extrajudicial: execução por expropriação, **913**,

Execução por quantia certa – Finalidade, **824**,

Execução por quantia certa – Fixação de honorários advocatícios no despacho inicial, **827**,

Execução por quantia certa – Modalidades expropriatórias, **825**,

Execução por quantia certa contra a Fazenda Pública fundada em título executivo extrajudicial, **910**,

Execução por quantia certa, **824**,

Execução por quantia certa, **824**, 1

Execução singular para a tutela do crédito, **premissas**, 1.2

Expropriação – Adjudicação – Intimação do executado, **876**, 4

Expropriação – Adjudicação – Legitimados, **876**, 3

Expropriação – Adjudicação – Prazo de manifestação, **877**, 1

Expropriação – Adjudicação – Preço da adjudicação, **876**, 5

Expropriação – Adjudicação – Preferencialidade da adjudicação, **876**, 2

Expropriação – Adjudicação – Remição e bem adjudicado, **877**, 3

Expropriação – Adjudicação, **877**, 2, **878**, 1

Expropriação – Alienação parcial de bem imóvel, **894**, 1

Expropriação – Alienação por iniciativa particular, **880**, 1, 2, 3, 4

Expropriação – Auto de arrematação – Carta de arrematação, **901**, 2, 3,

Expropriação – Auto de arrematação – Concretização da arrematação, **903**, 1

Expropriação – Auto de arrematação – Concretização da arrematação – Vícios da arrematação, **903**, 2

Expropriação – Auto de arrematação – Concretização da arrematação – Desistência da arrematação, **903**, 3

Expropriação – Auto de arrematação, **901**, 1

Expropriação – Definição, **876**, 1

Expropriação – Início dos atos expropriatórios, **875**, 1

Expropriação – Leilão eletrônico, **882**, 2

Expropriação – Leilão Judicial – Deveres do leiloeiro, **884**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Divulgação, **887**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Fiador, **898**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Inadimplemento do arrematante ou fiador, **897**, 1, 2,

Expropriação – Leilão Judicial – Indicação do leiloeiro, **883**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Intimação de outros sujeitos interessados, **889**, 3

Expropriação – Leilão judicial – Intimação do executado, **889**, 2

Expropriação – Leilão judicial – Legitimidade para oferta de lances, **890**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Nulidade da arrematação, **886**, 2

Expropriação – Leilão judicial – Pagamento em prestações, **895**, 1, 2, 3

Expropriação – Leilão judicial – Pluralidade de bens, **893**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Prosseguimento do leilão, **900**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Publicidade e intimações obrigatórias, **889**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Remição de bem hipotecado, **902**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Responsabilidade pelo adiamento, **888**, 2

Expropriação – Leilão judicial – Suspensão da arrematação e satisfação do crédito, **899**, 1

Expropriação – Leilão judicial – Suspensão de leilão de imóvel de incapaz, **896**, 1, 2,

Expropriação – Leilão judicial – Transferência, **888**, 1
Expropriação – Leilão judicial, **882**, 1, 2, **885**, 1, **886**, 1,
Expropriação – Local de realização do leilão, **882**, 3
Expropriação – Modalidades de alienação judicial, **879**, 1
Expropriação – Ordem de preferência, **881**, 1
Expropriação – Praça, **881**, 2
Expropriação – Quitação e levantamento do dinheiro, **906**, 1
Expropriação, **825**, 1
Extinção da execução – Renúncia ao crédito, **925**, 3
Extinção da execução, **923**, 2, 3, 4, **925**, 1
Extinção do processo de execução, **924**,
Extinção do processo de execução: sentença, **925**,

F

Fiança bancária e seguro garantia judicial, **835**, 4
Fim do usufruto judicial: simples apropriação de frutos e rendimentos, **825**, 5

H

Histórico da execução, **introdução**, 2.3
Honorários Advocatícios – Execução contra a Fazenda Pública, **910**, 11
Honorários advocatícios, **905**, 2
Honorários de advogado – Redução – Não aplicação ao cumprimento de sentença condenatória, **827**, 4
Honorários de advogado – Redução da verba honorária: pagamento integral, **827**, 3
Honorários de advogado, **827**, 2

I

Impenhorabilidade, **833**,
– Absoluta, **833**, 1, 3
– Bens inalienáveis e indisponíveis, **833**, 4
– Bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, **833**, 8
– Caderneta de poupança, **833**, 13
– Créditos oriundos de alienação de unidade imobiliárias, **833**, 15
– Disponibilidade do bem, **833**, 1, 3
– Limitação constitucional, **833**, 1

- Materiais empregados em obra, **833**, 10
- Pequena propriedade rural (constitucional), **833**, 11
- Possibilidade de preclusão, **833**, 2
- Recursos de fundo partidário recebido por partidos políticos, **833**, 14
- Recursos públicos recebidos por instituição privada, **833**, 12
- Remunerações e outras fontes de renda do executado, **833**, 7
- Restrição à impenhorabilidade (§ 1.º), **833**, 16
- Restrições (§§ 2.º e 3.º), **833**, 7, 13
- Seguro de vida em caso de morte e mesmo no caso do valor retido, **833**, 9
- Vestuário e pertences de uso pessoal, **833**, 6
- Bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas, **833**, 5

Incidente de desconsideração, **829**, 8

Incumbência do leiloeiro público, **884**,

Ineficácia da penhora, **836**,

Início dos atos expropriatórios, **875**,

Intercambialidade da execução, **introdução**, 2.10

Intimação do cônjuge, **842**,

Intimação do executado, **841**,

Irretratabilidade da arrematação, **903**,

L

Laudo de avaliação, **872**,

Legitimidade para arrematar, **890**,

Legitimidade, **826**, 3

Leilão de bem hipotecado, **902**,

Leilão judicial eletrônico ou presencial, **882**,

Levantamento do dinheiro, **905**, 1

Lugar de realização da penhora, **845**,

M

Mandado de levantamento e quitação, **906**,

Medidas coercitivas – Inscrição no cadastro de inadimplentes – Aplicação ao cumprimento de sentença e em execuções fundadas em título extrajudicial de obrigação de não fazer, fazer e entregar coisa, **827**, 7

Medidas coercitivas – Inscrição no cadastro inadimplentes, **827**, 6

Medidas coercitivas – Multa cominatória, **827**, 5

Menor onerosidade possível, **907**, 1

Modalidades de alienação, **879**,

Moratória – Suspensão da execução, **922**, 1

Moratória – Discordância do exequente e máxima efetividade da execução, **916**, 4

Moratória – Inadimplemento e sanções, **916**, 5

Moratória – Parcelamento, **916**, 1

Moratória – Requisitos legais do parcelamento, **916**, 2, 3

N

Não pagamento do preço, **897**,

Negócios jurídicos processuais, **introdução**, 2.17

Nemo potest praecise cogi ad factum, **introdução**, 2.8

Non money judgments, **introdução**, 2.12

Nova avaliação, **873**,

Novo requerimento de adjudicação, **878**,

Nulla executio sine titulo, **introdução**, 2.8

O

Objeto da penhora, **831**, 3

Ordem da penhora, **835**,

P

Pagamento pelo arremate, **892**,

Parcelamento da dívida (moratória), **916**,

Partidos políticos – Penhora, **854**, 7

Partidos políticos – Impenhorabilidade – Recursos de fundo partidário, **833**, 14

Penhora, **831 a 869**

– Agravo de instrumento, **853**, 2

– Alienação antecipada, **852**, 1

– Ampliação ou redução, **850**, 1

– Arresto cautelar, **830**, 2

– Aspectos formais, **838**, 1

- Aspectos introdutórios, **831**, 1
- Bem indivisível e coproprietário/cônjuge, **843**, 1, 2, 3
- Cartão de crédito (faturamento), **866**, 3
- Conceito e objetivo, **831**, 2
- Cônjuge, **842**, 1, 2, 3, 4
- Contraditório, **853**, 1
- Depósito judicial e os bens penhorados, **840**, 1
- Devedor da coisa determinada, **859**, 1
- Dos frutos e rendimentos de bens inalienáveis, **834**, 1
- Empresa e bens semoventes – Excepcionalidade, **865**, 1
- Empresa que presta serviço público mediante concessão ou autorização, **863**, 1, 2, 3,
- Estabelecimentos e bens semoventes – Administrador-depositário, **862**, 2
- Estabelecimentos e bens semoventes – Penhora sobre edifícios em construção, **862**, 3
- Estabelecimentos e bens semoventes, **862**, 1
- Frutos e rendimentos, **867**, 1, **868**, 1, **869**, 1
- Garantia Real, **835**, 5
- Impugnação por petição simples – segunda penhora, **851**, 2
- Intimação, **841**, 1
- Juros, rendimentos e prestações, **858**, 1
- Limitação constitucional, **833**, 1
- Lugar, **845**, 1
- Meios eletrônicos, **837**, 1, **854**,
- Navio e Aeronave, **864**, 1
- *On-line* – Multa sancionatória, **854**, 8
- *On-line* – Responsabilidade da instituição financeira, **854**, 6
- *On-line*, **854**, 1, 2, 3, 4, 5
- Oposição do executado, **846**, 1
- Ordem preferencial, **835**, 1, 2
- Penhora de créditos, **855**, 1, **856**, 1, **857**, 1
- Penhora de dinheiro, **835**, 3, **854**, 1
- Penhora de mão própria, **855**, 3

- Penhora no rosto dos autos, **860**, 1
- Percentual de faturamento de empresa, **866**, 1, 2
- Pré-penhora, **830**, 1
- Publicitação, **844**, 1
- Quotas ou ações de sociedades personificadas, **861**, 1, 2,
- Realização da penhora e lavratura do auto, **839**, 1
- Realização superveniente da penhora e impugnação por simples petição, **829**, 7
- Redução ou alteração, **874**, 1
- Reforço *ex officio* (vedação), **874**, 2
- Segunda penhora, **851**, 1, 2
- Substituição, **847**, 1, 2, 3, **848**, 1, 2, **849**, 1
- União estável, **842**, 4
- Usufruto, **867**, 2

Penhora das quotas ou das ações de sociedades personificadas, **861**,

Penhora de bem indivisível, **843**,

Penhora de créditos relativos a dívidas de dinheiro a juros, **858**,

Penhora de créditos, **855**,

Penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, **854**,

Penhora de direitos a prestação ou restituição de créditos, **859**,

Penhora de empresa sob concessão ou autorização, **863**,

Penhora de estabelecimento comercial, semoventes, plantações ou edifícios em construção, **862**,

Penhora de frutos e rendimentos – Hipótese de cabimento, **867**,

Penhora de frutos e rendimentos – Exequente ou executado como administrador-depositário, **869**,

Penhora de frutos e rendimentos – nomeação de administrador-depositário, **868**,

Penhora de navio ou aeronave, **864**,

Penhora de percentual de faturamento da empresa, **866**,

Penhora de títulos de crédito, **856**,

Penhora em direito e ação do executado, **857**

Penhora nos autos, **860**,

Penhora por meio eletrônico, **837**,

Penhorabilidade dos frutos e rendimentos dos bens impenhoráveis, **834**,

Posta in gioco (origem do crédito), **premissas**, 1.3

Precedentes, **introdução**, 2.18

Preço vil, **891**, 1

Preferência na arrematação – Coproprietário/cônjuge, **843**, 2, 3

Preferência, **825**, 2

Preferências para levantamento do dinheiro, **909**,

Pressupostos da arrematação, **885**,

Prosseguimento do leilão, **900**,

R

Redução ou ampliação da penhora, **850**,

Redução ou ampliação da penhora, **874**,

Remição da execução, **826**, 1

– Limites temporais da remição, **826**, 7

– Regimes da remição, **826**, 6

– Remição da execução fiscal, **826**, 2

Restituição ao executado do valor excedente, **907**,

Retomada da execução, **925**, 2

S

Satisfação do crédito, **904**, 1

– exequente único, **905**,

Segunda penhora, **851**,

Sentenças autossatisfativas, **introdução**, 2.11

Substituição da penhora a pedido das partes, **848**,

Substituição da penhora a pedido do executado, **847**,

Substituição da penhora: novo termo, **849**,

Suspensão da arrematação, **899**,

Suspensão da execução, **921**, 1, 2, 3, 4, 5,

– Suspensão da execução: atos passíveis de prática durante a suspensão, **923**,

– Suspensão da execução: convenção das partes, **922**,

– Suspensão da execução: hipóteses legais, **921**,

– Prática de atos processuais urgentes, **923**, 1

– Prescrição intercorrente, **921**, 6

T

Tutela do crédito adequada e efetiva, **premissas**, 1.3

U

Utilidade da tutela executiva, **836**, 1

– Execução Fiscal, **836**, 2

© desta edição [2018]